المقنع

ابن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠هـ)

الجزء ٧

نص المؤلف كما في طبعة: بيروت ، 1400 ، المكتب الإسلامي
المصدر: مجموعة OpenITI (KITAB)، برخصة المشاع الإبداعي CC BY-NC-SA 4.0، للاستخدام غير التجاري.
نص المؤلف دون تغيير، لا تشمل هذه النسخة حواشي المحققين.
Romanov, M. & Seydi, M. OpenITI. doi:10.5281/zenodo.3082463

النكاح سنة والاشتغال به أفضل من التخلي لنوافل العبادة إلا أن يخاف على نفسه مواقعة المحظور بتركه فيجب عليه [ج ٧ - ص ٤]

وعنه أنه واجب على الاطلاق [ج ٧ - ص ٥]

ويستحب تخير ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية [ج ٧ - ص ٦]

ويجوز لمن أراد خطبة امرأة النظر إلى وجهها من غير خلوة بها وعنه له النظر إلى ما يظهر غالبا كالرقبة واليدين والقدمين [ج ٧ - ص ٧]

وله النظر إلى ذلك وإلى الرأس والساقين من الأمة المستامة ومن ذوات محارمه وعنه لا ينظر من ذوات محارمه إلا الوجه والكفين وللعبد النظر إليهما من مولاته [ج ٧ - ص ٨]

ولغير أولي الإربة من الرجال كالكبير والعنين ونحوهما النظر إلى ذلك وعنه لا يباح وللشاهد والمبتاع النظر إلى وجه المشهود عليها ومن تعامله وللطبيب النظر إلى ما تدعو الحاجة إلى نظره [ج ٧ - ص ٩]

وللصبي المميز غير ذي الشهوة النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة فإن كان ذا شهوة فهو كذي المحرم وعنه كالأجنبي وللمرأة مع المرأة والرجل مع الرجل النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة وعنه أن الكافرة مع المسلمة كالأجنبي [ج ٧ - ص ١٠]

ويباح للمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة وعنه لا يباح [ج ٧ - ص ١١]

ويجوز النظر إلى الغلام لغير شهوة ولا يجوز النظر إلى أحد ممن ذكرنا لشهوة ولكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن الآخر ولمسه [ج ٧ - ص ١٢]

وكذلك السيد مع أمته

فصل

ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة [ج ٧ - ص ١٣]

ولا التعريض بخطبة الرجعية ويجوز في عدة الوفاة والبائن بطلاق ثلاث وهل يجوز في عدة البائن بغير الثلاث على وجهين والتعريض نحو قوله إني في مثلك لراغب ولا تفوتيني بنفسك وتجيبه ما يرغب عنك وإن قضي شيء كان ونحوه ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إن أجيب

[ج ٧ - ص ١٤]

فإن رد حل فإن لم تعلم الحال فعلى وجهين [ج ٧ - ص ١٥]

والتعويل في الرد والإجابة إن لم تكن مجبرة وإن كانت مجبرة فعلى الولي ويستحب عقد النكاح مساء يوم الجمعة وأن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود [ج ٧ - ص ١٦]

وأن يقال للمتزوج بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية وإذا زفت إليه قال اللهم إني اسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه

باب أركان النكاح وشروطه يحسنهما فإن قدر على تعلمهما بالعربية لم يلزمه في أحد الوجهين والقبول قبلت هذا النكاح أو ما يقوم مقامه في حق من لا يحسن

[ج ٧ - ص ١٨]

فإن اقتصر على قول قبلت أو قال الخاطب للولي أزوجت قال نعم وللمتزوج أقبلت قال نعم صح ذكره الخرقي ويحتمل ألا يصح وإن تقدم القبول الإيجاب لم يصح

[ج ٧ - ص ١٩]

وإن تراخى عنه صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه وإن تفرقا قبله بطل الإيجاب وعنه لا يبطل

فصل

وشروطه خمسة أحدها تعيين الزوجين [ج ٧ - ص ٢٠]

فإن قال زوجتك ابنتي وله بنات لم يصح وإن لم يكن له إلا ابنة واحدة صح ولو قال إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها لم يصح [ج ٧ - ص ٢١]

فصل الثاني

رضى الزوجين فإن لم يرضيا أو أحدهما لم يصح إلا الأب له تزويج أولاده الصغار والمجانين وبناته الأبكار بغير إذنهن [ج ٧ - ص ٢٢]

وعنه لا يجوز تزويج ابنة تسع سنين إلا بإذنها وهل له تزويج الثيب الصغيرة على وجهين [ج ٧ - ص ٢٣]

والسيد له تزويج إمائه الأبكار والثيب وعبيده الصغار بغير إذنهم

[ج ٧ - ص ٢٤]

ولا يملك إجباره عبده الكبير ويحتمل مثل ذلك في الصغير أيضا ولا يجوز لسائر الأولياء تزويج كبيرة إلا بإذنها إلا المجنونة لهم تزويجها إذا ظهر منها الميل إلى الرجال وعنه [ج ٧ - ص ٢٥]

لهم ذلك ولها الخيار إذا بلغت وعنه لهم تزويج ابنة تسع سنين بإذنها

[ج ٧ - ص ٢٦]

وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات ولا فرق بين الثيوبة بوطء مباح أو محرم فأما زوال البكارة بأصبع أو وثبة فلا تغير حفظ الإذن

فصل الثالث

الولي فلا نكاح إلا بولي [ج ٧ - ص ٢٧]

فإن تزوجت المرأة نفسها لم يصح وعنه له تزويج أمتها [ج ٧ - ص ٢٨]

ومعتقتها فيخرج منه صحة تزويج نفسها بإذن وليها وتزويج غيرها بالوكالة والأول المذهب [ج ٧ - ص ٢٩]

وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها ثم أبوه وإن علا ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل [ج ٧ - ص ٣٠]

ثم أخوها لأبويها ثم لأبيها والتسوية بين الجد والأخ وبين الأخ للأبوين والأخ من الأب [ج ٧ - ص ٣١]

ثم بنوا الاخوة وإن سفلوا ثم العم ثم ابنه ثم الأقرب فالأقرب من العصبات على ترتيب الميراث ثم عصابته من بعده الأقرب فالأقرب ثم السلطان [ج ٧ - ص ٣٢]

فأما الأمة فوليها سيدها وإن كانت لامرأة فوليها ولي سيدتها ولا يزوجها إلا بإذنها [ج ٧ - ص ٣٣]

ويشترط في الولي الحرية والذكورية واتفاق الدين والعقل [ج ٧ - ص ٣٤]

وهل يشترط بلوغه وعدالته على روايتين [ج ٧ - ص ٣٥]

وإذا كان الأقرب طفلا أو كافرا أو عبدا زوج الأبعد وإن عضل الأقرب زوج الأبعد وعنه يزوج الحاكم [ج ٧ - ص ٣٦]

وإن غاب غيبة منقطعة زوج الأبعد وهي مالا تقطع الا بكلفة ومشقة وقال الخرقي مالا يصل إليه الكتاب أو يصل فلا يجيب عنه وقال القاضي مالا تقطعه القافلة في السنة إلا مرة وعن أحمد إذا كان الأب بعيد السفر زوج الأبعد فيحتمل أنه أراد ما تقصر فيه الصلاة [ج ٧ - ص ٣٧]

ولا يلي كافر نكاح مسلمة بحال إلا إذا أسلمت أم ولده في وجه ولا يلي مسلم نكاح كافرة إلا سيد الأمة أو ولي سيدتها أو السلطان ويلي الذمي نكاح موليته الذمية من الذمي [ج ٧ - ص ٣٨]

وهل يليه من مسلم على وجهين وإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي لم يصح النكاح وعنه يصح ويقف على إجازة الولي [ج ٧ - ص ٣٩]

ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وإن كان حاضرا ووصيه في النكاح بمنزلته وعنه لا تستفاد ولاية النكاح بالوصية [ج ٧ - ص ٤٠]

وقال ابن حامد لا يصح إلا أن لا يكون له عصبة وإذا استوى الأولياء في الدرجة صح التزويج من كل واحد منهم والأولى تقديم أفضلهم ثم أسنهم وإن تشاحوا أقرع بينهم فإن سبق غير من وقعت له القرعة فزوج صح في أقوى الوجهين [ج ٧ - ص ٤١]

وإن زوج اثنان ولم يعلم السابق فسخ النكاحان وعنه يقرع بينهما فمن قرع أمر الآخر بالطلاق ثم يجدد القارع نكاحه [ج ٧ - ص ٤٢]

وإذا زوج عبده الصغير من أمته جاز أن يتولى طرفي العقد وكذلك ولي المرأة مثل ابن العم والمولى والحاكم إذا أذنت له في نكاحها فله أن يتولى طرفي العقد وعنه [ج ٧ - ص ٤٣]

لا يجوز حتى يوكل غيره في الطرف الآخر وإذا قال السيد لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك صح [ج ٧ - ص ٤٤]

فإن طلقتها قبل الدخول بها رجع عليها بنصف قيمتها وعنه لا يصح حتى يستأنف نكاحها بإذنها [ج ٧ - ص ٤٥]

فإن أبت ذلك فعليها قيمتها

فصل الرابع الشهادة

[ج ٧ - ص ٤٦]

فلا ينعقد إلا بشاهدين عدلين ذكرين بالغين عاقلين وإن كانا ضريرين

[ج ٧ - ص ٤٧]

وعنه ينعقد بحضور فاسقين ورجل وامرأتين ومراهقين عاقلين ولا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين ويتخرج أن ينعقد إذا كانت المرأة ذمية ولا ينعقد بحضور أصمين ولا أخرسين وهل ينعقد بحضور عدوين أو ابني الزوجين أو أحدهما على وجهين وعنه أن الشهادة ليست من شروط النكاح [ج ٧ - ص ٤٨]

فصل الخامس

كون المرء كفئا لها في إحدى الروايتين [ج ٧ - ص ٤٩]

فلو رضيت المرأة والأولياء بغيره لم يصح والثانية ليس بشرط وهي أصح

[ج ٧ - ص ٥٠]

لكن إن لم ترض المرأة والأولياء جميعهم فلمن لم يرض الفسخ فلو زوج الأب بغير كفء برضاها فللإخوة الفسخ نص عليه [ج ٧ - ص ٥١]

والكفاءة الدين والمنصب فلا تزوج عفيفة بفاجر ولا عربية بعجمي والعرب بعضهم لبعض أكفاء وسائر الناس بعضهم لبعض أكفاء وعنه لا تزوج قرشية لغير قرشي ولا هاشمية لغير هاشمي [ج ٧ - ص ٥٢]

وعنه أن الحرية والصناعة واليسار من شروط الكفاءة فلا تزوج حرة بعبد [ج ٧ - ص ٥٣]

ولا بنت بزاز بججام ولا بنت تانىء بحانك ولا موسرة بمعسر

[ج ٧ - ص ٥٤]

باب المحرمات في النكاح سبع الأمهات وهن الوالدة والجدات من قبل الأب والأم وإن علون والبنات من حلال أو حرام

[ج ٧ - ص ٥٦]

وبنات الأولاد وإن سفلن والأخوات من الجهات الثلاث وبنات الأخ وبنات الأخت وأولادهم وإن سفلوا والعمات والخالات وإن علون ولا تحرم بناتهن القسم الثاني المحرمات بالرضاع ويحرم به ما يحرم من النسب

[ج ٧ - ص ٥٧]

القسم الثالث المحرمات بالمصاهرة وهن أربع أمهات نسائه وحلائل آبائه

[ج ٧ - ص ٥٨]

وأبنائه فيحرمن بمجرد العقد دون بناتهن والربائب وهن بنات نسائه اللاتي دخل بهن دون اللاتي لم يدخل بهن فإن متن قبل الدخول فهل تحرم بناتهن على روايتين

[ج ٧ - ص ٥٩]

ويثبت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال والحرام فإن كانت المواطوءة ميتة أو صغيرة فعلى وجهين وإن باشر امرأة أو نظر إلى فرجها أو خلا بها لشهوة فعلى روايتين

[ج ٧ - ص ٦٠]

وإن تلوط بغلام حرم على كل واحد منهما أم الآخر وابنته وعن أبي الخطاب هو كالوطء دون الفرج وهو الصحيح

[ج ٧ - ص ٦١]

القسم الرابع الملاعنة تحرم على الملاعن إلا أن يكذب نفسه فله تحل له على روايتين

فصل

الضرب الثاني المحرمات إلى أبد وهن نوعان أحدهما [ج ٧ - ص ٦٢]

المحرمات لأجل الجمع فيحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها فإن تزوجها في عقد لم يصح وإن تزوجهما في عقدين أو تزوج إحداهما في عدة الأخرى سواء [ج ٧ - ص ٦٣]

كانت بائنا أو رجعية فنكاح الثانية باطل وإن اشترى أخت امرأته أو عمتها أو خالتها صح ولم يحل له وطؤها حتى يطلق امرأه وتنقضي عدتها وإن اشتراهن في عقد واحد صح فإن وطىء إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم على نفسه الأولى بإخراج عن ملكه أو تزويج ويعلم أنها ليست بحامل [ج ٧ - ص ٦٤]

فإن عادت إلى ملكه لم يصب واحدة منهما حتى يحرم الأخرى وعنه ليس بحرام ولكن ينهى عنه [ج ٧ - ص ٦٥]

وإن وطىء أمته ثم تزوج أختها لم يصح عند أبي بكر وظاهر كلام أحمد أنه يصح ولا يطؤها حتى يحرم الموطوءة فإن عادت إلى ملكنه لم يطأ واحدة منهما حتى يحرم الأخرى [ج ٧ - ص ٦٦]

ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع ولا للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين

[ج ٧ - ص ٦٧]

وإن طلق إحداهن لم يجز أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدتها

[ج ٧ - ص ٦٨]

فصل

النوع الثاني محرمات لعارض يزول فيحرم عليه نكاح زوجة غيره والمعتدة منه والمستبرئة منه وتحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها [ج ٧ - ص ٦٩]

ومطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره والمحرمة حتى تحل ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال ولا لمسلم نكاح كافرة إلا حرائر أهل الكتاب

[ج ٧ - ص ٧٠]

ولإجماع الصحابة عليه لا يقال ما تقدم يدل على عدم إباحتهن لشركهن وقول ابن عباس آية المائدة متأخرة عنهما لأن لفظ المشركين لا يتناول أهل الكتاب لقوله تعالى ﴿ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ﴾ ونص على الحرائر لأن الإماء يأتي حكمهن والأولى تركه وكرهه القاضي والشيخ تقي الدين كقول أكثرهم كذبائحهم بل حاجة وشمل الحربيات من أهل الكتاب وهو أحد الأقوال اختاره القاضي وهو ظاهر الوجيز والفروع لدخولهن في الآية الكريمة وقيل لا يجوز حملا لآية المنع على ذلك وآية الجواز على غير الحربيات ونص أحمد أنه لا يجوز في دار الإسلام فقط وإن اضطر اختاره ابن عقيل وقيل يجوز في دار الحرب مع الضرورة نص عليه وعلل الإمام المنع في دار الحرب من أجل الولد لئلا يستعبد ويصير على دينهم ومقتضاه لا يتزوج ونقل الأثرم لا يطأ زوجته إن كانت مغيبة فدل على أنه لا يتزوج آيسة وصغيرة

تنبيه أهل الكتاب هم اليهود والنصارى ومن وافقهم في أصل دينهم كالسامرة والفرنج والأرمن وأما الصابئة فقال أحمد هم من جنس النصارى وقال في موضع آخر بلغني أنهم يسبتون فألحقهم باليهود وفي المغني الصحيح أن من وافق اليهود والنصارى في أصل دينهم وخالفهم في فروعه فهو منهم ومن خالفهم في أصل دينهم فلا ومن سواهم من الكفار كالمتمسك بصحف إبراهيم وشيث وزبور داود فليسوا بأهل كتاب على الصحيح ذكره ابن عقيل فلا [ج ٧ - ص ٧١]

فإن كان أحد أبويها غير كتابي أو كانت من نساء بني تغلب فهل تحل على روايتين [ج ٧ - ص ٧٢]

وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابية وعنه يجوز ولا يحل لحر مسلم نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف العنت ولا يجد طولا لنكاح حرة

ولا ثمن أمة [ج ٧ - ص ٧٤]

وإن تزوجها وفيه الشرطان ثم أيسر أو نكح حرة فهل يبطل نكاح الأمة على روايتين وإن تزوج حرة أو أمة فلم تعفه ولم يجد طولا لحرة أخرى فهل له نكاح أمة أخرى على روايتين قال الخرقي وله أن ينكح من الاماء أربعا إذا كان الشرطان قائمين فيه [ج ٧ - ص ٧٥]

وللعبد نكاح الأمة وهل له أن ينكحها على حرة على روايتين وإن جمع بينهما في العقد جاز ويتخرج أن لا يجوز وليس له نكاح سيدته ولا للحر أن يتزوج أمته ولا أمة ابنه [ج ٧ - ص ٧٦]

ويجوز للعبد أن يتزوج أمة ابنه وإن اشترى الحر زوجته انفسخ نكاحها وإن اشتراها ابنه فعلى وجهين [ج ٧ - ص ٧٧]

ومن جمع بين محرمة ومحللة في عقد واحد فهل يصح فيمن تحل له على روايتين ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين إلا إماء أهل الكتاب

فصل

ولا يحل نكاح خنثى مشكل حتى يتبين أمره نص [ج ٧ - ص ٧٨]

عليه وقال الخرقي إذا قال أن رجل لم يمنع من نكاح النساء ولم يكن له أن ينكح بغير ذلك بعد وإن قال أنا امرأة لم ينكح إلا رجلا فلو تزوج امرأة ثم قال أنا امرأة انفسخ نكاحه ولو تزوج برجل ثم قال أنا رجل لم يقبل قوله في فسخ النكاح [ج ٧ - ص ٧٩]

باب الشروط في النكاح دارها أو بلدها

[ج ٧ - ص ٨٠]

أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى فهذا صحيح لازم إن وفى به وإلا فلها الفسخ وإن شرط لها طلاق ضرتها فقال أبو الخطاب هو صحيح ويحتمل أنه باطل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها

[ج ٧ - ص ٨١]

فصل

القسم الثاني فاسد وهو ثلاثة أنواع أحدها ما يبطل النكاح وهو ثلاثة أشياء أحدها نكاح الشغار وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما [ج ٧ - ص ٨٣]

فإن سمو مهرا صح نص عليه وقال الخرقي لا يصح [ج ٧ - ص ٨٤]

والثاني نكاح المحلل وهو أن يتزوجها على أنه إذا أحلها طلقها فإن نوى ذلك بغير شرط لم يصح في ظاهر المذهب [ج ٧ - ص ٨٥]

وقيل يكره ويصح [ج ٧ - ص ٨٦]

الثالث نكاح المتعة [ج ٧ - ص ٨٧]

وهو أن يتزوجها إلى مدة ونكاح يشرط فيه طلاقها في وقت أو علق ابتداءه على شرط كقوله زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها فهذا كله باطل من أصله [ج ٧ - ص ٨٨]

النوع الثاني أن يشترط أنه لا مهر لها ولا نفقة أو يقسم لها أكثر من امرأته الأخرى أو أقل فالشرط باطل ويصح النكاح [ج ٧ - ص ٨٩]

الثالث أن يشترط الخيار أو إن جاءها بالمهر في وقت وإلا فلا نكاح بينهما فالشرط باطل وفي صحة النكاح روايتان

فصل

فإن تزوجها على أنها مسلمة فبانت كتابية فله الخيار وإن شرطها كتابية فبانت مسلمة فلا خيار له وقال أبو بكر له الخيار كما إذا شرطها أمة فبانت حرة فلا خيار له [ج ٧ - ص ٩٠]

وإن شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو شرط نفي العيوب التي لا ينفسخ بها النكاح فبانت بخلافه فهل له الخيار على وجهين [ج ٧ - ص ٩١]

وإن تزوج أمة يظنها حرة فأصابها وولدت منه فالولد حر ويفديهم بمثلهم يوم ولادتهم [ج ٧ - ص ٩٢]

ويرجع بذلك على من غره [ج ٧ - ص ٩٣]

ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء وإن كان ممن يجوز له ذلك فله الخيار فإن رضي بالمقام معها فما ولدت بعد ذلك فهو رقيق

[ج ٧ - ص ٩٤]

وإن كان المغرور عبدا فولده أحرار ويفديهم إذا عتق ويرجع به على من غره وإن تزوجت رجلا على أنه حر أو تظنه حرا فبان عبدا فلها الخيار

[ج ٧ - ص ٩٥]

فصل

وإن عتقت الأمة وزوجها حر فلا خيار لها في ظاهر المذهب وإن كان عبدا فلها الخيار في فسخ النكاح ولها الفسخ بغير حكم حاكم [ج ٧ - ص ٩٦]

فإن أعتقت قبل فسخها أو أمكنته من وطئها بطل خيارها فإن ادعت الجهل بالعتق وهو مما يجوز جهله أو الجهل بملك الفسخ فالقول قولها وقال الخرقي يبطل خيارها علمت أو لم تعلم وخيار المعتقة على التراخي ما لم يوجد منها ما يدل على الرضى [ج ٧ - ص ٩٧]

فإن كانت صغيرة أو مجنونة فلها الخيار إذا بلغت وعقلت وليس لوليها الاختيار عنها فإن طلقت قبل اختيارها وقع الطلاق وإن عتقت المعتدة الرجعية فلها الخيار فإن رضيت بالمقام فهل يبطل خيارها على وجهين

[ج ٧ - ص ٩٨]

ومتى اختارت المعتقة الفرقة بعد الدخول فالمهر للسيد وإن كان قبله فلا مهر وقال أبو بكر لسيدها نصف المهر وإن أعتق أحد الشريكين وهو معسر فلا خيار لها وقال أبو بكر لها الخيار [ج ٧ - ص ٩٩]

وإن عتق الزوجان معا فلا خيار لها وعنه ينفسخ نكاحهما [ج ٧ - ص ١٠٠]

باب حكم العيوب في النكاح أحدهما أن يكون الرجل مجبوبا قد قطع ذكره أو لم يبق منه إلا ما لا يمكن الجماع به فإن اختلفا في إمكان الجماع بالباقي فالقول قولها

[ج ٧ - ص ١٠١]

ويحتمل أن القول قوله الثاني أن يكون عنينا لا يمكنه الوطء فإن اعترف بذلك أجل سنة منذ ترافعه

[ج ٧ - ص ١٠٢]

فإن وطىء فيها وإلا فلها الفسخ فإن اعترفت أنه وطئها مرة بطل كونه عنينا فإن وطئها في الدبر أو وطىء غيرها لم تزل العنة

[ج ٧ - ص ١٠٣]

ويحتمل أن تزول فإن ادعى أنه وطئها وقالت إنها عذراء فشهد بذلك امرأة ثقة فالقول قولها وإلا فالقول قوله وإن كانت ثيبا فالقول قوله وعنه القول قولها

[ج ٧ - ص ١٠٤]

وقال الخرقي يخلى معها في بيت ويقال لها أخرج ماءك على شيء فإن ادعت أنه ليس بمني جعل على النار فإن ذاب فهو مني وبطل قولها

فصل القسم الثاني

يختص بالنساء وهو شيئان الرتق [ج ٧ - ص ١٠٥]

الراء والتاء يعني ملتصقا لا يدخل الذكر فيه قاله أبو الخطاب وقال الجوهري هو مصدر امرأة رتقاء أي بينة الرتق لا يستطاع جماعها لارتتاق ذلك الموضع منها (وهو كون الفرج مسدودا لا مسلك للذكر فيه) قاله في الفروع وغيره لأنه يمنع من استيفاء مقصود النكاح أشبه الجب والعنة ولأن المرأة أحد العوضين في النكاح فجاز ردها بعيب كالصداق (وكذلك القرن والعفل وهو لحم يحدث فيه يسده) كذا قيل أما القرن بفتح القاف والراء قرنت المرأة بكسر الراء تقرن قرنا بفتحها فيهما إذا كان في فرجها قرن وهو العظم أو غدة مانعة من سلوك الذكر وأما العفل بوزن فرس شيء يخرج من فرج المرأة وحياء الناقة شبيه بما يكون في خصية الرجل (وقيل القرن عظم والعفل رغوة فيه) بتثليث الراء ورغوة اللبن معروفة وزبد كل شيء رغوته (تمنع لذة الوطء) قاله أبو حفص وقال القاضي هما والرتق لحم ينبت في الفرج

(الثاني الفتق) قال الجوهري الفتق بالتحريك مصدر قولك امرأة فتقاء وهي المنفتقة الفرج خلاف الرتقاء (وهو انخراق ما بين السبيلين) وهو المذهب واعتمد عليه في الفروع (وقيل انخراق ما بين مخرج البول والمني) قدمه في الكافي لأن فيه تنفيرا أشبه انخراق ما بين السبيلين وفي المحرر إذا انخرق مخرجا البول والمني في الفرج فهل يثبت الخيار على وجهين

(الثالث مشترك بينهما وهو الجذام والبرص) لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فرأى بكشحها بياضا فقال الحقي بأهلك فثبت [ج ٧ - ص ١٠٦]

الخيار بالبرص وباقي العيوب بالقياس عليه ولأنهما يثيران نفرة في النفس تمنع قربان أحدهما الآخر ويخشى تعديه إلى النفس والنسل (والجنون) لأنه يثير النفرة المذكورة ويخاف ضرره (سواء كان مطبقا) أين دائما (أو يخنق في الأحيان) أي يعتريه وقتا دون آخر لأن النفس لا تسكن إلى من هذه حاله وفي الواضح جنون غالب وفي المغني أو إغماء مريض لم يدم (فهذه الأقسام يثبت بها خيار الفسخ رواية واحدة) وهذا تصريح من المؤلف أنه لا خلاف عنه في ذلك

فصل

(واختلف أصحابنا في البخر وهو من الفم) على المذهب لأنه يثير نفرة كالبرص (وقال ابن حامد نتن في الفرج يثور عند الوطء) لأن النفرة حاصلة به قال في المغني إن أراد به أنه يسمى بخرا ويثبت الخيار وإلا فلا معنى له وذكر ابن عقيل في بخر روايتين

فائدة يستعمل له السواك ويأخذ كل يوم ورق آس مع زبيب منزوع العجم قدر جوزة واستعمال الكرفس ومضغ النعناع جيد فيه

(واستطلاق البول) أي لا يزال ينقض (والنجو) وهو الغائط (والقروح السيالة في الفرج) واحدها قرح بفتح القاف وضمها كالضعف والضعف (والباسور) [ج ٧ - ص ١٠٧]

وهو علة تخرج في المقعدة (والناسور) بالنون العرق الذي لا يزال ينقض (والخصاء) بالمد خصيت الفحل خصيا إذا سللت أنثيبه وقطعتهما أو قطعت ذكره (وهو قطع الخصيتين والسل وهو سل البيضتين والوجاء) بكسر الواو ممدودا (وهو رضهما) وفي المطلع وهو رض عروق البيضتين حتى تنفضخ فيكون شبيها بالخصاء (وفي كونه خنثى) سواء كان مشكلا أو لا قاله جماعة وخصه في المغني بالمشكل وفي الرعاية عكسه وفي ثبوت الخيار بذلك وجهان أحدهما لا يثبت لأن ذلك لا يمنع الاستمتاع ولا يخشى تعديه أشبه العمى بل يقال إن الخصي أقدر على الجماع والخنثى فيه خلقة زائدة كاليد الزائدة والثاني بلى لأن فيه نقصا وعارا ويثير نفرة وألحق بذلك في الموجز بول كبيرة في الفراش والقرع في الرأس وله رائحة منكرة وجهان (وفي ما إذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله) لا خيار لأنه لا مزية لأحدهما على صاحبه والثاني وهو الأصح ثبوته لوجود سببه أشبه العبد المغرور بأمة لأن الإنسان قد يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه وعلم منه أنه إذا اختلف العيب فيهما أنه يثبت الخيار إلا أن يجد المجبوب المرأة رتقاء فلا ينبغي أن يثبت لهما الخيار لامتناع الاستمتاع بعيب نفسه واختار في الفصول إن لم يطأ لبظر بها فرتقاء (أو حدث به العيب بعد العقد هل يثبت الخيار على وجهين) أحدهما واختاره القاضي وجزم به في الوجيز وصححه في الشرح يثبت الخيار لأنه عيب أثبت الخيار مقارنا فأثبته طارئا كالإعسار والرق والثاني

لا وهو قول أبي بكر وابن حامد لأنه عيب حدث بالمعقود عليه بعد لزوم العقد أشبه الحادث [ج ٧ - ص ١٠٨]

بالمبيع والأول أشبه لأنه ينتقض بالعيب الحادث في الإجارة

تنبيه علم مما سبق أنه لا فسخ بغير ذلك كعور وعمى وقطع يد بخلاف البيع وفي الروضة هل يحط من مهر المثل بقدر النقص فيه نظر وقيل لشيخنا لم فرق بين هذه العيوب وغيرها قيل قد علم أن عيوب الفرج المانعة من الوطء لا يرضى بها في العادة فإن المقصود من النكاح الوطء بخلاف اللون والطول والقصر وأن الحرة لا تقلب كما تقلب الأمة والزوج قد رضي رضى مطلقا وهو لم يشترط صفة فبانت بدونها والصواب أن له الفسخ وذكر صاحب الهدي في قطع يد أو رجل أو خرس أو طرش وكذا كل عيب لا يحصل به مقصود النكاح فوجب الخيار وانه أولى من البيع واختار بعض الشافعية رد المرأة بما ترد به الأمة في البيع حكاه أبو عاصم العباداني وقال أبو البقاء الشيخوخة في أحدهما عيب ولو بان عقيما فلا خيار نص عليه ونقل ابن منصور أعجب إلي أن يبين لها

(فإن علم بالعيب وقت العقد أو قال قد رضيت به معيبا) فلا خيار له بغير خلاف نعلمه لأنه قد رضي به أشبه مشتري المبيع وإن ظنه يسيرا فبان كثيرا فلا خيار له بخلاف ما إذا رضي بعيب فبان غيره لأنه وجد به عيبا لم يرض به ولا يحسبه وإن رضي بعيب فزاد بعد العقد فلا خيار له لأن رضاه به رضى بما يحدث منه (أو وجد منه دلالة على الرضى من وطء أو تمكين مع العلم بالعيب فلا خيار له) لأنه عيب يثبت الخيار

فبطل بما ذكر كالعيب في المبيع وعلم منه أن خيار العيب والشرط على التراخي لا يسقط إلا بما يدل على [ج ٧ - ص ١٠٩]

الرضى من قول أو فعل إلا في العنة فإنه لا يسقط بغير القول وصرح به الأصحاب

(ولا يجوز الفسخ إلا بحكم الحاكم) لأنه مجتهد فيه كالفسخ بالإعسار والعنة بخلاف خيار المعتقة تحت عبد فإنه متفق عليه فعليه بفسخه هو أو برده إلى من له الخيار وفي الوجيز يتولاه هو وإن فسخ مع عنيته أو فرق بين متلاعنين بعد عنيتهما ففيه خلاف في الانتصار وفي الترغيب لا يطلق على عنينين كولي في أصح الروايتين ولا تحرم أبدا وعنه كلعان وقال الشيخ تقي الدين ليس هو الفاسخ وإنما يأذن ويحكم به فمتى أذن أو حكم لأحد باستحقاق عقد أو فسخ فهو فعله

فرع إذا زال العيب فلا فسخ وكذا إن علم حالة العقد ومنعه في المغني في عنين ذكره في المصراة قال في الفروع ويتوجه في غيره مثله (فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر) سواء كان الفاسخ الزوج أو الزوجة لأن الفسخ إن كان منها فالفرقة من جهتها يسقط مهرها كرضاع زوجة له أخرى وإن كان منه فإنما فسخ لعيب بها دلسه بالإخفاء فصار الفسخ كأنه منها لا يقال هلا جعل فسخها لعيبه كأنه منه لحصوله بتدليسه لأن العوض من الزوج في مقابلة منافعهما فإذا اختارت الفسخ مع سلامة ما عقد عليه رجع العوض إلى العاقد منهما وليس من جهتها عوض في مقابلة منافع الزوج وإنما ثبت لها الخيار لأجل ضرر يلحقها لا لأجل تعذر ما

استحقت عليه في مقابلته عوضا فافترقا (وإن فسخ بعده فلها المهر المسمى) على المذهب لأنه نكاح صحيح وجد بأركانه [ج ٧ - ص ١١٠]

وشروطه فترتب عليه أحكام الصحة ولأن المهر يجب بالعقد ويستقر بالخلوة فلا يسقط بحادث بعده بدليل أنه لا يسقط بردتها وفيه مسمى صحيح فوجب كغير المعيبة والمعتقة تحت عبد وكما لو طرأ العيب (وقيل عنه مهر المثل) لأن الفسخ استند إلى العقد فصار كالعقد الفاسد وقيل عنه مهر المثل في فسخ الزوج لشرط أو عيب قديم وقيل فيه ينسب قدر نقص مهر المثل لأجل ذلك إلى مهر المثل كاملا فيسقط من المسمى بنسبته فسخ أو أمضى وقاسه في الخلاف على المبيع المعيب وفي مختصر ابن رزين مسمى بلاحق ومثل بسابق

فرع الخلوة هنا كالوطء في تقرير المهر ونحوه

(ويرجع به على من غره من المرأة والولي) أو الوكيل رواه مالك عن عمر وكما لو غر بحرية أمة قال المؤلف والصحيح أن المذهب رواية واحدة أنه يرجع قال أحمد كنت أذهب إلى قول علي فهبته فملت إلى قول عمر (وعنه لا يرجع) وهي قول أكثر العلماء لأنه ضمن ما استوفى بدله وهو الوطء فلا يرجع به على غيره كما لو كان المبيع معيبا فأكله فعلى الأول إن كان الولي علم غرم وإن لم يعلم رجع عليها بالصداق ويقبل قول الولي مع يمينه في عدم علمه بالعيب إلا أن تقوم عليه بينة بإقراره وقال القاضي إن كان أبا أو جدا أو ممن يجوز أن يراها فالتقرير في جهته علم أو لا ومثله

الرجوع على الغار ولو زوج امرأة فأدخلوا عليه غيرها ويلحقه الولد وتجهز زوجته بالمهر الأول نص عليه

فرع إذا طلقها قبل الدخول ثم علم أنه كان بها عيب فعليه نصف

الصداق وإن مات أو ماتت قبل العلم بالعيب فلها الصداق ولا يرجع فيهما وإذا بانت بالفسخ فلا سكنى لها ولا نفقة إن كانت حائلا كالبائن بالثلاث وإن كانت حاملا فلها النفقة للحمل والحمل لاحق به وقيل لا لأنها بائن وفي السكنى روايتان

فصل

(وليس لولي صغيرة) حرة (أو مجنونة ولا سيد أمة تزويجها معيبا) لأنه ناظر لهم بما فيه الحظ ولا حظ لهن في هذا العقد فإن زوجهن مع العلم بالعيب لم يصح وإن لم يعلم به صح كما لو اشترى معيبا لا يعلم عيبه وقيل مطلقا وعكسه وهل له الفسخ إذن أو ينتظرها فيه وجهان وفي الرعاية الخلاف إن أجبرها بغير كفء وصححه في الإيضاح مع جهله ويخير ومثله تزويج صغير ومجنون بمعيبة (ولا لولي كبيرة تزويجها به بغير رضاها) بغير خلاف نعلمه لأنها تملك الفسخ إذا علمت به بعد العقد فالامتناع أولى فإن خالف وفعل صح مع جهله به والأصح له الفسخ إذا علم (فإن اختارت الكبيرة نكاح مجبوب أو عنين لم يملك منعها) في الأصح لأن الحق لها والضرر مختص بها والثاني له منعها لأنه ضرر دائم ربما أفضى إلى الشقاق فيتضرر وليها وأهلها فملك الولي منعها كما لو أرادت نكاح غير كفء قال أحمد ما يعجبني أن يزوجها بعنين وإن رضيت الساعة تكره إذا دخلت عليه لأن من شأنهن النكاح ويعجبهن

من ذلك ما يعجبنا (وإن اختارت نكاح مجنون أو مجذوم أو أبرص فله منعها في أصح الوجهين) لأن فيه ضررا دائما وعارا عليها وعلى أهلها أشبه من تزويجها بغير كفء ولأنه يخشى تعديه إلى الولد والثاني لا يملك منعها لأن الحق لها أشبه المجبوب وعلى الأول فلو اتفقا على ذلك ورضيا به صح النكاح ويكره لهما ذلك لأنها وإن رضيت الآن تكره فيما بعد وقيل ولبقية الأولياء المنع لأن العار يلحقهم أشبه ما لو زوجها بغير كفء (وإن علمت العيب بعد العقد أو حدث به لم يملك إجبارها على الفسخ) ذكره الأصحاب لأن حق الولي في ابتداء العقد لا في دوامه لأنها لو دعت وليها أن يزوجها بعبد لم يلزمه إجابتها ولو عتقت تحت عبد لم يملك إجبارها على الفسخ

باب نكاح الكفار

(وحكمه حكم نكاح المسلمين فيما يجب به وتحريم المحرمات) أنكحة الكفار يتعلق بها أحكام النكاح الصحيح من وقوع الظهار والإيلاء ووجوب المهر والقسم والإباحة للزوج الأول والإحصان وكذا وقوع الطلاق في قول الجمهور لأنه طلاق من بالغ عاقل في نكاح صحيح فوقع كطلاق المسلم ودليل صحته قوله تعالى (وامرأته حمالة الحطب) و (امرأة فرعون) وحقيقة الإضافة تقتضي زوجية صحيحة ولهذا قال النبي

صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح لا من سفاح وإذا ثبت صحتها ثبت أحكامها كأنكحة المسلمين فعلى هذا لو طلق الكافر ثلاثا [ج ٧ - ص ١١٣]

ثم تزوجها قبل زوج وأصابه ثم أسلما لم يقرا عليه ولو طلقها أقل من ثلاث ثم أسلما فهي عنده على ما بقي من طلاقها ويحرم عليهم ما يحرم على المسلمين كما ذكر في بابه

(ويقرون على الأنكحة المحرمة ما اعتقدوا حلها) في شرعهم (ولم يرتفعوا إلينا) هذا هو المذهب لأنه أسلم الخلق الكثير في زمنه عليه السلام فأقرهم على أنكحتهم ولم يكشف عن كيفيتها خصوصا أهل هجر لعلمه أنهم يستبيحون نكاح محارمهم ولأن ما لا يعتقدون حله ليس من دينهم فلا يقرون عليه كالزنى قال أحمد فيمن عقد على ذات محرم إنه يقر مالم يرتفعوا إلينا (وعنه في مجوسي تزوج كتابية واشترى نصرانية يحول بينهما الإمام) لأنه لا مساغ له عندنا ولأن علينا ضررا في ذلك بتحريم أولاد النصرانية علينا ولأنه نكاح فاسد أشبه نكاح المسلم الفاسد (فيخرج من هذا أنهم لا يقرون على نكاح محرم) وأن يحال بينهم وبين نكاح محارمهم لقول عمر فرقوا بين كل رحم من المجوس وقال أحمد في مجوسي ملك أمة نصرانية يحال بينه وبينها ويجب عليه بيعها لأن النصارى لهم دين فلو ملك نصراني مجوسية فلا بأس أن يطأها وقال أبو بكر لا يباح لما فيه من الضرر (فإن أسلموا) وأتونا (أو ترافعوا إلينا) قبل إسلامهم (في ابتداء العقد) لنعقده لهم (لم نمضه إلا على الوجه الصحيح) كأنكحة المسلمين من الإيجاب والقبول والولي والشهود لأنه لا حاجة إلى

عقد يخالف ذلك قال الله تعالى ﴿ وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ﴾

[ج ٧ - ص ١١٤]

أي بالعدل (وإن كان في أثنائه) حتى ولو أسلم الزوجان فإن كانت المرأة تباح إذن كعقده في عدة فرغت أو بلا شهود نص عليهما أو بلا ولي وصيغة أو على أخت ماتت (لم نتعرض لكيفية عقدهم) بغير خلاف نعلمه قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حالة واحدة أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب أو رضاع (بل إن كانت المرأة ممن لا يجوز ابتداء نكاحها كذات محرمه ومن هي في عدتها أو شرط الخيار في نكاحها متى شاء أو مدة هما فيها أو مطلقته ثلاثا فرق بينهما) لأن الاستدامة أضعف من الابتداء فإذا لم يجز الابتداء وهو أقوى فلأن لا تجوز الاستدامة وهي أضعف بطريق الأولى وكذا إن كان بينهما نكاح متعة فإن اعتقدا فساد الشرط وحده أقرا (وإلا أقرا على النكاح) لعدم وجود ما يبطله وعنه يعتبر في المفسد مؤبدا أو مجمعا عليه فإذا أسلما والمرأة بنته من رضاع أو زنى أو هي في عدة مسلم متقدمة على القعد فرق بينهما وإن كانت من كافر فروايتان منصوصتان وفي حبلى من زنى وشرط الخيار فيه مطلقا أو إلى مدة هما فيها وجهان

(وإن قهر حربي حربية فوطئها أو طاوعته واعتقداه نكاحا) ثم أسلما (أقرا) لأن المصحح له اعتقاده الحل وهو موجود هنا كالنكاح بلا ولي (وإلا فلا) أي إذا لم يعتقاه لم يقرا عليه لأنه ليس من أنكحتهم وحكم أهل الذمة كذلك جزم به في المغني وفي الترغيب لا يقرون (وإن كان

المهر المسمى صحيحا) قبض أو لم يقبض (أو فاسدا قبضته استقر) لأنه لا يتعرض إلى [ج ٧ - ص ١١٥]

ما فعلوه يؤكده قوله تعالى ﴿ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ﴾ ولأن التعرض للمقبوض بإبطاله يسبق لتطاول الزمان وكثرة تصرفاتهم في الحرام ولأن في التعرض إليهم تنفيرا لهم عن الإسلام فعفي عنه كما عفي عما تركوه من الفرائض ولأنهم تقابضوا بحكم الشرك فرئت ذمة من عليه منه كما لو تبايعوا بيعا فاسدا وتقابضوا (وإن كان فاسدا) كالخمر (لم تقبضه) ولم يسم لها شيء (فرض لها مهر المثل) لأنه يجب في التسمية الفاسدة إذا كانت الزوجة مسلمة فكذا الكافرة ولأن الخمر لا قيمة لها في الإسلام فوجب مهر المثل وعن لا شيء لها في خمر وخنزير معين ولها في غير معين قيمته ذكرها القاضي فلو أسلما فانقلبت خلا وطلق ففي رجوعه بنصفه وجهان ولو تلف الخل ثم طلق ففي رجوعه بنصف مثله احتمالان

فرع إذا قبضت بعض المسمى الفاسد وجب قسط ما بقي من مهر المثل وتعتبر الحصة فيما يدخله الكيل أو الوزن به وفي معدود قيل بعده وقيل بقيمته عندهم ولا يرجع بما أنفقه من خمر ونحوه كما لو كان مهرا قبضته ذكره في الروضة

مسألة قال أحمد في المجوسية تكون تحت أخيها أو أبيها فيطلقها أو يموت عنها فترفع إلى المسلمين لا مهر لها لأنه باطل من أصله لا يقر عليه في الإسلام فإن دخل بها فهل يجب مهر المثل يخرج على الخلاف في المسلم

إذا وطئ امرأة من محارمه بشبهة انتهى فلو تزوج ذمي ذمية على أن لا صداق لها أو سكت عن ذكره فلها المطالبة بفرضه قبل الدخول وبعده يجب مهر المثل [ج ٧ - ص ١١٦]

فصل

(وإذا أسلم الزوجان معا) بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة فهما على نكاحهما إجماعا لأن اختلاف الدين مفسد للنكاح بمجرد سبق أحدهما وقيل يقف على المجلس بدليل القبض لأن اتفاقهما على النطق بكلمة الإسلام معا متعذر فلو اعتبر ذلك لوقعت الفرقة بين كل مسلمين إلا في الشاذ النادر (أو اسلم زوج الكتابية) سواء كان كتابيا أو غير كتابي قبل الدخول أو بعده (فهما على نكاحهما) لأن نكاح الكتابية يجوز ابتداؤه فالاستمرار أولى (وإن أسلمت الكتابية أو أحد الزوجين غير الكتابيين) كالوثنيين والمجوسيين (قبل الدخول يفسخ النكاح) لقوله تعالى ﴿ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ﴾ ﴿ ولا تمسكوا بعصم الكوافر ﴾ إذ لا يجوز لكافر نكاح مسلمة قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم ولأن دينها اختلف فلم يجز استمراره كابتدائه وتعجلت الفرقة وكان ذلك فسخا لا طلاقا كالردة (فإن كانت هي المسلمة فلا مهر لها) رجحه في الشرح وقدمه في الفروع لأن الفرقة من جهتها أشبه مالو ارتدت وعنه لها نصفه اختاره أبو بكر لأن الفرقة حصلت منه بامتناعه من الإسلام وهي فعلت الواجب عليها كما لو علق طلاقها على الصلاة فصلت وفرق المؤلف بينهما من حيث إن التعليق من جهة الزوج بخلاف الإسلام فإنه لا أثر له فيه البتة وعنه إن سبقها اختاره الأكثر (وإن أسلم قبلها فلها [ج ٧ - ص ١١٧]

نصف المهر) على المذهب لأن الفرقة حصلت من جهته أشبه ما لو طلقها (وعنه لا مهر لها) لأن الفرقة حصلت بتأخرها عن الإسلام فكان من جهتها ولأن في إيجاب المهر عليه تنفيرا له عن الإسلام لأنه يجتمع عليه فسخ النكاح مع وجوب المهر

(وإن قالت أسلمت قبلي وأنكرها فالقول قولها) لأنها تدعي استحقاق شيء أوجبه العقد وهو يدعي سقوطه فلم يقبل قوله لأن الأصل عدمه وهذا تفريع على أنها تستحق نصف المهر إذا سبقها بالإسلام وأما على الأخرى فلا (وإن قال أسلمنا معا فنحن على النكاح فأنكرته فعلى وجهين) كذا أطلقهما في المحرر والفروع أحدهما وجزم به في الوجيز أنه يقبل قوله لأن الأصل بقاء النكاح والثاني يقبل قولها لأن الظاهر معها إذ يبعد اتفاق الإسلام منهما دفعة واحدة وإن قبل العبرة بالمجلس فينبغي أن يقبل قوله لأن العمل بالظاهر متعين

فرع إذا قالا سبق أحدنا ولا نعلم عينه فلها نصف المهر قاله أبو الخطاب وقدمه في الفروع وقال القاضي إن لم تكن قبضت فلا شيء لها لأنها تشك في استحقاقه وإن كان بعد القبض لم يرجع عليها لأنه يشك في استحقاق الرجوع

(وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة فإن اسلم الثاني قبل انقضائها فهما على نكاحهما) هذا هو المشهور قال أبو بكر رواه

[ج ٧ - ص ١١٨]

عنه خمسين رجلا واختاره عامة الأصحاب لما روى ابن شبرمة قال كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبله فأيهما أسلم قبل انقضاء العدة فهي امرأته وإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما وروي أن بنت الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت ثم أسلم صفوان فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما قال ابن شهاب وكان بينهما نحو من شهر رواه مالك قال ابن عبد البر وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده وقال ابن شهاب وأسلمت أم حكيم وهرب زوجها عكرمة إلى اليمن فارتحلت إليه ودعته إلى الإسلام فأسلم وقدم فبايع النبي صلى الله عليه وسلم فبقيا على نكاحهما قال الزهري ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت وزوجها مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها روى ذلك مالك (وإلا) أي وإن لم يسلم الثاني قبل انقضائها (تبينا أن الفرقة وقعت حين أسلم الأول) لأن سبب الفرقة اختلاف الدين فوجب أن تحتسب الفرقة منه كالطلاق (فعلى هذا لو وطئها في عدتها ولم يسلم الثاني فعليه المهر) لأنه تبينا أنه وطئ في غير ملك ويؤدب (وإن أسلم فلا شيء لها) لأنه وطئها في نكاحه (وإذا أسلمت قبله فلها نفقة العدة) لأنها محبوسة بسببه فكان لها النفقة لكونه يتمكن من استمتاعها كالرجعية وسواء أسلم في عدتها أو لا (وإن كان هو المسلم فلا نفقة لها) لأنه لا سبيل إلى تلافي

نكاحها أشبهت البائن (فإن اختلفا في السابق منهما فالقول قولها في أحد الوجهين) جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر [ج ٧ - ص ١١٩]

والفروع لأن الأصل وجوب النفقة وهو يدعي سقوطها

والثاني يقبل قوله لأن النفقة إنما تجب بالتمكين من الاستمتاع والأصل عدمه فإن قال أسلمت بعد شهرين من إسلامي فلا نفقة لك فيهما وقالت بعد شهر فالقول قوله فأما إن ادعى هو ما يفسخ النكاح وأنكرته انفسخ

فرع لو لاعن ثم اسلم صح لعانه وإلا فسد ففي الحد إذن وجهان وفي الترغيب لهما فيمن ظن صحة نكاح فلاعن ثم بان فساده

(وعنه أن الفرقة تتعجل بإسلام أحدهما كما قبل الدخول) اختارها الخلال وصاحبه وقدمها السامري وابن حمدان ونصرها ابن المنذر لقوله تعالى ﴿ فإن علمتموهن مؤمنات ﴾ الآية وهي تدل من وجه عموم ﴿ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ﴾ فأمر برد المهر ولو لم تقع الفرقة باختلاف الدين لما أمر برد المهر وقوله تعالى ﴿ ولا جناح عليكم أن تنكحوهن ﴾ وأباح نكاحهن على الإطلاق وقوله ﴿ ولا تمسكوا بعصم الكوافر ﴾ يكون منسوخا بهذه الآية والجواب بأن المراد في حال كفرهم بدليل قوله ﴿ فلا ترجعوهن إلى الكفار ﴾ وبأنه يجب دفع المهر إلى الزوج إذا جاء وإن كان قبل انقضاء عدتها ثم نسخ وجوب دفع المهر إليه وبأنه محمول على ما بعد العدة

والثالثة الوقف بإسلام الكتابية والانفساخ بغيرها

والرابعة الوقف مطلقا وظاهره أن الفرقة حيث تقع تقع في الحال

[ج ٧ - ص ١٢٠]

ولا يحتاج إلى حاكم ولا إلى عرض الزوج على الإسلام ولا فرق بين دار الإسلام وغيرها نص عليه لأن أبا سفيان أسلم بمر الظهران ثم أسلمت امرأته بمكة فأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على نكاحهما ولأنه عقد معاوضة فلم ينفسخ باختلاف الدار كالبيع

تنبيه إذا أسلم أحدهما وتخلف الآخر حتى انقضت العدة انفسخ النكاح في قول عامتهم وعن أحمد ترد إلى زوجها وإن طالت المدة وهو قول النخعي لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا رواه أحمد وأبو داود والترمذي ولفظه له وقال ليس بإسناده بأس وصححه أحمد

وجوابه بأنه يحتمل أن يكون قبل نزول تحريم المسلمات على الكفار أو تكون حاملا استمر حملها أو مريضة لم تحض ثلاث حيض حتى أسلم زوجها أو تكون ردت إليه بنكاح جديد رواه أحمد والترمذي عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بنكاح جديد ومهر جديد قال أحمد هذا ضعيف وقال الدارقطني لا يثبت وقال يزيد بن هارون حديث ابن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب واختار الشيخ تقي الدين أنها إذا أسلمت قبله بقاء نكاحه قبل الدخول وبعده ما لم تنكح من غيره

والأمر إليها ولا حكم له عليها ولا حق عليه لأن الشارع لم يستفصل وهو مصلحة محضة وكذا عبده إن أسلم قبلها وليس له حبسها وأنها متى أسلمت ولو قبل الدخول وبعد العدة فهي امرأته إن اختار [ج ٧ - ص ١٢١]

(وأما الصداق فواجب) بعد الدخول (بكل حال) يعني إذا وقعت الفرقة بإسلام أحدهما بعد الدخول يجب لها المهر لأنه استقر بالدخول فإن كان صحيحا أو فاسدا قبضته استقر وإن كان فاسدا لم تقبضه أو لم يسم لها شيء فلها مهر المثل

فصل

(وإن ارتد أحد الزوجين) أو هما معا (قبل الدخول انفسخ النكاح) في قول عامتهم لقوله تعالى ﴿ ولا تمسكوا بعصم الكوافر ﴾ ولأنه اختلاف دين يمنع الإصابة فأوجب فسخ النكاح كما لو أسلمت تحت كافر (ولا مهر لها إن كانت هي المرتدة) لأن الفسخ من قبلها (وإن كان هو المرتد فلها نصف المهر) لأن الفسخ من جهته أشبه طلاقها قبل الدخول وإن كانت التسمية فاسدة فلها نصف مهر المثل (وإن كانت الردة بعد الدخول فهل تتعجل الفرقة أو تقف على انقضاء العدة على روايتين) كذا في الكافي والمحرر والفروع إحداهما تتعجل الفرقة روي عن الحسن وعمر بن عبد العزيز والثوري لأن ما أوجب فسخ النكاح استوى فيهما قبل الدخول وبعده كالرضاع والثانية وهي أشهر تقف على انقضاء العدة كإسلام الحربية تحت الحربي والرضاع تحريم المرأة على التأبيد فلا فائدة في تأخير الفسخ إلى ما بعد انقضاء العدة فإن كان هو المرتد فلها نفقة العدة لأنه يمكنه تلافي نكاحها بإسلامه [ج ٧ - ص ١٢٢]

فهي كزوج الرجعية (وإن كانت هي المرتدة فلا نفقة لها) لأنه لا سبيل إلى تلافي نكاحها فلم يكن لها نفقة كما بعد العدة

تتمة إذا وطئها أو طلق ولم تتعجل الفرقة ففي المهر ووقوع الطلاق خلاف في الانتصار

(وإن انتقل أحد الكتابيين إلى دين لا يقر عليه) أو تمجس كتابي تحته كتابية (فهو كردته) بغير خلاف نعلمه لأنه انتقل إلى دين لا يقر عليه أهله بالجزية أشبه عبادة الأوثان وإن تمجست دونه فوجهان وظاهره أنه إذا انتقل إلى دين يقر عليه كاليهودي يتنصر فنص أحمد أنه يقر وهو ظاهر الخرقي واختاره الخلال وصاحبه لأنه لم يخرج عن دين أهل الكتاب أشبه غير المتنقل والثانية لا يقر لأنه انتقل إلى دين قد أقر ببطلانه فهو كالمرتد

فرع من هاجر إلينا بذمة مؤبدة أو مسلما أو مسلمة والآخر بدار الحرب لم ينفسخ النكاح

فصل

(وإن أسلم كافر وتحته أكثر من أربع نسوة فأسلمن معه) وكن كتابيات (اختار منهن) ولو كان محرما بحج أو عمرة خلافا للقاضي (أربعا) ولو من شاب إن كان مكلفا وإلا وقف الأمر حتى يكلف (وفارق سائرهن) لقوله عليه السلام لغيلان بن سلمة وقد أسلم على عشر نسوة فأسلمن معه فأمره أن يختار [ج ٧ - ص ١٢٣]

منهن أربعا رواه الترمذي وابن ماجه وفي لفظ اختر منهن أربعا وفارق سائرهن روى أبو داود وابن ماجه عن قيس بن الحارث معناه وهو من رواية محمد بن أبي ليلى عن حميضة بن الشمردل وقد ضعفا وسواء تزوجهن في عقد واحد أو عقود اختار الأوائل أو الأواخر ولفظ الاختيار نحو اخترت هؤلاء أو أمسكتهن أو اخترت حبسهن أو نكاحهن أو أمسكت هؤلاء أو تركت هؤلاء فإن أسقط اخترت فظاهر كلام بعضهم يلزمه فراق بقيتهن والمهر لمن انفسخ نكاحها بالاختيار ولا مدخل للقرعة هنا لأنها قد تقع على من لا يحبها فيفضي إلى تنفيره ولا يصح تعليقها بشرط وعدة المتروكات منذ اختار لأن البينونة حصلت به وقيل منذ أسلم لأن البينونة الحقيقية حصلت بالإسلام وإنما الاختيار بين محلها فإن أسلم البعض وليس الباقي كتابيات ملك إمساكا وفسخا في مسلمة فقط وله تعجيل إمساك مطلقا وتأخيره حتى تنقضي عدة البقية أو يسلمن (فإن لم يختر أجبر عليه) لأنه حق عليه يمكنه فعله وهو يمتنع منه فأجبر عليه كإيفاء الدين وظاهره أنه يجبر عليه بحبس ثم تعزير وليس للحاكم أن يختار عنه كما يطلق على المولى لأن الحق هنا لغير معين (وعليه نفقتهن إلى أن يختار) لأنهن محبوسات عليه وهن في حكم الزوجات (فإن طلق إحداهن) فقد اختارها في الأصح لأن الطلاق لا يكون إلا في زوجة فإن قال فارقت أو أخترت هؤلاء فإن لم ينو به الطلاق كان اختيارا لغيرهن للخبر لأنه يدل على أن لفظ الفراق صريح فيه وقيل اختيار

للمفارقات عند الإطلاق والأول أولى واختار في الترغيب أن لفظ الفراق هنا ليس طلاقا ولا اختيارا للخبر [ج ٧ - ص ١٢٤]

فإن نوى به طلاقا كان طلاق واختيارا (أو وطئها كان اختيارا لها) في قياس المذهب لأنه لا يجوز إلا في ملك كوطء الجارية المبيعة بشرط الخيار وفي الواضح وجه كرجعة بناء على أن الوطء في حق المطلقة الرجعية لا يوجب الرجعة (وإن طلق الجميع ثلاثا أقرع بينهن فأخرج بالقرعة أربع منهن) لأن ذلك فائدة الإقراع (وله نكاح البواقي) لأنهن لم يطلقن منه وشرطه أن تنقضي عدة المطلقات ذكره في المغني والشرح لئلا يكون جامعا بين أكثر من أربع وقيل لا قرعة ويحرمن إلا بعد زوج وإن وطئ الكل تعين الأول

فرع أسلم ثم طلق الجميع ثم أسلمن في العدة اختار منهن أربعا فإذا اختار تبينا أن طلاقه وقع بهن لأنهن زوجات ويعتددن من حين طلاقه وبان البواقي باختياره لغيرهن ولا يقع بهن طلاقه وله نكاح أربع منهن إذا انقضت عدة المطلقات والفرق بينها وبين التي قبلها أن طلاقهن قبل إسلامهن في زمن ليس له الاختيار فيه فإذا أسلمن تجدد له الاختيار حينئذ

(وإن ظاهر أو آلى من إحداهن فهل يكون اختيارا لها على وجهين) كذا أطلقهما في المحرر والفروع أحدهما لا يكون اختيارا جزم به في الكافي والوجيز لأنه يصح في غير زوجته

والثاني بلى لأن حكمه لا يثبت في غير زوجه فإن قذفها لم يكن اختيارا (وإن مات) ولم يختر (فعلى الجميع عدة الوفاة) قدمه في المحرر وجزم به في الوجيز لأن الزوجات لم يتعين منهن (ويحتمل أن يلزمهن أطول

الأمرين من ذلك أو ثلاثة قروء) وقاله القاضي في المجرد وإن كانت حاملا فعدتها بوضعه لأن ذلك تنقضي به العدة بكل حال وإن كانت آيسة أو صغيرة فعدتها عدة الوفاة لأنها أطول العدتين في حقها وإن كانت من ذوات الأقراء اعتدت أطول الأجلين من ثلاثة أقراء أو أربعة أشهر وعشرا لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون مختارة وعدتها عدة الوفاة أو مفارقة وعدتها ثلاثة قروء فأوجبنا أطولهما لتقضى به العدة بيقين كما لو نسي صلاة من خمس ذكره في المغني والكافي وقال في الشرح عن القول الأول لا يصح وحكاهما في الفروع قولين من غير ترجيح (والميراث لأربع منهن بالقرعة) في قياس المذهب لأن الميراث بالزوجية ولا زوجية فيما زاد على الأربع فإن اخترن الصلح جاز كيفما اصطلحن

فرع إذا أسلمن معه ثم متن قبل اختياره فله أن يختار منهن ويكون له ميراثهن ولا يرث الباقيات وإن مات بعضهن فله الاختيار من الأحياء والأموات ولو أسلم بعضهن فمتن ثم أسلم البواقي فله الاختيار من الجميع وإن لم يسلم البواقي لزم النكاح في الميتات وإن وطئ الجميع قبل إسلامهن ثم أسلمن فاختار أربعا فليس لهن إلا المسمى ولسائرهن المسمى بالعقد الأول ومهر المثل للوطء الثاني وإن وطئهن بعد اسلامهن فالموطوءات أولا المختارات والباقي أجنبيات والحكم في المهر على ما تقدم

(وإن أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة) لما روى الضحاك بن فيروز عن أبيه قال أسلمت وعندي امرأتان أختان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر أيتهما شئت رواه الترمذي وفي رواية أحمد وأبي داود قال فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما ولأن أنكحة الكفار صحيحة وإنما حرم الجمع في الإسلام [ج ٧ - ص ١٢٦]

ما لو طلق إحداهما قبل إسلامه ثم أسلم والأخرى في حباله وكذا الحكم في المرأة وعمتها أو خالتها لأن المعنى في الجميع واحد وإن أسلمت إحداهما معه قبل المسيس تعينت وقيل إن لم تكن الأخرى كتابية (وإن كانتا أما وبنتا فسد نكاح الأم) وحرمت على الأبد لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل نكح امرأة دخل بها أو لم يدخل فلا تحل له أمها رواه ابن ماجه ولأنها من أمهات نسائه فيدخل في عموم قوله تعالى ﴿ وأمهات نسائكم ﴾ ولأنها أم زوجته فتحرم عليه كما لو طلق ابنتها في حال شركه (وإن كان دخل بالأم فسد نكاحهما) وحرمتا على الأبد حكاه ابن المنذر إجماعا والمهر للأم قاله في الترغيب وغيره

فصل

(وإن أسلم وتحته إماء فأسلمن معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام فمن يحل له نكاح الإماء) أي يكون عادما للطول خائفا العنت فله الاختيار منهن) لأن شروط النكاح تعتبر في وقت الاختيار أي فيختار واحدة وإن كانت لا تعفه فله أن يختار منهن من تعفه في إحدى الروايتين والأخرى لا يختار إلا واحدة (وإلا فسد نكاحهن) أي إذا لم يوجد الشرطان فإنه يفسد نكاح الكل ولم يكن له أن يختار لأنه لا يجوز ابتداء العقد عليها حال الإسلام فلم يملك اختيارها كالمعتدة وإن كان

دخل بهن ثم أسلم ثم أسلمن في عدتهن فالحكم كذلك وقال أبو بكر لا يجوز هنا أن يختار بل تبين بمجرد إسلامه [ج ٧ - ص ١٢٧]

وإن لم يسلمن إلا بعد العدة انفسخ نكاحهن وإن كن كتابيات

(وإن أسلم وهو موسر فلم يسلمن حتى أعسر فله الاختيار منهن) لأن شرائط النكاح تعتبر في وقت الاختيار بخلاف مالو أسلمت إحداهن وهو موسر ثم أسلم البواقي بعد إعساره لم يكن له الاختيار منهن لأن وقت الاختيار دخل بإسلام الأولى فلو أسلمت الأولى وهو معسر فلم يسلم البواقي حتى أيسر لم يكن له أن يختار من البواقي لأن الأولى اجتمعت معه في حال يجوز ابتداء نكاحها ولو أسلم وأسلمت معه وهو معسر فلم يختر حتى أيسر كان له أن يختار لأن تغير حاله لا يسقط ما ثبت (وإن أسلمت إحداهن بعده ثم عتقت ثم أسلم البواقي فله الاختيار منهن) لأن العبرة بحالة الاختيار وهي حالة اجتماعهم على الإسلام وحال اجتماعهما على الإسلام كانت أمة (وإن عتقت ثم أسلمت ثم اسلم البواقي لم يكن له الاختيار من البواقي) لأنه مالك لعصمة حرة من حين اجتماعهما على الإسلام (وإن أسلم وتحته حرة وإماء فأسلمت الحرة في عدتها قبلهن أو بعدهن انفسخ نكاحهن) لأنه قادر على حرة فلا يختار أمة وإن لم تسلم الإماء حتى انقضت عدتهن بن باختلاف الدين وإن أسلمن في عدتهن بن من حين إسلام الحرة وابتداء العقد من حين البينونة فإن ماتت الحرة بعد إسلامها لم يتغير الحكم بموتها وإن انقضت عدة الحرة قبل إسلامها بانت باختلاف الدين وله أن يختار من الإماء لأنه لم يقدر على الحرة وليس له أن يختار من الإماء قبل إسلامها وقضاء عدتها وإن

طلق الحرة ثلاثا قبل إسلامها ثم لم يسلم لم يقع الطلاق لأن النكاح

[ج ٧ - ص ١٢٨]

انفسخ باختلاف الدين وله الاختيار من الإماء وإن أسلمت في عدتها فالنكاح ثابت ووقع فيها الطلاق وبن الإماء بثبوت نكاحها قبل الطلاق (وإن أسلم عبد وتحته إماء فأسلمن معه) أو في العدة (ثم عتق فله أن يختار منهن) اثنتين لأنه حال اجتماعهم على الإسلام كان عبدا يجوز له الاختيار من الإماء (فإن أسلم وعتق ثم أسلمن فحكمه حكم الحر لا يجوز أن يختار منهن إلا بوجود الشرطين فيه) لأنه في حال اجتماعهم في الإسلام كان حرا فيشترط في حقه ما يشترط في حق الحر وحينئذ يلزمه نكاح أربع لثبوت خياره حرا ولو أسلم على أربع فأسلمت ثنتان ثم عتق فأسلمتا فهل تتعين الأوليان فيه وجهان ولا مهر بالفسخ قبل الدخول

كتاب الصداق

وهو العوض المسمى في النكاح وفيه لغات صداق بفتح الصاد وكسرها وصدقة بفتح الصاد وضم الدال وصدقة بسكون الدال فيهما مع ضم الصاد وفتحها وله أسماء الصداق والصدقة والمهر والنحلة والفريضة والأجر والعلائق والعقر والحباء وقد نظمت في بيت وهو قوله % صداق ومهر نحلة وفريضة % حباء وأجر ثم عقر علائق %

يقال أصدقت المرأة ومهرتها ولا يقال أمهرتها قاله في المغني وفي النهاية (وهو مشروع في النكاح) لقوله تعالى ﴿ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ﴾ وقيل النحلة الهبة والصداق في معناها وقيل نحلة من الله تعالى للنساء وقوله تعالى ﴿ فآتوهن أجورهن فريضة ﴾ وقوله عليه السلام فإن دخل بها لها المهر بما استحل من فرجها وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال مهيم فقال يا رسول الله تزوجت امرأة قال ما أصدقتها قال وزن نواة من ذهب رواه الجماعة قوله وزن نواة هو اسم لما زنته خمسة دراهم ذهبا كان أو فضة وقيل كانت قدر نواة من ذهب قيمتها خمسة دراهم ونصف وقيل كانت ربع دينار

(ويستحب تخفيفه) لقوله عليه السلام أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة

رواه أحمد وفيه ضعف وقال عمر لا تغالوا في بصدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه (وألا يعرى النكاح عن تسميته) بل يستحب تسميته في العقد لأنه عليه السلام كان يزوج ويتزوج ولم يكن يخلي ذلك من صداق مع أنه كان عليه السلام له أن يتزوج بلا مهر وقال للذي زوجه الموهوبة هل من شيء تصدقها قال لا قال التمس ولو خاتما من حديد ولأنه أقطع للنزاع وليس ذكره شرطا وفاقا لقوله تعالى ﴿ ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ﴾ ولأن القصد بالنكاح الوصلة والاستمتاع وبالغ في التبصرة فكره تركه وذكر الطحاوي أن كثيرا من أهل المدينة يبطلون هذا النكاح إذا خوصموا فيه قبل الدخول

(وألا يزيد على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته وهو خمسمائة درهم) وقال في المستوعب لما روى مسلم من حديث عائشة أن صداق النبي صلى الله عليه وسلم على أزواجه خمسمائة درهم وفي الرعاية والوجيز والفروع ألا يزيد على مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته من أربعمائة إلى خمسمائة وقدم في الترغيب لا يزاد على مهر بناته أربعمائة درهم لما روى أبو العجفاء قال سمعت عمر يقول ما أصدق النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه لكن أبو العجفاء فيه ضعف

(ولا يتقدر أقله) وقاله الأوزاعي والليث لقوله عليه السلام التمس ولو خاتما من حديد وعن عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت على

نعلين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت نعم فأجازه رواه الترمذي وقال حسن صحيح وزوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين ولأنه بدل منفعتها فجاز ما تراضيا عليه من المال كالبيع (ولا أكثره) بالإجماع قاله ابن عبد البر لقوله تعالى ﴿ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ﴾ يؤيده ما روى أبو حفص بإسناده أن عمر أصدق أم كلثوم بنت علي أربعين ألفا وقال عمر خرجت أنا أريد أن أنهى عن كثرة الصداق فذكرت هذا ﴿ وآتيتم إحداهن قنطارا ﴾ قال أبو صالح القنطار مائة رطل وقال أبو سعيد بل ملء مسك ثوب هنا وقال مجاهد سبعون ألف مثقال (بل كل ما جاز أن يكون ثمنا) أو أجرة (جاز أن يكون صداق من قليل أو كثير) لأنه أحد العوضين أشبه عوض البيع لكن قال جماعة ولنصفه قيمة قال في المغني والشرح يشترط أن يكون له نصف يتمول عادة بحيث إذا طلقها قبل الدخول بقي لها من النصف مال حلال وفي الروضة له أوسط النقود ثم أدناها (وعين ودين ومعجل ومؤجل ومنفعة معلومة كرعاية غنمها مدة معلومة) لقوله تعالى ﴿ إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج ﴾ ولأنها منفعة معلومة يجوز العوض عنها في الإجارة فجازت صداقا كمنفعة العبد وظاهره أن منفعة الحر كالمملوك لقوله عليه السلام أنكحوا الأيامى وأدوا العلائق قيل ما العلائق يا رسول الله قال ما تراضى به الأهلون ولو قضيب من أراك

رواه الدار قطني وعنه لا يجوز أن يكون منافع الحر صداقا لأنها ليست بمال [ج ٧ - ص ١٣٢]

(وخياطة ثوب ورد عبدها من موضع معين) لأنها منفعة معلومة وعلم منه أن كل مالا يجوز أن يكون ثمنا في المبيع كالمحرم والمعدوم والمجهول ومالا منفعة فيه مالم يتم ملكه عليه كالمبيع من المكيل والموزون قبل قبضه وما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء وما لا يتمول عادة كقشر جوزة وحبة حنطة لا يجوز أن يكون صداقا لأنه نقل الملك فيه بعوض فلم يجز فيه ذلك كالبيع (وإن كانت مجهولة كرد عبدها أين كان وخدمتها فيما شاءت لم يصح) لأنه عوض في عقد معاوضة فلم يصح مجهولا كالثمن في البيع والأجرة في الإجارة فلو تزوجها على أن يحج بها لم تصح التسمية لأن الحملان مجهول لا يوقف له على حدود

(وإن تزوجها على منافعه مدة معلومة فعلى روايتين) إحداهما لا يصح لأنها ليست مالا فلا يصح أن يكون مهرا كرقبته ومنفعة البضع والثانية وهي الأصح أنه يصح بدليل قصة موسى وقياسا على منفعة العبد وقال أبو بكر إن كانت خدمة معلومة كبناء حائط صح وإن كانت مجهولة مثل أن يأتيها بعبدها الآبق أين كان ويخدمها في أي شيء أرادت فلا يصح ولا يضر جهل يسير وغرر يرجى زواله في الأصح فلو تزوجها على شرائه لها عبد زيد صح في المنصوص فإن تعذر شراؤه بقيمته فلها قيمته وكذا على دين سلم وآبق ومغصوب يحصله ومبيع اشتراه ولم يقبضه نص عليه (وكل موضع لا تصح التسمية) كالخمر والمعدوم والآبق والمجهول (وجب

مهر المثل) لأن فساد العوض يقتضي رد المعوض وقد تعذر رده بصحة النكاح فوجب قيمته وهو مهر [ج ٧ - ص ١٣٣]

المثل كمن اشترى بثمن فاسد فقبض المبيع وتلف في يده فإنه يجب عليه رد قيمته وعنه يفسد اختاره أبو بكر لأنه عقد معاوضة أشبه البيع وجوابه بأن فساد المسمى ليس بأكثر من عدمه وعدمه لا يفسد العقد كذا هذا ويجب مهر المثل لأنها لم ترض إلا ببدل ولم يسلم البدل وتعذر رد العوض فوجب رد بدله كما لو باعه سلعة بخمر فتلفت عند المشتري (وإن أصدقها تعليم أبواب من الفقه أو الحديث أو قصيدة من الشعر المباح) أو أدب أو صنعة أو كتابة وهو معين (صح) لأنه يصح أخذ الأجرة على تعليمه فجاز أن يكون صداقا كمنافع الدار حتى ولو كان لا يحفظها نص عليه ويتعلمها ثم يعلمها (فإن كان لا يحفظها لم يصح) على المذهب كذا قيل واختاره في الوجيز لأنه أصدقها شيئا لا يقدر عليه كما لو استأجر على الخياطة من لا يحسنها وكذا لو قال على أن أعلمك (ويحتمل أن يصح) ذكره في المجرد لأن هذا يكون في ذمته أشبه ما لو أصدقها مالا في ذمته لا يقدر عليه في الحال وعلى هذا (يتعلمها ثم يعلمها) أو يقيم لها من يعلمها لأنه بذلك يخرج عن عهدة ما وجب عليه فإن جاءت بغيرها فقالت علمهم القصيدة التي تريد تعليمي إياها أو أتاها بغيره يعلمها لم يلزم ذلك في الأشهر لأن المستحق عليه العمل في عين لم يلزمه إيقاعه في غيرها ولأن المعلمين يختلفون في التعليم (فإن تعلمتها من غيره لزمه أجرة تعلمها) لأنه لما تعذر الوفاء بالواجب وجب الرجوع إلى بدله وكذا إن تعذر عليه تعليمها كما لو أصدقها خياطة ثوب فتعذر فإن ادعى أنه علمها وأنكرته قبل

قولها لأن الأصل عدمه وفيه وجه لأن الظاهر معه وإن علمها ثم أنسيتها فلا [ج ٧ - ص ١٣٤]

شيء عليه وإن لقنها الجميع وكلما لقنها شيئا أنسيته لم يعتد بذلك في الأشهر (وإن طلقها قبل الدخول وقبل تعليمها فعليه نصف الأجرة) لأنها صارت أجنبية فلا يؤمن في تعليمها من الفتنة وبعد الدخول كلها (ويحتمل أن يعلمها نصفها) هذا رواية لأنه موضع حاجة أشبه سماع كلامها في المعاملات وعلى هذا يعلمها من وراء حجاب من غير خلوة بها لأن ذلك حرام وإن كان الطلاق بعد الدخول ففي تعليمها الكل الوجهان (وإن كان بعد تعليمها رجع عليها بنصف الأجر) لأن الطلاق قبل الدخول يوجب نصف الصداق والرجوع بنصف التعليم متعذر فوجب الرجوع إلى بدله وهو نصف وإن سقط مهرها رجع بالكل (وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن معين لم يصح) على المذهب واختاره أبو بكر وغيره لأن الفروج لا تستباح إلا بالمال لقوله تعالى ﴿ أن تبتغوا بأموالكم ﴾ ﴿ ومن لم يستطع منكم طولا ﴾ والطول المال لأن تعليم القرآن قربة ولا يصح أن يكون صداقا كالصوم (وعنه يصح) ذكر ابن رزين أنها الأظهر وجزم بها في عيون المسائل لحديث الموهوبة ولأن تعليم القرآن منفعة مباحة فجاز جعل ذلك صداقا كتعليم قصيدة من الشعر المباح وقيل إن جاز أخذ الأجرة عليه والأول أولى وحديث الموهوبة قيل معناه زوجتكها لأنك من أهل القرآن كما زوج طلحة على إسلامه ويحتمل أن يكون خاصا به يؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج غلاما على سورة من القرآن ثم قال لا يكون بعدك مهرا رواه سعيد والنجاد فعلى

هذا تعين السورة أو الآية لأنه إذا لم يعين يصير مجهولا مفضيا إلى المنازعة (ولا يحتاج إلى ذكر قراءة) من [ج ٧ - ص ١٣٥]

القراءات السبعة لأن الاختلاف في ذلك يسير (وقال أبو الخطاب يحتاج إلى ذلك) لأن الأغراض تختلف والقراءات تختلف فمنها ماهو صعب كقراءة حمزة وهشام ووقوفهما على المد أشبه تعيين الآيات فإن أطلق فعرف البلد فإن تعلمته من غيره لزمه الأجرة وإن علمها ثم سقط رجع بالأجرة ومع تنصفه بنصفها وإن طلقها ولم يعلمها لزمه أجرة مايلزمه لخوف الفتنة جزم به في الفصول وأنه يكره سماعه بلا حاجة وعنه يعلمها مع أمن الفتنة

ملحق بقية القرب كصوم وصلاة تخرج على الروايتين ذكره في الواضح

تنبيه إذا أصدق الكتابية تعليم شيء من القرآن لم يصح نص عليه ولها مهر المثل وفي المذهب يصح بقصدها الاهتداء به ولقوله تعالى ﴿ فأجره حتى يسمع كلام الله ﴾ وجوابه أن الجنب يمنع من قراءة القرآن مع إيمانه واعتقاده فالكافر أولى والسماع غير الحفظ وكذا إذا أصدقها تعليم شيء من التوراة أو الإنجيل ولزم مهر المثل لأنه منسوخ ومبدل

(وإن تزوج نساء بمهر واحد أو خالعهن بعوض واحد صح) لأن العوض في الجملة معلوم فلم تؤثر جهالة ما لكل واحدة كما لو اشترى أربعة أعبد من رجل بثمن واحد واختار ابن حمدان وهو احتمال في الترغيب يجب مهر المثل لأن مايجب لكل واحدة غير معلوم (ويقسم العوض بينهن على قدر مهورهن) أي مهور مثلهن (في أحد الوجهين) اختاره القاضي وابن

حامد وجزم به في الوجيز ونصره في الشرح وقدمه في الفروع لأن الصفقة إذا وقعت [ج ٧ - ص ١٣٦]

على شيئين مختلفي القيمة وجب تقسيط العوض بينهما بالقيمة كما لو باع شقصا وسيفا (وفي الآخر يقسم بينهن بالسوية) اختاره أبو بكر لأنه أضافه إليهن إضافة واحدة فكان بينهن بالسوية كما لو وهبه لهن أو أقر لهن وفي الرعاية وكما لو قال بينهن وقيل في الخلع يقسم على قدر مهورهن المسماة

فرع تزوج امرأتين إحداهما لا يصح العقد عليها بصداق واحد وقلنا يصح في الأخرى فلها حصتها من المسمى وقيل مهر المثل فإن جمع بين نكاح وبيع صح في الأشهر فعلى هذا يقسط العوض على قدر صداقهما وقيمة المبيع

فصل

(ويشترط أن يكون معلوما كالثمن) لأن الصداق عوض في عقد معاوضة فاشترط كونه معلوما كالعوض في البيع لأن غير المعلوم مجهول لا يصلح عوضا في البيع فلم تصح تسميته كالمحرم لكن لا يضر جهل يسير وغرر يرجى زواله في الأصح (وإن أصدقها دارا غير معينة أو دابة لم يصح) لأن الصداق يشترط فيه أن يكون معلوما وهو معدوم هنا (وإن أصدقها عبدا مطلقا لم يصح) للجهالة (وقال القاضي يصح) لقوله عليه السلام العلائق ما تراضى عليه الأهلون ولأنه موضع ثبت فيه العوض في

الذمة بدلا عما ليس المقصود فيه المال فثبت مطلقا كالدية ولأن جهالة التسمية هذه أقل من جهالة مهر المثل وحكى في [ج ٧ - ص ١٣٧]

المغني والشرح عن القاضي يصح مجهولا مالم تزد جهالته على جهالة مهر المثل كعبد وفرس من جنس معلوم فإن كان دابة أو حيوانا لم يصح لأنه لا سبيل إلى معرفة الوسط (ولها الوسط وهو السندي) بالعراق لأن الأعلى التركي والأسفل الزنجي والوسط السندي والمنصوري والأول أصح والخبر المراد به ما تراضى عليه الأهلون مما يصلح عوضا بدليل سائر ما لا يصلح والدية ثبتت بالشرع لا بالعقل وهي خارجة عن القياس في تقديرها ومن وجبت عليه فلا ينبغي أن تجعل أصلا ثم الحيوان الثابت فيها موصوف مقدر بقيمته فكيف يقاس عليه العبد المطلق وأما كون جهالة المطلق أقل من جهالة قدر مهر المثل فممنوع لأن العادة في القبائل يكون لنسائهم مهر لا يكاد يختلف إلا بالثيوبة والبكارة فيكون إذا معلوما

(وإن اصدقها عبدا من عبيده لم يصح ذكره أبو بكر) لأنه مجهول كما لو باع عبدا من عبيده أو دابة أو ثوبا (وروي عن أحمد أنه يصح) اختاره أبو الخطاب وجزم به في الوجيز كموصوف وكما لو عين ثم نسي وهذا مما لا نظير له يقاس عليه وتأويل أبو بكر نص أحمد على أنه تزوجها على عبد معين ثم أشكل عليه وفيه نظر فعلى هذا يعطى من عبيده وسطهم وهو رواية (و) الأشهر أن (لها أحدهم بالقرعة) نقله مهنا لأنه إذا صح أن يكون صداقا استحقت واحدا غير معين فشرعت القرعة مميزة كما لو أعتق أحد عبده وقيل يعطيها ما اختاره وقيل ما اختارت ذكرهما ابن عقيل (

وكذلك يخرج إذا أصدقها دابة من دوابه أو قميصا من قمصانه ونحوه) لأنه في معنى ما سبق (وإن أصدقها عبدا [ج ٧ - ص ١٣٨]

موصوفا صح) لأنه يجوز أن يكون عوضا في البيع والصفة تنزله منزلة المعين فجاز أن يكون صداقا (وإن جاءها بقيمته أو أصدقها عبدا وسطا وجاءها بقيمته أو خالعته على ذلك فجاءته بقيمته لم يلزمها قبوله) في الأشهر واختاره أبو الخطاب (وقال القاضي يلزمها ذلك) قياسا على الإبل في الدية وجوابه بأنها استحقت عليه عبدا بعقد معاوضة فلم يلزمها أخذ قيمته كالمسلم فيه وكما لو كان معينا والأثمان أصل في الدية كالإبل فيلزم الولي القبول لا على طريق القيمة ولأن الدية خارجة عن القياس ثم قياس العوض على سائر الأعواض أولى من قياسه على غير عقود المعاوضة ثم ينتقض بالعبد المعين

فرع إذا تزوجها على أن يعتق أباها صح نص عليه فإن طلبت به أكثر من قيمته أو تعذر عليه فلها قيمته (وإن أصدقها طلاق امرأة له أخرى لم يصح) قدمه في المحرر والفروع وهو ظاهر المذهب وقول أكثر الفقهاء لقوله تعالى ﴿ أن تبتغوا بأموالكم ﴾ وقوله عليه السلام لا تسأل المرأة طلاق أختها ولأن هذا لا يصح ثمنا في بيع ولا أجرا في إجارة فلم يصح صداقا كالمنافع المحرمة فعلى هذا لها مهل المثل أو نصفه قبل الدخول أو المتعة عند من يوجبها في التسمية الفاسدة (وعنه يصح) جزم به في الوجيز لأن لها فائدة ونفعا لما يحصل لها في الراحة بطلاقها من مقاسمتها والغيرة منها فصح جعله صداقا كخياطة ثوبها وعتق أمتها (فإن فات

طلاقها بموتها فلها مهرها) أي مهر الضرة (في قياس المذهب) لأنه سمى لها صداقا لم يصل إليها [ج ٧ - ص ١٣٩]

فكان لها قيمته كما لو أصدقها عبدا فخرج حرا وقيل يستحق مهر مثلها لأن الطلاق لا قيمة له ولا مثل له وكذا جعله إليها إلى سنة وهل يسقط حقها من المهر فيه وجهان فإن قلنا لا يسقط فهل ترجع إلى مهر مثلها أو إلى مهر الأخرى في وجهان

(وإن تزوجها على ألف إن كان أبوها حيا وألفين إن كان أبوها ميتا لم تصح) التسمية (نص عليه) في رواية مهنا لأن حال الأب غير معلومة فيكون مجهولا ولأنه في معنى بيعتين في بيعة وحينئذ لها صداق نسائها وعنه يصح لأن الألف معلومة وإنما جهل الثاني وهو ومعلق على شرط (وإن تزوجها على ألف إن لم يكن له زوجة وألفين إن كان له زوجة لم يصح في قياس التي قبلها) لأنها في معناها وكذا إن تزوجها على ألف إن لم يخرجها من دارها وعلى ألفين إن أخرجها (والمنصوص أنه يصح) هذه التسمية هنا وذكر القاضي فيهما روايتان إحداهما لا تصح اختاره أبو بكر لأن سبيله سبيل الشرطين فلم تصح كالبيع والثانية تصح لأن ألفا معلومة وإنما جهلت الثانية وهي معلقة على شرط فإن وجد الشرط كان زيادة في الصداق والزيادة فيه صحيحة والأول أولى يعني القول بالفساد فيهما ويجاب عنه بأنه تعليق على شرط لا يصح لوجهين أحدهما أن الزيادة لا يصح تعليقها على شرط فلو قال إن مات أبوك فقد زدتك في صداقك ألفا لم يصح ولم تلزم الزيادة عند موت الأب والثاني أن الشرط يتجدد في قوله إن كان لي زوجة أو إن كان أبوك حيا [ج ٧ - ص ١٤٠]

ولا الذي جعل الألف فيه معلوم الوجود لتكون الألف الثانية زيادة عليه ويمكن الفرق بين نص أحمد على بطلان التسمية ونصه على صحتها بأن المرأة ليس لها غرض يصح بدل العوض فيه وهو كون أبيها ميتا وخلوها عن ضرة من أكبر أغراضها وكذلك قرارها في دارها بين أهلها وفي وطئها فعلى هذا يمتنع قياس إحدى الصورتين على الأخرى وما وردت من المسائل الحق بما يشبهها ولا يكون في كل مسألة إلا رواية واحدة

(وإذا قال العبد لسيدته أعتقيني على أن أتزوجك فأعتقته على ذلك عتق) لأن سيدته أعتقته (ولم يلزمه شيء) لأن النكاح يحصل به الملك للزوج فلم يلزمه ذلك كما لو اشترطت عليه أن تملكه دارا وكذا إن قالت لعبدها أعتقتك على أن تتزوج بي لم يلزمه ذلك ويعتق ولا يلزمه قيمة نفسه لأنها اشترطت عليه شرطا هو حق له فلم يلزمه كما لو شرطت عليه أن تهبه دينارا ليقبلها ولأن النكاح من الرجل لا عوض له بخلاف نكاح المرأة (وإذا فرض الصداق مؤجلا ولم يذكر محل الأجل صح في ظاهر كلامه) لأن لذلك عرفا فوجب أن يصح ويحمل عليه وعلم منه أنه يجوز أن يكون مؤجلا وحالا وبعضه كذلك لأنه عقد معاوضة فجاز فيه ذلك كالثمن ومتى أطلق اقتضى الحلول كما لو أطلق ذكر الثمن وإن شرطه مؤجلا إلى وقت فهو إلى أجله (ومحله الفرقة عند أصحابنا) لأن المطلق يحمل على العرف والعرف ترك المطالبة بالصداق إلى حين الفرقة بموت أو طلاق فحمل عليه فيصير حينئذ معلوما (وعند أبي الخطاب لا تصح)

التسمية وهو رواية وحينئذ لها مهر المثل كثمن المبيع وعلى الأول

[ج ٧ - ص ١٤١]

لو جعل الأجل مدة مجهولة كقدوم زيد ونحوه لم يصح وقال ابن أبي موسى يحتمل إذا كان الأجل مجهولا أن يكون حالا فإن طلقها قبل الدخول كان لها نصفه في رواية وفي أخرى منعه كما لو تزوجها على محرم نكمر

فصل

(وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا صح النكاح) نص عليه وقاله عامة الفقهاء لأنه عقد لا يبطل بجهالة العوض فلا يفسد بتحريمه كالخلع ولأن فساد العوض لا يزيد على عدمه (وجب مهر المثل) في قولهم لأن فساد العوض يقتضي رد المعوض فوجب رد قيمته وهو مهر المثل كمن اشترى ثوبا بثمن فاسد فتلف المبيع في يده بالغا ما بلغ لأن ما تضمنه بالعقد الفاسد اعتبر قيمته بالغا ما بلغ كالمبيع لا يقال إنما وجب لحق الله لأنه لو كان كذلك لوجب أقل المهر (وعنه أنه يعجبه استقبال النكاح اختاره أبو بكر) وشيخه الخلال لأنه جعل عوضه محرما أشبه نكاح الشغار وخرج عليها في الواضح فساده بتعويض كمبيع وهو رواية في الإيضاح وعند ابن أبي موسى مثل مغصوب أو قيمته وفي الواضح إن باعه ربه قبله بثمن لزمه وعنه مثل خمر خلا (والمذهب صحته) وكلام أحمد محمول على الاستحباب فأما إذا فسد الصداق لجهالته أو عدمه أو العجز عن تسليمه فالنكاح ثابت بغير خلاف نعلمه فإن طلقها قبل الدخول فلها نصف مهر المثل وذكر القاضي في الجامع أنه لا فرق [ج ٧ - ص ١٤٢]

بين من لم يسم لها صداقا وبين من سمى لها محرما كالخمر أو مجهولا كالثوب وفي روايتان إحداهما لها المتعة لأنه يرتفع مهر المثل بها والثانية تجب لها نصف مهر المثل لأنه قد وجب فينتصف به كالمسمى

(وإن تزوجها على عبد فخرج حرا أو مغصوبا أو عصير فبان خمرا فلها قيمته) لأنها رضيت بما سمى لها وتسليمه ممتنع لكونه غير قابل لجعله صداقا فوجب الانتقال إلى قيمته يوم العقد لأنها بدل ولا تستحق مهر المثل لعدم رضاها به ولا بد أن يلحظ أن المغصوب لو كان مثليا لكان لها مثله لا قيمته كما لو استحق عليه مثلي بغير الصداق والعصير محمول على عصير عدم مثله إذ المذهب أنه يلزمه عصير مثله قدمه في الفروع وجزم به في الوجيز وقدم في الإيضاح مهر مثلها (وإن وجدت به عيبا فلها الخيار بين أخذ أرشه أو رده وأخذ قيمته) لأنه عوض في عقد معاوضة فثبتت الخيرة فيه بين أخذ الأرش أو البدل وأخذ القيمة كالمبيع المعيب وكذا عوض الخلع المنجز وعنه إن أمسكه فلا أرش وما عقد عليه في الذمة وجب بذله فقط

فرع إذا تزوجها على عبدين فخرج أحدهما حرا أو مغصوبا صح الصداق في ملكه ولها قيمة الآخر نص عليه وعنه قيمتها وإن بان نصفه مستحقا أو أصدقها ألف ذراع فبانت تسعمائة خيرت بين أخذه وقيمة الفائت وبين قيمة الكل [ج ٧ - ص ١٤٣]

فصل

(وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح) لأنه لو شرط الكل لنفسه لصح فكذا إذا شرط البعض بل هو من باب أولى يؤيده أن شعيبا زوج ابنته على رعاية غنمه وذلك اشتراط لنفسه لأن للوالد الأخذ من مال ولده لقوله عليه السلام أنت ومالك لأبيك ولقوله عليه السلام إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم رواه أبو داود والترمذي وحسنه فإذا شرط شيئا لنفسه من مهر ابنته كان ذلك أخذا من مالها (وكانا جميعا مهرها) وهذا في أب يصح تملكه أو شرطه له وحكى أبو عبد الله ابن تيمية رواية يبطل الشرط وتصح التسمية وقيل يبطلان ويجب مهر المثل وعلى الأول شرطه مالم يجحف بابنته فإن أجحف بها لم يصح الشرط وكان الجميع لها ذكره القاضي وابن عقيل والمؤلف وضعفه الشيخ تقي الدين لأنه لا يتصور الإجحاف لعدم ملكها له وظاهر كلام أحمد والقاضي في تعليقه وأبي الخطاب أنه لا يشترط (فإن طلقها قبل الدخول) بعد قبضهما (رجع عليها بألف) لأنه نصف الصداق (ولم يكن على الأب شيء مما أخذ) لأنه أخذ من مال ابنته ألفا فلا يجوز الرجوع عليه بشيء وقيل إلا في شرط جميعه له وهذا ظاهر فيما إذا قبضت الألفين فإن طلقها قبل قبضهما سقط عن الزوج ألف وبقي عليه ألف للزوجة يأخذ الأب منها ما شاء وقال القاضي يكون بينهما نصفين ونقله مهنا عن أحمد

لأنه شرط لنفسه النصف ولم يحصل من الصداق إلا النصف قال في المغني [ج ٧ - ص ١٤٤]

والشرح هذا على سبيل الاستحباب فلو شرط لنفسه الجميع ثم طلق قبل الدخول بعد تسليم الصداق رجع في نصف ما أعطى الأب لأنه الذي فرضه لها فيرجع في نصفه وقيل يرجع عليها بنصفه ولا شيء على الأب فيما أخذ لأنا قدرنا أن الجميع صار لها ولو ارتدت قبل الدخول فهل ترجع في الألف الذي قبضها الأب له أو عليها فيه وجهان (وإن فعل ذلك غير الأب) كالجد والأخ (فالكل لها دونه) وكان الشرط باطلا نص عليه لأن جميع ما اشترطه عوض في تزويجها فيكون صداقا لها كما لو جعله لها وليس للغير أن يأخذ شيئا بغير إذن فيقع الاشتراط لغوا وفي الترغيب في الأب رواية كذلك

(وللأب تزويج ابنته البكر والثيب) صغيرة كانت أو كبيرة (بدون صداق مثلها وإن كرهت) لأن عمر خطب الناس فقال لا تغالوا في صدق النساء فما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من نسائه ولا بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر فكان اتفاقا منهم على أن له أن يزوج بذلك وإن كان دون صداق مثلها ولأنه ليس المقصود من النكاح العوض وإنما المقصود السكن والازدواج ووضع المرأة في منصب عند من يكفلها ويصونها والظاهر من الأب مع تمام شفقته وحسن نظره أنه لا ينقصها من الصداق إلا لتحصيل المعاني المقصودة فلا يمنع منه وعقود المعاوضات المقصود منها العوض لا يقال كيف يملك الأب تزويج البنت الكبيرة بدون صداق

مثلها لأن الأشهر أنه يتصور بأن يأذن في أصل النكاح دون قدر المهر وقيل عليه تتميمه كبيعه بعض مالها بدون ثمنه لسلطان يظن به حفظ الباقي ذكره في الانتصار وقيل لبنت [ج ٧ - ص ١٤٥]

كبيرة لصحة تصرفها وفي الروضة إلا أن ترضى بما وقع عليه العقد قبل لزومه (وإن فعل غيره بإذنها) توكانت رشيدة (صح) لأن الحق لها فإذا رضيت بإسقاطه سقط كبيع سلعتها (ولم يكن لغيره الاعتراض) لأن الحق في ذلك تمحض لها دون غيرها بخلاف تزويجها بغير كفء (وإن فعله بغير إذنها وجب مهر المثل) لأنه قيمة بضعها وليس للولي نقصها منه والنكاح صحيح لا يؤثر فيه فساد التسمية وعدمها (ويحتمل ألا يلزم الزوج إلا المسمى) هذا رواية لأنه ما التزم غيره وكمن زوج بدون ما عينته له (والباقي على الولي) لأنه مفرط (كالوكيل في البيع) وفي الشرح وقدمه في الفروع تمام المهر على الزوج لأن التسمية فاسدة ويضمنه الولي لأنه مفرط كما لو باع مالها بدون ثمن مثله ويحتمل في تزويج الأب الثيب الكبيرة وجوب التمام

(وإن زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل صح) لأن تصرف الأب ملحوظ فيه المصلحة فكما يصح أن يزوج ابنته بدون مهر المثل للمصلحة فكذا يصح هنا تحصيله لها (ولزم ذمة الابن) لأن العقد له فكان بدله عليه كثمن المبيع ونقل ابن هانئ مع رضاه (فإن كان معسرا فهل يضمنه الأب يحتمل وجهين) وحكاهما في المغني روايتين أشهرهما لا يضمنه كثمن مبيعه وقدمه في الفروع قال القاضي وهذا أصح والثانية يضمنه الأب نص عليه وجزم به في الوجيز كما لو نطق بالضمان وللعرف وقيل

يضمن الزيادة وفي النوادر نقل صالح كالنفقة فلا شيء على ابن كذا قال ونقل المروذي [ج ٧ - ص ١٤٦]

النفقة على الصغير من ماله قلت فإن كانت صغيرة لا توطأ قال إن كان لها مال أنفق عليها منه والنفقة تجب مع المنع من قبله لا من قبلهم

فرع إذا طلق قبل الدخول سقط نصف الصداق فإن كان بعد دفع الأب الصداق رجع نصفه إلى الابن وليس للأب الرجوع فيه في الأشهر وكذا الحكم فيما لو قضى الصداق عن ابنه الكبير ثم طلق قبل الدخول فإن ارتدت قبل الدخول فالرجوع في جميعه كالرجوع في نصفه بالطلاق (وللأب قبض صداق ابنته الصغيرة) أي المحجور عليها (بغير إذنها) لأنه يلي مالها فكان له قبضه كثمن مبيعها والسفيهة والمجنونة كذلك (ولا يقبض صداق البنت الكبيرة إلا بإذنها) إذا كانت رشيدة لأنها المتصرفة في مالها فاعتبر إذنها في قبضه كثمن مبيعها (وفي البكر البالغة) العاقلة (روايتا ن) الأصح أنه لايقبضه إلا بإذنها إذ ا كانت رشيدة كالثيب والثانية بلى لأنه العادة بدليل أنه يملك إجبارها على النكاح أشبهت الصغير زاد في المحرر مالم يمنعه فعليها يبرأ الزوج بقبضه ويرجع على أبيها بما بقي لا بما أنفق

فصل

(وإن تزوج العبد سيده على صداق مسمى صح) لأن الحجر عليه لحق سيده فإذا أسقط حقه سقط بغير خلاف وله نكاح أمة ولو أمكنه حرة

ويملك نكاح واحدة إذا طلق نص عليه وفي تناول النكاح الفاسد

[ج ٧ - ص ١٤٧]

احتمالان (وهل يتعلق برقبته أو ذمة سيده على روايتين) الأصح أنه يتعلق بذمة سيده نقله الجماعة لأنه حق تعلق بالعبد برضى السيد فتعلق بذمته كالدين وكذا النفقة والكسوة والمسكن نص عليه والثانية تتعلق برقبته لأنه وجب بفعله أشبه جنايته وعنه يتعلق بهما وعنه بذمتيهما بذمة العبد أصالة وذمة سيده ضمانا وعنه بكسبه وفائدة الخلاف أن من ألزم السيد المهر والنفقة أوجبهما عليه وإن لم يكن للعبد كسب وليس للمرأة الفسخ لعدم كسب العبد وللسيد استخدامه ومنعه من الاكتساب ومن علقه بكسبه فللمرأة الفسخ إن لم يكن له كسب وليس لسيده منعه من التكسب وعلى الأول إن باعه سيده أو أعتقه لم يسقط المهر عن السيد نص عليه فأما النفقة فإنها تتجدد فيكون في الزمن المستقبل على المشتري وعلى العبد إذا أعتق

(وإن تزوج بغير إذنه لم يصح النكاح) نقله الجماعة وهو قول عثمان وابن عمر لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وإسناده جيد لكن فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه كلام ورواه الخلال من حديث ابن عمر مرفوعا وأنكره أحمد ورواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر موقوفا ولأنه نكاح فقد شرطه فكان باطلا كما لو تزوج بغير شهود ونقل حنبل هو كفضولي وقاله الأصحاب ولأنه عقد يقف على الفسخ فوقف على الإجازة كالوصية (فإن دخل بها) ووطئها (وجب في رقبته

مهر المثل) في قول أكثرهم كسائر الأنكحة الفاسدة فعلى هذا يباع فيه إلا أن يفديه السيد وقيل [ج ٧ - ص ١٤٨]

يتعلق بذمة العبد والأول أظهر لأن الوطء أجري مجرى الجناية الموجبة للضمان بغير إذن الولي (وعنه يجب خمسا المسمى) نقله الجماعة (اختارها الخرقي) والقاضي وأصحابه لما روى خلاس بن عمرو أن غلاما لأبي موسى تزوج بغير إذنه فكتب في ذلك إلى عثمان فكتب إليه أن فرق بينهما وخذ لها الخمسين من صداقها وكان صداقها خمسة أبعرة رواه أحمد ولأن المهر أحد موجبي الوطء فجاز أن ينقص فيه العبد عن الحر كالحد قال الشيخ تقي الدين المهر يجب في نكاح العبد بخمسة أشياء عقد النكاح وعقد الصداق واذن السيد في النكاح واذنه في الصداق والدخول فبطل ثلاثة من قبل السيد فبقي من قبله اثنان وهو التسمية والدخول وعنه إن علمت أنه عبد فلها خمسا المهر وإلا فلها المهر في رقبة العبد وقيل يجب خمسا مهر المثل وعنه المسمى قدمه في الرعاية ونقل المروذي يعطي شيئا قلت تذهب إلى حديث عثمان قال أذهب أن يعطي شيئا قال أبو بكر هو القياس

تنبيه السيد مخير بين أن يفديه بأقل الأمرين من قيمته أو مهر واجب كأرش جنايته ونقل حنبل لا مهر لأنه بمنزلة العاهر ويروى عن ابن عمر وهو رواية في المحرر إن علما التحريم وظاهر كلام جماعة أو علمته هي (وإن زوج السيد عبده أمته لم يجب مهر ذكره أبو بكر) والقاضي لأنه لا يجب للسيد على عبده مال (وقيل يجب ويسقط) قدمه في الكافي و المستوعب و الرعاية وهو رواية في التبصرة لأن النكاح لا يخلو من مهر ثم

بسقط لتعذر إتيانه وقال أبو الخطاب يجب المسمى أو مهر المثل إن لم يكن مسمى [ج ٧ - ص ١٤٩]

والمذهب أنه يجب مهر المثل ويتبع به بعد عتقه نص عليه في رواية سندي وجزم به في الوجيز (وإن زوج عبده حرة ثم باعها العبد بثمن في الذمة تحول صداقها أو نصفه إن كان قبل الدخول إلى ثمنه) لأن ذلك متعلق برقبة العبد فوجب أن ينتقل إلى بدله وهو الثمن وحاصله أنه إذا باعه لها بثمن في ذمتها فعلى حكم مقاصصة الدينين وإن تعلق برقبته تحول مهرها إلى ثمنه كشراء غريم عبدا مدينا وإن تعلق بذمتيهما سقط المهر لملكها العبد والسيد تبع له لأنه ضامنه ويبقى الثمن للسيد عليها وقيل لا يسقط بناء على من ثبت له دين على عبد ثم ملكه ففي سقوطه وجهان والنصف قبل الدخول كالجميع إن لم يسقط في رواية قال في الشرح المذهب أنه لا يسقط بعد الدخول بحال (وإن باعها إياه بالصداق صح قبل الدخول وبعده) نص عليه لأن الصداق يصلح أن يكون ثمنا لغير العبد فكذا له وفي رجوعه قبل الدخول بنصفه أو جميعه الروايتان وبطل النكاح إذن (ويحتمل ألا يصح قبل الدخول) هذا رواية لأنه يلزم من صحته فسخ النكاح ومن سقوط المهر بطلان البيع لأنه عوضه ولا يصح بغير عوض واختار ولد صاحب الترغيب إن تعلق برقبته أو ذمته وسقط ما في الذمة بملك طارئ برئت ذمة السيد فيلزم الدور فيكون في الصحة بعد الدخول الروايتان قبله وإن جعله مهرها بطل العقد كمن زوج ابنه على رقبة من يعتق على الابن لو ملكه إذ نقدره له قبلها بخلاف اصداق الخمر لأنه لو ثبت لم ينفسخ ذكره جماعة [ج ٧ - ص ١٥٠]

فصل

(وتملك الصداق المسمى بالعقد) في قول عامتهم لقوله عليه السلام إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك فيدل على أن الصداق كله للمرأة ولا يبقى للرجل فيه شيء ولأنه عقد يملك به العوض فملك به العوض كاملا كالبيع وعنه تملك نصفه قال ابن عبد البر هذا موضع اختلف فيه السلف وسقوط نصفه بالطلاق لايمنع وجوب جميعه بالعقد ألا ترى أنها لو ارتدت سقط جميعه وإن كانت ملكت نصفه (فإن كان معينا كالعبد والدار فلها التصرف فيه) لأنه ملكها فكان لها ذلك كسائر أملاكها (ونماؤه لها وزكاته ونقصه وضمانه عليها) سواء قبضته أو لم تقبضه متصلا كان النماء أو منفصلا وعليها زكاته إذا تم عليه الحول نص عليه لأن ذلك كله من توابع الملك وإن تلف فهو من ضمانها ولو زكت ثم طلقت قبل الدخول كان ضمان الزكاة عليها لأنها قد ملكته أشبه ما لو ملكته بالبيع (إلا أن يمنعها قبضه فيكون ضمانه عليه) لأنه غاصب أو بمنزلته وإن زاد فالزيادة لها وإن نقص فالنقص عليه وهو بالخيار بين أخذ نصفه ناقصا وبين أخذ نصف قيمته أكثر ما كانت من يوم العقد إلى يوم القبض لأنه إذا زاد بعد العقد فالزيادة لها وإن نقص فالنقص عليه إلا أن تكون الزيادة لتغير الأسعار (وعنه فيمن تزوج على عبد ففقئت عينه إن كان قد قبضته فهو لها وإلا فهو على الزوج) هذه الرواية نقلها مهنا فعلى هذا (

لا يدخل في ضمانها إلا بقبضه) لأنه غير مقبوض فلم يضمنه قياسا على البيع في رواية وظاهر هذا [ج ٧ - ص ١٥١]

أنه جعله قبل قبضه من ضمان الزوج بكل حال سواء كان معينا أو لم يكن وإن تلف قبل قبضه ضمنه الزوج بمثله إن كان له مثل وإلا قيمته يوم العقد ذكره القاضي وقال أبو الخطاب يضمنه بقيمته يوم التلف (وإن كان غير معين كقفيز من صبرة لم يدخل في ضمانها ولم يملك التصرف فيه إلا بقبضه كالمبيع) نقول حكم الصداق حكم المبيع في أن ما كان مكيلا أو موزونا لا يجوز لها التصرف فيه إلا بقبضه وما عداه لا يحتاج إلى قبض وقال القاضي وأصحابه ما كان متعينا فله التصرف فيه وما لم يكن متعينا كقفيز من صبرة ورطل زيت من دن لا يملك التصرف فيه حتى يقبضه كالمبيع وعنه لا يملك التصرف في شيء منه قبل قبضه وقيل ما لا ينقص العقد بهلاكه كالمهر وعوض الخلع يجوز التصرف فيه قبل قبضه لأنه بدل لا ينفسخ للسبب الذي ملك بهلاكه كالوصية وقد نص أحمد على هبة المرأة زوجها صداقها قبل قبضها وهو نوع تصرف وقياس المذهب أن كلما جاز التصرف فيه فهو من ضمانها وما لا يتصرف فيه فهو من ضمان الزوج إلا أن يمنعها قبضه فيكون ضمانه عليه كما نص على العبد إذا فقئت عينه وحيث قبل فضمانه عليه قبل القبض إذا تلف لم يبطل الصداق بتلفه ويضمنه بمثله أو قيمته

(وإن قبضت صداقها ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه إن كان باقيا) بحاله لم يتغير ولم يتعلق به حق غيره بغير خلاف لقوله تعالى ﴿ وإن

طلقتموهن ﴾ الآية (ويدخل في ملكه حكما كالميراث) نص عليه لأن قوله [ج ٧ - ص ١٥٢]

تعالى ﴿ فنصف ما فرضتم ﴾ يدل عليه لأن التقدير فنصف ما فرضتم لكم أو لهن وذلك يقتضي كينونة النصف له أو لها بمجرد الطلاق وأن الطلاق سبب تملك به بغير عوض فلم يفتقر إلى اختياره كالإرث فعلى هذا ما يحدث من النماء يكون بينهما (ويحتمل ألا يدخل) في ملكه (حتى يطالب به ويختار) لأن الإنسان لا يملك شيئا بغير اختياره إلا بالميراث وكالشفيع (فما ينمي قبل ذلك فهو لها) لأنه نماء ملكها لأن التقدير أنه لايملك إلا باختياره فهو قبل الاختيار على ملك الزوجة وفي الترغيب أصلها اختلاف الرواية فيمن بيده عقدة النكاح وعلى المنصوص لو طلقها على أن المهر لها لم يصح الشرط وعلى الثاني وجهان (فإن) كان الصداق (زاد زيادة متصلة) كالولد والثمرة (رجع في نصف الأصل) لأن الطلاق قبل الدخول يقتضي الرجوع في نصف الصداق وقد أمكن الرجوع فيه من غير ضرر على أحد فوجب أن يثبت حكمه (والزيادة لها) لأنه نماء ملكها وعنه يرجع بنصفهما (وإن كانت متصلة) كالسمن وتعلم صناعة وبهيمة حملت (فهي مخيرة بين دفع نصفه زائدا) ويلزمه القبول (وبين دفع نصف القيمة وقت العقد) لأنها إن اختارت دفع نصف الأصل زائدا كان لها ذلك إسقاطا لحقها من الزيادة وإن اختارت دفع نصف قيمته كان لها ذلك لأنه لا يلزمها دفع نصف الأصل زائدا لاشتماله على الزيادة التي لا يمكن فصلها عنه وحينئذ تعينت القيمة كالإتلاف ويتخرج أن يجب دفعه بزيادته كالمنفصلة وأولى وفي التبصرة لها

نماؤه بتعيينه وعنه بقبضه فعلى المذهب له قيمة نصفه يوم الفرقة على أدنى صفة من وقت العقد إلى وقت قبضه وفي الكافي أو التمكين منه فإن قلنا

[ج ٧ - ص ١٥٣]

يضمن المهر بالعقد اعتبرت صفة وقته وفي الترغيب المهر المعين قبل قبضه هل هو بيده أمانة أو مضمون فمؤونة دفن العبد عليه فيه روايتان

فرع إذا كانت محجورا عليها لم يكن له الرجوع إلا في نصف القيمة (وإن كان ناقصا) بغير جناية عليه (خير الزوج بين أخذه) أي أخذ نصفه (ناقصا) لأنه إذا اختار ذلك فقد رضي بإسقاط حقه (وبين نصف القيمة) لأن قبوله ناقصا ضرر عليه وهو منفي شرعا فعلى الأول هل له أرش النقص كما هو مختار القاضي في تعليقه كالمبيع المعيب أو لا أرش كواجد متاعه عند المفلس وهو اختيار الأكثرين فيه قولان وتعتبر القيمة (وقت العقد) ذكره الخرقي والمؤلف وابن حمدان وحرر المجد ذلك فجعله في المتميز إذا قلنا على المذهب يضمنه بالعقد وعلى هذا يحمل قولهم إذ الزيادة في غير المتميز صورة نادرة وفي الشرح إذا كان ناقصا متميزا كعبدين تلف أحدهما رجع بنصف الباقي ونصف قيمة التالف وإن لم يكن متميزا كشاب صار شيخا فنصف قيمته أو نسي صناعة فإن شاء رجع بنصف قيمته وقت ما أصدقها لأن ضمان النقص عليها فلا يلزمه أخذ نصفه لأنه دون حقه وإن شاء رجع بنصفه ناقصا فتجبر المرأة على ذلك

فرع إذا زاد من وجه ونقص من وجه كعبد صغير كبر ومصوغ كسرته وأعادته صناعة أخرى فلكل منهما الخيار وكذا حمل أمة وفي البهيمة زيادة

مالم يفسد وزرع وغرس بعض الأرض (وإن كان تالفا أو مستحقا بدين أو شفعة فله نصف قيمته) إذا لم يكن مثليا لأنه تعذر الرجوع في عينه

[ج ٧ - ص ١٥٤]

فوجب الرجوع في نصف القيمة كالاتلاف (وقت العقد) لأن الزيادة بعد ذلك تكون ملكا للزوجة لكونها نماء ملكها فلا يجوز تقويمها بعد العقد لكونه تقويما لملك الغير (إلا أن يكون مثليا فيرجع بنصف مثله) لأن المثلي يضمن في الإتلاف بالمثل لأنه أقرب مشابهة ومماثلة لحقه (وقال القاضي له القيمة أقل ما كانت من يوم العقد إلى يوم القبض) لأنه لو نقص في يده كان ضمانه عليه قال المؤلف هذا مبني على أن الصداق لا يدخل في ضمان المرأة إلا بقبضه وإن كان معينا في رواية فعلى هذا إن كانت القيمة وقت العقد أقل لم يلزمها إلا نصفها لأن الزيادة بعد العقد لها لأنه نماء ملكها أشبهت الزيادة بعد القبض وإن كانت القيمة وقت القبض أقل لم يلزمها أكثر من نصفها لأن ما نقص من القيمة من ضمانه لم يلزمه غرامة لها فكيف تجب له عليها قال صاحب النهاية فيها والأول أصح لأن المعين لا يفتقر الملك فيه إلى قبض ولا يضمن باليد

مسائل الأولى إذا خرج عن ملكها ثم عاد إليها ثم طلقها وهو في يدها كان له الرجوع في نصفه لعدم المانع منه ولا يلزم إذ لو وهب لولده شيئا فخرج عن ملكه ثم عاد حيث لا يملك الرجوع وإن أسلم فلان حق الولد سقط بخروجه عن ملكه بدليل أنه لا يطالبه ببدله بخلاف الزوج

الثانية إذا تصرف تصرفا لا ينقل الملك كوصية لم يمنع الرجوع كعارية وكذا إذا دبرته في ظاهر المذهب ولا يجبر على الرجوع في نصفه وإن قلنا

لا يباع لم يجز الرجوع فإن كان التصرف لازما لا ينقل الملك كنكاح وإجارة [ج ٧ - ص ١٥٥]

خير بين الرجوع في نصفه ناقصا وبين نصف قيمته فإن رجع في نصف المستأجر صبر حتى تنفسخ الإجارة

الثالثة إذا أصدقها نخلا فاطلعت أبر أو لم يؤبر ثم طلق قبل الدخول فزيادة متصلة وفي الترغيب وجهان فيما أبر

الرابعة إذا أصدقها أرضا فزرعتها فحكمها حكم الشجر إذا أثمر سواء قاله القاضي وقال غيره يفارق الزرع الثمرة في أنها إذا بذلت نصف الأرض مع نصف الزرع لم يلزمه قبوله فلو أصدقها ثوبا فصبغه أو أرضا فبنتها فبذل قيمة زيادته لتملكه فله ذلك خلافا

الخامسة أصدقها صيدا ثم طلق وهو محرم فإن لم يملكه بإرث فنصف قيمته وإلا فهل يقدم حق الله فيرسله ويغرم لها قيمة النصف أم حق الآدمي فيمسكه ويبقى ملك المحرم ضرورة أم هما سواء فيخيران فإن أرسله برضاها غرم لها وإلا بقي مشتركا قال في الترغيب مبني على حكم الصيد المملوك بين محل ومحرم وفيه أوجه

(وإن نقص الصداق في يدها بعد الطلاق فهل تضمن نقصه يحتمل وجهين) أما إذ منعته منه بعد طلبه وتلف فعليها الضمان لأنها غاصبة وإن تلف قبل مطالبته فوجهان أصلهما الزوج إذا تلف الصداق المعين في يده قبل مطالبتها وقياس المذهب أنه لا ضمان عليها لأنه دخل في يدها بغير فعلها ولا عدوان من جهتها فلم تضمنه كالوديعة وإن اختلفا في المطالبة

قبل قولها لأنها منكرة والثاني عليها الضمان أشبه المبيع إذا ارتفع العقد بالفسخ وقيل لا يضمن [ج ٧ - ص ١٥٦]

المتميز كما لو تلف بآفة سماوية (وإن قال الزوج نقص قبل الطلاق وقالت بعده فالقول قولها) لأنه يدعي عليها ما يوجب الضمان والقول قول المنكر (مع يمينها) لأن الأصل براءة ذمتها وفهم منه أن النقص في الصداق في يد الزوجة بعد الطلاق أنها لا تضمنه لأنه إذا كان مضمونا بعده كما يضمن قبله فلا فائدة في الاختلاف

تنبيه إذا فات النصف مشاعا فله النصف الباقي وكذا معينا من النصف وفي المغني له نصف البقية ونصف قيمة التالف أو مثله وإن قبضت المسمى في الذمة فكالمعين إلا أنه لا يرجع بنمائه مطلقا ويعتبر في تقويمه صفته يوم قبضه وفي وجوب رده بعينه وجهان

(والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح) في ظاهر المذهب لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولي العقدة الزوج رواه الدارقطني عن ابن لهيعة ورواه أيضا بإسناد جيد عن علي ورواه بإسناد حسن عن جبير بن مطعم عن ابن عباس ولأن الذي بيده عقدة النكاح بعد العقد هو الزوج لقوله تعالى ﴿ إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ﴾ ﴿ وأن تعفوا أقرب للتقوى ﴾ والعفو الذي هو أقرب للتقوى هو عفو الزوج عن حقه أما عفو الولي عن مال المرأة فليس هو أقرب للتقوى ولأن المهر للزوجة فلا يملك الولي إسقاطه كسائر

الأولياء ولا يمتنع العدول عن خطاب الحاضر إلى الغائب لقوله تعالى ﴿ حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم ﴾ [ج ٧ - ص ١٥٧]

وعفوه أن يسوق إليها المهر كاملا ولأن الصغير لو رجع إليه صداق زوجته أو نصفه لانفساخ النكاح برضاع أو نحوه لم يكن لوليه العفو عنه رواية واحدة فكذا ولي الصغير (فإذا طلق قبل الدخول) فإنه يتنصف المهر بينهما (فأيهما عفا لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز الأمر في ماله برئ منه صاحبه) أي سواء كان العافي الزوج أو الزوجة إذا كان جائز التصرف في ماله فإن كان صغيرا أو سفيها لم يصح لأنه ليس من أهل التصرف في ماله ولا يصح عفو الولي عن الصداق أبا كان أو غيره صغيرة كانت أو كبيرة نص عليه (وعنه أنه الأب) نقله ابن منصور وقدمه ابن رزين واختاره الشيخ تقي الدين قال ومثله سيد الأمة رواه الدارقطني بإسناد حسن عن ابن عباس ولأن عقدة النكاح بعد الطلاق إلى الولي لأن الله تعالى خاطب الأزواج بخطاب المواجهة ثم خاطب الأولياء فقال ﴿ أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ﴾ وهو خطاب غيبة ومعناه أنه يعفو للمطلقات عن أزواجهن فلا يطالبنهم بنصف المهر وشرطه أن يكون أبا لأنه هو الذي يلي مالها لكن قال أبو حفص ما أرى ما نقله ابن منصور إلا قولا قديما فظاهره أن المسألة رواية واحدة وأن أبا عبد الله رجع عن قوله بجواز عفو الأب وهو الصحيح لأن مذهبه أنه لا يجوز للأب إسقاط ديون ولده الصغير ولا إعتاق عبيده ولا تصرفه إلا بما فيه مصلحتهم (فله) أي للأب (أن يعفو عن نصف مهر ابنته الصغيرة) والمجنونة لأنه يكون وليا على مالها فإن الكبيرة العاقلة تلي مال نفسها

وفي المغني والكافي بشرط البكارة واختار جمع وقدمه في المحرر وجزم به

[ج ٧ - ص ١٥٨]

في الموجز وبكر بالغة وفي الترغيب أصله هل ينفك الحجر بالبلوغ (إذا طلقت) لأنه قبل الطلاق معترضة لاتلاف البضع (قبل الدخول) لأن ما بعده قد أتلف البضع فلا يعفو عن بدل متلف وسواء فيه عفوه أو عفوها ولم يقيد في عيون المسائل بصغر وكبر وبكارة وثيوبة وذكر ابن عقيل رواية الولي في حق الصغيرة وذكر ابن حمدان قولا للأب العفو بعد الدخول مالم تلد أو تبقى في بيتها سنة بناء على بقاء الحجر عليها وقدم اعتبار كونه دينا فلا يعفو عن عين فيصح بلفظ الهبة

فصل

(إذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها أو وهبته له ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه) على المذهب لأن الطلاق قبل الدخول يقتضي الرجوع في نصف الصداق وقد وجد ولا أثر لكونها أبرأته أو وهبته له لأن ذلك حصل مستأنفا فلم يمنع استحقاق النصف كما لو وهبته لأجنبي فوهبه الأجنبي للزوج (وعنه لا يرجع بشيء) لأن نصف الصداق يعجل له بالهبة لأن عقد الهبة لا يقتضي ضمانا وعنه يرجع مع الهبة دون الإبراء صححه في المحرر لأن الإبراء إسقاط لا تمليك وفي الترغيب أصل الخلاف في الإبراء أيهما يلزمه زكاته إذا مضى أحوال وهو دين فيه روايتان وفي المغني هل هو إسقاط أو تمليك وإن وهبته بعضه ثم تنصف رجع بنصف غير الموهوب ونصف الموهوب استقر ملكها له فلا ترجع به ونصفه الذي لم يستقر ترجع به على الأولى والثانية [ج ٧ - ص ١٥٩]

فرع إذا خالعته بنصف صداقها قبل الدخول صح وكان الصداق كله له ويحتمل أن يصير له ثلاثة أرباعه فإن خالعته بمثل جميع الصداق في ذمتها صح ورجع عليها بنصفه فإن خالعته بصداقها كله فكذا في وجه وفي الآخر لا يرجع عليها بشيء

مسألة باع عبدا ثم أبرأه البائع من الثمن أو قبضه منه ثم وهبه إياه ثم وجد المشتري بالعبد عيبا فهل له رد المبيع والمطالبة بالثمن أو أخذ أرش العيب مع إمساكه على روايتين بناء على الخلاف في الصداق وإن كانت بحالها فوهب المشتري العبد البائع ثم أفلس المشتري وهو في ذمته فللبائع أن يضرب بالثمن مع الغرماء وجها واحدا لأن الثمن ما عاد إلى البائع منه شيء

فرع تبرع أجنبي بأداء المهر ثم سقط أو تنصف فالراجع للزوج وقيل للأجنبي ومثله أداء ثمن ثم يفسخ بعيب ورجوع مكاتب أبرئ من كتابته بالإيتاء واختار المؤلف فيه لا رجوع

(وإن ارتدت قبل الدخول فهل يرجع عليها بجميعه على روايتين) مأخذهما ما سبق والمذهب أنه يرجع بجميعه

(وكل فرقة جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه) سواء سألته أو سأله أجنبي (وإسلامه وردته أو من أجنبي كالرضاع ونحوه قبل الدخول يتنصف بها المهر بينهما) لقوله تعالى ﴿ وإن طلقتموهن من قبل أن

تمسوهن ﴾ ثبت في الطلاق والباقي قياسا عليه لأنه في معناه وعنه إذا أسلم فلا مهر عليه [ج ٧ - ص ١٦٠]

والأول المذهب وإنما تنصف المهر بالخلع لأن المغلب فيه جانب الزوج بدليل أنه يصح منها ومن غيرها وهو خلعه مع الأجنبي فصار كالمنفرد به وذكر ابن أبي موسى أن المختلعة لا متعة لها وأن المخالعة في المرض لا ترث وعلل بأن الفرقة حصلت من جهتها وفي الرعاية وإن تخالعا وقلنا هو فسخ وقيل أو طلاق وجهان وإن جعل لها الخيار فاختارت نفسها أو وكلها في الطلاق فطلقت نفسها فهو كطلاقه لأنها بائنة عنه وفي رواية وإن علقه على فعل منها لم يسقط مهرها لأن السبب وجد منه وإن طلق الحاكم على الزوج في الإيلاء فهو كطلاقه وأما فرقة الأجنبي كالرضاع ونحوه فإنه يجب نصف المهر لأنه لا جناية منها يسقط مهرها ويرجع الزوج بما لزمه على الفاعل لأنه قرره عليه

(وكل فرقة جاءت من قبلها كإسلامها وردتها ورضاعها من ينفسخ به نكاحها وفسخها لعيبه أو إعساره وفسخه لعيبها يسقط به مهرها ومتعتها) لأنها أتلفت العوض قبل تسليمه فسقط البدل كله كالبائع يتلف المبيع قبل تسليمه وكذا إن فسخت لعتقها تحت عبد أو لفوات شرط وعنه يتنصف بفسخها لشرط فيتوجه في فسخها لعيبه الخلاف وفي الرعاية إن فسخت قبل الدخول فروايتان وإن كان لها مهر مسمى فهل يتنصف أو يسقط على روايتين وذكر أبو بكر أنه إذا تزوجها بشرط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا يخرجها من دارها فلم يف لها ففسخت ولم يكن سمى لها مهرا فلها المتعة (وفرقة اللعان تخرج على روايتين) لأن النظر إلى كون

الفسخ عقيب لعانها فهو كفسخها لعيبه أو إلى أن سبب اللعان القذف من الزوج فهو كفسخه لطلاقه وقال القاضي يخرج [ج ٧ - ص ١٦١]

على روايتين أصلهما إذا لاعنها في مرض موته هل ترثه على روايتين إحداهما هو كطلاقه لأن سبب اللعان قذفه الصادر منه أشبه الخلع والثانية يسقط به مهرها لأن الفسخ عقيب لعانها هو كفسخها لعيبه (وفي فرقة بيع الزوجة من الزوج وشرائها له وجهان) أحدهما يتنصف المهر بشرائها زوجها لأن البيع الموجب للفسخ تم بالسيد وبالمرأة أشبه الخلع والثاني يسقط به المهر لأن الفسخ وجد عقيب قبولها أشبه فسخها لعيبه وكذا إذا اشترى الزوج امرأته وفي المغني في شرائها له روايتان وفي شرائه لها وجهان مخرجان على الروايتين وقيل هما إن اشتراها من مستحق مهرها وإن اشترته فروايتان (وفرقة الموت يستقر بها المهر كله كالدخول) حرة كانت أو أمة لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق رواه معقل بن سنان ولأنه عقد ينتهي بموت أحدهما فاستقر به العوض كانتهاء الإجارة (ولو قتلت نفسها) أو قتلها غيرها (لاستقر مهرها كاملا) كالموت حتف أنفها لأنها فرقة حصلت بانقضاء الأجل وانتهاء النكاح فهو كموتها حتف أنفها وفي رواية وفي الوجيز يتقرر إن قتل نفسه أو قتله غيرهما فظاهره لا يتقرر إن قتل أحدهما الآخر قال في الفروع وهو متجه إن قتلته

فصل

(وإذا اختلف الزوجان) أو ورثتهما (في قدر الصداق) ولا نية على مبلغه (فالقول قول الزوج) قدمه في المحرر والفروع لأنه منكر للزيادة (

يمينه) لأنه مدعى عليه فيدخل في قوله عليه السلام ولكن اليمين على المدعى عليه (وعنه القول قول من يدعي مهر المثل منهما) نصره القاضي وأصحابه وجزم به في الوجيز لأن الظاهر صدق من يدعيه فيقدم قوله أشبه المنكر في سائر الدعاوي فلو ادعت المرأة مهر المثل أو أقل منه قبل قولها وإن ادعى الزوج مهر المثل أو أكثر منه قبل قوله لأن الظاهر صدق المدعي ولا فرق بين أن يكون هذا الاختلاف قبل الدخول أو بعده قبل الطلاق أو بعده وعنه ثالثة يتحالفان ذكرها في المبهج فإن حلف أحدهما ونكل الآخر ثبت ما قاله الآخر وإن حلفا وجب مهر المثل والأصح لا تحالف لأنه عقد لا ينفسخ بالتحالف فلم يشرع فيه كالعفو عن دم العمد (فإن ادعى أقل منه وادعت أكثر منه رد إليه) أي إلى مهر المثل لأن ذلك فائدة قبول قول من يدعيه (بلا يمين عند القاضي) لأنها دعوى في نكاح أشبهت الدعوى في أصل النكاح (في الأحوال كلها) سواء وافق قول الزوج أو قولها (وعند أبي الخطاب يجب اليمين) لأنه اختلاف فيما يجوز بدله فوجب أن تجب فيه اليمين كسائر الدعاوي في الأموال وفي المغني إذا ادعى أقل من مهر المثل وادعت أكثر منه رد إلى مهر المثل ولم يذكر أصحابنا يمينا والأولى أن يتحالفا فإن ما يقوله كل واحد منهما محتمل للصحة فلا يعدل عنه إلا بيمين كالمنكر في سائر الدعاوي ولأنهما متساويان في عدم الظهور فشرع التحالف كاختلاف المتبايعين

وفيه نظر لأنه نفى أن يكون الأصحاب ذكروا يمينا والحال أنه ذكره عن القاضي نفيا وعن أبي الخطاب إثباتا وقوله فشرع [ج ٧ - ص ١٦٣]

التحالف يقتضي أنه ليس بواجب وليس كذلك فيقول هو ما أصدقتها كذا وإنما أصدقتها كذا أو تقول هي ما أصدقني كذا وإنما أصدقني كذا كاختلاف المتبايعين (وإن قال تزوجتك على هذا العبد قالت بل على هذه الأمة) خرج على الروايتين أي إذا اختلفا في عينه أو صفته فإن كان قيمة العبد مهر المثل أو أكثر منه وقيمة الأمة دون ذلك حلف الزوج ولها قيمة العبد وإن كان قيمة الأمة مهر المثل أو أقل وقيمة العبد دون ذلك فالقول قولها مع يمينها وهل تجب الأمة أو قيمتها فيه وجهان إحداهما تجب عين الأمة لأنه يقبل قولها في القدر فكذا في العين والثاني تجب لها قيمتها لأن قولها إنما وافق الظاهر في القدر لا في العين وفي فتاوى المؤلف إن عينت أمها وعين أباها فينبغي أن يعتق أبوها لأنه مقر بملكها له وإعتاقه عليها ثم يتحالفان ولها الأقل من قيمة أمها أو مهر مثلها وفي (الواضح) يتحالفان كبيع ولها الأقل مما ادعته أو مهر مثلها وفي الترغيب يقبل قول مدع جنس مهر المثل في أشهر الروايتين والثانية قيمة ما يدعيه هو

فرع اختلف الزوج وأبو الصغيرة أو المجنونة قام الأب مقامها في اليمين لأنه يحلف على فعل نفسه كالوكيل ذكره في الكافي والشرح وفي الواضح توقف اليمين إلى حين بلوغها ويجب على الزوج دفع ما أقر به وعلى الأول إن لم يحلف حتى بلغت الصغيرة وعقلت المجنونة فاليمين عليها لأنه إنما حلف لتعذر اليمين منهما فإذا أمكن لزمهما كالوصي إذا بلغ الطفل فأما أبو البكر

البالغة العاقلة فلا تسمع مخالفة الأب لأن قولها مقبول والحق لها وأما سائر الأولياء فليس لهن أن يزوجوا بدون مهر المثل فإن فعلوا ثبت لها

[ج ٧ - ص ١٦٤]

مهر المثل بغير يمين فإن ادعى أنه زوجها بأكثر من مهر مثلها فاليمين على الزوج لأن قوله مقبول في قدر مهر المثل

(فإن اختلفا في قبض المهر فالقول قولها) مع يمينها لأن الأصل عدمه وذكر ابن الزاغوني رواية أنه يقبل قول الزوج مع يمينه بناء على كان له علي وقضيته (وإن اختلفا فيما يستقر به المهر) من المسيس والخلوة (فالقول قوله) لأنه منكر والأصل عدمه (وإن تزوجها على صداقين سر وعلانية أخذ بالعلانية وإن كان انعقد بالسر ذكره الخرقي) ونص عليه أحمد لأن الزوج وجد منه بذل الزائد على مهر السر فلزمه كما لو زادها في صداقها ومقتضى ذلك أنه يؤخذ بأزيدهما وقدمه في الفروع (وقال القاضي إن تصادقا على السر لم يكن لها غيره) أي الواجب المهر الذي انعقد به النكاح سرا كان أو علانية لأنه هو الذي ثبت به النكاح والعلانية ليس بعقد حقيقة وإنما هو عقد صورة والزيادة فيه غير مقصودة وحمل كلام أحمد والخرقي على أن المرأة لم تقر بنكاح السر وإذا القول قولها لأن الأصل عدم نكاح السر فلو اتفقا على أن المهر ألف وأنهما عقدا بألفين تجملا فالمهر ألفان أي ما عقد به في الأصح كعقده هزلا وتلجئة نص عليه ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون السر من جنس العلانية أو يكونا من جنسين وذكر الحلواني في بيع مثله (وإن قال هو عقد واحد أسررته ثم أظهرته وقالت بل هو عقدان فالقول قولها مع يمينها) لأن الظاهر أن الثاني عقد صحيح يفيد حكما كالأول ولها المهران وإن [ج ٧ - ص ١٦٥]

أصر على الإنكار سئلت المرأة فإن ادعت أنه دخل بها ثم طلقها ثم نكحها حلفت واستحقت وإن أقرت بما يسقط جميعه أو نصفه لزمها ما أقرت به

فرع يلحق الزيادة بعد العقد بالمهر على الأصح فيما يقرره وينصفه وتملك الزيادة من حينها نقله مهنا في أمة عتقت فزيد مهرها وجعلها القاضي لمن الأصل له فأما هديته فليست من المهر نص عليه فإن كانت قبل العقد وقد وعد به فزوجوا غيره رجع قاله الشيخ تقي الدين وقال ما قبض بسبب نكاح فكمهر وقال فيما كتب فيه المهر لا يخرج منها بطلاقها إذا كان منه

فصل في المفوضة

يجوز فيه فتح الواو وكسرها (والتفويض) معناه الإهمال كأنها أهملت المهر حيث لم يسمه قال الشاعر % لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم % ولا سراة إذا جهالهم سادوا %

(على ضربين تفويض البضع) وهو الذي ينصرف إطلاق التفويض إليه (وهو أن يزوج الأب ابنته البكر أو تأذن المرأة لوليها في تزويجها بلا مهر) أو مطلقا قاله في الرعاية فعلم منه أن النكاح صحيح من غير تسمية صداق في قول عامتهم لقوله تعالى ﴿ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ﴾) ولقول ابن مسعود وسيأتي ولأن

القصد من النكاح الوصلة والاستمتاع دون الصداق فصح من غير ذكره كالنفقة وسواء [ج ٧ - ص ١٦٦]

شرطا نفي المهر أو تركا ذكره فلو قال زوجتك بغير مهر في الحال ولا في الثاني صح (وتفويض المهر وهو أن يتزوجها على ما شاءت أو شاء أجنبي ونحو ذلك) لأنها لم تزوج نفسها إلا بصداق وهو مجهول فسقط لجهالته (فالنكاح صحيح ويجب مهر المثل بالعقد) لقول ابن مسعود وقد سئل عن امرأة تزوجت برجل لم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت به ففرح بها ابن مسعود رواه الخمسة وصححه الترمذي ولفظه له ولأنها تملك المطالبة به فكان واجبا كالمسمى ولأنه لو لم يجب بالعقد لما استقر بالموت كالعقد الفاسد وإنما لم يتنصف لأن الله تعالى نقل غير مسمى لها بالطلاق إلى المتعة فعلى هذا لو فرض الرجل مهر أمته ثم أعتقها أو باعها ثم فرض لها كان لمعتقها أو بائعها وإن طلقت عند المشتري فالمتعة لها (ولها المطالبة بفرضه) قبل الدخول فإن امتنع أجبر عليه لأن النكاح لا يخلو من المهر فوجب لها المطالبة ببيان قدره لا نعلم فيه خلافا إذ القول بعدم وجوبه بالعقد يفضي إلى خلوه منه مع أنه يقع صحيحا قال جماعة ولها المطالبة بمهر المثل وقيل لا لأنه لم يستقر ويصح ابراؤها منه قبل فرضه وعنه لا لجهالته وإن وقف وجوبه على الدخول فكالعفو عما انعقد سبب وجوبه (فإن) امتنع من

بيان قدره (فرضه الحاكم) لأنه معد لذلك فدل على أنه لو فرضه أجنبي لها لم يصح وإن رضيته وفيه وجه بالصحة فإن سلم إليها [ج ٧ - ص ١٦٧]

ما فرض لها فرضيته فهل يصح فيه احتمالان فإن قلنا يصح فطلقت قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج و (لم يجز إلا بمقداره) لأن الزيادة ميل عليه والنقصان ميل عليها والعدل المثل ولأنه إنما يفرض بدل البضع فوجب أن يتقدر به كالسلعة إذا تلفت وحينئذ يلزمها فرضه بحكمه فدل أن ثبوت سبب المطالبة كتقديره أجرة المثل والنفقة ونحوه حكم فلا يغير حاكم آخر ما لم يتغير السبب كيسره في النفقة أو عسره

(وإن تراضيا على فرضه جاز ما اتفقا عليه من قليل وكثير) سوءا كانا عالمين بمهر المثل أو لا لأن الحق لهما لا يعدوهما لأنه إذا فرض لها كثيرا فقد بذل لها من ماله فوق ما يلزمه وإن رضيت باليسير فقد رضيت بدون ما يجب لها ويصير ما فرضاه كالمسمى في العقد في أنه يتنصف بالطلاق ولا تجب لها المتعة

تنبيه يجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئا للخبر وعن ابن عباس وابن عمر لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا للخبر وجوابه بأنه محمول على الاستحباب ويجب المسمى بوطء أو خلوة من يطأ مثله بمن يوطأ مثلها بدون مانع عرفا وفي المانع حسا أو شرعا روايتان

(وإن مات أحدهما قبل الإصابة) وقبل الفرض (ورثه صاحبه) بغير خلاف نعلمه لأن عقد الزوجية صحيح ثابت فيورث به لدخوله في عموم

النص (ولها مهر نسائها) في ظاهر المذهب لحديث ابن مسعود ولأن الموت يكمل [ج ٧ - ص ١٦٨]

به المسمى فكمل به مهر المثل كالدخول (وعنه أنه يتنصف بالموت) لأن المفروض لها يخالف التي لم يفرض لها في الطلاق فجاز أن يخالفها بعد الموت ولأنها فرقة وردت على تفويض صحيح قبل فرض ومسيس فلم يجب لها مهر المثل كفرقة الطلاق (إلا أن يكون قد فرضه لها) الحاكم فإنه لا يتنصف لأن الفرض يجعله كالمسمى ولو سمى ثم مات لوجب كله فكذا إذا فرضه

(وإن طلقها قبل الدخول بها لم يكن لها عليه إلا المتعة) هذا المذهب ونص عليه في رواية جماعة وهو قول ابن عباس وابن عمر لقوله تعالى ﴿ إذا نكحتم المؤمنات ﴾ إلى قوله ﴿ فمتعوهن ﴾ ولقوله تعالى ﴿ وللمطلقات متاع ﴾ والأمر يقتضي الوجوب ولأنه طلاق في نكاح يقتضي عوضا فلم يعر عن ذكر العوض كما لو سمى مهرا ﴿ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ﴾ أي المتعة معتبرة بحال الزوج لقوله تعالى ﴿ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف ﴾ وقيل بحالها وقيل بحالهما وعلى الأول (فأعلاها خادم وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها) لقول ابن عباس أعلا المتعة خادم ثم دون ذلك النفقة ثم دون ذلك الكسوة وقيدت بما يجزئها في صلاتها لأن ذلك أقل الكسوة (وعنه يرجع في تقديرها إلى الحاكم) لأنه أمر لم يرد الشرع بتقديره (وعنه يجب لها نصف مهر المثل) لأنها بدل عنه فيجب أن يتقدر به وعنه يجب للمطلقة قبل الدخول نصف مهر

مثلها لأنه نكاح صحيح يوجب مهر المثل بعد الدخول فوجب نصفه بالطلاق كالتي سمى لها وكما لو سمى لها محرما [ج ٧ - ص ١٦٩]

(فإن دخل بها استقر مهر المثل) لأن الدخول يوجب استقرار المسمى فكذا مهر المثل لاشتراكهما في المهر في المعنى الموجب للاستقرار (فإن طلقها بعد ذلك فهل تجب المتعة على روايتين أصحهما لا تجب) وجزم به في الوجيز لأن كل من وجب لها نصف المهر لم يجب لها متعة سواء كانت ممن سمى لها صداقا أو لا ولأنه وجب لها مهر المثل فلم يجب لها المتعة لأنه كالبدل مع مهر المثل والثانية لكل مطلقة متاع روى عن علي والحسن وسعيد بن جبير وغيرهم للآية والمذهب أن المتعة لا تجب إلا لحرة أو سيد أمة على زوج بطلاق قبل الدخول كمن لا مهر لها لأنه تعالى قسم المطلقات قسمين وأوجب المتعة لغير المفروض لهن ونصف المسمى لغير المفروض لهن وذلك يدل على اختصاص كل قسم بحكمه مع أن أبا بكر قال العمل عندي على الثانية لتواتر الروايات عنه بخلافها فإنه لم يرو عنه هذا إلا حنبل وعنه تجب المتعة إلا لمن دخل بها وسمى لها

فرع لا متعة للمتوفى عنها بغير خلاف لأن النص لم يتناولها وإنما يتناول المطلقات ولأنها أخذت العوض المسمى لها في عقد المعاوضة فلم يجب لها به سواه كما في سائر العقود

فصل

(ومهر المثل معتبر بمن يساويها من نساء عصبتها) من جهة أبيها وجدها (كأختها وعمتها وبنت أخيها وعمها) قال في الشرح هو الأولى لقضاء

النبي صلى الله عليه وسلم [ج ٧ - ص ١٧٠]

في بروع بنت واشق بمثل مهر قومها ولأن شرف المرأة معتبر في مهرها وشرفها بعصباتها لأنهم نسباؤها وأمها وخالتها لا يساويانها في شرفها وقد تكون أمها مولاة وهي شريفة وبالعكس وينبغي أن يعتبر الأقرب فالأقرب من نساء عصباتها كأختها لأبيها ثم عماتها (وعنه يعتبر جميع أقاربها كأمها وخالتها) جزم بها في الوجيز وقدمها في المحرر والمستوعب والفروع لأن مطلق القرابة له أثر له في الجملة وأمها وخالتها يشملهما حديث ابن مسعود لها مهر نسائها وحينئذ يعتبر بمن يساويها في الصفات الحسنة والمال والبلد بالأقرب فالأقرب منهن

(وتعتبر المساواة في المال والجمال والعقل والأدب والسن والبكارة والثيوبة والبلد) لأن مهر المثل بدل متلف فاعتبرت الصفات المفقودة فإن لم يكن في نسائها من هو مثل حالها فمن نساء أرحامها (فإن لم يكن في نسائها إلا دونها زيدت بقدر فضيلتها) لأن زيادة فضيلتها تقتضي زيادة المهر (وإن لم يوجد إلا فوقها نقصت بقدر نقصها) كأرش العيب مقدر بقدر نقص المبيع ولأن له أثرا في تنقيص المهر فوجب أن يترتب بحسبه (وإن كان عادتهم التخفيف على عشيرتهم دون غيرهم اعتبر ذلك) لأن العادة لها أثر في المقدار فكذا في التخفيف لا يقال مهر المثل بدل متلف فوجب أن لا يختلف كسائر المتلفات لأن النكاح يخالف سائر المتلفات باعتبار أن المقصود منه أعيان الزوجين بخلاف بقية المتلفات فإن المقصود منه المالية خاصة فلذلك لم يختلف باختلاف العوائد والمهر

يختلف باختلاف العوائد (وإن كان عادتهم التأجيل فرض مؤجلا في أحد الوجهين) جزم به [ج ٧ - ص ١٧١]

في الوجيز وقدمه في الفروع لأنه مهر نسائها والثاني يفرض حالا لأنه بدل متلف فوجب الحلول كقيم المتلفات وكما لو لم يكن لهم عادة بالتأجيل فلو اختلفت مهورهن أخذ بالوسط الحال (فإن لم يكن لها أقارب اعتبرت بنساء بلدها) لأن ذلك لا أثر له في الجملة (ثم بأقرب النساء شبها بها) لأنه لما تعذر الأقارب اعتبر أقرب النساء شبها بها من غيرهن كما اعتبر قرابتها البعيد إذا لم يوجد القريب

(وأما النكاح الفاسد فإذا افترقا قبل الدخول بطلاق أو غيره فلا مهر فيه) لأن المهر يجب بالعقد والعقد فاسد فوجوده كعدمه كالبيع الفاسد وظاهره ولو لموت قال في الفروع ويتوجه أنه على الخلاف في وجوب العدة به وتقرره بالخلوة وفي مختصر ابن رزين يستقر به وفي الرعاية إذا طلق قبل الدخول فلا يقع ففي سقوط المهر وإيجابه احتمالان (فإن دخل بها) ووطئها (استقر عليه المسمى) في المنصوص وقدمه في الفروع لأن في بعض ألفاظ حديث عائشة ولها الذي أعطاها بما أصاب منها رواه أبو بكر البرقاني وأبو محمد الخلال بإسنادهما (وعنه يجب مهر المثل وهي أصح) جزم به في الوجيز وهو ظاهر الخرقي لقوله عليه السلام فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها فجعل لها المهر بالإصابة والإصابة إنما توجب مهر المثل لأن العقد ليس بموجب بدليل الخبر وأنه لو طلقها قبل مسيسها لم يكن لها عليه شيء وإذا لم يكن موجبا كان وجوده كعدمه وكوطء الشبهة ولأن [ج ٧ - ص ١٧٢]

التسمية لو فسدت لوجب مهر المثل فكذا إذا فسد العقد (ولا يستقر بالخلوة) وهو رواية وقاله أكثر العلماء كمن منعته الوطء أو افترقا بلا وطء ولا خلوة (وقال أصحابنا يستقر) نص عليه قياسا على العقد الصحيح وفي المغني الأول أولى لأن الصداق إنما أوجبه الوطء ولذلك لا يتنصف بالطلاق قبل الدخول أشبه الخلوة بالأجنبية ولأنه عليه السلام جعل المهر بما استحل من فرجها ولم يوجد وقيل لا يكمل بها

فرع لا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الطلاق أو فسخ فإن أبى الزوج فسخه الحاكم نص عليه وظاهره لو زوجها قبل فسخه لم يصح مطلقا فإن زوجت نفسها بلا شهود ففي تزويجها قبل فرقة روايتان في الإرشاد وهما في الرعاية بلا ولي أو بدونهما

(ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة) بغير خلاف علمناه كبدل متلف (والمكرهة على الزنى) أي يجب لها مهر المثل بوطء في قبل ولو من مجنون في ظاهر المذهب ولا يلحقه نسبه وعنه المهر للبكر اختاره أبو بكر وعنه لا يجب لمكرهة اختاره الشيخ تقي الدين لأنه خبيث وظاهره لا يجب لمطاوعة وصرح به في الكافي لأنها باذلة فلم يجب لها شيء كما لو أذنت في قطع طرفها ويستثنى منه الأمة وفي وطء دبر وأمة أذنت وجهان وفي الانتصار لمطاوعة ويسقط وعنه لا مهر لذات رحم وعنه تحرم بنتها كلواط قال بعضهم بخلاف مصاهرة لأنه طارئ قال المؤلف ورضاع (ولا يجب

معه أرش البكارة) كالوطء في نكاح صحيح (ويحتمل أن يجب للمكرهة) [ج ٧ - ص ١٧٣]

وهو رواية لأنه إتلاف جزء فوجب عوضه كما لو جرحها ثم وطئها والأولى أولى لأن المهر بدل المنفعة المستوفاة بالوطء لأن الأرش يدخل في المهر لكون الواجب لها مهر المثل ومهر البكر على مهر الثيب ببكارتها وكانت الزيادة في المهر مقابلة لما أتلف من البكارة ولا يجب عوضهما مرة ثانية

تنبيه يتعدد المهر بتعدد الشبهة والزنى لا بتكرر الوطء في الشبهة قاله في الترغيب وغيره وذكر أبو يعلى الصغير يتعدد بتعدد الوطء في الشبهة لا في نكاح فاسد وفي المغني والنهاية يتعدد في نكاح فاسد ووطئه مكاتبته إن استوفت مهرا عن الوطء الأول وإلا فلا ومن نكاحها باطل بالإجماع كالمزوجة والمعتدة فهي كالمكرهة جزم به الجماعة وعنه يلزم المسمى وعنه لا مهر لمحرمة بنسب ذكرها ابن عقيل

(وإذا دفع أجنبية فأذهب عذرتها) أو أزالها بأصبع أو غيرها (فعليه أرش بكارتها) هذا هو المذهب لأنه إتلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير ديته فرجع فيها إلى الحكومة كسائر مالم يقدر ولأنه إذا لم يكمل الصداق به في حق الزوجة ففي حق الأجنبي أولى (وقال القاضي يجب مهر المثل) هذا رواية عن أحمد لما روى سعيد ثنا هشيم ثنا مغيرة عن إبراهيم أن رجلا كانت عنده يتيمة فخافت امرأته أن يتزوجها فاستعانت بنسوة فأذهبتن عذرتها وقالت لزوجها فجرت فأخبر علي بذلك فأرسل إلى امرأته والنسوة فلما أتين لم يلبثن أن اعترفن بما صنعن فقال للحسن بن علي اقض

فيها فقال الحد على من قذفها والعقر عليها وعلى الممسكات ولأنه إتلاف بستحق به مهر المثل في العقد [ج ٧ - ص ١٧٤]

فإذا أتلفه أجنبي وجب مهر المثل كمنفعة البضع ونقل مهنا فيمن تزوج بكرا فدفعها هو وأخوه فأذهبا عذرتها ثم طلقها قبل الدخول إن على الزوج نصف الصداق وعلى الأخ نصف العقر روى عن علي والحسن وعبد الله بن معقل وعبد الملك بن مروان وهذه قصص مشتهرة ولم تنكر فكانت كالإجماع والأول هو القياس لولا ماروي عن الصحابة وأرش البكارة ما بين مهر البكر والثيب (وإن فعل ذلك الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى) في ظاهر المذهب لقوله تعالى ﴿ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ﴾ الآية لأنه أتلف ما يستحق إتلافه بالعقد فلم يضمنه كغيره كما لو أتلف عذرة أمته ويتخرج أن يجب لها الصداق كاملا فإن أحمد قال إذا فعل ذلك أجنبي فعليه الصداق ففيما إذا فعله الزوج أولى وظاهره أنه لا يجب أرش البكارة وقيل بلى إن قيل يجب على الأجنبي أرشها فيعطي حكمه من حين الإتلاف ويمتاز عليه بنصف المسمى لكونه قبل الدخول

فرع لو وطئ ميتة لزمه المهر في ظاهر كلامهم قال في الفروع وهو متجه وفي كلام القاضي ما يدل على خلافه وإن مات أو طلق من دخل بها فوضعت في يومها ثم تزوجت فيه وطلق قبل دخوله بها ثم تزوجت في يومها من دخل بها فقد استحقت في يوم واحد بالنكاح مهرين ونصف ذكره المؤلف في فتاويه

(وللمرأة) سمي لها أو مفوضة (منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال) حكاه ابن المنذر إجماعا لأن في إجبارها أولا على تسليم نفسها خطرا بإتلاف [ج ٧ - ص ١٧٥]

البضع ولا يمكن الرجوع فيه بخلاف المبيع وقيل أو حل قبل التسليم وسافر بلا اذنه في أصح الروايتين ولها النفقة إذا امتنعت ولو كان معسرا والسفر بغير إذنه لأنه امتناع بحق أشبه مالو امتنعت للإحرام بحجة الإسلام وعلل أحمد وجوب النفقة بأن الحبس من قبله وظاهر كلام جماعة لا نفقة قال في الفروع وهو متجه وظاهره أنه إذا كان مؤجلا فليس لها منع نفسها قبل قبضه لأن رضاها بتأجيله رضى منها بتسليم نفسها قبل قبضه كتأجيل الثمن فأما إذا كان بعضه حالا وبعضه مؤجلا فلها منع نفسها قبل قبض العاجل ولا فرق بين حلوله بعد تأجيله وعدمه صرح به في المغني لأن التسليم قد وجب عليها فاستقر قبل قبضه فلم يكن لها أن تمتنع منه

فرع إذا كانت محبوسة أو لها عذر يمنع التسليم وجب تسليم الصداق كمهر الصغيرة في الأصح

(فإن تبرعت بتسليم نفسها ثم أرادت المنع فهل لها ذلك على وجهين) إذا سلمت نفسها تبرعا فدخل أو خلا ثم أرادت المنع فقد توقف أحمد في الجواب عنها وفيه وجهان أحدهما لا يملكه واختاره الأكثر منهم صاحب الوجيز لأن التسليم استقر به العوض برضى المسلم فلم يكن لها أن تمتنع منه كتسليم البائع المبيع وفيه تنبيه على الفرق بين المتبرع بالتسليم وعدمه وهو قادح في صحة القياس والثاني واختاره ابن حامد على أن لها المنع لأنه

تسليم يوجبه العقد فكان لها أن تمتنع منه قبل صداقها كما لو تبرع بتسليم نفسها فأما إن وطئها مكرهة لم يسقط حقها من الامتناع صرح به في المغني

[ج ٧ - ص ١٧٦]

والشرح كالبائع المكره على التسليم والأصح أنه إذا أظهر معيبا بعد قبضه وتسليم نفسها أن لها المنع

فرع إذا أبى كل من الزوجين التسليم الواجب أجبر زوج ثم زوجة وإن بادر به أحدهما أجبر الآخر عليه فلو أبت التسليم بغير عذر فله استرجاع الصداق

(وإن أعسر بالمهر) الحال (قبل الدخول فلها الفسخ) اختاره أبو بكر وجزم به في الوجيز كما لو أعسر المشتري بالثمن قبل تسليم المبيع وقيل لا يفسخ اختاره ابن حامد وصححه في المغني لأنه دين فلم ينفسخ بالإعسار كالنفقة الماضية والثمن كل مقصود البائع والعادة تعجيله والصداق فضلة والعادة تأخيره (وإن أعسر بعده) أي بعد الدخول (فعلى وجهين) هما مبنيان على منع نفسها إن قلنا لها منع نفسها بعد الدخول فلها الفسخ كما قبل الدخول وإن قلنا ليس لها منع نفسها فليس لها الفسخ كما لو أفلس بدين آخر والأشهر أن الحرة مكلفة الفسخ بعده مالم تكن عالمة بعسرته ونقل ابن منصور إن تزوج مفلسا ولم تعلم المرأة لا يفرق بينهما إلا أن يكون قال عندي عوض ومال وغيره فإن رضيت بالمقام فلا فسخ في الأصح لكن لها منع نفسها

فرع المنع والفسخ لسيد الأمة وقيل لا وهو أولى كولي الصغيرة والمجنونة

(ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم) في الأصح لأنه فسخ مختلف فيه

[ج ٧ - ص ١٧٧]

كالفسخ للعنة والإعسار بالنفقة ولأنه يفضي أن يكون للمرأة زوجان كل واحد يعتقد حلها له وتحريمها على الآخر والثاني يجوز بغير حكم نكيار المعتقة تحت عبد والأول أصح إذ القياس على المعتقة غير صحيح لأنه متفق عليه وهذا مختلف فيه والله أعلم [ج ٧ - ص ١٧٨]

باب الوليمة

قال في المستوعب وليمة الشيء كماله وجمعه وسميت دعوة العرس وليمة لاجتماع الزوجين يقال أولم إذا صنع وليمة

(وهي اسم لدعوة العرس خاصة) لا تقع على غيره حكاه ابن عبد البر عن ثعلب وغيره من أئمة اللغة وقال بعض أصحابنا تقع على كل طعام لسرور حادث إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر وقول أهل اللغة أقوى لأنهم أهل الشأن وهم أعرف بموضوعات اللغة وأعلم بلسان العرب

والأطعمة التي يدعى إليها الناس عشرة الأولى وليمة العرس والثانية عذرة وإعذار للختان والثالثة خرسة وخرس الولادة والرابعة وكيرة لدعوة البناء والخامسة نقيعة لقدوم الغائب والسادسة عقيقة الذبح لأجل الولد والسابعة حذاق لأجل حذاق الصبي والثامنة مأدبة وهي كل دعوة بسبب كانت أو غيره ذكر ذلك في المغني وغيره والتاسعة وضيمة وهي طعام المأتم نقله الجوهري عن الفراء والعاشرة تحفة لقدوم الغائب ذكره أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي وشدخية لطعام املاك على زوجة وشداخ لمأكول في ختمة القارئ

(وهي مستحبة) بالعقد قاله ابن الجوزي ولا خلاف بين أهل العلم في أن وليمة العرس سنة مشروعة لأنه عليه السلام أمر بها وفعلها قال لعبد

الرحمن بن عوف تزوجت قال نعم قال أولم متفق عليه فعلى هذا يستحب بشاة فأقل وعنه أنها واجبة ذكرها ابن عقيل وكونها للأمر وقال السنة أن يكثر للبكر وجوابه بأنه طعام لسرور حادث أشبه سائر الأطعمة والخبر محمول على الاستحباب وقوله ولو بشاة للتقليل أي ولو بشيء قليل كشاة فيستفاد منه أن الوليمة جائزة بدونها لما روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بمدين من شعير (والإجابة إليها واجبة) في الأشهر عنه قاله في الإفصاح وذكر ابن عبد البر أنه لا خلاف فيها إذا لم يكن فيها لهو لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها متفق عليه وقال عليه السلام شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك لها الفقراء ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله رواه البخاري من حديث أبي هريرة وليس المراد به كل طعام الولائم فإنه لو أراد ذلك لما أمر بها ولا ندب إليها واستحب في الغنية إجابة وليمة العرس وكره حضور غيرها على الوجه الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وقيل فرض كفاية لأنها إكرام وموالاة أشبه رد السلام وقيل مستحبة لفعلها وعنه إن دعاه من يثق به فإجابته أفضل (إذا عينه الداعي المسلم في اليوم الأول) فيشترط لوجوب الإجابة إليها شروط منها أن يعين الداعي المدعو بالدعوى فلو لم يعينه كقوله يا أيها الناس أجيبوا إلى الوليمة لم يجب لعدم كسر القلب ومنها أن يكون الداعي مسلما فلا تجب بدعوى الذمي لأنها تراد للإكرام والموالاة وذلك منتف في حقه

وعنه في جواز تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتان وكذا يخرج في إجابتهم ويشترط فيه ألا يجوز هجره فإن جاز كمبتدع ونحوه لم تجب ومنع

[ج ٧ - ص ١٨٠]

في المنهاج من فاسق ومبتدع ومفاخر بها أو فيها مبتدع يتكلم ببدعته إلا لراد عليه وكذا مضحك بفحش أو كذب وإلا أبيح القليل وفي الترغيب إن علم حضور الاراذل ومن مجالستهم تزري بمثله لم يجب ومنها أن يكون في اليوم الأول فإن كان في الثاني لم يجب لما روى ابن مسعود مرفوعا قال طعام أول يوم حق والثاني سنة والثالث سمعة ومن سمع سمع الله به رواه الترمذي وقال لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله وهو كثير الغرائب وروى له مسلم وكذا البخاري مقرونا بغيره ويشترط أن يكون مكسبه طيبا في المنصوص ومنها أن لا يكون فيها منكرا وسيأتي

(فإن دعى الجفلى كقوله أيها الناس تعالوا إلى الطعام) أو يقول الرسول أمرت أن أدعو من لقيت أو شئت فهذه دعوة عامة لا يخص فيها أحد (أو دعاه فيما بعد اليوم الأول أي إذا تكرر فعل الوليمة أكثر من يوم جاز لما روى الخلال بإسناده عن أبي أنه عرس الانصار ثمانية أيام لكن إن كان في الثاني فيستحب قاله أحمد ويكره في الثالث لأنه قصد الرياء والسمعة وقد روي عن سعيد بن المسيب أنه دعي إلى وليمة مرتين فأجاب فلما دعي الثالثة حصب الرسول رواه الخلال (أو دعاه ذمي لم تجب الإجابة) لأنه لا يأمن اختلاط طعامهم بالحرام والنجاسة ودعواه الجفلى وإجابة الذمي قيل بجوازها وقيل يكره وقيل له في رواية أبي داود ويجيب دعوة الذمي قال نعم قيل يأكل عند المجوسي قال لا بأس مالم يأكل من قدورهم

(وسائر الدعوات والإجابة إليها مستحبة غير واجبة) قطع به المؤلف في

[ج ٧ - ص ١٨١]

كتبه واختاره أبو حفص العكبري لما فيه من إطعام الطعام وجبر القلوب ولأن في فعلها شكرا لنعمة الله تعالى وإظهارا لإحسانه وظاهر رواية ابن منصور ومثنى يجب لما روى ابن عمر مرفوعا قال إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو غير عرس رواه مسلم وأبو داود وجوابه بحمله على الاستحباب مع أن أحمد نص على إباحة بقية الدعوات اختاره الأكثر ويستثنى منه العقيقة فإنها تسن وعنه تكره دعوة الختان لقول عفان بن أبي العاص كنا لا نأتي الختان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ندعى إليه رواه أحمد وفيه ضعف وكالمأتم وظاهر الخرقي أن الإجابة إلى دعوة الختان مباحة ونص عليه أحمد وقاله القاضي وعامة أصحابه كعملها وظاهر كلام الأكثر على استحباب الإجابة مطلقا نص عليه وفي الغنية يكره لأهل الفضل والعلم المسارعة إلى إجابة الطعام والتسامح لأن فيه دناءة وشرها لا سيما الحاكم

(وإذا حضر وهو صائم صوما واجبا لم يفطر) يعني أن الصائم إذا دعي تسقط الإجابة فإذا حضر وكان الصوم واجبا لم يفطر لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليدع وإن كان مفطرا فليطعم رواه أبو داود ورواه مسلم أيضا ولفظه إن كان صائما فليصل ولأن الصوم واجب عليه فلم يجز تركه ولأن صاحب الطعام يعذره فلا يؤدي إلى كسر قلبه (وإن كان نفلا) أفطر لأن فيه إدخال السرور على قلب أخيه المسلم وقيل إن جبر قلب داعيه وقيل يدعو

أو ينصرف نص عليه ويستحب له إعلامهم بصومه وهو قول عثمان وابن عمر لأن التهمة [ج ٧ - ص ١٨٢]

تزول ويتمهد عذره (أو كان مفطرا استحب له الأكل) إن شاء قاله أحمد وفي الواضح ظاهر الحديث وجوبه وفي مناظرات ابن عقيل لو غمس أصبعه في ماء ومصها حصل به إرضاء الشرع وإزالة المأثم بإجماعنا ومثله لا يعد إجابة عرفا بل استخفافا بالداعي (فإن أحب دعا وانصرف) لدخوله في قوله عليه السلام وإن كان صائما فليدع ولأن الأكل غير واجب نصا لقوله عليه السلام إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك رواه مسلم من حديث جابر وقوله فليطعم محمول على الاستحباب ولأنه لو وجب الأكل لوجب على المتطوع بالصوم بل المقصود الإجابة (وإن دعاه إثنان أجاب أولهما) لقوله عليه السلام فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق رواه أبو داود ولأن إجابته وجبت بدعوته فلم تزل بدعوة الثاني والسبق بالقول وقيل بالباب وظاهره أنه لا يجيب الثاني وهو صحيح لكن بشرط أن لا يتسع الوقت لإجابتهما لأنه لو وجب عليه إجابة الثاني مع عدم اتساع الوقت لأوجبنا عليه ما لا يمكنه فعله إلا بترك واجب مثله بل أرجح فإن اتسع الوقت لهما وجبا للأخبار (فإن استويا أجاب أدينهما) لأن كثرة الدين لها أثر في التقديم بدليل الأمانة (ثم أقربهما جوارا) وكذا في المستوعب لقوله عليه السلام إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا رواه أبو داود وفي الفروع يقدم أسبقهما ثم أقربهما وفي المغني والكافي يقدم

أقربهما جوارا ثم رحما وفي المحرر و الرعاية و الوجيز عكسه ثم القرعة بعد الكل [ج ٧ - ص ١٨٣]

(وإن علم أن في الدعوة منكرا كالزمر والخمر وأمكنه الإنكار حضر وأنكر) لأنه يؤدي فرضين إجابة الدعوة وإزالة المنكر (وإلا) إذا لم يمكنه الإنكار (لم يحضر) لأن عليه ضررا في الحضور ولأنه يحرم عليه مشاهدة ذلك لقوله عليه السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها خمر رواه الترمذي وقال حسن غريب ولأنه يشاهد المنكر من غير حاجة إليه فمنع منه كما لو شاهده مع القدرة على إزالته (وإن حضر فشاهد المنكر أزاله وجلس) لأن في ذلك جمعا بين مصلحتي الإنكار ومقصود الإجابة الشرعية (فإن لم يقدر انصرف) لأن الجلوس مع مشاهدة التحريم حرام وقد خرج أحمد من وليمة فيها آنية فضة فقال الداعي نحولها فلم يرجع نقله حنبل (وإن علم به ولم يره ولم يسمعه فله الجلوس) لأن المحرم رؤية المنكر وسماعه ولو يوجد واحد منهما وله الأكل نص عليه وله الامتناع من الحضور في ظاهر كلامه كإسقاط الداعي حرمة نفسه باتخاذ المنكر قال أحمد لا بأس وفي المذهب و المستوعب لا ينصرف وقاله أحمد وإن وجب الإنكار على رواية أو قول (وإن شاهد ستورا معلقة فيها صور الحيوان لم يجلس إلا أن تزال) أي إذا كانت صورة الحيوان على الستور والحيطان وما لا يوطأ وأمكنه حطها أو قطع رأسها فعل ذلك وجلس وإن لم يمكنه ذلك انصرف وعليه أكثر العلماء قال ابن عبد البر وهذا أعدل المذاهب لأن عائشة نصبت سترا فيه تصاوير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه قالت فقطعته وسادتين يرتفق

عليهما متفق عليه وأما دخول منزل فيه تصاوير فليس بمحرم وإنما أبيح ترك الدعوة [ج ٧ - ص ١٨٤]

من أجله عقوبة الداعي بإسقاط حرمته لاتخاذه المنكر في داره فلا يجب على من رآه في منزل الداعي الخروج في ظاهر كلام أحمد ذكره في المغني وفيه وجه

فائدة إذا قطع رأس الصورة أو ما لا تبقى الحياة بعد ذهابه أو جعل له رأس منفصل عن البدن لم يدخل تحت النهي وإن كان الذاهب تبقى الحياة بعده كاليد والعين فهو صورة وصنعه التصاوير محرمة على فاعلها للأخبار والأمر بعملها محرم كعملها

(فإن كانت مبسوطة أو على وسادة فلا بأس بها) لأن فيه إهانة لها ولأن تحريم تعليقها إنما كان لما فيه من التعظيم والاغرار والتشبه بالأصنام التي تعبد وذلك مفقود في البسط لقول عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على نمرقة فيها تصاوير رواه ابن عبد البر ولأن فيه إهانة كالبسط (وإن سترت الحيطان بستور) غير حرير (لا صور فيها أو فيها صور غير الحيوان فهل يباح على روايتين) إحداهما يكره وهو عذر في ترك الإجابة إلى الدعوة قال أحمد قد خرج أبو أيوب حين دعاه ابن عمر فرأى البيت قد ستر رواه الأثرم وابن عمر أقر على ذلك وقال أحمد دعي حذيفة فخرج وإنما رأى شيئا من زي الأعاجم وكراهته لما فيه من السرف في ذلك لا يبلغ به التحريم والأخرى يحرم لما روى الخلال عن علي بن الحسين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستر الجدر وكما لو كانت الستر

حريرا واختار في المغني الأول لأنه لم يثبت في تحريمه حديث ولو ثبت حمل على الكرهه فإن كان ضرورة من حر أو برد فلا بأس لأنه يستعمله لحاجة أشبه الستر على الباب وفي جواز [ج ٧ - ص ١٨٥]

خروجه لأجله وجهان فلو كان فيها آنية ذهب أو فضة فهو منكر يخرج من أجله وكذا ما كان من الفضة مستعملا كالمكحلة

(ولا يباح الأكل بغير إذن) صريح أو قرينة كدعائه إليه نص عليه لأن أكل مال غيره بغير إذنه محرم كلبس ثوبه وركوب دابته (والدعاء إلى الوليمة إذن فيها) جزم به في المغني وغيره لقوله عليه السلام رسول الرجل إلى الرجل إذنه رواه أبو داود بإسناد جيد وعن ابن مسعود إذا دعيت فقد أذن لك رواه أحمد وظاهره ولو من بيت قريبه وصديقه ولم يجوزه عنه نقله ابن القاسم وجزم به جماعة أنه يجوز واختاره الشيخ تقي الدين وهو أظهر وفي الفروع ليس الدعاء إذنا للدخول في ظاهر كلامهم وجزم القاضي في المجرد وابن عقيل فيمن كتب من محبرة غيره يجوز في حق من تنبسط إليه ويأذن له عرفا

(والنثار والتقاطه مكروه) على المذهب لأنه عليه السلام نهى عن النهي والمثلة رواه أحمد والبخاري من حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري ولأن في تزاحما وقتالا وقد يأخذه من غيره أحب إلى صاحبه وربما دل على دناءة نفس المنتهب لا يقال ظاهره التحريم لأنه مردود بالإجماع انه للإباحة ذكره في المغني ولأنه نوع إباحة لمال فلم يكن محرما كسائر الإباحات (وعنه لا يكره) اختارها أبو بكر وقاله الحسن وقتادة لما روى عبد الله بن قرط قال قرب للنبي صلى الله عليه وسلم خمس بدنات أو

ست فقال من شاء اقتطع رواه أبو داود وقال هذا جار مجرى النثار وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي [ج ٧ - ص ١٨٦]

إلى وليمة رجل من الأنصار وجعل يزاحم الناس على النهبة قالوا يا رسول الله أوما نهيتنا عن النهبة قال إنما نهيتكم عن نهبة العساكر ولم أنهكم عن نهبة الولائم رواه العقيلي ولأنه نوع إباحة أشبه إباحة الطعام للضيفان وعنه لا يعجبني هذه نهبة لا تؤكل وفرق ابن شهاب وغيره بأنه بذبحه زال ملكه والمساكين عنده سواء والنثر لا يزيل الملك (ومن حصل في حجره فهو له) لأنه مباح حصل في حجره فملكه كما لو ثبت إليه سمكة وليس لأحد أخذه وفي لمحرر يملكه مع القصد وبدون القصد وجهان

فرع إذا قسم على الحاضرين فلا بأس لقول أبي هريرة قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه تمرا وقد روى عن أحمد أنه حذق بعض ولده فقسم على الصبيان الجوز لكل واحد خمسة ولأن بذلك تنتفي المفسدة مع أن فيه إطعام الطعام وجبر القلوب وانبساطها وهو مصلحة محضة

(ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف) لما روى محمد بن حاطب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه قال أحمد يستحب أن يظهر النكاح ويضرب عليه بالدف حتى يشهر ويعرف قيل ما الدف قال هذا الدف قيل له في رواية جعفر يكون فيه جرس قال لا قال أحمد يستحب ضرب الدف والصوت في الأملاك فقيل له ما

الصوت قال يتكلم ويتحدث ويظهر ولا بأس بالغزل فيه كقوله عليه السلام للأنصار % أتينا كم أتينا كم % فحيونا نحييكم % [ج ٧ - ص ١٨٧]

وإنما يستحب الضرب به للنساء وجزم به في الوجيز وظاهر نصه وكلام الأصحاب يدل على التسوية قيل له في رواية المروذي ما ترى للناس اليوم تحرك الدف في املاك أو بناء بلا غناء فلم يكره ذلك وختان وقدوم غائب مثله نص عليه وعلم منه تحريم كل ملهاة سواه كمزمار وطنبور ورباب وجنك سواء استعمل لحزن أو سرور وسأله ابن الحكم عن النفخ في القصبة كالمزمار قال أكرهه وفي القصص وجهان وفي المغني لا يكره إلا مع تصفيق أو غناء أو رقص ونحوه وكره أحمد الطبل لغير حرب واستحبه ابن عقيل لتنهيض طباع الأولياء وكشف صدور الأعداء وليس عبثا

فصل يتعلق بآداب الأكل وغيره

الأول يستحب غسل يديه قبل الطعام وبعده نص عليه وإن كان على وضوء وعنه يكره قبله اختاره القاضي واستحبه في المذهب بعد قاله عمر ويكره بطعام ولا بأس بنخالة وغسله في الإناء الذي أكل فيه نص عليهما قال بعضهم ويكره بدقيق حمص وعدس وباقلا ونحوه

الثاني إنه إذا قدم إليه الطعام فإنه يحرم أخذه فإن علم به بقرينة رضى مالكه وفي الترغيب يكره وقيل يباح وانه يكره مع ظنه رضاه ولا يملكه بتقديمه إليه بل يهلك على ملك صاحبه

الثالث يلعق أصابعه قبل غسلها أو يلعقها ويعرض الماء لغسلهما ويقدمه بقرب الطعام وبعده نص عليه وإن كان على وضوء وعنه يكره ولا يعرضه

ذكره في التبصرة [ج ٧ - ص ١٨٨]

الرابع يستحب له التسمية في ابتدائه ويأكل بيمينه ويحمد إذا فرغ وقيل يجب ذلك قال الأصحاب يقول بسم الله وفي الخبر المشهود يقول بسم الله أوله وآخره قال الشيخ تقي الدين لو زاد الرحمن الرحيم كان حسنا بخلاف الذبح ونقل ابن هانئ أنه جعل عند كل لقمة يسمى ويحمد قال أحمد يأكل بالسرور مع الإخوان وبالإيثار مع الفقراء وبالمروءة مع أبناء الدنيا وأكل وحمد خير من أكل وصمت

الخامس سيتحب الأكل بثلاث أصابع مما يليه قال جماعة والطعام نوع واحد قال الآمدي لا بأس وهو وحده وقال ابن حامد ويخلع نعليه

السادس يكره عيب الطعام وحرمه في الغنية ونفخه فيه وقال الآمدي لا يكره وهو حار وأكله حارا أو فعل ما يستقذره من غيره ورفع قبلهم بلا قرينة ومدح طعامه وتقويمه وحرمهما في الغنية وتنفسه في إنائه وأكله من وسطه وأعلاه قال أحمد ومتكئا وعلى الطريق قاله في الغنية

السابع يكره قرانه في التمر وقيل مع شريك لم يأذن قال بعضهم وكذا قران ما العادة جارية بتناوله مفردا ونقل مهنا أكره أن يستعمل الخبز على المائدة ولا بأس بتكسيره قال أحمد لئلا يعرف ما يأكلون

الثامن له قطع لحم بسكين والنهي عنه لا يصح قاله أحمد واحتجوا بنهي ضعيف على الكراهة ولو على قول قال في الفروع فيتوجه هنا مثله بلا حاجة [ج ٧ - ص ١٨٩]

التاسع يجوز أكله كثيرا حيث لا يؤذيه وفي الغنية يكره مع خوف تخمة وحرمه الشيخ تقي الدين وكذا الإسراف فيه إلى مجاوزة الحد ولا بأس باطعام ما جرت به العادة كسائل وسنور وتلقيم وفي تقديم الأظهر جوازه

العاشر لا يكره شربه قائما نقله الجماعة وعنه بلى وسأله صالح عن شربه قائما في نفس قال أرجو وفي الفروع ويتوجه كأكل وظاهر كلامهم لا يكره أكله قائما ويتوجه كشرب قاله شيخنا وكره أحمد الشرب من في السقاء والجلوس بين ظل وشمس والنوم بعد العصر وعلى سطح غير محجر واستحب القائلة نصف النهار والنوم اذن

الحادي عشر لا بأس بالتخليل قال في رواية عبد الله عن ابن عمر ترك الخلال يوهن الأسنان قال الأطباء هو نافع للثة وتغير للنكهة

الثاني عشر لا بأس أن يخلط المسافرون أزوادهم ويأكلون جميعا لأنه فعل السلف نقل أبو داود لا بأس أن يتناهد في الطعام ويتصدق منه لم يزل الناس يفعلونه ويتوجه رواية لا يتصدق منه إلا بإذن

مسألة له دخول بيعة وكنيسة والصلاة فيهما وعنه يكره وعنه مع صورة وظاهر كلام جماعة تحريم دخوله معها ويحرم شهود عيد ليهود أو نصارى نقله مهنا وكرهه الخلال وفيه تنبيه على المنع أن يفعل كفعلهم قاله الشيخ تقي الدين لا البيع لهم فيها نقله مهنا وحرمه الشيخ تقي الدين وخرجه على

الروايتين في حمل التجارة إلى دار الحرب وإن مثله مهاداتهم لعيدهم والله أعلم [ج ٧ - ص ١٩٠]

باب عشرة النساء

وهي ما يكون بينه وبين أهله من الألفة والانضمام

(يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف) والمراد هنا النصفة وحسن الصحبة مع الأهل (وأن لا يمطله) هو بضم الطاء والمطل الدفع عن الحق بوعد (بحقه ولا يظهر الكراهة لبذله) لقوله تعالى ﴿ وعاشروهن بالمعروف ﴾ ﴿ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ﴾ قال أبو زيد يتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله فيكم وقال ابن الجوزي وغيره هو المعاشرة الحسنة والصحبة الجميلة قال ابن عباس إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي لهذه الآية فعلى هذا يلزم تحسين الخلق والرفق واستحبهما في المغني و الشرح كاحتمال أذاه لقوله تعالى ﴿ والصاحب بالجنب ﴾ قيل هو كل واحد من الزوجين ولقوله تعالى ﴿ فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ﴾ قال ابن عباس ربما رزق منها ولد فجعل الله فيه خيرا كثيرا وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء متفق عليه ولفظه لمسلم وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة باتت وزوجها راض عنها دخلت

الجنة رواه ابن ماجه والترمذي وقال حسن غريب فدل على أن حق الزوج عليها آكد من حقها عليه [ج ٧ - ص ١٩١]

(وإذا تم العقد وجب تسليم المرأة) لأن بالعقد يستحق الزوج تسليم المعوض كما تستحق المرأة تسليم العوض وكالإجارة (في بيت الزوج) لأن الحق له فملك تعيين موضعه وله شروط (إذا طلبها) لأن الحق له فلا يجب بدون الطلب (وكانت حرة) لأن الأمة لا يجب تسليمها مطلقا بل ليلا لأن النهار تكون في خدمة سيدها (يمكن الاستمتاع بها) لأن التسليم إنما وجب ضرورة استيفاء الاستمتاع الواجب فإذا لم يمكن الاستمتاع بها لم يكن واجبا وظاهره ولو كانت نضوة الخلقة وهو جسيم فإنه يجب تسليمها كما لو كانت مريضة مرضا مزمنا ويقبل قول امرأة ثقة في ضيق فرجها وعبالة ذكره ونحوه وتنظرهما وقت اجتماعهما للحاجة ولو أنكر أن وطأه يؤذيها لزمها البينة ونص على أنها تكون بنت تسع قال القاضي ليس هذا عندي على سبيل التحديد وإنما ذكره لأنه الغالب ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة ومريضة وصغيرة وحائض ولو قال لا أطا وفيه احتمال (ولم يشترط دارها) فإن شرطته لزم الوفاء به ويجب عليها تسليم نفسها في دارها (وإن سألت الإنظار وأنظرت مدة جرت العادة بإصلاح أمرها فيها) لأن ذلك يسير جرت العادة بمثله يدل عليه قوله عليه السلام لا تطرقوا النساء ليلا حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة فمنع من الطروق وأمر بإمها لها لتصلح أمرها مع تقدم صحبتها له فهنا أولى وقيده في المغني والكافي والشرح باليومين والثلاثة لأن ما يحتاج إليه يمكن فعله في ذلك لا لعمل جهازها وكذا لو سأل هو الإنظار وفي الغنية إن

استمهلت هي أو أهلها استحب له إجابتهم ما يعلم به التهيؤ من شراء جهاز وتزين وولي من به صغر [ج ٧ - ص ١٩٢]

أو جنون مثله (وإن كانت أمة لم يجب تسليمها إلا بالليل) مع الإطلاق نص عليه لأنها مملوكة عقد على إحدى منفعتها فلم يجب تسليمها في غير وقتها كما لو آجرها لخدمة النهار فلو شرطه نهارا أو بذله سيد وجب حتى ولو شرطها كونها عند السيد فإن بذله وقد شرطه لنفسه فوجهان

(وله الاستمتاع بها مالم يشغلها عن الفرائض من غير إضرار بها) لقوله تعالى ﴿ وعاشروهن بالمعروف ﴾ ولقوله عليه السلام من باتت مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه من حديث أبي هريرة ولأن المقصود من النكاح الاستمتاع فإذا لم يشغلها عن الفرائض ولم يضر بها وجب عليها التمكين منه وظاهره له الاستمتاع بها في قبل ولو من جهة العجز قال ابن الجوزي كره العلماء الوطء بين الآليتين لأنه يدعو إلى الوطء في الدبر ولو كانت على تنور أو ظهر قتب رواه أحمد مرفوعا ولا تطوع بصلاة وصوم إلا بإذنه نقله حنبل وأنها تطيعه في كل ما أمرها به من الطاعة (وله السفر بها) حتى لو كان عبدا لأنه عليه السلام كان يسافر بنسائه ولأنه تدعو الحاجة إلى الاستمتاع وهو حق عليها فكان له ذلك بلا إذن بشرط أمن الطريق (إلا أن تشترط بلدها) لقوله عليه السلام إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج أو تكون أمة قال في الشرح إن أراد السيد السفر بها فقد توقف أحمد عن ذلك وفي ملك السيد له بلا إذن زوج صحبه أم لا وجهان وينبني عليها لو بوأها مسكنا ليأتيها الزوج فيه هل يلزمه قاله في الترغيب [ج ٧ - ص ١٩٣]

فرع له السفر بعبده المزوج بدون إذن زوجته نص عليه واستخدامه نهارا وإن قلنا النفقة والمهر من كسبه لم يمنعه منه

مسألة لو قال سيد بعتكها قال زوجتنيها وجب تسليمها للزوج لاتفاقهما على استحقاقه لها ويلزمه الأقل من ثمنها أو مهرها ويحلف لثمن زائد فإن نكل لزمه وعند القاضي لا مهر ولا ثمن ولا يمين عنده على البائع لأنه لا براها في نكاح وذكر الأزجي كذلك إلا في اليمين قال ولا ترد الأمة إليه لاعترافه بأنها أم ولد ونفقته على أبيه ونفقتها على الزوج وقال الأزجي إن قلنا لا يحل له فهل هي على مالكها السابق أم في كسبها فيه احتمالان

(ولا يجوز وطؤها في الحيض) إجماعا وسنده الآية (ولا الدبر) في قول أكثر العلماء لما روى أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها رواه ابن ماجه وقوله تعالى ﴿ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ﴾ أي كيف شئتم إلا الدبر لما روى جابر قال كان اليهود يقولون إذا جامع الرجل امرأته في فرجها من ورائها جاء الولد أحول فأنزلت هذه الآية أي من بين يديها ومن خلفها غير أنه لا يأتيها إلا في المأتى فإن تطاوعا عليه فرق بينهما ويعزر عالم بتحريمه بخلاف وطء الأجنبية وليس لها استدخال ذكره وهو نائم بلا إذنه بل القبلة واللمس لشهوة ذكره في الرعاية (ولا يعزل) أي ينزع قرب الإنزال فينزل خارج الفرج (عن الحرة إلا بإذنها

) لما روى ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها رواه أحمد وابن ماجه ولأنه يقطع [ج ٧ - ص ١٩٤]

اللذة عن الموطوءة ولها حق في الولد عليها ضرر فلم يجز إلا بإذنها إلا بدار حرب فيسن عزله مطلقا ذكره في الفصول وهو ظاهر الخرقي (ولا عن الأمة) المعقود عليها (إلا بإذن سيدها) لأن الولد حق للسيد فاشترط إذنه وهذا إذا لم يشترط حريته وقيل وإذنها لأنها زوجة تملك المطالبة بالوطء في الفيأة والفسخ عند تعذره بالعنة وترك العزل من تمامه فلم يجز إلا بإذنها كالحرة وقيل يباح العزل مطلقا روى عن علي وسعد بن أبي وقاص وأبي أيوب وزيد بن ثابت وجابر وابن عباس استدلالا بمفهوم حديث الحرة ولأن حقها في الوطء دون الإنزال بدليل أنه يخرج من الفيئة والعنة وقيل عكسه وظاهره أنه يجوز من أمته نص عليه لأنه لا حق لها في الوطء ولا في الولد فلم يملك المطالبة بالقسم والفيئة فلأن لا يملك المنع من العزل أولى وفي أم الولد وجهان (وله إجبارها على غسل الحيض) والنفاس مسلمة كانت أم ذمية حرة أو أمة لأنه يمنع الاستمتاع الذي هو حق له فملك إجبارها على إزالة ما يمنع حقه فإن احتاجت إلى شراء ماء فثمنه عليه في الأشهر (والجنابة) أي له إجبار المسلمة عليه لأنه واجب عليها وفي الواضح ظاهر المذهب لا وفي المحرر روايتان (والنجاسة) فإن كانت في فيها فله إجبارها على غسله ليتمكن من الاستمتاع بفيها وكذا لو تزوج مسلمة تعتقد إباحة يسير النبيذ (واجتناب المحرمات) كالسكر لأنه واجب عليها لا ما دونه نص عليه وتمنع من دخول كنيسة وبيعة لاشد الزنار ولا يشتريه لها نص عليه (وأخذ الشعر الذي تعافه

النفس) كشعر العانة إذا طال رواية واحدة ذكره القاضي وكذا الأظفار

[ج ٧ - ص ١٩٥]

فإن طالا قليلا بحيث لا تعافه النفس فوجهان وهل له منعها من أكل ذي رائحة كريهة كبصل وكراث فيه وجهان والصحيح تمنع (إلا الذمية فله إجبارها على الغسل من الحيض) والنفاس على الأصح لأن إباحة الوطء تقف عليه والثانية لا تجبر على ذلك فعلى ذلك يطأ بدونه (وفي سائر) أي باقي (الأشياء روايتان) أصحهما أنها تجبر لأن كمال الاستمتاع يقف عليه إذ النفس تعاف وطء من عليها غسل أو شربت مسكرا أو لها شعرة والثانية لا تجبر لأن غسل الجنابة والنجاسة واجتناب المحرم عندنا غير واجب عليها وإزالة الشعر غير مشروع عندنا إلا شعر العانة إذا خرج عن العادة فله إجبارها عليه رواية واحدة ذكره في المغني و الشرح وفي التن والاستحداد وتقليم الأظفار وجهان قال القاضي له إجبارها على الاستحداد إذا طال الشعر

فصل

(ولها عليه أن يبيت عندها ليلة من أربع) إذا كانت حرة بطلبها لما روى كعب بن سور أنه كان جالسا عند عمر بن الخطاب فجاءته امرأة فقالت يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي والله إنه ليبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما فاستغفر لها وأثنى عليها واستحيت المرأة وقامت راجعة فقال كعب يا أمير المؤمنين هلا أعديت المرأة على زوجها فقال وما ذاك فقال إنها جاءت تشكوه إذا كان هذا حاله في العبادة فمتى يتفرغ لها فبعث عمر إلى زوجها وقال لكعب اقض بينهما فإنك فهمت

من أمرها ما لم أفهمه قال فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن فأقضي له بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن ولها يوم وليلة فقال عمر والله ما رأيك الأول بأعجب إلي من الآخر [ج ٧ - ص ١٩٦]

اذهب فأنت قاض على البصرة وفي لفظ قال عمر القاضي أنت رواه سعيد ثنا خالد بن عبد الله عن حصين عن عامر الشعبي وهذه قضية اشتهرت ولم تنكر فكانت كالإجماع يؤيده قوله عليه السلام لعبد الله بن عمرو بن العاص فإن لجسدك عليك حقا ولزوجك عليك حقا متفق عليه ولأنه لو لم يجب لها حق لملك الزوج تخصيص إحدى زوجاته به كالزيادة في النفقة على قدر الواجب (وإن كانت أمة فمن كل ثمان) اختاره المؤلف وجزم به في التبصرة لأنها على النصف من الحرة لأن زيادتها على ذلك تحل بالتنصيف وزيادة الحرة على ليلة من أربع زيادة على الواجب فتعين ما ذكرناه (وقال أصحابنا) منهم صاحب المحرر و الوجيز وقدمه في الفروع (من كل سبع) لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معهما ثلاث حرائر لهن ست ولها السابعة قال في المغني و الشرح والأول أولى أي لها ليلة من ثمان لتكون على النصف من الحرة فإن حقها من كل ثمان ليلتان فلو كان للأمة ليلة من سبع لزاد على النصف ولم يكن للحرة ليلتان ولها ليلة ولأنه إذا كان تحته ثلاث حرائر وأمة ولم يرد أن يزيد لهن على الواجب فقسم بينهن سبعا فما يصنع في الليلة الثامنة إن أوجبنا عليه مبيتها عند الحرة فقد زاد على الواجب وإن باتها عند الأمة جعلها كالحرة ولا سبيل إليه وعلى ما اختاره تكون هذه الليلة الثامنة له إن أحب انفرد بها فيها وإن أحب بات عند الأولى ستا إبقاء للقسم (وله الانفراد بنفسه فيما بقي) فإن كان تحته حرة وأمة قسم لهن ثلاث ليال من ثمان وله الانفراد في خمس

وإن كان تحته حرتان وأمة فلهن خمس وله ثلاث وإن كان تحته

حرتان وأمتان فلهن ست وله ليلتان وإن كانت أمة فلها ليلة وله سبع وعلى قول الأصحاب لها ليلة وله ست ولكن قال أحمد ما أحب أن يبيت وحده إلا أن يضطر وقاله في سفره وحده وعنه لا يعجبني وعن أبي هريرة مرفوعا أنه لعن راكب الفلاة وحده والبائت وحده رواه أحمد وفيه طيب بن محمد قيل لا يكاد يعرف وله مناكير وذكره ابن حبان في الثقات

(و) يجب (عليه أن يطأ في كل أربعة أشهر مرة إن لم يكن عذر) على المذهب لأنه لو لم يكن واجبا لم يصر باليمين على تركه واجبا كسائر ما لا يجب ولأن النكاح شرعه لمصلحة الزوجين ورفع الضرر عنهما وهو مفض إلى دفع ضرر الشهوة عن المرأة كإفضائه إلى رفعه عن الرجل ويكون الوطء حقا لهما جميعا ولأنه لو لم يكن لها فيه حق لما وجب استئذانها في العزل كالأمة وشرط المدة ثلث سنة لأن الله قدر في حق المؤلي ذلك فكذا في حق غيره وأن لا يكون عذر فإن لم يكن لمرض ونحوه لم يجب عليه من أجل عذره (وإن سافر عنها) لعذر وحاجة سقط حقها من القسم والوطء وإن طال سفره بدليل أنه لا يفسخ نكاح المفقود إذا ترك لامرأته نفقة وإن لم يكن عذر مانع من الرجوع فإن أحمد ذهب إلى توقيته بستة أشهر ونبه عليه بقوله (أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك) لما روى أبو حفص بإسناده [ج ٧ - ص ١٩٨]

عن زيد بن أسلم قال بينا عمر بن الخطاب يحرس المدينة فمر بامرأة في بيتها وهي تقول % تطاول هذا الليل واسود جانبه % وطال على أن لا خليل ألاعبه % % فوالله لولا خشية الله والحيا % لحرك من هذا السرير جوانبه %

فسأل عنها فقيل له فلانة زوجها غائب عنها في سبيل الله فأرسل إليها امرأة تكون معها وبعث إلى زوجها فأقفله ثم دخل على حفصة فقال يا بنية كم تصبر المرأة عن زوجها فقالت سبحان الله مثلك يسأل مثلي عن هذا فقال لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك فقالت خمسة أشهر ستة أشهر فوقت للناس في مغازيهم ستة أشهر يسيرون شهرا ويقيمون أربعة أشهر ويرجعون في شهر وسئل أحمد كم للرجل أن يغيب عن أهله قال بروى ستة أشهر وقد يغيب أكثر من ذلك لأمر لا بد له منه ويلحق بذلك الحج وطلب رزق محتاج إليه نص عليه (إن لم يكن عذر) يعني إذا كان له عذر لا يلزمه القدوم لأن صاحب العذر يعذر من أجل عذره (فإن أبى شيئا من ذلك ولم يكن عذر فطلبت الفرقة فرق بينهما) ولو قبل الدخول نص عليه لأنه في معنى مؤل قال أحمد في رواية ابن منصور في رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها هل يجبر عليه قال اذهب إلى أربعة أشهر إن دخل بها وإلا فرق بينهما وعنه لا يفرق وفي المغني هو ظاهر قول أصحابنا وقاله أكثر الفقهاء (لأنه لو ضربت له المدة لذلك وفرق بينهما لم

يكن للإيلاء أثر) وقيل إن غاب أكثر من ذلك لغير عذر راسله الحاكم فإن أبى أن يقدم فسخ نكاحه ولا يجوز [ج ٧ - ص ١٩٩]

الفسخ إلا بحكم الحاكم لأنه مختلف فيه (وعنه ما يدل على أن الوطء غير واجب فيكون هذا كله غير واجب) لأنه حق له فلم يجب عليه كسائر حقوقه والأولى خلافها وفي الترغيب ذكر القاضي وابن عقيل أنه يلزم من البيتوتة بما يزول معه ضرر الوحشة ويحصل معه الأنس المقصود بالزوجية فلا توقيت فيجتهد الحاكم وفي المغني في امرأة من علم خبره كأسير ومحبوس لها الفسخ بتعذر النفقة من ماله إجماعا وإلا فلا وإن تعذر الوطء لعجز كالنفقة وأولى للفسخ يتعذر الإيلاء وقاله أبو يعلى الصغير

(ويستحب أن يقول عند الجماع بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا) لقوله تعالى ﴿ وقدموا لأنفسكم ﴾ قال عطاء هو التسمية عند الجماع ولما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان متفق عليه ويستحب تغطية رأسه عنده وعند تخليه ذكره جماعة وأن لايستقبل القبلة وقيل يكره استقبالها قال في رواية عبد الله إن عطاء كره ذلك (ولا يكثر الكلام حال الوطء) لما روى قبيصة بن ذؤيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء فإنه يكون منه الخرس والفأفاء رواه أبو حفص وبأنه يكره الكلام حالة البول والجماع في معناه بل أولى منه (ولا ينزع إذا فرغ قبلها حتى تفرغ) لما روى أنس بن مالك مرفوعا قال إذا جامع الرجل أهله فليصدقها ثم إذا قضى حاجته

فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها رواه أبو حفص العكبري ولأن في ذلك

[ج ٧ - ص ٢٠٠]

ضررا عليها ومنعا لها من قضاء شهوتها وكما يكره متجردين وفي المستوعب لا سترة بينهما

فائدة يستحب له أن يلاعب امرأته عند الجماع لتنهض شهوتها فتنال من لذة الجماع مثل ما ناله وأن تناوله خرقة بعد فراغه ليتمسح بها وهو مروي عن عائشة

(وله الجمع بين وطء نسائه وإمائه بغسل واحد) لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة بغسل واحد رواه أحمد والنسائي ولأن حدث الجنابة لا يمنع الوطء بدليل إتمام الجماع (ويستحب الوضوء عند معاودة الوطء) نص عليه لما روى أبو سعيد مرفوعا إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ رواه مسلم ورواه ابن خزيمة والحاكم وزادا فإنه أنشط للعود فإن اغتسل بين الوطأين فهو أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو أزكى وأطيب وأطهر رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي رافع

(ولا يجوز له الجمع بين زوجتيه في مسكن واحد) صغيرا كان أو كبيرا لأن اجتماعهما يثير العداوة والغيرة وينشر الخصومة والمقاتلة (إلا برضاهما) لأن الحق لهما فلهما حق المسامحة بتركه كبيتوتته بينهما في لحاف واحد وجوز في المغني و الترغيب جعل كل واحدة في بيت مسكن مثلها وفي الرعاية وقيل يحرم مع اتحاد المرافق وأما جمع زوجته

وسريته فيه فيمنع منه إلا برضى الزوجة فقط لثبوت حقها كالجماع والسرية لا حق لها في الاستمتاع [ج ٧ - ص ٢٠١]

مسألة يجوز نوم الرجل مع زوجته بلا جماع بحضرة محرمها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم (ولا يجامع إحداهما بحيث تراه الإخرى أو غيرها) غير طفل لا يعقل أو يسمع حسهما ولو رضيتا وذكر المؤلف أن ذلك حرام لأن فيه دناءة وسقوط مروءة وربما كان وسيلة إلى وقوع الرائية في الفاحشة لأنها قد تثور شهوتها بذلك قال أحمد في الذي يجامع امرأته والأخرى تسمع قال كانوا يكرهون الرجس وهو الصوت الخفي (ولا يحدثهما بما جرى بينهما) لأنه سبب لإثارة الغيرة وبغض إحداهما الأخرى وحرمه في الغنية والآدمي قال في الفروع وهو أظهر وحرم في أسباب الهداية إفشاء السر وقيده في الرعاية بالمضر ولأحمد ومسلم من حديث أبي سعيد إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه

(وله منعها من الخروج عن منزله) إلى مالها منه بد سواء أرادت زيارة والدتها أو حضور جنازة أحدهما لما روى أنس أن رجلا منع زوجته الخروج فمرض أبوها فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها اتقي الله ولا تخالفي زوجك فمات أبوها فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في حضور جنازته فقال لها كالأول فأوحى الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني قد غفرت لها بطاعة زوجها رواه ابن بطة ولأن حق الزوج واجب فلا يجوز تركه بما ليس بواجب فلو خرجت بلا إذنه حرم ولا

تستحق نفقة ونقل أبو طالب إذا قام بحوائجها وإلا لابد لها قال الشيخ تقي الدين فيمن حبسته بحقها إن خاف خروجها بلا [ج ٧ - ص ٢٠٢]

إذنه أسكنها حيث لا يمكنها فإن لم يكن له من يحفظها غير نفسه حبست معه فإن عجز عن حفظها أو خيف حدوث شر أسكنت في رباط ونحوه ومتى كان خروجها مظنة للفاحشة صار حقا لله يجب على ولي الأمر رعايته

(فإن مرض بعض محارمها أو مات استحب له أن يأذن لها في الخروج إليه) لما في ذلك من صلة الرحم وفي منعها قطيعة الرحم وحمل لها على مخالفته وأوجبه ابن عقيل للعيادة وقيل أو نسيب وقيل لها زيارة أبويها ككلامهما ولا يملك منعها من زيارتها في الأصح ولا يلزمها طاعة أبويها في فراق وزيارة ونحوه بل طاعة زوجها أحق

فرع ليس عليها طحن وعجن وخبز نص عليه خلافا للجوزجاني وقاله أبو بكر بن أبي شيبه لأنه عليه السلام قضى على فاطمة ابنته بخدمة البيت وعلى علي ما كان خارج البيت رواه الجوزجاني من طرق وأجيب بأن المعقود عليه من جهتها الاستمتاع فلا يلزمها غيره كسقي دوابه وأوجب الشيخ تقي الدين المعروف مثلها لمثله وقال ابن حبيب في الواضحة إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على فاطمة بخدمة البيت وقال أبو ثور عليها أن تخدمه في كل شيء

(ولا تملك المرأة إجارة نفسها للرضاع والخدمة بغير إذن زوجها) لأنه يملك الاستمتاع بها وكونها تملك ذلك يؤدي إلى فوات حقه فلم يملكه كما

لا تملك منعه من الوطء فلو فعله بإذنه جاز فإن أجرت نفسها للرضاع ثم تزوجت صح العقد ولم يملك الزوج فسخ الإجارة ولا منعها من الرضاع حتى تنقضي المدة لأن منافعها ملكت بعقد سابق على نكاحه أشبه بيع

[ج ٧ - ص ٢٠٣]

المستأجرة وقيل له الفسخ إن جهله وله الوطء وقيل لا إن ضر بلبن (وله أن يمنعها من رضاع ولدها) لأن إرضاعه ليس بواجب عليها وحق الزوج واجب لأن عقد النكاح يقتضي ملكه للاستمتاع في كل زمان سوى أوقات الصلوات والرضاع يفوته عليه وظاهره سواء كان منه أو من غيره وهو أحد الوجهين فيما إذا كان منه وهو ظاهر كلام القاضي لأنه يخل باستمتاعه والثاني ليس له منعها منه وصرح به المؤلف في النفقات لقوله تعالى ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن ﴾ وهو خبر بمعنى الأمر وهو عام في كل والدة وحكم ولد غيرها كذلك (إلا أن يضطر إليها وتخشى عليه) بأن لا يوجد من ترضعه أو لا يقبله من غيرها لأنها حالة ضرورة وحفظ لنفس الولد فقدم على حق الزوج كتقديم المضطر على المالك حيث لم يكن به مثل ضرورته

فصل في القسم

القسم بفتح القاف مصدر قسمت الشيء وأما بالكسر فهو النصيب (و) واجب (على الرجل أن يساوي بين نسائه في القسم) لا نعلم فيه خلافا لقوله تعالى ﴿ وعاشروهن بالمعروف ﴾ وليس مع الميل معروف لقوله تعالى ﴿ فلا تميلوا كل الميل ﴾ وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني

القلب رواهما الخمسة ولفظهما لأبي داود وخرج منه الطفل

[ج ٧ - ص ٢٠٤]

(وعماد القسم الليل) لقوله تعالى ﴿ وجعل الليل سكنا ﴾ ولقوله تعالى (ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله لأن الليل للسكن والنهار للمعاش (إلا لمن معيشته بالليل كالحارس) فإنه يقسم بين نسائه النهار ويكون الليل في حقه كالنهار في حق غيره لأن النهار يدخل في القسم تبعا بدليل أن سودة وهبت يومها لعائشة متفق عليه

فرع له أن يأتيهن وأن يدعوهن إلى منزله ويسقط حق ممتنعه وله دعاء البعض وقيل يدعو الكل أو يأتي الكل فعلى هذا ليست الممتنعة ناشزة والحبس كغيره إلا أنه إن دعاهن لم يلزم ما لم يكن سكن مثلهن

(وليس له البداءة بإحداهن ولا السفر بها إلا بقرعة) لأن البداءة بها تفضيل لها والتسوية واجبة لأنهن متساويات في الحق ولا يمكن الجمع بينهن فوجب المصير إلى القرعة لأنه عليه السلام كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فمن خرج سهمها خرج بها معه متفق عليه وظاهره لا يشترط كونه مباحا بل يشترط كونه مرخصا وقال أكثر العلماء لا يجوز إلا برضاهن أو قرعة (فإذا بات عندها بقرعة أو غيرها) أتم وقضى واختار المؤلف لا زمن سيره (لزمه المبيت عند الثانية) لتعين حقها فإن كانتا اثنتين كفاه قرعة واحدة ويصير في الليلة الثانية إلى الثانية بغير قرعة لأنه حقها (وليس عليه التسوية بينهن في الوطء بل يستحب) لا نعلم خلافا

أنه لا يجب التسوية بينهن في الجماع لأن طريقه الشهوة والميل وإن قلبه قد يميل إلى إحداهن قال [ج ٧ - ص ٢٠٥]

تعالى ﴿ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ﴾ وكالتسوية بين دوابه وكالنفقة والكسوة والسكنى إذا قام بالواجب عليه نصا قال الشيخ تقي الدين يقسم في النفقة والكسوة ونصه لا بأس وقال في الجماع لا ينبغي أن يدعه عمدا يبقى لنفسه لتلك ليلة وليلة وقال القاضي وغيره أو ثلاثا ثلاثا

(ويقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين) لقول علي إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين رواه الدار قطني واحتج به أحمد لأن الحرة حظها في الإيواء أكثر وتخالف النفقة والكسوة فإنه مقدر بالحاجة وقسم الابتداء شرع ليزول الاحتشام من كل منها (وإن كانت كتابية) يعني أن الحرة الكتابية كالحرة المسلمة وصرح به في المغني والشرح وحكاه ابن المنذر إجماعا لأن القسم من حقوق الزوجية فاستويا فيه كالنفقة وتفارق الأمة لأنه لايتم تسليمها ولا يحصل لها الإيواء التام بخلاف الحرة والمعتق بعضها بالحساب

فرع عتقت أمة في نوبتها أو نوبة حرة مسبوقة فلها قسم حرة وفي نوبة حرة سابقة قيل يتم للحرة على حكم الرق وقيل يستويان بقطع أو استدراك وفي (المغني) و (الترغيب) وإن عتقت بعد نوبتها اقتصرت على يومها زاد في الترغيب بدأ بها أو بالحرة ويطوف بمجنون مأمون وله وجوبا لا بطفل

ويحرم تخصيص بإفاقته وإن أفاق في نوبة واحدة ففي قضاء يوم جنونه للأخرى وجهان [ج ٧ - ص ٢٠٦]

(ويقسم للحائض والنفساء والمريضة والمعيبة والرتقاء) ومظاهر منها وصغيرة ممكن وطؤها لأن القصد السكن والإيواء والأنس وحاجتهن داعية إلى ذلك فأما المجنونة فإن خيف منها فلا قسم لها وإلا فهي كالعاقلة ذكره في الشرح وظاهره أن المريض والمجبوب والعنين والخصي يقسم لأنه للأنس وذلك حاصل ممن لا يطأ فإن شق ذلك عليه استأذنهن في الكون عند إحداهن فإن لم يأذن له أقام عند إحداهن بقرعة أو اعتزلهن جميعا (فإن دخل في ليلتها إلى غيرها لم يجز) لأنه ترك الواجب عليه (إلا لحاجة داعية) ككون ضرتها منزولا بها فيريد أن يحضرها أو توصي إليه مما لا بد منه عرفا لأن ذلك حالة ضرورية وحاجة فأبيح به ترك الواجب إلى قضائه في وقت آخر وظاهره أنه يدخل إليها نهارا وإن لم يكن حاجة داعية وفي المغني والشرح أنه يجوز لحاجة كدفع نفقة وعيادة وفي الترغيب فيهما لحاجة ماسة أو لمرض فيداويها وفي قبلة ونحوها نهارا وجهان (فإن لم يلبث عندها لم يقض) لأنه لا فائدة فيه لقلته (وإن لبث أو جامع لزمه أن يقضي مثل ذلك من حق الأخرى) لأن التسوية واجبة ولا يحصل إلا بذلك وظاهره أنه يلزمه القضاء ولو جامعها في الزمن اليسير وهو الأصح فيدخل على المظلومة في ليلة المجامعة فيجامعها ليعدل بينهما والثاني لا يلزمه القضاء لأن الوطء لا يستحق في القسم ولا يقضي ليلة صيف عن شتاء وله قضاء أول الليل عن آخره وعكسه وقيل يتعين زمنه وهو ظاهر كلامه

فرع إذا خرج في ليلة إحداهن أول الليل وآخره الذي جرت العادة

[ج ٧ - ص ٢٠٧]

بالانتشار فيه والخروج إلى الصلاة جاز وإن خرج لغير ذلك ولم يلبث لم يقض وإن لبث قضى مطلقا ويستحب أن يقضي لها في مثل ذلك الوقت فإن قضاه في غيره من الليل جاز في الأصح لأنه قد قضى بقدر ما فاته من الليل والثاني لا لعدم المماثلة

(وإن أراد النقلة من بلد إلى بلد وأخذ إحداهن معه والأخرى مع غيره لم يجز إلا بقرعة) وجملته أن الزوج إذا أراد النقلة بنسائه إلى بلد آخر وأمكنه استصحاب الكل في سفره فعلى ذلك ليس له إفراد إحداهن به لأن هذا السفر لا يختص بواحدة فإن خص بعضهن قضى للباقيات كالحاضر وإن شق عليه صحبة الجميع وبعث بهن جميعا مع غيره ممن هو محرم لهن جاز بغير قرعة فإن أفرد بعضهن بالسفر معه لم يجز إلا بقرعة وهي مسألة المتن ومتى سافر بأكثر من واحدة سوى بينهن كالحضر فإذا وصل البلد الذي انتقل إليه فأقامت معه فيه قضى للباقيات مدة كونها معه في البلد خاصة لأنه صار مقيما (ومتى سافر بها بقرعة لم يقض) أي للحاضرات بعد قدومه في قول أكثرهم لحديث عائشة ولم يذكر قضاء ولأن المسافرة اختصت بمشقة السفر فاختصت بالقسم (وإن كان بغير قرعة لزمه القضاء للأخرى) لأنه خص بعضهن بمدة على وجه يلحقه التهمة فيه فلزمه القضاء كما لو كان حاضرا وعلى هذا يقضي مدة غيبته ما لم تكن الضرة رضيت بسفرها وينبغي أن يقضي منها ما أقام منها لمبيت ونحوه ويقضي مع قرعة ما تعقبه السفر أو تخلله من إقامة

تنبيه إذا خرجت القرعة لإحداهن لم يجب عليه السفر بها وله تركها

[ج ٧ - ص ٢٠٨]

والسفر وحده لأن القرعة إنما تعين من يستحق التقديم ولهذا يمنع من السفر بغيرها وإن أبت السفر معه سقط حقها إذا رضي الزوج وإن أبى فله إكراهها على السفر معه فإن رضي الزوجات بسفر واحدة من غير قرعة جاز ولا فرق بين السفر الطويل والقصير لعموم الخبر والمعنى ذكره في الشرح وغيره وذكر القاضي احتمالا أنه يقضي للبواقي في السفر القصير وجوابه بأنه سافر بها بقرعة فلم يقض كالطويل (وإن امتنعت من السفر معه أو من المبيت عنده أو سافرت بغير إذنه سقط حقها من القسم) بغير خلاف نعلمه لأنها عاصية بمنع نفسها منه فيسقط حقها كالناشزة وكذا لا نفقة لها قاله في الرعاية والفروع وقيل يجب لها النفقة بالوطء (وإن أشخصها هو) بأن بعثها في حاجة أو أمرها بالنقلة من بلدها ذكره في المغني والشرح (فهي على حقها من ذلك) أي من القسم والنفقة لأنه ما فات بسبب من جهتها وإنما فات بتفويته فلم يسقط حقها كما لو أتلف المشتري المبيع لم يسقط حق البائع من تسليم ثمنه إليه فعلى هذا يقضي لها بحسب ما أقام عند ضرتها وإن سافرت معه فهي على حقها منها جميعا (وإن سافرت لحاجتها) كسفرها لزيارة أو حج تطوع أو عمرة (بإذنه فعلى وجهين) أحدهما يسقطان ذكره الخرقي والقاضي لأن القسم للأنس والنفقة للتمكين وقد تعذر ذلك بسبب من جهتها والثاني لا يسقطان ذكره أبو الخطاب لأنها سافرت بإذنه أشبه ما لو سافرت معه وقيل يسقط

القسم وجها واحدا لأنه لو سافر عنها لسقط قسمها والتعذر من جهته فإذا تعذر من جهتها كان أولى [ج ٧ - ص ٢٠٩]

(وللمرأة أن تهب حقها من القسم) بلا مال) لبعض ضرائرها (لفعل سودة بأنها وهبت لعائشة يومها فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة متفق عليه (بإذنه) لأن حقه على الواهبة ثابت فلا ينتقل إلى غيرها إلا برضاه وظاهره ولو أبت الموهوب لها أي لا يشترط رضاها وليس لنا هبة يقبل فيها غير الموهوب له مع تأهله للقبول إلا هذه ثم إن كانت ليلة الواهبة لا تلي ليلة الموهوبة لم تجز الموالاة بينهما لأن الموهوبة قائمة مقام الواهبة فلم يجز تغييرها عن موضعها وذكر جماعة وإذن سيد أمة لأن ولدها له (وله) أي للزوج (الرجوع) لأن الحق لها فلمن نقلته إليه انتقل (فيجعله لمن شاء منهن) لأنه قائم مقام الواهبة فالخيرة له كهي وفي الترغيب لو قالت خص بها من شئت الأشبه أنه لا يملكه لأنه يورث الغيظ بخلاف تخصيصها واحدة (فمتى رجعت في الهبة عاد حقها) لأنها هبة لم تقبض والمراد به العود في المستقبل لا فيما مضى لأنه قد اتصل به القبض فعلى هذا إذا رجعت في أثناء ليلتها لزم الزوج الانتقال إليها وإن لم يعلم حتى أتم الليلة لم يقض لها شيئا لأن التفريط منها

فرع إذا بذلت ليلتها بمال لم يصح لأنها ليست مالا ولا منفعة يستحق بها المال فإن كان العوض غير المال كإرضاء زوجها عنها أو غيره جاز ولها بذل قسم ونفقة وغيرهما ليمسكها والرجوع ليجدد الحق وفي الهدي يلزم ولا مطالبة لأنها معاوضة كما يلزم ما صالح عليه من الحقوق

(ولا قسم عليه في ملك يمينه) بل يطأ من شاء منهن متى شاء لقوله تعالى [ج ٧ - ص ٢١٠]

﴿ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ﴾ وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم مارية وريحانة فلم يكن يقسم لهما ولأن الأمة لا حق لها في الاستمتاع ولذلك لا يثبت لها الخيار بكون السيد مجبوبا أو عنينا ولا تضرب لها مدة الإيلاء وظاهره وإن أخذ من زمن زوجاته وفي المحرر لكن يسوي في حرمانهن (وتستحب التسوية بينهن) لأنه أطيب لقلوبهن وأبعد من النفرة والبغضة (و) عليه (أن لا يعضلهن إن لم يرد الاستمتاع بهن) أي إذا احتاجت الأمة إلى النكاح وجب عليه إعفافها إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها لأن إعفافهن وصونهن عن احتمال الوقوع في المحظور واجب

فصل

(وإذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا) لما روى أبو قلابة عن أنس قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه ولفظه للبخاري وخصت البكر بزيادة لأن حياءها أكثر والثلاث مدة مغتفرة في الشرع والسبع لأنها أيام الدنيا وما زاد عليها يتكرر وحينئذ يقطع الدور (فإن أحبت) وقيل أو هو (أن يقيم عندها سبعا فعل وقضاهن للبواقي) لما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال [ج ٧ - ص ٢١١]

إنه ليس بك هوان على أهلك وإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي رواه مسلم قال ابن عبد البر والأحاديث المرفوعة على ذلك وليس مع من خالف حديث مرفوع والحجة مع من أدلى بالسنة وفي الروضة الفاضل للبقية والمذهب أن يقضي السبع لأنها اختارتها فسقط حقها وظاهره أن الأمة كالحرة ونصره في الشرح وغيره لعموم الأحاديث ولأنها تراد للأنس وإزالة الاحتشام فاستويا فيه كالنفقة وقيل هي على نصف الحرة كسائر القسم

(وإن زفت إليه امرأتان) في ليلة واحدة أو في حق عقد واحدة كره ذلك لأنه لا يمكن الجمع بينهما في إيفاء حقهما وتستضر التي يؤخر حقها وتستوحش (قدم السابقة منهما) دخولا لأن حقها سابق (ثم أقام عند الأخرى) لأن حقها واجب عليه ترك العمل به في المدة الأولى لأنه عارضه ورجح عليه فإذا زال العارض وجب العمل بالمقتضى (ثم دار) ليأتي بالواجب عليه من حق الدور (فإن زفتا معا قدم إحداهما بالقرعة) لأنهما استويا في سبب الاستحقاق والقرعة مرجحة عند التساوي وفي التبصرة يبدأ بالسابقة بالعقد وإلا أقرع (ثم أقام عند الأخرى) لما ذكرنا (وإن أراد السفر فخرجت القرعة لإحداهما سافر بها ودخل حق العقد في قسم السفر) لأنه نوع قسم يختص بها (فإذا قدم بدأ بالأخرى فوفاها حق العقد) في الأصح لأنه حق وجب لها قبل سفره لم يؤده فلزمه قضاؤه كما لو لم يسافر بالأخرى معه [ج ٧ - ص ٢١٢]

والثاني لا يقضيه لئلا يكون تفضيلا لها على التي سافر بها ولأن الإيواء في الحضر أكثر فيتعذر قضاؤه وقيل يستأنف قضاء العقد لكل منهما ولا يحتسب على المسافرة بمدة سفرها كما لا يحتسب به عليها فيما عدا حق العقد قال في المغني والشرح وهذا أقرب إلى الصواب من إسقاط حق العقد الواجب بالشرع بغير مسقط فإن قدم من سفره قبل مدة تنقضي فيها حق عقد الأولى أتمه في الحضر وقضى للحاضرة مثله وجها واحدا

(وإذا طلق إحدى نسائه في ليلتها أتم) لأنه فوت حقها الواجب لها (فإن تزوجها بعد) أي عادت إليه برجعة أو نكاح (قضى لها ليلتها) لأنه قدر على إيفاء حقها فلزمه كالمعسر إذا أيسر بالدين

فائدة يجوز بناء الرجل بامرأته في السفر وركوبها معه على دابة بين الجيش لفعله صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي قاله بعض أصحابنا

(وله أن يخرج في نهار ليل القسم لمعاشه وقضاء حقوق الناس) لقوله تعالى ﴿ وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا ﴾ وحكم الثلاثة والسبعة التي يقيمها عند المزفوفة حكم سائر القسم فإن تعذر عليه المقام عندها ليلا لشغل أو حبس أو ترك ذلك لغير عذر قضاه لها وله الخروج إلى صلاة الجماعة وإلى ما لا بد لهما منه فإن أطال قضاه ولا يقضي اليسير

فرع قسم لاثنتين من ثلاث ثم يجدد حق رابعة فإن رجعت في هبة أو عن نشوز أو نكاح وفاها حق عقده ثم ربع الزمن المستقبل للرابعة

[ج ٧ - ص ٢١٣]

وبقيته للثالثة فإذا كمل الحق استأنف التسوية ولو بات ليلة عند إحدى امرأتيه ثم نكح وفاها حق عقده ثم ليلة للمظلومة ثم نصف ليلة للثالثة ثم يبتدئ واختار المؤلف لا يبيت نصفها بل ليلة لأنه حرج وفي الترغيب لو أبان المظلومة ثم نكحها وقد نكح جديدات تعذر القضاء

فصل في النشوز

وهو كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه وسوء عشرته يقال نشزت المرأة على زوجها فهي ناشزة وناشز ونشز عليها زوجها إذا جفاها وأضر بها (وهو معصيتها إياه مما يجب عليها) من طاعته مأخوذ من النشز وهو الارتفاع فكأنها ارتفعت وتعالت عما يجب عليها من طاعته (وإذا ظهر منها أمارات النشوز بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة متكرهة وعظها) بأن يذكر لها ما أوجب الله تعالى عليها من الحق وما يلحقها من الاثم بالمخالفة وما يسقط بذلك من النفقة والكسوة وما يباح له من هجرها وضربها لقوله تعالى ﴿ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن ﴾ فإن أصرت ناشزة بأن تعصيه وتمتنع من فراشه أو تخرج بغير إذنه (هجرها في المضجع) بفتح الجيم والمراد أن يهجر فراشها فلا يضاجعها فيه (ما شاء) لقوله تعالى ﴿ واهجروهن في المضاجع ﴾ وقال ابن عباس لا تضاجعها في فراشك لأن [ج ٧ - ص ٢١٤]

القرآن مطلق فلا يقيد بغير دليل وفي التبصرة والغنية والمحرر ثلاثة أيام لأن الهجران فوق ذلك حرام (وفي الكلام ما دون ثلاثة أيام) لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فلم يدخل عليهن شهرا متفق عليه وفي الواضح يهجرها في الفراش فإن أضاف إليه الهجر في الكلام ودخوله وخروجه عليها جاز مع الكراهة (فإن أصرت فله أن يضربها ضربا غير مبرح) أي غير شديد لقوله تعالى ﴿ واضربوهن ﴾ ولا يبرح بالضرب للخبر الصحيح قال الخلال سألت أحمد بن يحيى ثعلبا عن قوله ضربا غير مبرح أي غير شديد وهو عشرة أسواط فأقل قاله الأصحاب وهو حسبه ذكره في الانتصار لكن يمنع منها من علم بمنعه حقها حتى يؤديه وعليه اجتناب المواضع المخوفة والمستحسنة لأن المقصود التأديب وعنه له ضربها بأول النشوز للآية والخبر وظاهر المذهب لا لأن المقصود بهذه العقوبات زجرها عن المعصية في المستقبل فيبدأ بالأسهل فالأسهل كإخراج من هجم بمنزله وظاهره أن ليس لنا موضع يضرب المستحق من منعه حقه غير هذا والعبد يمتنع من حق سيده ولا يملك تعزيرها في حق الله نقل مهنا هل يضربها على ترك زكاة قال لا أدري وفيه ضعف لأنه نقل عنه يضربها على فرائض الله تعالى قاله في الانتصار وذكر غيره يملكه ولا ينبغي سؤاله لم ضربها قاله أحمد لنهيه عليه السلام عن ذلك رواه أبو

داود وفي الترغيب وغيره والأولى تركه إبقاء للمودة والأولى أن لا يتركه عن الصبي لإصلاحه [ج ٧ - ص ٢١٥]

(فإن ادعى كل واحد ظلم صاحبه له أسكنهما الحاكم إلى جانب ثقة يشرف عليهما ويلزمها الإنصاف) لأن ذلك طريق إلى الإنصاف فتعين فعله كالحكم بالحق ويلزمه أن يكشف عنه كما يكشف عن عدالة وإفلاس من خبرة باطنة قاله في الترغيب (فإن خرجا إلى الشقاق والعداوة بعث الحاكم حكمين حرين مسلمين عدلين) مكلفين لأن هذه شروط العدالة سواء قلنا هما حكمان أو وكيلان لأن الوكيل إذا كان متعلقا بنظر الحاكم لم يجز إلا أن يكون عدلا كما لو نصب وكيلا لصبي أو مفلس ويشترط ذكوريتهما ذكره في المغني وغيره لأنه يفتقر إلى الرأي والنظر وصريحه يقتضي اشتراط الحرية وهو الأصح لأن العبودية نقص وفي المغني الأولى إن كانا وكيلين لم يعتبر لأن توكيل العبد جائز بخلاف الحكم وظاهره أنه لا يشترط فيه الفقه وهو وجه وفي الكافي متى كانا حكمين اشترط كونهما فقيهين وإن كانا وكيلين جازا أن يكونا عاميين وفي الترغيب لا يعتبر اجتهاد وهو ظاهر وإن مثله ما يفوضه الحاكم من معين جرى كقسمة (والأولى أن يكونا من أهلهما برضاهما) وتوكيلهما لقوله تعالى ﴿ وإن خفتم ﴾ الآية ولأنهما أشفق وأعلم بالحال ويجوز أن يكونا من غير أهلهما لأن القرابة ليست شرطا في الحكم ولا الوكالة وظاهره بأن الحاكم ليس له أن يبعثهما بغير رضاهما على المذهب لأنه حق لهما فلم يجز لغيرهما التصرف إلا بالوكالة (فيكشفان عن حالهما ويفعلان ما يريانه من جمع وتفريق بينهما بطلاق أو خلع) فما فعلا [ج ٧ - ص ٢١٦]

من ذلك لزمهما والأصل فيه الآية الكريمة لكن لا يصح منهما إبراء لأنهما وكيلان فيما يتعلق بالإصلاح لا في إسقاط الحقوق وإن أبرأه وكيلهما برئ في الخلع فقط وإن شرطا ما لا ينافي نكاحا لزم وإلا فلا كترك قسم أو نفقة ولمن رضي العود (فإن امتنعا من التوكيل لم يجبرا) على المشهور حتى إن القاضي في الجامع الصغير والشريف وغيرهما لم يذكروا خلافا لأنهما رشيدان والبضع حق الزوج والمال حق الزوجية فلم يجبرا على التوكيل منهما كغيرهما من الحقوق (وعنه أن الزوج إن وكل في الطلاق بعوض أو غيره ووكلت المرأة في بدل العوض برضاهما وإلا) إن أبيا ذلك (جعل الحاكم إليهما ذلك) اختاره ابن هبيرة والشيخ تقي الدين وهو ظاهر الخرقي وحينئذ لهما فعل ما رأياه بغير رضى الزوجين وروي عن علي وابن عباس لأن الله تعالى سماهما حكمين وعن عبيدة السلماني أن رجلا وامرأته أتيا عليا مع كل منهما فئام من الناس فقال علي ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فبعثوا حكمين ثم قال للحكمين هل تدريان ما عليكما من الحق إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما فقالت المرأة رضيت بكتاب الله لي وعلي وقال الرجل أما الفرقة فلا فقال علي كذبت حتى ترضى بما رضيت به رواه أبو بكر وهذا يدل على أنه أجبره على ذلك ولا يمتنع أن تثبت الولاية على الرشيد عند امتناعه من أداء الحق كالمدين الممتنع وطلاق الحاكم على المؤلي (فإن

غاب الزوجان أو أحدهما لم ينقطع نظر الحكمين على الأولى) لأن

[ج ٧ - ص ٢١٧]

الوكالة لا تبطل بالغيبة (وتنقطع على الثانية) لأنه لا يجوز الحكم للغائب وكل منهما محكوم عليه وقيل لا ينقطع عليها حكاه في المستوعب والمحرر (وإن جنا) أو أحدهما (انقطع نظرهما على الأولى) لأن الوكالة تبطل بالجنون (ولم ينقطع على الثانية) لأن الحاكم يحكم على المجنون وقيل ينقطع عليها أيضا حكاه في المغني و المحرر لأنه لا يتحقق معه بقاء الشقاق وحضور المتداعيين وهو شرط [ج ٧ - ص ٢١٨]

كتاب الخلع

يقال خلع امرأته خلعا وخالعها مخالعة واختلعت هي منه فهي خالع وأصله من خلع الثوب لأن المرأة تخلع من لباس زوجها قال تعالى ﴿ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ﴾ وهو عبارة عن فراق امرأته بعوض بألفاظ مخصوصة وفائدته تخليصها من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها

(وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل) لخلقه أو خلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك (وتخشى أن لا تقيم حدود الله في حقه فلا بأس أن تفتدي نفسها منه) لقوله تعالى ﴿ فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ ولقول ابن عباس جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقته قالت نعم فأمرها بردها وأمره ففارقها رواه البخاري وبه قال جميع الفقهاء في الأمصار إلا بكر بن عبد الله المزني فإنه لم يجزه وزعم أن آية الخلع منسوخة بقوله تعالى ﴿ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ﴾

وقال ابن سيرين وأبو قلابة لا يحل الخلع حتى يجد على بطنها رجلا لقوله تعالى ﴿ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة

والجواب عن ذلك بأنه قول عمر وعلي ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف فكان كالإجماع ودعوى النسخ لا تسمع حتى يثبت تعذر الجمع وان الآية الناسخة متأخرة ولم يثبت ذلك وظاهره أنه يباح لها أن تفتدي نفسها منه وصرح به في الوجيز والفروع والمذهب أنه يسن إجابتها إليه لأن حاجتها داعية إلى فرقته إلا أن يكون له إليها ميل ومحبة فيسن صبرها وعدم افتدائها نص عليه واختلف كلام الشيخ تقي الدين في وجوبه وألزم بعض حكام المقادسة الفضلاء به نقل أبو طالب إذا كرهته حل أن يأخذ منها ما أعطاها

(وإن خالعته لغير ذلك) أي لغير سبب مع استقامة الحال (كره ووقع الخلع) عند أصحابنا والأكثر لقوله تعالى ﴿ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ﴾ وعنه لا يجوز ولا يصح وقاله ابن عباس وخلق لقوله تعالى ﴿ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ﴾ وقوله عليه السلام أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة رواه أبو داود من حديث ثوبان وقوله عليه السلام المختلعات هن المنافقات رواه أحمد واحتج من حديث أبي هريرة قال المؤلف والحجة مع من حرمه وخصوص الآية في التحريم يجب تقديمها على عموم آية الجواز مع ما عضدها من الأخبار

فرع لا يفتقر الخلع إلى حاكم نص عليه ورواه البخاري عن عمر وعثمان لأنه معاوضة فلم يفتقر إلى سلطان كالبيع والنكاح وقال الحسن وابن

سيرين لا يجوز إلا عند السلطان وجوابه ما سبق مع أنه قطع عقد بالتراضي أشبه الإقالة (فإن عضلها) بأن ضاررها بالضرب والتضييق عليها ظلما أو منعها حقها من النفقة والقسم ونحوه (لتفتدي نفسها منه ففعلت فالخلع باطل والعوض مردود) في قول الجمهور لقوله تعالى ﴿ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ﴾ ولأنه عوض أكرهت على بذله بغير حق فكان باطلا كالثمن في البيع (والزوجية بحالها) لأن المقتضي للفرقة الخلع الصحيح ولم يوجد (إلا أن يكون طلاقا فيقع رجعيا) أي إذا لم يملك العوض وقلنا الخلع طلاق وقع الطلاق بغير عوض فإن كان أقل من ثلاث فله رجعتها لأن الرخصة إنما سقطت بالعوض فإذا سقط العوض ثبتت الرجعة إن كان بلفظ طلاق أو نيته وإلا فهو لغو وقيل يقع بائنا إن صح بلا عوض وإن قلنا هو فسخ ولم ينو به الطلاق لم يقع شيء لأن الخلع بغير عوض لا يقع على الأشهر ويخرج أنه إن أخذ منها شيئا على الوجه المذكور رده ووقع الخلع عليه إذا قلنا يقع بغير وعوض على كلامه يستثنى صور منها إذا ضربها لتركها فرضا أو على نشوزها أو منعها حقها من أجله لم يحرم خلعها ومنها إذا ضربها لسوء خلقه لايريد بذلك الفداء لم يحرم خلعها لأنه لم يعضلها ليذهب ببعض ما آتاها وهو آثم بالظلم ومنها إذا زنت فعضلها لتفتدي نفسها منه جاز وصح الخلع نص عليه لقوله تعالى ﴿ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾ والاستثناء من النهي إباحة

فرع إذا قالت بعني عبدك هذا وطلقني بألف ففعل صح وبسطت الألف على الصداق المسمى وقيمة العبد على الأشهر

(ويجوز الخلع من كل زوج يصح طلاقه مسلما كان أو ذميا) لأنه إذا ملك الطلاق بغير عوض فبالعوض أولى وفي المميز وجه وجزم ابن المنجا أنه يصح منه ومن السفيه والعبد لأن كل واحد منهم زوج يصح طلاقه فصح خلعه قياسا ويصح من أب صبي ومجنون إن صح طلاقه عليهما (فإن كان محجورا عليه دفع المال إلى وليه) كسائر حقوقه (وإن كان عبدا دفع إلى سيده) لأنه للسيد لكونه من أكساب عبده وإن كان مكاتبا دفع العوض إليه لأنه يملك أكسابه وهو الذي يتصرف لنفسه (وقال القاضي يصح القبض من كل من يصح خلعه) لأنه يصح منه أحد ركني المعاوضة وهو العقد فيصح منه قبض العوض الذي هو الركن الآخر قياسا عليه فعلى هذا يصح قبض العبد والمحجور عليه لأن من صح خلعه صح قبضه العوض كالمحجور عليه لفلس ونص عليه أحمد في العبد قال في الشرح والأولى أنه لا يجوز فإن سلمت العوض إلى المحجور عليه لم يبرأ فإن أخذه الولي منه برئت وإن سلمت العبد برئت مطلقا قال صاحب النهاية فيها والأول أصح لأن النظر له في صحة العقد دون قبضه (وهل للأب خلع زوجة ابنه الصغير أو طلاقها على روايتين) إحداهما له ذلك نصره القاضي وأصحابه لأنه يصح أن يزوجه بعوض فلأن يصح أن يطلق عليه بطريق [ج ٧ - ص ٢٢٢]

الأولى لا يقال التزويج إدخال ملك والخلع عكسه لأن الأب كامل الشفقة فلا يفعله إلا لمصلحة ولده فيه وكالحاكم يملك الطلاق على الصغير والمجنون بالإعسار والثانية وهي الأشهر لا يملكه وفاقا للأكثر لقوله عليه السلام الطلاق لمن أخذ بالساق رواه ابن ماجه والدارقطني بإسناد فيه ضعف ولأنه إسقاط لحقه فلم يملكه كالإبراء وإسقاط القصاص ولأن طريق الشهوة لا مدخل لها في الولاية وحكم المجنون كذلك وكذا سيد صغير ومجنون والأظهر جوازه إن رآه مصلحة (وليس له خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها) على المذهب لأن فيه إسقاط نفقتها وكسوتها وبدل مالها ولا حظ لها في ذلك وقيل له ذلك إذا رأى الحظ فيه كتخليصها ممن يتلف مالها ويخاف منه على نفسها وعقلها والأب وغيره في ذلك سواء إذا خالعوا في حق المجنونة والمحجور عليه لسفه أو صغر وظاهره أنه إذا خالع بشيء من ماله أنه يجوز صرح به في الشرح وغيره لأنه يجوز مع الأجنبي فمن الولي أولى (ويصح الخلع مع الزوجة) إذا كانت رشيدة (ومع الأجنبي) بغير رضى المرأة في قول أكثرهم وقال أبو ثور لا يصح فانه يبذل عوضا في مقابلة ما لا منفعة له فيه وجوابه بأنه بذل مال في إسقاط حق عن غيره فصح كما لو قال أعتق عبدك وعلي ثمنه ولأنه لو قال ألق متاعك في البحر وعلي ثمنه صح ولزمه ثمنه مع أنه لا يسقط حقا عن أحد فهنا أولى ولأنه حق على المرأة يجوز أن يسقط عنها بعوض فجاز لغيرها كالدين وقيل إن قلنا هو فسخ فلا [ج ٧ - ص ٢٢٣]

فرع إذا قالت امرأته طلقني وضرتي بألف فطلقهما وقع بهما بائنا واستحق الألف على ما ذكرته وإن طلق أحداهما فقال القاضي تطلق بائنا ويلزم الباذلة بحصتها من الألف قياس قول أصحابنا فيما إذا قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة أن لا يلزم الباذلة هنا شيء لأنه لم يجبها إلى ما سألت وإن قالت طلقني بألف على أن تطلق ضرتي أو على أن لا تطلق ضرتي فالخلع صحيح والشرط والبدل لازم

مسألة يجوز في الحيض وطهر أصابها فيه لأن تحريم الطلاق فيه ثبت دفعا لضرر تطويل العدة والخلغ يندفع به ضرر سوء العشرة وهو أعظم وأدوم فكان رفعه أولى وقيل لا يجوز وفي الواضح فيه روايتان

(ويصح بذلك العوض فيه من كل جائز التصرف) لأنه بذل عوض في عقد معاوضة أشبه البيع

فرع إذا قال طلق بنتي وأنت بريء من صداقها فطلق بانت ولم يبرأ ويرجع على الأب نص عليها لأنه غره وحمله القاضي على أن الزوج كان جاهلا بأن إبراء الأب صحيح

فإن علم أن إبراء الأب غير صحيح لم يرجع وطلاقه رجعي وقاله في الشرح وقدمه في الرعاية

وإن قال إن أبرأتني أنت منه فهي طالق فقال قد أبرأتك منه طلقت نص عليه وحمله القاضي على أنه اعتقد أن إبراء الأب صحيح

فأما إن علم أنه لا يصح فقولان [ج ٧ - ص ٢٢٤]

فلو قال طلقتها بألف من مالها وعلي دركه فطلقها بانت وغرمه الأب ولم برجع به عليها (فإن خالعت الأمة بغير اذن سيدها) فالخلع صحيح قطع به المؤلف في كتبه وهو قول الخرقي والقاضي وعامة أصحابه لأنه يصح مع الأجنبي فمع الزوجة أولى

والثاني لا يصح وقاله القاضي في المجرد والمجد لأن الخلع عقد معاوضة فلم يصح منها كالبيع والأول أولى

والخلع يفارق البيع بدليل صحته على المجهول وعلى غير عوض على قول وقيل يصح إن خالعته على شيء في ذمتها لا على عين في يدها كالبيع (على شيء معلوم كان في ذمتها) لأنه رضي بذلك (يتبع به بعد العتق وهو اختيار الخرقي جزم به في الهداية لأنه الوقت الذي يملك فيه ويرجع بقيمته أو مثله إن كان مثليا فإن كان على عين في يدها فكذلك وقياس المذهب كما قاله المؤلف أنه لا شيء له لأنه يعلم أنها أمة فقد علم أنها لا تملك العين كما لو قال خالعتك على هذا الحر فيكون راضيا بغير عوض ومقتضاه بطلان الخلع على المشهور فأما إن كان بإذن السيد فهو صحيح كاستدانتها فإن أذن لها في قدر من المال فخالعت بأكثر منه فالزيادة في ذمتها وإن أطلق الإذن اقتضى الخلع بالمسمى

فرع المكاتبة كالأمة القن سواء فيما ذكرنا (وإن خالعته المحجور عليها) لسفه أو صغر أو جنون (لم يصح الخلع) لأنه تصرف في المال وليست

من أهله فلم يصح كالهبة ونحوها وظاهره ولو أذن فيه الولي لأنه لا إذن له [ج ٧ - ص ٢٢٥]

في التبرعات والأظهر الصحة مع الإذن لمصلحة على ما ذكره (ووقع طلاقه رجعيا) لأنه طلاق لا عوض له فوجب وقوعه رجعيا لسلامته عما ينافيه وهذا إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق أو نواه به

فأما إن وقع بلفظ الفسخ أو المفاداة ولم ينو به طلاقا فهو كالخلع بغير عوض وفي المغني والشرح يحتمل أن لا يقع الخلع هنا لأنه إنما رضي به بعوض ولم يحصل له ولا أمكن الرجوع ببذله وهذا إذا كان الطلاق بغير الثلاث فإن كان بها لم يقع رجعيا لأن الثلاث لا رجعة معها فأما المحجور عليها لفلس فلا يصح بغير إذن غرمائها لأنها ممنوعة من التبرع ويصح بإذنهم لأنها من أهل التصرف ولهذا يصح تصرفها في ذمتها بخلاف المحجور عليها لحظ نفسها

(والخلع) له صريح وهو لفظ الخلع والمفاداة وكذا الفسخ في الأشهر وكناية وهو الإبانة والتبرئة وفي الروضة صريحه الخلع أو الفسخ أو الفداء أو بارئتك (طلاق) أي إذا وقع بغير الألفاظ المذكورة بغير خلاف لوجود صريحه أو كنايته مقترنة بالنية (بائن لقوله) تعالى ﴿ فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ وإنما يكون فداء إذا خرجت من قبضته وسلطانه ولو لم يكن بائنا لكانت له الرجعة وكانت تحت حكمه وقبضته لأن القصد إزالة الضرر عنها فلو جازت الرجعة لعاد الضرر (إلا أن يقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة ولا ينوي به الطلاق فيكون فسخا لا ينقص به عدد

الطلاق في إحدى الروايتين) إختارها أبو بكر وقال ابن هبيرة وهي أظهرهما وصححها في [ج ٧ - ص ٢٢٦]

المحرر وجزم بها في الوجيز وروي عن ابن عباس وطاووس وعكرمة وإسحاق واحتج ابن عباس بقوله تعالى ﴿ الطلاق مرتان ﴾ ثم قال ﴿ فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ ثم قال ﴿ فإن طلقها فلا تحل له ﴾ فذكر طلقتين والخلع وتطليقه بعدهما فلو كان الخلع طلاقا لكان أربعا ولأنها فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته فكانت فسخا كسائر الفسوخ قال الشيخ تقي الدين وعليه دل كلام أحمد وقدماء أصحابه ومراده ما قال عبد الله رأيت أبي كان يذهب إلى قول ابن عباس وابن عباس صح عنه ما أجازه المال فليس بطلاق وصح عنه أن الخلع تفريق وليس بطلاق

(وفي الأخرى هو طلاق بائن بكل حال) رواه الشافعي عن عثمان وروي عن علي وابن مسعود وقاله سعيد بن المسيب وعطاء والأكثر لكن ضعف أحمد الحديث عنهم وقال ليس في الباب أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ ولأنها بذلت العوض للفرقة والفرقة التي يملك الزوج إيقاعها هي الطلاق دون الفسخ ولأنه أتى بكناية الطلاق قاصدا فراقها فكان طلاقا كغير الخلع وفائدة الخلاف أنه إذا قلنا بأنه طلاق حسب ونقص به عدد طلاقه وإن قيل هو فسخ لم تحرم عليه وإن خالعها بمائة مرة وتعتبر الصيغة منهما فيقول خلعتك على كذا وتقول هي قبلت أو رضيت وتصح ترجمة خلع بكل لفظ طلاق من أهلها

فرع لا يحصل الخلع بمجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ الزوج قال القاضي ذهب إليه شيوخنا البغداديون وأومأ إليه أحمد وذهب أبو حفص

[ج ٧ - ص ٢٢٧]

العكبري وابن شهاب إلى وقوع الفرقة بقبول الزوج العوض وأفتى به ابن شهاب بعكبرا واعترض عليه أبو الحسين بن هرمز نقل إسحاق بن منصور قال قلت لأحمد كيف الخلع قال إذا أخذ المال فهي فرقة وعن علي من قبل مالا على فراق فهي تطليقة بائنة وجوابه بأنه تصرف في البضع بعوض فلم يصح بدون اللفظ كالنكاح والطلاق ولأن أخذ المال قبض لعوض فلم يقم بمجرده مقام الإيجاب كقبض أحد العوضين في البيع ولعل أحمد وغيره استغنى عن ذكر اللفظ لأنه معلوم

(ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجهها به) بأن يقول أنت طالق قال الشافعي أنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير أنهما قالا لا يلحق المختلعة الطلاق في العدة ولم يعرف لهما مخالف في الصحابة فكان كالإجماع ولأنها لا تحل له إلا بنكاح جديد فلا يلحقها طلاقه كالمطلقة قبل الدخول وفي الترغيب إلا إن قلنا هو طلقة ويكون بلا عوض وهو ظاهر (وإن شرط الرجعة في الخلع لم يصح الشرط في أحد الوجهين) جزم به في الوجيز وقدمه في الفروع كشرط الخيار ولأن الخلع لا يفسد بالعوض الفاسد فلا يفسد بالشرط الفاسد كالنكاح (وفي الآخر يصح الشرط ويبطل العوض) أي فيقع رجعيا بلا عوض لأن شرط العوض والرجعة يتنافيان فيسقطان ويبقى مجرد الطلاق فتثبت الرجعة بالأصل لا بالشرط

وعلى الأول قال القاضي يسقط المسمى في العوض لأنه لم يرض به عوضا حتى ضم إليه الشرط فإذا سقط الشرط فيصير مجهولا فيسقط ويجب

المسمى في العقد ويحتمل أن يجب المسمى في الخلع لأنهما تراضيا به عوضا فلم يجب غيره كما لو خلا عن شرط الرجعة

فرع إذا شرط الخيار في الخلع بطل الشرط وصح الخلع لأن الخيار في البيع لا يمنع وقوعه ومتى وقع فلا سبيل إلى رفعه

فصل

(ولا يصح الخلع إلا بعوض في أصح الروايتين) جزم به الأصحاب وقدمه في الفروع لأن العوض ركن فيه فلم يصح تركه كالثمن في المبيع (فإن خالعها بغير عوض لم يقع) لأن الشيء إذا لم يكن صحيحا لم يترتب عليه دليله للبيع (إلا أن يكون طلاقا) دون الثلاث (فيقع رجعيا) لأنه طلاق لا عوض فيه فكان رجعيا كغيره ولأنه يصح كناية عن الطلاق وإن لم ينو به طلاقا لم يكن شيئا لأن الخلع إن كان فسخا فلا يملك الزوج فسخ النكاح إلا لعيبها ولذلك لو قال فسخت النكاح ولم ينو به الطلاق لم يقع شيء بخلاف ما إذا دخله العوض فإنه معاوضة ولا يجتمع العوض والمعوض (والأخرى يصح بغير عوض اختارها الخرقي) وابن عقيل في التذكرة لأنه قطع للنكاح فصح من غير عوض كالطلاق ولأن الأصل في مشروعية الخلع أن يوجد من المرأة رغبة عن زوجها فإذا سألته الفراق فأجابها إليه حصل المقصود من الخلع أشبه ما لو كان بعوض

قال أبو بكر لا خلاف عن أبي عبد الله أن الخلع ما كان من قبل النساء فإذا كان من قبل الرجال فلا نزاع في أنه طلاق يملك به الرجعة ولا

[ج ٧ - ص ٢٢٩]

يكون فسخا وظاهره أنه لا بد فيه من سؤال المرأة أو من يقوم مقامها وصرح به في الكافي والأصفهاني في شرح الخرقي لأن خالع من باب المفاعلة وهي للمشاركة وفي الترغيب أنها تبين بقوله فسخت أو خلعت إذا قلنا هو فسخ بمجرده فظاهره أنه لا يحتاج فيه إلى سؤال لكنه مخالف لما ذكره الجماعة

فرع تبين بالخلع على كلتا الروايتين فلا يملك رجعتها إلا بشرط كالبيع

(ولا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها) لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثابت بن قيس أن يأخذ من زوجته حديقته ولا يزداد رواه ابن ماجه ولأنه بذل في مقابلة فسخ فلم يزد على قدره في ابتداء العقد كالإقالة (فإن فعل كره وصح) في قول أكثر العلماء روي عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا لو اختلعت من زوجها بميراثها وعقاص رأسها كان جائزا

ودليل الكراهة قوله عليه السلام في حديث رواه أبو حفص بإسناده أنه كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها وفي قول المؤلف نظر لأنه لا يلزم من الكراهة عدم الاستحباب وفيه شيء وأما الصحة فلقوله تعالى ﴿ فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ ولأنه قول جماعة من الصحابة ومن بعدهم قالت الربيع بنت معوذ اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي فأجاز ذلك علي واشتهر ولم ينكر فكان كالإجماع (وقال أبو بكر لا يجوز) هو رواية عن أحمد روي عن علي بإسناد منقطع ولأمره عليه السلام ثابتا

أن لا يزداد وأمره للوجوب (ويرد الزيادة) لعدم جوازها (وإن خالعها بمحرم) يعلمانه (كالخمر والحر فهو كالخلع بغير عوض) في قول أكثر العلماء لأن الخلع على ذلك مع [ج ٧ - ص ٢٣٠]

العلم بتحريمه يدل على رضى فاعله بغير شيء لا يقال هلا يصح الخلع ويجب مهر المثل لزوجها عليه لأن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم فإذا رضي بغير عوض لم يكن له شيء كما لو طلقها أو علقه على فعل فعلته وفارق النكاح فإن وصول البضع في ملك الزوج متقوم وقدم في الرعاية أنه إذا خالعها بمحرم يعلمانه فإنه يصح مجانا واقتضى أنهما إذا لم يعلما المحرم أن له قيمته كما ذكره في الروضة وغيرها

فرع إذا تخالع كافران بمحرم يعلمانه ثم أسلما أو أحدهما قبل قبضه لغا وقيل له قيمته وقيل مهر مثلها

(وإن خالعها على عبد فبان حرا أو مستحقا فله قيمته عليها) لأن ذلك عين يجب تسليمها مع سلامتها فوجب بدلها مع تعذرها كالمغصوب وهذا بخلاف ما سبق لأنه هنا لم يرض بغير عوض متقوم فيرجع بحكم الغرور ويجب مثله إن كان مثليا فلو خالعها على دن خل فبان خمرا رجع عليها بمثله خلا لأن الخل من ذوات الأمثال وقيل ترجع بقيمة مثله خلا لأن الخمر من ذوات الأمثال والأول أصح وقيل يجب مهر المثل لأنه على البضع بعوض فاسد أشبه النكاح بخمر وجوابه بأنها عين يجب تسليمها مع سلامتها وبقاء سبب الاستحقاق فوجب بدلها مقدرا بقيمتها أو مثلها كالمغصوب

(فإن بان معيبا فله أرشه أو قيمته ويرده) لأنه عوض في معاوضة فكان له ذلك كالبيع والصداق فإن كان على معين كقولها اخلعني على هذا

العبد فيقول خلعتك ثم يجد به عيبا لم يكن علم به فهذا يخير فيه بين

[ج ٧ - ص ٢٣١]

أخذ أرشه أو رده وأخذ قيمته وإن قال إن أعطيتني هذا الثوب فأنت طالق فأعطته إياه طلقت وملكه قال أصحابنا والحكم فيه كما لو خالعها عليه (وإن خالعها على رضاع ولده عامين) أو مدة معلومة صح قل أو أكثر لأن هذا مما تصح المعاوضة عليه في غير الخلع ففيه أولى فلو خالعها من إرضاع ولده مطلقا صح وانصرف إلى ما بقي من الحولين أو هما نص عليه (أو سكنى دار) معينة ويشترط تعيين المدة كالاجارة (صح) وكذا إذا خالعها على نفقة الطفل أو كفالته (فإن مات الولد أو خربت الدار رجع بأجرة باقي المدة) لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه فوجب الرجوع بباقي أجرة المدة كما لو أجره دابة شهرا بعشرة ثم مات في نصفه وفي الكفالة بقيمة مثلها لمثله وهل يستحقه دفعة أو يوما بيوم فيه وجهان أحدهما يستحقه دفعة واحدة ذكره القاضي في الجامع واحتج بقول أحمد يرجع عليها ببقية ذلك والثاني يستحقه يوما بعد يوم وهو الأصح لأنه ثبت منجما فلا يستحقه معجلا كما لو أسلم إليه في خبز يأخذ منه كل يوم أرطالا معلومة فمات وقيل يرجع بأجرة المثل لباقي المدة في الكل فإن أراد أن يقيم بدله من يرضعه أو يكفله فأبت أو أرادته هي فأبى لم يلزما وكذا نفقته مدة معينة إذا مات والأشهر أنه لا يعتبر قدر نفقتها وصفتها بل يرجع إلى العرف والعادة وكذا موت مرضعة أو جفاف لبنها في أثنائها

(وإن خالع الحامل على نفقة عدتها صح وسقطت) نص عليه لأن نفقة الحامل مقدرة واجبة بالشرع فهو كالخلع على الرضاع ولأنها تسقط لأنها

صارت مستحقة له فان لم تكن حاملا فلا نفقة لها عليه وقيل لها ومن

[ج ٧ - ص ٢٣٢]

مهر المثل لأن النفقة لم تجب فلم يصح الخلع وجوابه بأنها إحدى النفقتين فصحت المخالعة كنفقة الصبي وقيل إن وجبت النفقة بالعقد وإلا فهو خلع بمعدوم

فرع إذا خالع حاملا منه فأبرأته من نفقة حملها فلا نفقة لها ولا للولد حتى تفطمه نقل المروذي إذا أبرأته من مهرها ونفقتها ولها ولد فلها النفقة عليه إذا فطمته لأنها قد أبرأته مما يجب لها من النفقة فإذا فطمته فلها طلبه بنفقته وكذا السكنى

مسألة العوض في الخلع كالعوض في الصداق والبيع فإن كان مكيلا أو موزونا لم يدخل في ضمان الزوج ولم يملك التصرف فيه إلا بقبضه وإن كان غيرهما دخل في ضمانه بمجرد الخلع وصح تصرفه فيه

فصل

(ويصح الخلع بالمجهول) في ظاهر المذهب لأن الطلاق معنى يجوز تعليقه بالشرط فجاز أن يستحق به العوض المجهول كالوصية ولأن الخلع إسقاط لحقه من البضع وليس فيه تمليك شيء والإسقاط تدخله المسامحة ولذلك جاز بغير عوض على رواية (وقال أبو بكر لا يصح) وإنه قياس قول أحمد وجزم به أبو محمد الجوزي لأنه معاوضة فلم يصح بالمجهول كالبيع (والتفريع على الأول) لأنه المذهب والفرق بينه وبين البيع أن

البيع لا يصح إلا بثمن قولا واحدا بخلاف الخلع على قول وحينئذ يجب في ظاهر نصه المسمى (فإذا خالعها على ما في [ج ٧ - ص ٢٣٣]

يدها من الدراهم أو ما في بيتها من المتاع فله ما فيهما) إذا كان فيهما شيء لأن ذلك هو المخالع عليه وجهالته لا تضر لأن التفريع على صحة الخلع بالمجهول وظاهره أنه يستحق ما في يدها وإن كان أقل من ثلاثة دراهم وهو احتمال حكاه في المغني والشرح لأنه الذي في اليد والثاني له ثلاثة دراهم لأن لفظه يقتضيها

(فإن لم يكن فيهما شيء فله ثلاثة دراهم وأقل ما سمي متاعا) لأن ذلك أقل ما يقع عليه اسم الدراهم والمتاع حقيقة (وقال القاضي) وأصحابه (يرجع عليها بصداقها في مسألة المتاع) لأنها فوتت عليه البضع ولم يحصل له العوض لجهالته فوجب عليها قيمة ما فوتت عليه وهو الصداق وأما على الرواية الأولى ففيه خمسة أوجه

أحدهما وهو ظاهر كلامه صحة الخلع بالمسمى لكن يجب أدنى ما يتناوله الاسم لما تبين عدمه وإن لم يكن غرته كحمل الأمة

الثاني صحته بمهرها فيما يجهل حالا ومآلا فإن تبين عدمه رجع إلى مهرها وقيل إذا لم تغره فلا شيء عليها

الثالث فساد المسمى وصحة الخلع بمهرها

الرابع بطلان الخلع قاله أبو بكر

الخامس بطلانه بالمعدوم وقت العقد كما تحمل شجرته وصحته مع الوجود يقينا أو ظنا ثم هل يجب المسمى أو مهر أو الفرق قاله في المحرر (وإن خالعها [ج ٧ - ص ٢٣٤]

على حمل أمتها أو ما تحمل شجرتها فله ذلك) أي ما تحملانه لأنه المخالع عليه ولو كان معدوما إذ لا أثر له والمراد بحمل الأمة ما تحمله بدليل قوله بعد فإن لم تحملا وهكذا ذكره في المغني ولا فرق بين مسألة حمل الأمة وحمل الشجرة (فإن لم تحملا فقال أحمد ترضيه بشيء) لئلا يخلو الخلع عن عوض وفي المغني قول أحمد ترضيه بشيء إن له أقل ما يقع عليه اسم الحمل والثمرة فهو كمسألة المتاع لأنه بمعناه (وقال القاضي لا شيء له) لأنه رضي بالحمل ولا حمل وتأويل قول أحمد على الاستحباب لأنه لو كان واجبا لقدره بتقدير يرجع إليه

وعليه الفرق بينهما وبين مسألة الدراهم والمتاع أن المرأة في مسألة الدراهم والمتاع أوهمته أن معها دراهم وفي بيتها متاع لأنها خاطبته بلفظ يقتضي الوجود مع إمكان علمها به فكان له مادل عليه لفظها كما لو خالعته على عبد فوجد حرا وفي هاتين المسألتين دخل معها في العقد مع تساويهما في العلم في الحال ورضاهما بما فيه من الاحتمال فلم يكن لها شيء غيره كما لو قال خالعتك على هذا الحر وقال ابن عقيل له مهر المثل وقال أبو الخطاب له المسمى (وإن خالعها على عبد فله أقل ما يسمى عبدا) أي بصح تمليكه نص عليه لأنه خالعها على مسمى مجهول فكان له أقل ما يقع عليه الاسم كما لو خالعها على ما في يدها من الدراهم فإن خالعته على عبيد فله ثلاثة في ظاهر كلام أحمد والخرقي كمسألة الدراهم (وإن قال إن أعطيتني عبدا فأنت طالق طلقت بأي عبد أعطته طلاقا بائنا وملك

العبد نص عليه) لأن الشرط عطية عبد وقد وجد ويقع الطلاق بائنا لأنه على [ج ٧ - ص ٢٣٥]

عوض ويملك العبد لأنه عوض خروج البضع من ملكه (وقال القاضي يلزمها عبد وسط فيهما) كالصداق وتأول كلام أحمد على أنها تعطيه عبدا وسطا وعلى قوله إن أعطته معيبا أو دون الوسط فله رده وأخذ بدله

تتمة لو أعطته مدبرا أو معتقا بعضه وقع الطلاق لأنهما كالقن في التمليك وإن أعطته حرا أو مغصوبا أو مرهونا لم تطلق لأن العطية إنما تتناول ما يصح تمليكه وفي الرعاية لو بان حرا أو مغصوبا أو مكاتبا بانت وله القيمة وقيل لا تطلق (وإن قال إن أعطيتني هذا العبد) أو الثوب الهروي (فأنت طالق فأعطته إياه طلقت) لتحقق وجود الشرط ويقع بائنا (وإن خرج معيبا) أو مرويا (فلا شيء) له ذكره أبو الخطاب وجزم به في الوجيز لأنه شرط لوقوع الطلاق أشبه ما لو قال إن ملكته فأنت طالق ثم ملكه وقال القاضي له رده وأخذ قيمته بالصفة سليما أو أخذ أرشه كما لو قالت اخلعني على هذا العبد فخلعها وفي الترغيب في رجوعه بأرشه وجهان وأنه لو بان مباح الدم بقصاص أو غيره فقتل فذكر القاضي وهو المذهب أنه يرجع بأرش عيبه وذكر ابن البنا يرجع بقيمته (وإن خرج مغصوبا) أو حرا (لم يقع الطلاق عليها) على المذهب لأن العطية إنما تتناول ما يصح تمليكه وما لا يصح تمليكه لأنه لا يكون عطية له فإذا لم يوجد شرط الطلاق (وعنه يقع وله قيمته) جزم به في الروضة وغيرها لأنه معاوضة بالبضع فلا يفسد بفساد العوض كالنكاح فعلى هذا يرجع عليها بقيمته لأنه لم يرض بغير عوض والصحيح [ج ٧ - ص ٢٣٦]

أنها لا تطلق ولا يستحق القيمة لأنها لا تطلق بعطية المغصوب والحر لأن العطية هنا التمليك بدليل حصوله فيما إذا كان العبد مملوكا لها (وكذلك في التي قبلها) لأنهما سواء معنى فكذا يجب أن يكونا حكما

فرع إذا خالعها على عبد موصوف في الذمة فأعطته إياه معيبا بانت وله طلب عبد سليم بتلك الصفة وإن أعطته قيمته لزمه قبولها وقال ابن حمدان له مهر المثل فإن خالعها على عبد بعينه ثم أعتقته لم يصح وقيل بلى وعليها قيمته فإن باعته ولم يعلم فعليها قيمته وقيل يبطل البيع

(وإن قال إن أعطيتني ثوبا هرويا فأنت طالق فأعطته مرويا لم تطلق) لأن الصفة التي علق عليها الطلاق لم توجد وإن خالعته على مروي في الذمة فأتته بهروي صح وخير وإن خالعها على ثوب على أنه قطن فبان كتانا رده ولم يكن له إمساكه لأنه جنس آخر وكل موضع علق طلاقها على عطيتها إياه فمتى أعطته على صفة يمكنه القبض وقع الطلاق سواء قبضه منها أو لا فإن هرب الزوج أو غاب قبل عطيتها أو قالت يضمنه لك زيد أو أجعله قصاصا بما لي عليك أو احالته به لم يقع الطلاق وكذلك كل موضع تعذر العطية فيه سواء كان التعذر من جهتها أو من جهته أو من جهة غيرهما لانتفاء الشرط ولو قالت طلقني بألف فطلقها استحق الألف وبانت وإن لم تقبض نص عليه لأن هذا ليس تعليقا على شرط بخلاف الأول

فرع إذا تخالعا على حكم أحدهما أو غيرهما أو بمثل ما خالع به زيد زوجته صح بالمسمى وقيل بل بمهرها وقيل بل بمهر مثلها وإن خالعته على هروي

[ج ٧ - ص ٢٣٧]

فبان مرويا فله الخيار بين رده) لأنه غير المعقود عليه (وإمساكه) لأنه من الجنس ولأن مخالفة الصفة بمنزلة العيب في جواز الرد (وعند أبي الخطاب ليس له غيره إن وقع الخلع على عينه) لأن الخلع واقع على عينه وقوله الأول مشعر بأن الخلع واقع على غير العين وفي اشتراط وقوع الخلع على عينه عند أبي الخطاب ينفيه ويؤذن بأن الكلام الأول عام إذ لو كان خاصا بالخلع على عين الثوب لم يكن في اشتراط وقوع الخلع على العين عند أبي الخطاب فائدة

فصل

(إذا قال إن أعطيتني أو إذا أعطيتني أو متى أعطيتني ألفا فأنت طالق كان على الترخي أي وقت أعطته ألفا طلقت) بائنا وملكه وإن لم يقبضه لأنه علق الطلاق بشرط فكان على التراخي كسائر التعاليق فلو نويا صنفا منها حمل العقد عليها وإن أطلقا حمل على نقد البلد كالبيع فإن لم يكن فعل ما يقع عليه ولا يقع بدفعها عددا ناقصة الوزن كدفع نقرة زنتها ألف لأن الدراهم في عرف الشرع المضروبة الوازنة وقيل يكفي عدد متفق عليه بلا وزن لحصول المقصود وتطلق إذا أعطته وازنة بإحضاره ولو كانت ناقصة في العدد وإذنها في قبضه وإن دفعت إليه مغشوشة تبلغ فضتها ألفا طلقت وإلا فلا وتقدم أنه يمكنه قبضه كما في المنتخب والمغني وغيرهما وفي الترغيب وجهان في إن اقبضتني فأحضرته ولم تقبضه فلو

قبضه فهل يملكه فيقع بائنا أولا فيقع رجعيا فيه احتمالان ظاهره أنها إذا وضعته بين يديه أنها تطلق [ج ٧ - ص ٢٣٨]

وإن لم يأخذه إذا كان متمكنا من أخذه لأنه إعطاء عرفا بدليل أعطته فلم يأخذ واستشكله بعض المحققين لأنه إن حمل الإعطاء على الإقباض من غير تمليك فينبغي أن تطلق ولا يستحق شيئا وإن حمل عليه مع التمليك فلا يصح التمليك بمجرد فعلها والتعليق لازم من جهة الزوج لزوما لا سبيل إلى دفعه خلافا للشيخ تقي الدين كالكتابة عنده ووافق على شرط محض كإن قدم زيد (وإن قالت له اخلعني بألف أو على ألف أو طلقني بألف أو على ألف) أو طلقني ولك ألف (ففعل) على الفور وقيل أو التراخي جزم به في المنتخب وفي المحرر وغيره في المجلس (بانت) لأن الباء للمقابلة وعلى في معناها ويكفي قوله خلعتك أو طلقتك وإن لم يذكر الألف في الأصح (واستحق) المجيب (الألف) لأنه فعل ما جعل الألف في مقابلته وكذا قولها إن طلقتني فلك علي ألف ولها أن ترجع قبل أن يجيبها

فرع إذا قالت اخلعني بألف فقال أنت طالق فإن قلنا الخلع طلقة بائنة وقع واستحق الألف وإن قلنا هو فسخ فهل يستحق العوض فيه وجهان وإن لم يستحق ففي وقوعه رجعيا احتمالان وإن قالت طلقني بها فقال خلعتك فإن كان طلاقا استحقه وإلا لم يصح وقيل خلع بلا عوض وفي الروضة يصح وله العوض لأن القصد أن تملك نفسها بالطلقة وحصل بالخلع (وإن قالت له طلقني واحدة بألف) أو على ألف أو ولك ألف (فطلقها ثلاثا) وفي الروضة أو اثنتين (استحقها) لأنه حصل لها ما طلبته [ج ٧ - ص ٢٣٩]

وزيادة (وإن قالت له طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة) وقعت الواحدة بغير خلاف لأنه أتى بلفظه الصريح و (لم يستحق شيئا) على المنصوص والمجزوم به عند أصحابنا لأنها إنما بذلتها في مقابلة الثلاث ولم تحصل وصار كما لو قال بعني عبديك بألف فقال بعتك أحدهما بنصفها وفارق ما إذا قال من رد عبيدي فله كذا فرد بعضهم فإنه يستحق القسط لأن غرضه يتعلق بكل واحد من العبيد وهنا غرضها يتعلق ببينونة كبرى ولم تحصل (ويحتمل أن يستحق ثلث الألف) وهو لأبي الخطاب في الهداية كما لو قال من رد عبيدي الثلاثة فله ألف فعلى هذا يقع الطلاق بائنا وعلى الأول يكون رجعيا إذا كان في يده الثلاث لأنها استدعت فرقة تحرم بها قبل زوج آخر فلم يجبها إليه

فرع لو وصف طلقة ببينونة وقلنا به لعدم التحريم التام فإن لم يصفها فواحدة رجعية وقيل بائن بثلاثة وهو رواية في التبصرة

(وإن لم يكن بقي من طلاقها إلا واحدة ففعل بانت واستحق الألف) لأن الواحدة التي فعلها كملت الثلاث وحصلت ما يحصل من الثلاث من البينونة وتحريم العقد فوجب العوض كما لو طلقها ثلاثا (علمت أو لم تعلم) لأن القصد تحريمها قبل زوج آخر وقد حصل ذلك (ويحتمل ألا يستحق إلا ثلثه إذا لم تعلم) وهو قول ابن سريج لأنها بذلت العوض في

مقابلة الثلاث ولم يوجد بخلاف ما إذا كانت عالمة فإن معنى كلامها كمل لي الثلاث وقد فعل

مسائل إذا قال أنت طالق وطالق وطالق بألف بانت بالأولى ولم يقع ما بعدها في الأصح وهذه المسألة في جواب قولها طلقني واحدة بألف

[ج ٧ - ص ٢٤٠]

ويدل عليه كلام بعضهم ولو قال أنت طالق وطالق بألف وطالق بانت بالثانية ولغت الثالثة وإن قال أنت طالق وطالق وطالق بألف بانت بالثالثة وما قبلها رجعي وقال ابن حمدان تطلق ثلاثا ولو قالت طلقني عشرا بألف فطلقها ثلاثا استحقها لأنه حصل المقصود وإن طلقها أقل من ذلك لم يستحق شيئا وإن قالت طلقني بألف إلى شهر فطلقها قبله طلقت ولا شيء له نص عليه وإن قالت من الآن إلى شهر فطلقها قبله استحقها لأنه أجابها إلى ما سألت وقال القاضي تبطل التسمية وله صداقها لأن زمن الطلاق مجهول

(وإن كان له امرأتان مكلفة) أي رشيدة (وغير مكلفة) أي مميزة (فقال أنتما طالقتان بألف إن شئتما فقالتا قد شئنا لزم المكلفة نصف الألف وطلقت بائنا ووقع الطلاق بالأخرى رجعيا ولا شيء عليهما) كذا ذكره في الوجيز وغيره وحاصله أن المكلفة إذا كانت رشيدة فمشيئتها صحيحة وتصرفها في مالها صحيح فيقع عليهما الطلاق فتبين المكلفة بنصف الألف عند أبي بكر ورجحه في المغني وجزم به في (الوجيز) وعند ابن حامد يسقط بقدر مهريهما ذكره في (المغني) و (الشرح) ظاهر المذهب وتطلق الأخرى رجعيا مجانا فإن بذلها للعوض غير صحيح وكذا المحجور عليها لسفه لأن لها مشيئة وتصرفها في المال غير صحيح بدليل أنه يرجع إلى مشيئة المحجور عليه في النكاح فإن كانت مجنونة أو صغيرة لم تصح المشيئة منها ولم يقع الطلاق وعنه لا مشيئة لمميزة كدونها فلا طلاق

فإن كانتا رشيدتين وقع بهما الطلاق بائنا فإن قبلته إحداهما لم تطلق واحدة منهما ذكره في المغني والشرح لأنه جعل [ج ٧ - ص ٢٤١]

مشيئتهما شرطا في طلاق كل واحدة منهما والأصح أنها تطلق وحدها بقسطها فلو قال الزوج ما شئتما وإنما قلتما ذلك بألسنتكما أو قالتا ما شئنا بقلوبنا لم يقل (وإن قال لامرأته) ابتداء (أنت طالق وعليك ألف طلقت ولا شيء عليها) لأنه لم يجعل الألف عوضا للمطلقة ولا شرطا فيها وإنما عطفه على الطلاق الذي أوقعه فوقع ما يملكه دون مالا يملكه كقوله أنت طالق وعليك الحج فإن أعطته المرأة عوضا عن ذلك كان هبة مبتدأة تعتبر فيها شروط الهبة (وإن قال على ألف أو بألف فكذلك) أي يطلق بغير شيء على المذهب لأنه أوقع الطلاق غير معلق بشرط وجعل عليه عوضا لم يبذله فوقع رجعيا لأن على ليست للشرط ولا للمعاوضة بدليل أنه لا يصح بعتك ثوبي على دينار وقيل لا تطلق كنظيرتهن في العتق وقيل تطلق إلا في وعليك والمختار أنها إذا قبلته في المجلس بانت واستحقه وإلا وقع رجعيا وله الرجوع قبل قبولها ولا ينقلب بائنا ببذلها العوض في المجلس بعد عدم قبولها (ويحتمل ألا تطلق حتى تختار فلزمها الألف) هذا قول القاضي في المجرد لأن تقديره إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق ولأن على تستعمل للشرط بدليل قوله تعالى ﴿ إني أريد أن أنكحك ﴾) الآية وقيل تطلق بألف فقط والأولى أنها لاتطلق في بألف حتى تختار فيلزمها الألف لأنها إن لم تكن حرف شرط فهي للمعاوضة في بعتك بكذا وزوجتك بكذا

فرع إذا قال أنت طالق ثلاثا بألف أو على ألف فقالت قبلت واحدة بثلث الألف لم يقع وإن قالت قبلت واحدة بألف وقع الثلث [ج ٧ - ص ٢٤٢]

واستحق الألف وإن قالت قبلت بألفين وقع ولزمها الألف فقط وإن قال أنت طالق ثلاثا واحدة منها بألف طلقت اثنتين ووقعت الثالثة على قبولها ولو لم يبق من طلاقها إلا واحدة فقال أنت طالق اثنتين الأولى بغير شيء والثانية بألف بانت بالثلاث ولم يستحق شيئا

فصل

(وإذا خالعته في مرض موتها) المخالعة في المرض صحيحة سواء كانا مريضين أو أحدهما بغير خلاف نعلمه لأنها معاوضة كالبيع ثم إذا خالعته في مرض موتها بميراثه منها فما دون صح ولا رجوع وان خالعته بزيادة بطلت الزيادة (فله الأقل من المسمى أو من ميراثه منها) لأن ذلك لا تهمة فيه بخلاف الأكثر منها فإن الخلع إن وقع بأكثر من الميراث تطرقت إليه التهمة من قصد إيصالها إليه شيئا من مالها بغير عوض على وجه لم تكن قادرة عليه أشبه ما لو أوصت أو أقرت له وإن وقع بأقل من الميراث فالباقي هو أسقط حقه منه فلم يستحقه فتعين استحقاق الأقل منهما وقيل إن كان ميراثه منها بقدر ما ساق إليها من الصداق أو أقل صح وإن كان ما خالعته أكثر بطلت الزيادة (وإن طلقها في مرض موته وأوصى لها بأكثر من ميراثها لم تستحق أكثر من ميراثها) أي للورثة منعها من ذلك لأنه اتهم في أنه قصد إيصال ذلك إليها كالوصية لوارث وعلم منه أنه إذا أوصى لها بمهر مثلها أو أقل أنه يصح لأنه لا تهمة في

ذلك (وإن خالعها في مرضه وحاباها فهو من رأس المال) مثل أن يخالعها بأقل من مهر مثلها [ج ٧ - ص ٢٤٣]

مثل أن يكون قادرا على خلعها بشيء فخالعها بدونه لم يحسب ما حاباها من الثلث في مرض موته لأنه لو طلق بغير عوض لصح فلأن يصح بعوض أولى فلو خالعها في مرضها باكثر من مهرها فللورثة أن لا يعطوه أكثر من ميراثه منها لأنه متهم

(وإذا وكل في خلع امرأته مطلقا فخالع بمهرها فما زاد صح) ولزم المسمى لأنه زاده خيرا وعلم منه صحة التوكيل في الخلع لكل من يصح تصرفه في الخلع لنفسه كالعبد والأنثى والكافر والمحجور عليه لا نعلم فيه خلافا ويجوز التوكيل من غير تقدير عوض كالبيع والنكاح والمستحب التقدير لأنه أسلم من الغرر وأسهل على التوكيل

(وإن نقص عن المهر رجع على الوكيل بالنقص) على المذهب لأن الخلع عقد معاوضة أشبه البيع (ويحتمل أن يخير بين قبوله ناقصا) لأن الحق له فإذا رضي بدونه وجب أن يصح (وبين رده وله الرجعة) لأن الطلاق قد وقع والعوض مردود (وإن عين له العوض فنقص لم يصح الخلع عند ابن حامد) وهو أولى وأصح لأنه خالف موكله أشبه ما لو وكله في خلع امرأة فخالع غيرها (وصح عند أبي بكر) لأن المخالعة في قدر العوض وهو لا يبطله كحالة الإطلاق (ويرجع على الوكيل بالنقص) لأنه أمكن الجمع بين تصحيح التصرف ودفع الضرر فوجب كما لو لم يخالف وصحح ابن المنجا هذا القول لأن الفرق ثابت بين المخالفة وبين المعقود عليه

وبين المخالفة في تعيين العوض لأنه لو وكله في عبده من زيد فباعه من غيره لم يصح ولو وكله في بيعه بعشرة فباعه بأقل منها أنه يصح ويضمن الوكيل النقص [ج ٧ - ص ٢٤٤]

فرع إذا خالف بالجنس أو أمره بالخلع حالا فخالع عن عوض نسيئة فالقياس أنه لا يصح وقال القاضي إنه يلزم الوكيل القدر الذي أذن فيه ويكون له ما خالع به كالمخالفة في القدر وهذا يبطل بالوكيل في البيع وفارق المخالفة في القدر لأنه أمكن جبره بالرجوع بالنقص على الوكيل وكذا الحكم لو خالع بغير نقد البلد وإن خالع بما ليس بمال فلغو وقيل يصح إن صح بلا عوض وإلا رجعيا

(وإن وكلت المرأة في ذلك فخالع بمهرها فما دون أو بما عينته فما دون صح) لأنه امتثل وزاد خيرا (وإن زاد لم يصح) على المذهب لأنه خالفها في تعيينها أو فيما اقتضاه الإطلاق فلم يصح كما لو وكلته في الخلع بدراهم فخالع بعروض (ويحتمل أن يصح) لأن المخالفة في القدر لا توجب الضمان (وتبطل الزيادة) لأن الموكلة ما التزمتها ولا أذنت فيها وقاله في الشرح ولزم الوكيل لأنه ألزمه للزوج فلزمه الضمان كالمضارب إذا اشترى من يعتق رب المال وقال القاضي في المجرد عليها مهر مثلها ولا شيء على وكيلها لأنه لا يقبل العقد لنفسه وإنما يقبله لغيره بخلاف الشراء (وإذا تخالعا) بغير لفظ الطلاق (تراجعا بما بينهما من الحقوق) أي حقوق النكاح لأنه أحد نوعي الخلع فلم يسقط به شيء كالطلاق (وعنه أنها تسقط) بالسكوت عنها إلا نفقة عدة الحامل وما خولع ببعضه لأن الخلع يقتضي انخلاع كل واحد من صاحبه ولو بقيت الحقوق كما كانت لبقي بينهما علقة وذلك ينافي الانخلاع فعليه إن كان خلعها قبل الدخول ولم

تكن قبضت منه شيئا لم ترجع عليه وإن كانت قبضته لم يرجع وعلى

الأول يرجع كل واحد بما يستحقه وهو الاصح وهذا الخلاف في حقوق النكاح وأما الديون فلا تعلق للخلع بها

فصل

(وإذا قال خالعتك بألف فأنكرته أو قالت انما خالعت غيري بانت) بإقراره (والقول قولها مع يمينها في العوض) لأنها منكرة لبذله (وإن قالت نعم لكن ضمنه غيري لزمها الألف) لأنها أقرت بها ولا يلزم الغير شيء إلا أن يقر به فإن ادعته المرأة وأنكره الزوج قبل قوله ولا شيء عليها لأنها لا تدعيه وإن قالت سألتك طلاقا ثلاثا بألف فأجبت فقال بل طلقة فأجبت قبل قوله وبانت بألف وقيل يتحالفان ولها المهر المسمى (وإن اختلفا في قدر العوض أو عينه أو تأجيله أو صفته فالقول قولها مع يمينها) نص عليه لأنه يقبل قولها في أجله فكذا في قدره وصفته ولا ينكر الزائد والحلول والقول قول المنكر مع يمينه (ويتخرج أن القول قول الزوج) هذا رواية حكاها القاضي لأن البضع يخرج عن ملكه فقبل قوله في عوضه كالسيد مع مكاتبه (ويحتمل أن يتحالفا) إن لم يكن يلفظ طلاق لأنه اختلاف في عوض العقد فيتحالفان فيه كالمتبايعين (ويرجعا إلى المسمى أو مهر المثل إن لم يكن مسمى) لأن البضع تلف بالخلع فوجب الرجوع إلى البدل كما لو تلف المبيع ووقع التحالف فإنه يجب بدله وهو المثل أو القيمة وجوابه بأن [ج ٧ - ص ٢٤٦]

التحالف في البيع يحتاج إليه في فسخ العقد والخلع في نفسه فسخ فلا يفسخ وقيل إن اختلفا في قدر العوض فلا يمين وأيهما يصدق فيه وجهان (وإن علق طلاقها على صفة ثم خالعها فوجدت الصفة ثم عاد فتزوجها فوجدت الصفة طلقت نص عليه) لأن عقد الصفة ووقوعها وجدا في النكاح فوقع الطلاق كما لو لم يتخلله بينونة لا يقال الصفة انحلت بفعلها حال البينونة ضرورة ألا تقتضي التكرار لأنها إنما تحل على وجه تحنث به لأن اليمين حل وعقد والعقد يفتقر إلى الملك فكذا الحل والحنث لا يحصل بفعل الصفة حال البينونة ولا تحل اليمين (ويخرج ألا تطلق بناء على الرواية في العتق) وهو أن الصفة لا تحل لأن الملك الثاني لا ينبني على الأول في شيء من أحكامه (واختاره أبو الحسن التميمي) وأكثر العلماء لأن العتق يتشوف الشارع إليه بخلاف الطلاق قال صاحب النهاية وغيره والأول أصح والفرق بين الطلاق والعتاق من حيث إن الاصل في الأبضاع الحرمة وفي الأموال العصمة فإذا تعارض دليل الطلاق وجب وقوعه لأن الأصل حرمة الوطء وإذا تعارض دليل العتق وجب عدم وقوعه لأن الأصل عصمة الملك فإن قيل لو طلقت بذلك لوقع الطلاق بشرط سابق على النكاح ولا خلاف أنه لو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق فتزوجها ثم دخلت لم تطلق والفرق أن النكاح الثاني مبني على الأول في عدد الطلقات وسقوط اعتبار العدد وبهذا فرق صاحب المغني

فيه بين الطلاق والملك (وإن لم توجد الصفة حال البينونة عادت رواية

واحدة) لأن اليمين لم تنحل لكون الصفة في حال البينونة لم توجد فإذا وجدت الصفة بعد التزويج وجب أن تعمل عملها كما لو لم يكن بينونة فإن كانت الصفة لا توجد بعد النكاح الثاني كقوله إن أكلت هذا الرغيف فأنت طالق ثلاثا ثم أبانها فأكلته لم يحنث

أصل يحرم الخلع حيلة لإسقاط يمين الطلاق ولا يقع في اختيار الأكثر واحتج القاضي بما روي عن عمر أنه قال الحلف حنث أو ندم رواه ابن بطة وفي المغني هذا يفعل حيلة على إبطال الطلاق المعلق والحيل خداع لا تحل ما حرم الله فلو اعتقد البينونة ففعل ما حلف فكمطلق معتقد أجنبية فتبين امرأته ذكره الشيخ تقي الدين وقيل يقع وصححه ابن حمدان وصاحب الحاوي وعمل غالب الناس عليه وفي واضح ابن عقيل يستحب إعلام المستفتي بمذهب غيره إن كان أهلا للرخصة كطالب التخلص من الربا فيدله على من يرى التحيل للخلاص منه والخلع بعدم وقوع الطلاق والله أعلم [ج ٧ - ص ٢٤٨]

كتاب الطلاق

والإجماع على جوازه وسنده قوله تعالى ﴿ الطلاق مرتان ﴾ وقوله تعالى ﴿ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ﴾ وقوله عليه السلام لعمر لما سأله عن تطليق ابنه امرأته وهي حائض مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء متفق عليه والمعنى يدل عليه لأن الحال ربما فسد بين الزوجين فيؤدي إلى ضرر عظيم فبقاؤه إذا مفسدة محضة بلزوم الزوج النفقة والسكنى وحبس المرأة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة فشرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه (وهو حل قيد النكاح) أو بعضه وهو راجع إلى معناه لغة لأن من حل قيد نكاحها فقد خليت إذ أصل الطلاق التخلية يقال طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت وحبس فلان في السجن طلقا بغير قيد وهو مصدر طلقت المرأة أي بانت من زوجها بفتح اللام وضمها تطلق بضم اللام فيهما طلاقا وطلقة وجمعها طلاق بفتح اللام فهي طالق وطلقها زوجها فهي مطلقة (ويباح عند الحاجة إليه) لضرره بالمقام على النكاح فيباح له رفع الضرر عن نفسه (ويكره من غير حاجة) وقاله الأكثر لما روى محارب ابن دثار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله تعالى [ج ٧ - ص ٢٤٩]

الطلاق رواه أبو داود وابن ماجه ورجاله ثقات وروي مرسلا وعنه لا يكره صححه الحلواني لما سبق (وعنه أنه يحرم) لقوله عليه السلام لا ضرر ولا إضرار ولأنه يضر بنفسه وزوجته (ويستحب إذا كان بقاء النكاح ضررا) أي يندب عند تضرر المرأة بالنكاح إما لبغضه أو لغيره فيستحب إزالة الضرر عنها ولتركها صلاة وعفة ونحوهما وعنه يجب لعفة وعنه وغيرها فإن ترك حقا لله فهي كهو فتختلع والزنى لا يفسخ نكاحا نص عليهما ونقل المروذي فيمن يسكر زوج اخته يحولها إليه وعنه أيضا أيفرق بينهما قال الله المستعان وبقي هنا قسمان آخران واجب هو طلاق المؤلي بعد التربص وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأياه وعنه ولأمر أبيه وعنه العدل وقاله أبو بكر اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أمرته أمه فنصه لا يعجبني طلاقه ومنعه الشيخ تقي الدين منه ونص في بيع السرية إن خفت على نفسك فليس لها ذلك ومحظور وهو طلاق من دخل بها في حيضها أو في طهر أصابها فيه ويسمى طلاق بدعة لمخالفته الشرع لأن طلاق الحائض يضر بها لتطويل عدتها والمصابة ترتاب فلا تدري أذات حمل هي فتعتد بوضعه أم حائل فتعتد بالقروء وحيث كانت حاملا فيندم على فراقها مع ولدها أما غير المدخول بها فلا يحرم لعدم العدة وكذا الصغيرة والآيسة والحامل التي استبان حملها فلا (ويصح من الزوج البالغ العاقل المختار) بغير خلاف نعلمه لأن المصحح لوقوع

الطلاق موجود وهو التكليف فظاهره يقع من كتابي وسفيه نص عليهما (ومن الصبي العاقل) أي إذا عقل [ج ٧ - ص ٢٥٠]

الطلاق في الاختيار الأكثر وذكره ابن هبيرة ظاهر المذهب لقوله عليه السلام الطلاق لمن أخذ بالساق وقال علي كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه ذكره البخاري ورواه الترمذي والدارقطني مرفوعا بإسناد فيه ضعف (وعنه لا يصح حتى يبلغ) نقلها أبو طالب وقدمها في المحرر وجزم بها الآدمي وابن أبي موسى وهو قول أكثر العلماء لقوله عليه السلام رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ولأنه غير مكلف فلا يقع طلاقه كالمجنون وعنه لا يقع لدون عشر اختاره أبو بكر وعنه اثنتي عشرة سنة وقاله إسحاق وعنه لأب صغير ومجنون فقط الطلاق نصره القاضي وأصحابه ومن أجاز طلاقه اقتضى مذهبه أن يجوز توكيله فيه وتوكله لغيره أومأ إليه ونصره في الشرح كالبالغ وقال أبو بكر وحكاه عن أحمد لا يصح أن يوكل حتى يبلغ وجوابه بأنه على الرواية التي لا تجيز طلاقه

فرع تعتبر إرادة لفظ الطلاق لمعناه فلا طلاق لفقيه يكرره وحاك عن نفسه حكاه ابن عقيل كغيره

(ومن زال عقله بسبب يعذر فيه كالمجنون والنائم والمغمى عليه والمبرسم لم يقع طلاقه) إجماعا لقوله عليه السلام رفع القلم عن المجنون حتى يفيق وعن أبي هريرة مرفوعا أنه قال كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله رواه النجاد قال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث

عطاء بن عجلان وهو ذاهب الحديث ولأنه قول يزيل الملك فاعتبر له العقل كالبيع وسواء [ج ٧ - ص ٢٥١]

زال بجنون أو إغماء أو شرب دواء أو أكره على شرب الخمر أو شرب ما يزيل عقله أو لم يعلم أنه مزيل العقل لكن لو ذكر المغمي عليه أو المجنون لما أفاق أنه طلق وقع نص عليه قال المؤلف هذا فيمن جنونه بذهاب معرفته بالكلية فأما المبرسم ومن به نشاف فلا يقع وفي الروضة أن المبرسم والموسوس إن عقل الطلاق لزمه ويدخل في كلامهم من غضب حتى أغمي أو غشي عليه قال الشيخ تقي الدين بلا ريب ويقع من غيره في ظاهر كلامهم لأن أبا موسى أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله فوجده غضبان وحلف لا يحملهم وكفر الحديث ولأنه قول ابن عباس ولأنه من باطن كالمحبة الحاملة على الزنى وقال الشيخ تقي الدين إن غيره ولم يزل عقله لم يقع لأنه الجأه وحمله عليه فأوقعه وهو يكرهه ليستريح منه فلم يبق له قصد صحيح فهو كالمكره ولهذا لا يجاب دعاؤه على نفسه وماله ولا يلزمه نذر الطاعة فيه وفي صحة حكمه الخلاف وإنما انعقدت يمينه لأن ضررها يزول بالكفارة ولهذا إتلاف

فرع لو ادعى أنه طلق وهو زائل العقل ينبني على ما إذا أقر وهو مجنون هل يقبل وفيه ثلاثة أقوال ثالثها يقبل إن كان ممن غلب وجوده منه

(وإن زال بسبب لا يعذر فيه كالسكران ومن شرب ما يزيل عقله لغير حاجة ففي صحة طلاقه روايتان) إحداهما يقع قال ابن هبيرة هي أظهرهما اختارها الخلال والقاضي والأكثر لما تقدم من قوله كل الطلاق جائز إلا

طلاق المعتوه وقال معاوية كل أحد طلق امرأته جائز إلا طلاق المجنون رواه البيهقي بإسناد [ج ٧ - ص ٢٥٢]

حسن ولأن الصحابة جعلوه كالصاحي في الحد بالقذف وقال علي بمحضر من عمر وغيره نراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون رواه مالك بإسناد جيد ولأنه مكلف فوقع طلاقه كالصاحي بدليل القتل والقطع في السرقة

والثانية لا يقع اختارها أبو بكر والمؤلف ورجحه في الشرح والشيخ تقي الدين وقال المكره لم يأثم في الأصح ونقل الميموني كنت أقول يقع حتى تبينته فغلب علي أنه لا يقع ونقل أبو طالب الذي لا يأمر بالطلاق أتى خصلة والذي يأمر به أتى خصلتين حرمها عليه وأحلها لغيره وذكره البخاري عن عثمان وابن عباس وهو قول جمع قال ابن المنذر لا نعلم أحدا من الصحابة خالف عثمان وقال أحمد حديث عثمان أرفع شيء فيه ولأن العقل شرط للتكليف وكالمجنون وعنه أنه توقف في الجواب ويقال اختلف الصحابة فيه وذكر الشيخ تقي الدين أن الخلاف فيمن يفهم وإلا لم يقع قال وزعم طائفة من العلماء أن الخلاف إنما هو في النشوان الذي يفهم ويغلط فأما الذي تم سكره بحيث لا يفهم ما يقول فلا يقع منه قولا واحدا والأئمة الكبار جعلوا النزاع في الكل وهو من يخلط في كلامه أو لم يعرف ثوبه أو هذى ولا يعتبر أن لا يعرف السماء من الأرض لأن ذلك كان لا يخفى إلا على المجنون (وكذلك يخرج في قتله وقذفه وسرقته وزناه وظهاره وإيلائه) وإقراره وإسلامه وكل قول أو فعل يعتبر له العقل لأن المعنى في الجميع واحد وعنه كالمجنون في أقواله وكالصاحي في أفعاله وعنه

في الحد كالصاحي وفي غيره كالمجنون وعنه أنه فيما يستقل به كعتقه وقتله بالصاحي وفيما لا يستقل به كبيعه ونكاحه كالمجنون قال جماعة

ولا تصح عبادته وقال أحمد لاتقبل صلاته أربعين يوما حتى يتوب للخبر

فرع البنج ونحوه كجنون لأنه لا لذة به نص عليه وذكر جماعة يقع لتحريمه ولهذا يعزر قال الشيخ تقي الدين قصد إزالة العقل بلا سبب شرعي محرم وفي الواضح إن تداوي ببنج فسكر لم يقع وهو ظاهر كلام جماعة

(ومن أكره على الطلاق بغير حق لم يقع طلاقه) رواه سعيد وأبو عبيد عن عمر وهو قول جماعة من الصحابة قال ابن عباس فيمن يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء ذكره البخاري ولقوله عليه السلام إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه ابن ماجه والدارقطني قال عبد الحق إسناد متصل صحيح وعن عائشة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في غلاق رواه أبو داود وهذا لفظه وأحمد وابن ماجه ولفظهما في إغلاق قال المنذري هو المحفوظ قال أبو عبيد والقتيبي معناه في إكراه لكن فسره في رواية حنبل بالغضب ذكره أبو بكر في الشافي ولأنه قول حمل عليه بغير حق أشبه الإكراه على كلمة الكفر وعنه لا يكون إلا من سلطان ذكرها ابن هبيرة والحلواني وظاهره أنه لا يلزمه شيء ولو نوى به الطلاق في أحد القولين نظرا إلى أن اللفظ مرفوع عنه بالإكراه فيبقى بنية مجردة والثاني أنه بمنزلة الكناية إن نوى به الطلاق وقع وإلا فلا حكاهما أبو الخطاب في الانتصار وحكى شيخه عن أحمد روايتين وجعل الأشبه الوقوع وهو الذي أورده

المؤلف مذهبا ولا خلاف في أنه إذا لم ينو به طلاقا ولم يتأول بلا عذر أنه لا يقع وفيه احتمال قوله بغير حق يحترز بذلك عن الإكراه بحق كإكراه الحاكم المؤلي على [ج ٧ - ص ٢٥٤]

الطلاق بغير التربص إذا لم يف وإكراه من زوجها وليان ولم يعلم السابق منهما لأنه قول حمل عليه بحق فصح كإسلام المرتد

(وإن هدده بالقتل ونحوه وأخذ المال قادر يغلب على الظن وقوع ما هدده به فهو إكراه) اختاره ابن عقيل وجزم به المؤلف وفي الوجيز لقول عمر في الذي قالت طلقني ثلاثا وإلا قطعته فطلقها ثلاثا فرده إليها رواه سعيد وهذا كان وعيدا ولأن الإكراه إنما يتحقق بالوعيد فإن الماضي من العقوبة لا يندفع بفعل ما أكره وإنما يباح الفعل المكره دفعا لما يتوعد به من العقوبة فيما بعد فعلى هذا يشترط له أمور

أحدها أن يكون ما هدده فيه ضرر كثير كالقتل والضرب الشديد فأما السب والشتم فليس بإكراه رواية واحدة وكذا أخذ المال اليسير والضرب في حق من لا يبالي به

الثاني أن يكون التهديد من قادر لأن غيره لم يخف وقوع المحذور به لأنه يمكن دفعه

الثالث أن يغلب على الظن وقوع ما هدده به

فرع ضرب ولده وحبسه ونحوهما إكراه لوالده وإكراه على عتق ويمين ونحوهما كطلاق [ج ٧ - ص ٢٥٥]

(وعنه لا يكون مكرها حتى يناله شيء من العذاب كالضرب والخنق وعصر الساق اختاره الخرقي) والقاضي والشريف وأبو الخطاب والشيرازي ونص عليه أحمد في رواية الجماعة وقال كما فعل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يشير إلى قصة عمار حين أخذه المشركون وأرادوه على الشرك فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي فجعل يمسح الدموع عن عينيه ويقول أخذك المشركون فغطوك في الماء وأمروك أن تشرك بالله ففعلت فإن أمروك مرة أخرى فافعل ذلك بهم رواه أبو حفص فعلى هذا يشترط في الضرب أن يكون شديدا أو يسيرا في حق ذي مروءة ومما يشبه الضرب وعصر الساق القيد والحبس الطويلان وأخذ المال الكثير زاد في الكافي والإخراج من الديار لا السب ونحوه رواية واحدة قاله في المغني والشرح وعنه إن هدد بقتل وعنه أو قطع طرف وقيل أو إحراق من يؤلمه فإكراه قال القاضي الإكراه يختلف قال ابن عقيل وهو قول حسن وإن سحره ليطلق فإكراه قاله الشيخ تقي الدين

تنبيه إذا أكره على طلاق امرأة فطلق غيرها أو على طلقة فطلق ثلاثا أو على لفظ صريح فأتى بكناية أو على تعليقه فنجزه وقع وإن ترك التأويل بلا عذر أو أكره على مبهمة فطلق معينة فوجهان لا يقال لو كان الوعيد إكراها لكنا مكرهين على العبادات فلا ثواب مع أنه يجوز أن يقال إننا مكرهون عليها والثواب بفضله لا مستحقا عليه عندنا ثم العبادات تفعل للرغبة ذكره في الانتصار

(ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه كالنكاح بلا ولي عند أصحابنا) لأنه عقد يسقط الحد ويثبت النسب والعدة والمهر أشبه الصحيح

[ج ٧ - ص ٢٥٦]

أو لأنه إزالة ملك فكان كالعتق ينفذ في الكتابة الفاسدة بالأداء كالصحيحة ويقع بائنا نص عليه كحكم بصحة العقد وهو إنما يكشف خافيا أو ينفذ واقعا ويجوز في حيض ولا يكون بدعة (واختار أبو الخطاب أنه لا يقع حتى يعتقد صحته) هذا رواية واختارها أيضا في المذهب والتلخيص لأن الطلاق يفيد تحريم الحل أو حل العقد ولم يوجد في الفاسد واحد منهما ولأنه نكاح فاسد فلم يقع فيه كالجمع عليه وفي المستوعب من طلق في نكاح متفق على بطلانه كمن نكحها وهو في عدة غيره أو نكحها أختها لم يصح طلاقه وعنه أنه قال أحتاط وأجيز طلاقه اختاره أبو بكر والأول عنه أظهر ولا يقع في نكاح فضولي قبل إجازته في الأصح ونقل حنبل إن تزوج عبد بلا إذن فطلق سيد جاز طلاقه وفرق بينهما (وإذا وكل في الطلاق من يصح توكيله صح طلاقه) لأنه إزالة ملك فصح التوكيل فيه كالعتق وقوله من يصح توكيله يحترز به عن الطفل والمجنون فلو وكل عبدا أو كافرا صح وإن جعل أمر الصغيرة أو المجنونة في يدها لم تملكه نص عليه وظاهر كلام أحمد أنها إذا عقلت الطلاق وقع وإن لم تبلغ كالصبي (وله أن يطلق متى شاء) لأن لفظ التوكيل يقتضي ذلك لكونه توكيلا مطلقا أشبه التوكيل في البيع إلا وقت بدعة ولا يملك بالإطلاق تعليقا (إلا أن يحد له حدا) لأن الأمر على ما أذن له لأن الأمر إلى الموكل في ذلك (ولا يطلق أكثر من واحدة) لأن الأمر المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم (إلا أن يجعل إليه) أكثر من

واحدة بلفظه أو نيته نص عليه لأنه نوى بكلامه ما يحتمله ويقبل قوله في نيته لأنه أعلم بها [ج ٧ - ص ٢٥٧]

زاد في الرعاية أو يفسخ أو يطأ وقيل لا يملك فوق طلقة بلا إذن ولا ينعزل بالوطء

فرع إذا أوقعه الوكيل ثم ادعى الزوج أنه رجع قبل إيقاع الوكيل قبل قوله ذكره أصحابنا (وإن وكل اثنين فيه فليس لأحدهما الانفراد به) لأنه إنما رضي بتصرفهما جميعا (إلا بإذن) لأنه راض بتصرف كل واحد منهما فملك الانفراد كما لو وكله وحده (وإن وكلهما في ثلاث فطلق أحدهما أكثر من الآخر وقع ما اجتمعا عليه) لأنه مأذون لهما في ذلك فلو طلق أحدهما واحدة والآخر ثلاثا وقع واحدة كما لو طلق ثنتين والآخر ثلاثا فيقع ثنتان (ولو قال لامرأته طلقي نفسك فلها ذلك) لأنه يصح توكيلها في طلاق غيرها فكذا في طلاق نفسها (كالوكيل) لأنها متصرفة بالإذن فتملك ما ملكه الوكيل فعليه لها أن تطلق متى شاءت إلا أن يحد لها حدا ولا تملك أكثر من واحدة إلا أن يأذن قال أحمد إذا نوى ثلاثا فطلقت نفسها ثلاثا فهي ثلاث وإن نوى واحدة فواحدة لأن الطلاق يكون ثلاثا وواحدة فأيهما نواه صح ولو وكل معها غيرها لم يكن لها الانفراد إلا أن يجعل ذلك إليها ولو اختلفا في العدد وقع ما اتفقا عليه فإن طلقت نفسها أو طلقها الوكيل في المجلس أو بعده وقع لأنه توكيل وقال القاضي وقدمه في الرعاية يتقيد لها بالمجلس كاختاري وجوابه بأنه توكيل فكان على التراخي كالأجنبي ولو قال طلقي ثلاثا فطلقت واحدة وقع نص عليه لأنها تملك إيقاع ثلاثا فتملك إيقاع واحدة كالوكيل ولا تملك تعليقا فلو قال

طلقي نفسك فقالت أنا طالق إن قدم زيد لم يصح لأن إذنه انصرف إلى

[ج ٧ - ص ٢٥٨]

المنجز فلم تتناول المعلق على شرط ولو قال طلقي نفسك طلاق السنة فطلقت نفسها ثلاثا فهي واحدة وهو أحق برجعتها (وإن قال اختاري من ثلاث ما شئت لم يكن لها أن تطلق أكثر من اثنتين) لأن من للتبعيض فلم يكن لها أن تختار الثلاث لأنها كل الطلاق

فرع يحرم تطليق وكيل مطلق وقت بدعة وفي وقوعه وجهان وفي المغني الزوج يملكه بملك محله ولم يعلل الأزجي عدم الوقوع إلا لمخالفة أمر الشارع فإن أوقعه ثلاثا فوجهان ولو قال أمرك بيدك أو طلاقك بيدك أو وكلتك في الطلاق فهل تملك به الثلاث على روايتين وفي الرعاية لو قال طلقي نفسك بألف فقالت في الحال طلقتك وقع بائنا بالألف وله الرجوع قبل أن تطلقه وهو بعيد

باب سنة الطلاق وبدعته

طلاق السنة ما أذن فيه الشارع والبدعة ما نهى عنه ولا خلاف أن المطلقة على الصفة الأولى مطلق للسنة قاله ابن المنذر وابن عبد البر والأصل فيه قوله تعالى ﴿ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ﴾ قال ابن مسعود وابن عباس طاهرا من غير جماع وحديث ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض [ج ٧ - ص ٢٥٩]

فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن تمس وهو في الصحيحين

(السنة في الطلاق أن يطلقها واحدة) لقول علي رواه البخاري (في طهر لم يصبها فيه) لما تقدم من قول ابن مسعود وغيره إلا في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض فبدعة في ظاهر المذهب اختاره الأكثر (ثم يدعها حتى تنقضي عدتها) أي لا يتبعها طلاقا آخر قبل انقضاء العدة لقول علي لا يطلق أحد للسنة فيندم رواه الأثرم (وإن طلق المدخول بها في حيضها أو طهر أصابها فيه فهو طلاق بدعة محرم ويقع) في قول عامتهم لأنه عليه السلام أمر ابن عمر بالمراجعة وهي لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق وفي لفظ للدار قطني قال قلت يا رسول الله أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا قال كانت تبين منك وتكون معصية وذكر في الشرح هذا الحديث مع غيره وقال كلها أحاديث صحاح ولأنه طلاق من مكلف في محله فوقع كطلاق الحامل ولأنه ليس بقربة فيعتبر لوقوعه موافقة السنة بل هو إزالة عصمة وقطع ملك فإيقاعه في زمن البدعة أولى تغليظا عليه وعقوبة له وفي المحرر وكذا أنت طالق في آخر طهرك ولم يطأ فيه وكلام الأكثر أنه مباح إلا على رواية القروء الأطهار وفي الترغيب تحملها ماءه في معنى الوطء واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يقع وهو قول ابن علية وهشام بن الحكم والسبعة لأن الله تعالى أمر به قبل العدة فإذا

طلق في غيره لم يقع كالوكيل إذا أوقعه في زمن أمره موكله بإيقاعه في غيره (ويستحب [ج ٧ - ص ٢٦٠]

رجعتها) في ظاهر المذهب وهو قول الأكثر لأنه عليه السلام أمر به ابن عمر وأدنى أحواله الاستحباب ولأنه طلاق لا يرتفع بالرجعة فلم تجب الرجعة فيه كالطلاق في طهر أصابها فيه فإنهم أجمعوا على أن الرجعة لا تجب فيه حكاه ابن عبد البر عن الجميع (وعنه أنها واجبة) ذكرها في الموجز والتبصرة والترغيب واختارها ابن أبي موسى لظاهر أمره عليه السلام بها ولأن الرجعة تجري مجرى استبقاء النكاح وهو واجب بدليل تحريم الطلاق وعنه تجب في حيض اختاره في الإرشاد والمبهج وظاهر كلامه أن الخلاف راجع إلى الصورتين وليس كذلك فإن الطاهر المصابة فيه لا تجب رجعتها رواية واحدة وتقدم حكاية الإجماع قبله ولكن يستحب لأنه طلاق بدعة فاستحب قطعه بها كطلاق الحائض

فرع إذا علقه بقيام فقامت حائضا ففي الانتصار مباح وفي الترغيب بدعي وفي الرعاية يحتمل وجهين وذكر المؤلف إن علقه بقدومه فقدم في حيضها فبدعة ولا إثم وكذا طلاقها في الطهر المتعقب الرجعة بدعي في ظاهر المذهب وعنه يجوز واختار في الترغيب ويلزمه وطؤها

(وإن طلقها ثلاثا) وقيل أو اثنتين بكلمة أو كلمات (في طهر) لم يقيده في الفروع (لم يصبها فيه كره) للاختلاف في تحريمه (وفي تحريمه روايتان) إحداهما لا يحرم ويكون تاركا للاختيار واختاره الخرقي وهو

قول عبد الرحمن بن عوف والحسن بن علي لأن الملاعن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية [ج ٧ - ص ٢٦١]

داود فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنفذه ولم ينقل أنه عليه السلام أنكره ولو لم يكن للسنة لأنكره فعليها يكره ذكره جماعة نقل أبو طالب هو طلاق السنة والثانية يحرم وهو بدعة ويقع اختاره الأكثر لقوله تعالى ﴿ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ﴾ الآية ثم قال ﴿ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ﴾ ومن طلق ثلاثا لم يبق له أمر يحدث ولم يجعل له مخرجا وقد روى النسائي عن محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله ولأنه تحريم للبضع من غير حاجة فحرم كالظهار بل هذا أولى لأن الظهار يرتفع تحريمه بالتكفير والثالثة يحرم في الطهر لا الأطهار وظاهره أنه إذا طلق اثنتين فهو للسنة وإن كان الجمع بدعة وقال المجد هو كما لو جمع بين الثلاث

مسألة إذا أوقع ثلاثا في كلمة واحدة وقع الثلاث روي عن جماعة من الصحابة وهو قول أكثر العلماء وقال جماعة من طلق البكر ثلاثا فهو واحدة وحكى المحب الطبري عن الحجاج بن أرطاة وابن مقاتل أن طلاق الثلاث واحدة وأنكر النووي حكايته عن الحجاج وأن المشهور عنه أنه لا يقع شيء وأوقع الشيخ تقي الدين من ثلاث مجموعة أو مفرقة قبل رجعة واحدة وقال إنه لا يعلم أحدا فرق بين الصورتين ولم يوقعه على حائض وفاقا لابن عقيل في الواضح لأن النهي للفساد ولا في طهر وطىء فيه وقال عن قول

عمر في إيقاع الثلاث إنما جعله لإكثارهم منه فعاقبهم على الإكثار لما عصوا بجمع [ج ٧ - ص ٢٦٢]

الثلاث فيكون عقوبة من لم يتق الله من التعزير الذي يرجع إلى اجتهاد الأئمة كالزيادة على الأربعين في حد الخمر لما أكثر الناس منه وأظهروه ساغت الزيادة عقوبة ثم هذه العقوبة إن كانت لازمة مؤبدة كانت حدا وإن كان المرجع إلى اجتهاد الإمام كان تعزيزا (وإن كانت المرأة صغيرة أو آيسة أو غير مدخول بها أو حاملا قد استبان حملها فلا سنة لطلاقها ولا بدعة) هذا هو المذهب وقاله في المحرر والوجيز وقدمه في الفروع أي من حيث الوقت وقوله (إلا في العدد) أي يثبتان من جهة العدد هذا رواية عن أحمد وحاصله أن طلاق السنة إنما هو للمدخول بها لأن غير المدخول بها لا عدة عليها وكذا الصغيرة والآيسة عدتها بالأشهر فلا تحصل الريبة والحامل التي استبان حملها عدتها بوضع الحمل ولا ريبة لأن حملها قد استبان وإنما شرطه لأنها لو كانت حاملا ولم يستبن حملها فطلقها ظنا أنها حائل ثم ظهر حملها ربما ندم على ذلك وحكى في المغني أن ابن عبد البر قال لا خلاف بين أهل العلم أن الحامل طلاقها للسنة قال ابن المنجا وفيما قاله المؤلف نظر من حيث إن السنة ما وافق أمر الله ورسوله ومن طلق أحد هؤلاء فقد وافق طلاقه ذلك لأن في حديث ابن عمر ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا رواه مسلم والطلاق في الطهر سنة فكذا في الحمل لكن الحامل التي استبان حملها قد دخل على بصيرة فلا يخاف ظهور أمر يتجدد به الندم وليست بمرتابة لعدم اشتباه الأمر ونقل ابن منصور لا يعجبني أن يطلق حائضا لم يدخل بها وعنه سنة الوقت تثبت لحامل

اختاره الخرقي فلو قال لها أنت طالق للبدعة طلقت بالوضع وعلى الأولى لو قال لإحداهن [ج ٧ - ص ٢٦٣]

أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة وقعتا ويدين في غير آيسة إذا صارت من أهل ذلك وفي الحكم وجهان

تنبيه إذا قال لصغيرة أو غير مدخول بها أنت طالق للبدعة ثم قال أردت إذا حاضت الصغيرة أو أصيبت غير المدخول بها دين والأشبه بالمذهب أنه يقبل في الحكم فإن قال في ظهر جامع فيه أنت طالق للسنة فيئست من المحيض لم تطلق وكذا إن استبان حملها إلا على قول من جعل طلاق الحائض طلاق سنة فيقع (وإن قال لها أنت طالق للسنة أو قال للبدعة طلقت في الحال) لأنه وصفها بما لا تتصف به فلغت الصفة وبقي قوله أنت طالق وذلك يوجب وقوع الطلاق في الحال وأن يكون واحدة لأن ما زاد عليها غير ملفوظ به ولا منوي وكذلك قوله أنت طالق للسنة والبدعة أو أنت طالق لا للسنة ولا للبدعة (وان قال لمن لها سنة وبدعة أنت طالق للسنة في طهر لم يصبها فيه طلقت في الحال واحدة) لأن معنى السنة في وقت السنة وذلك وقتها (وإن كانت حائضا طلقت إذا طهرت) لأن الصفة قد وجدت (وإن كانت في طهر أصابها فيه طلقت إذا طهرت من الحيضة المستقبلة) بغير خلاف نعلمه لأن ذلك هو وقت السنة في حقها لا سنة لها قبلها

فرع إذا قال لها أنت طالق ثلاثا نصفها للسنة ونصفها للبدعة طلقت في الحال طلقتين والثالثة في ضد حالها الراهنة قال القاضي وإن نوى تأخير

اثنتين ففي الحكم وجهان وقال ابن أبي موسى تطلق ثلاثا في الحال لتبعيض كل طلقة فإن قال لطاهر أنت طالق للبدعة فقيل تلغو الصفة ويقع الطلاق فإن قال لحائض [ج ٧ - ص ٢٦٤]

أنت طالق للسنة في الحال لغت الصفة ووقع الطلاق وإن قال أنت طالق ثلاثا للسنة وثلاثا للبدعة طلقت ثلاثا في الحال (وإن قال أنت طالق للبدعة وهي حائض أو في طهر أصابها فيه طلقت في الحال) لأن ذلك هو وقت البدعة وينزع في الحال إن كان ثلاثا فإن بقي حد عالم وعزر جاهل (وإن كانت في طهر لم يصبها فيه طلقت إذا أصابها أو حاضت) لأن كل واحد منهما وقت للبدعة فأيهما سبق وقع الطلاق فيه عملا بقوله للبدعة (وإن قال لها أنت طالق ثلاثا للسنة طلقت ثلاثا في أول طهر لم يصبها فيه في إحدى الروايتين) هذا هو المنصوص لأن جمع الثلاث سنة على رواية ويقع فيما ذكرنا لأن ذلك حينئذ سنة وإن كانت حائضا طلقت ثلاثا إذا طهرت (وفي الأخرى تطلق فيه) أي في طهر لم يصبها فيه (واحدة وتطلق في الثانية والثالثة في طهرين في نكاحين) أو بعد رجعتين إن عادت إليه (إن أمكن) لأنها لو بانت منه ولم تعد إليه لم يمكن إيقاع الطلاق في النكاح لعدمه وعنه تطلق ثلاثا في ثلاثة أطهار لم يصبها فيها فإن قال أردت بقولي للسنة إيقاع واحدة في الحال واثنتين في نكاحين آخرين قبل منه وإن قال أردت أن يقع في كل قرء طلقة دين وفي الحكم وجهان

فرع من نكاحها فاسد جاز طلاقها في الحيض وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت وهي حائض فهل هو للسنة أو البدعة قال ابن حمدان يحتمل وجهين

(وإن قال أنت طالق في كل قرء طلقة هي من اللائي لم يحضن لم تطلق حتى تحيض فتطلق في كل حيضة طلقة) الأشهر عندنا أن القروء الحيض فإن كانت [ج ٧ - ص ٢٦٥]

من ذوات القروء وقع بها واحدة في الحال ويقع بها طلقتان في قرأين آخرين في أولهما سواء قلنا القروء الحيض أو الأطهار وسواء كانت مدخولا بها أو لا إلا أن غير المدخول بها تبين بالأولى فإن تزوج بها وقع في القرء الثاني طلقة أخرى وكذا الحكم في الثالثة (وإن قلنا القروء الأطهار فهل تطلق طلقة في الحال يحتمل وجهين) أشهرهما تطلق طلقة في الحال لأن الطهر قبل الحيض كله قرء واحد فعلى هذا لا فرق بين كونها من اللائي لم يحضن أولا والثاني لا لأن القرء هو الطهر بين الحيضتين ولذلك لم يحنث بالطهر قبل الحيض من عدة الصغيرة في وجه وإن لم يكن قرءا لم يطلق فيه فعلى هذا يحصل الفرق بين من حاضت ومن لم تحض (ويقع بها الباقي في الأطهار الباقية) لأن الطهر قبل الحيض كله قرء واحد (وإن قال أنت طالق أحسن الطلاق وأجمله فهو كقوله أنت طالق المسنة) لأن الطلاق السني أحسن الطلاق وأجمله كقوله أعدله وأكمله وأفضله (وإن قال أقبح الطلاق وأسمجه فهو كقوله للبدعة) لأن الطلاق البدعي أقبح الطلاق وأسمجه أي تطلق في الموضع الذي تطلق فيه إذا قال أنت طالق للبدعة وظاهره أنها تطلق في الحيض أو في طهر أصابها فيه لأن ذلك زمن البدعة وفيه شيء لأنها لا تطلق إلا في الحيض فقط وصرح به في الخلاصة كقوله أفحش الطلاق أو أردأه أو أنتنه فإن كان في وقت بدعة وإلا وقت إلى زمانها وفي المحرر فهو ثلاث

إن قلنا جمعه بدعة وحكاه في الشرح عن أبي بكر ثم قال وينبغي أن تقع الثلاث في وقت البدعة ليكون جامعا [ج ٧ - ص ٢٦٦]

لبدعي الطلاق وفي الفصول وعندي يجب أن تقع الثلاث في الحيض أو الطهر المجامع فيه لأنه أفحش لما فيه من اجتماع الضيق على النفس وقطع الرجعة والعود بنكاح جديد وفيه تطويل العدة فمتى أوقعتا ثلاثا في طهر كان فاحشا لكن هناك ما هو أفحش فما أعطينا اللفظة حقها ألا ترى أنه لو قال عندي أجود نفد ثم فسره بشيء فوقه أجود منه لم يقبل فإن قال أردت طلاق السنة ليتأخر الطلاق عن نفسه إلى زمن السنة لم يقبل في الأشهر لأن لفظه لا يحتمله (إلا أن ينوي أخس أحوالك أو أقبحها أن تكون مطلقة فيقع في الحال) لأن أنت طالق يقتضي وقوعه في الحال وإنما تأخر إلى زمن السنة كعكسه فيجب أن يقع في الحال عملا بالمقتضى السالم عن المعارض

(وإن قال أنت طالق طلقة حسنة قبيحة طلقت في الحال) لأنه وصفها بصفتين مضادتين فلغتا وبقي مجرد الطلاق فوقع فإن قال إنها حسنة لكونها في زمان السنة وقبحها لإضرارها بل أو قال إنها حسنة ليتخلص من شرك وقبحه لكونها في زمان البدعة كان ذلك يرجى وقوع الطلاق عنه دين وفي الحكم وجهان

مسألة يباح الخلع والطلاق بسؤالها في زمن البدعة وقيل هو بدعة وتنقضي بدعتها بانقطاع الدم وقيل بالغسل لأثر رواه الدار قطني والنفاس كالحيض

باب صريح الطلاق وكنايته

إنما انقسم إليها لأنه لإزالة ملك النكاح فكان له صريح وكناية كالعتق

[ج ٧ - ص ٢٦٧]

والجامع بينهما الإزالة فالصريح هو الذي يفيد حكمه من غير انضمام شيء إليه وعكسه الكناية ويدل على معنى الصريح وعلم منه أن الطلاق لا يقع بغير لفظ فلو نواه بقلبه من غير لفظ لم يقع خلافا لابن سيرين والزهري ورد بقوله عليه السلام إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به متفق عليه ولأنه إزالة ملك فلم تحصل بمجرد النية كالعتق وكذا إن نواه بقلبه وأشار بأصبعه لم يقع نص عليه لأنه ليس بصريح ولا كناية

(وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه) بغير أمر ومضارع (في الصحيح عنه) لأنه موضوع له على الخصوص ثبت له عرف الشارع والاستعمال فلو قال أنت طالق أو الطلاق أو طلقتك أو مطلقة فهو صريح وعنه في أنت مطلقة ليس بصريح لأنه محتمل أن يريد طلاقا ماضيا وقيل وطلقتك كناية قال في الفروع فيتوجه أنه يحتمل الإنشاء والخبر وعلى الأول هو إنشاء وذكر القاضي في مسألة الأمر أن العقود الشرعية بلفظ الماضي اخبار وقال شيخنا هذه الصيغ إنشاء من حيث إنها أثبتت الحكم وبها تم وهي إخبار لدلالتها على المعنى الذي في النفس وهذا الذي ذكره المؤلف اختاره ابن حامد وقدمه ابن حمدان والجد وصححه في الشرح وجزم به المتأخرون لأن الفراق والسراح يستعملان في غير الطلاق كثيرا فلم يكونا صريحين فيه كسائر كناياته لقوله تعالى ﴿ واعتصموا ﴾ الآية ﴿ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب ﴾ الآية وأما قوله ﴿ فإمساك بمعروف أو

تسريح بإحسان ﴾ فليس المراد به الطلاق إذ الآية في الرجعية وهي إذا قارنت انقضاء عدتها فإما أن يمسكها برجعة وإما أن تترك حتى تنقضي عدتها فتسرح فالمراد بالتسريح في الآية قريب من معناها اللغوي وهو الإرسال [ج ٧ - ص ٢٦٨]

تنبيه إذا كان اسمها طالقا فقال يا طالق ولم يرد طلاقها أو أراد طلاقها ثلاثا فماتت بعد قوله أنت يقع وإن ماتت بعد طالق وبعد قوله ثلاثا وقع الثلاث وقيل بل طلقة ذكره ابن حمدان

فرع إذا فتح تاء أنت طلقت خلافا لأبي بكر وأبي الوفاء ويتوجه على الخلاف لو قال لمن قال لها كلما قلت لي قولا ولم أقل لك مثله فأنت طالق فقال لها مثله طلقت ولو علقه ولو كسر التاء تخلص وبقي معلقا ذكره ابن عقيل قال وله جواب آخر بقوله بفتح التاء فلا يجب قال ابن الجوزي وله التمادي إلى قبيل الموت وقيل لا يقع شيء لأن استثناء ذلك معلوم فزوجتك بفتح ونحوه يتوجه مثله وصححه المؤلف وقيل من عامي وفي الرعاية يصح جهلا أو عجزا وإلا احتمل وجهين

(وقال الخرقي) وأبو بكر ونصره القاضي وغيره وفي الواضح اختاره الأكثر (صريحه ثلاثة ألفاظ الطلاق إجماعا والفراق والسراح) كالطلاق لورودهما في الكتاب العزيز لقوله تعالى ﴿ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ ولقوله تعالى ﴿ فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ﴾ ﴿ وإن يتفرقا ﴾ الآية ولقوله تعالى ﴿ فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ﴾ ولأنهما فرقة بين الزوجين فكانا صريحين فيه كلفظ الطلاق (وما تصرف منهن) كالمتصرف من الطلاق والأول أصح لأنه لا يصح القياس على لفظ الطلاق فإنه مختص بذلك سابق إلى الأفهام من غير

قرينة ولا دلالة (فمتى أتى بصريح الطلاق وقع نواه أو لم ينوه) بغير خلاف ذكره في الشرح لأن سائر الصرائح لا تفتقر إلى نية فكذا صريح الطلاق سواء كان ذلك جادا أو هازلا حكاه ابن المنذر إجماع من

يحفظ عنه وسنده ما روى أبو هريرة مرفوعا ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب وعنه أن الصريح يفتقر إلى نية أو دلالة حال من غضب أو محاورة في كلام

(وإن نوى بقوله أنت طالق من وثاق) هو بكسر الواو وفتحها ما يوثق به الشيء من حبل ونحوه (أو أراد أن يقول طاهر فسبق لسانه) فقال طالق لأن ذلك جار مجرى لفظ الحاكي (أو أراد بقوله مطلقة من زوج كان قبله لم تطلق) لأنه قصد عدم إيقاع طلاقها فوجب ألا يقع كما لو اتصل بكلامه أنت طالق من وثاق (وإذا ادعى ذلك دين) باطنا لأنه أعلم بما أراد ولا يمكن الاطلاع على ذلك إلا من جهته وعنه كهازل على الأصح (وهل تقبل دعواه في الحكم) ولا قرينة (على روايتين) إحداهما تقبل وهو ظاهر كلامه لأنه فسر كلامه بما يحتمله احتمالا غير بعيد فقبل كما لو كرر لفظ الطلاق وأراد بالثانية التأكيد والثانية وهي الأشهر وقدمها في الرعاية أنه لا تقبل لأنه خلاف ما يقضيه الظاهر في العرف فلم يقبل في الحكم كما لو أقر بعشرة ثم قال زيوفا أو إلى شهر (إلا) على الأولى (أن يكون في حال الغضب أو بعد سؤالها الطلاق فلا يقبل) لأنه خالف الظاهر من جهتين مقتضى اللفظ ودلالة الحال (وفيما إذا قال أردت أنها مطلقة من زوج قبلي وجه ثالث أنه يقبل إن كان وجد) لأن كلامه يحتمل الصدق (وإلا فلا) أي لا يقبل إن لم

يكن وجد لأنه لا يحتمله وكذا قبل لو قال طلقتها ثم قال في نكاح آخر وقيل [ج ٧ - ص ٢٧٠]

إن لم يرفع إلى حاكم فلو ادعى أنه كان هزلا فالأظهر أنه لا يدين هو ولا سكران كما لا يقبل منهما في الحكم

فرع إذا قال أنت طالق ثم قال أردت إن قمت قبل وقيل لا ويتوجه مثله إن علقه بشرط شهدت به بينة وادعى أن معه شرطا آخر وأوقعه في الفنون وغيره لأنه لا يقبل قول الإنسان في رد شاهدين كما لو أقر أنه وكيل فلان ببيع ثم ادعى عزلا أو خيارا

(ولو قيل له طلقت امرأتك قال نعم وأراد الكذب طلقت) وإن لم ينو لأن نعم صريح في الجواب والجواب الصريح للفظ الصريح صريح ولأنه لو قال عليك ألف قال نعم وجبت فلو قيل له طلقت امرأتك فقال قد كان بعض ذلك وقال أردت الإيقاع وقع وإن قال أردت أني علقت طلاقها بشرط قبل ولو قيل له أخليتها قال نعم فكناية (ولو قيل له ألك امرأة قال لا وأراد الكذب لم تطلق) لأن قوله مالي امرأة كناية تفتقر إلى نية الطلاق فإذا نوى الكذب فما نوى الطلاق فلم يقع وقيل تطلق في الحكم كقوله كنت طلقتها وهكذا إذا نوى أنه ليس لي امرأة تخدمني أو ترضيني أو لا امرأة لي أو لم ينو شيئا لم تطلق لعدم النية المشترطة في الكناية

فرع من شهد عليه بطلاق ثلاث ثم أفتى بأنه لا شيء عليه لم يؤاخذ بإقراره لمعرفة مستنده ويقبل بيمينه أن مستنده في إقراره ذلك ممن يجهله مثله ذكره الشيخ تقي الدين واقتصر عليه في الفروع

(وإن لطم امرأته) أو أخرجها من دارها أو ألبسها ثوبا أو قبلها و

[ج ٧ - ص ٢٧١]

قال هذا طلاقك طلقت إن نواه لأنه كناية والمنصوص أنه صريح فيقع مطلقا قال أصحابنا وعلى قياسه (إذا أطعمها أو سقاها وقال هذا طلاقك طلقت) اختاره ابن حامد لأن تقريره أوقعت عليك طلاقا هذا الفعل من أجله فعلى هذا يكون صريحا وقال أكثر الفقهاء لا يقع به وإن نوى والأشهر أنه كناية لأنه يحتمل التفسير المذكور ويحتمل أن يكون سببا للطلاق لكون الطلاق معلقا عليه فصح أن يعبر به عنه لأن الكناية ما احتمل الطلاق وهذا محتمل ويحتمل أنه كناية لأنه يحتاج إلى تقرير والصريح لا يحتاجه فإن كان ذلك جوابا عن سؤالها الطلاق أو في حال الغضب وقع (إلا أن ينوي أن هذا سبب طلاقك أو نحو ذلك) فيدين لأنه إذا نوى بالصريح عدم وقوع الطلاق لم يقع فلأن لا يقع هذا بطريق الأولى والأصح أنه يقبل في الحكم لأنه يجوز أن يكون سببا له في زمان بعد هذا الزمان وفي الترغيب لو أطعمها أو سقاها ففي كونه كالضرب وجهان

(وإن قال أنت طالق لا شيء أو ليس بشيء أو لا يلزمك) أو لا يقع عليك أو طالق طلقة لا ينقص بها عدد الطلاق (طلقت) بغير خلاف نعلمه لأن ذلك رفع لجميع ما تناوله اللفظ فلم يصح كاستثناء الجميع وفي الرعاية في أنت طالق لا شيء وجه أنه لا يقع (وإن قال أنت طالق أو لا أو طالق واحدة أو لا لم يقع) على الأشهر لأن هذا استفهام فإذا اتصل به خرج عن أن يكون لفظا للإيقاع وبهذا فارق الأولى لأنه إيقاع لم

يعارضه استفهام وظاهره أنهما سواء وهو وجه لاستوائها في الاستفهام وفي آخر تطلق في الثانية [ج ٧ - ص ٢٧٢]

واحدة دون الأولى لأن قوله أولا يرجع إلى ما يليه من لفظ واحدة دون لفظ الإيقاع فيصير كأنه قال أنت طالق وفرق في المغني والشرح بينهما لأن الواحدة صفة للطلقة الواقعة فما اتصل بهما يرجع إليهما فصارت كالأولى (ويحتمل أن يقع) لأن الاستفهام يكون بالهمزة ونحوها فيقع ما أوقعه ولا يرتفع بما ذكر بعده (وإن كتب طلاق امرأته) بشيء يبين (ونوى الإيقاع وقع) رواية واحدة لأن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق أشبهت النطق ولأن الكتابة تقوم مقام الكاتب بدليل أنه عليه السلام كان مأمورا بتبليغ الرسالة فبلغ بالقول مرة وبالكتابة أخرى ولأن كتاب القاضي يقوم مقام نطقه في إثبات الديون وعنه أنه صريح نصره القاضي وأصحابه وذكره الحلواني عن أصحابنا ويتخرج أنه لغو واختاره ابن حمدان بناء على إقراره بخطه وفيه وجهان قال في الفروع ويتوجه عليهما صحة الولاية بالخط وصحة الحكم به

(وإن نوى تجويد خطه أو غم أهله لم يقع) لأنه نوى باللفظ غير الإيقاع فالكتابة الأولى وعنه بلى لأن تجويد الخط وغم أهله لا ينافي الإيقاع وجوابه بأن نية ذلك يدل على أنه لم يوجد منه الطلاق فلم يقع لفوات شرطه (وهل تقبل دعواه في الحكم على روايتين) أصحهما أنه يقبل لأن ذلك يقبل في اللفظ الصريح على قول فهنا أولى ولأنه إذا أراد غم أهله بتوهم الطلاق دون حقيقته فلا يكون ناويا للطلاق والثانية لا يقبل لقوله عليه السلام إن الله تجاوز لأمتي الخبر ولأن غم أهله يحصل

بالطلاق فيجتمع غم أهله ووقوع طلاقه والجواب أنه يدل على مؤاخذته بما نواه عند العمل به أو الكلام فإن قرأ [ج ٧ - ص ٢٧٣]

ما كتبه ففي قبوله حكما لخلاف قاله في الترغيب (فإن لم ينو شيئا فهل يقع على وجهين) وذكر أبو الخطاب أن الشريف خرجها في الإرشاد على روايتين إحداهما يقع قاله الشعبي والنخعي والحكم لأن الكتابة تقوم مقام اللفظ والثانية لا يقع إلا بنية لأن الكتابة محتملة فإنه قد يقصد بها تجربة القلم وتجويد الخط فلم يقع من غير نية كالكنايات في الطلاق

(وإن كتبه بشيء لا يتبين) كالكتابة على الهواء أو في ماء (لم يقع) في ظاهر كلامه لأن الكتابة بما لا تثبت كالهمس بلسانه بما لا يسمع (وقال أبو حفص يقع) ورواه الأثرم عن الشعبي أشبه ما لو كتبه بشيء يبين والفرق واضح وعلم منه أن الطلاق لا يقع بغير لفظ إلا في موضعين أحدهما الكتابة بشرطه والثاني الأخرس فإنه إذا طلق بالإشارة فإنه يقع بغير خلاف علمناه فلو فهمها البعض فكناية وتأويله مع صريح كالنطق وكتابته طلاق ويقع من العدد ما أشار إليه وفي الشرح إذا أشار بأصابعه الثلاث لم يقع إلا واحدة لأن إشارته لا تكفي

(وصريح الطلاق في لسان العجم بهشتم) بكسر الباء والهاء وسكون الشين المعجمة وفتح التاء ومعناه خليتك وهي واحدة إن لم ينو أكثر ولو لم تكن صريحة لم يكن في العجمية صريح للطلاق ولا يضر كونها بمعنى خليتك لأن معنى طلقتك خليتك فإن زاد بسيار فثلاث وفي المذهب ما نواه ونقله ابن منصور وإن كل شيء بالفارسية على ما نواه لأنه ليس له

حد مثل كلام عربي (فإن قاله العربي ولا يفهمه لم يقع) لأنه لم يختر الطلاق لعدم علمه [ج ٧ - ص ٢٧٤]

بمعناه (وإن نوى موجبه فعلى وجهين) أحدهما لا يقع جزم به في الوجيز وهو ظاهر الفروع لأنه لم يتحقق فيه اختيار لما لا يعلمه أشبه ما لو نطق بكلمة الكفر من لا يعرف معناه والثاني يقع بنية موجبة عند أهله لأنه أتى بالطلاق ناويا مقتضاه فوقع كما لو علمه

فرع من لم تبلغه الدعوة فهو غير مكلف ويقع طلاقه ذكره في الانتصار وعيون المسائل و المفردات

فصل

(والكنايات) قال الجوهري هي أن يتكلم بشيء ويريده غيره وقد كنيت عن كذا وقال ابن القطاع كنيت عن الشيء سترته ولمراد بها أنها تشبه الصريح وتدل على معناه فإن لم يكن كذلك فليس بصريح ولا كناية نحو قومي واقعدي (نوعان ظاهرة) لأن معنى الطلاق فيها أظهر من الثاني (وهي سبعة) ألفاظ (أنت خلية) هي في الأصل الناقة تطلق من عقالها ويخلى عنها ويقال للمرأة خلية كناية عن الطلاق قاله الجوهري وجعل أبو جعفر مخلاة كخلية ويفرق بينهما (وبرية) بالهمز وتركه (وبائن) أي منفصلة (وبتة) بمعنى مقطوعة (وبتلة) بمعنى منقطعة وسميت مريم البتول لانقطاعها عن النكاح بالكلية (وأنت حرة) كذا ذكرها الأكثرون أنها من الكنايات الظاهرة لأن الحرة هي التي لا رق عليها ولا شك أن النكاح رق وفي الخبر فاتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أي أسرى

والزوج ليس له على الزوجة إلا رق الزوجية فإذا أخبر بزوال

الرق فهو الرق المعهود وهو رق الزوجية (وأنت الحرج) بفتح الحاء والراء يعني الحرام والإثم زاد في المغني أمرك بيدك وأسقط أنت الحرج وزاد أبو الخطاب أنت طالق لا رجعة لي عليك وفيه نظر لأنه من حيث الطلاق صريح ومن حيث البينونة هل هو صريح أو كناية فيه احتمالان (وخفية) هي النوع الثاني وهي أخفى من الدلالة عن الأولى (نحو اخرجي) ودعيني أو دعيني قاله في الرعاية (واذهبي وذوقي وتجرعي وخليتك وأنت مخلاة) أي فأنت مطلقة من قولهم خلي سبيلي فهو مخلى (وأنت واحدة) أي منفردة (ولست لي بامرأة واعتدي واستبري) استبري أصله الهمز لأنه من قولهم استبرأت الجارية إذا تركتها حتى تبرأ رحمها وتبين حالها هل هي حامل أولا (واعتزلي) اعتزل الشيء إذا كان بمعزل منه فمعنى اعتزلي أي كوني وحدك في جانب (وما أشبهه) كقوله اختاري نفسك ووهبتك لأهلك ولا حاجة لي بك والله قد أراحك مني وما بقي شيء وجرى القلم بما فيه وأغناك الله فهذا يقع بما نواه لأنه محتمل له وإن لم ينو شيئا وقعت واحدة لأنه اليقين وفي المغني والشرح في أنت واحدة يقع واحدة وإن نوى ثلاثا لأنه لا يحتمل أكثر منها قال ابن عقيل وإن الله قد طلقك ونقل أبو داود قال فرق الله بيني وبينك في الدنيا والآخرة قال إن كان يريد أي دعاء يدعو به فأرجو أنه ليس بشيء فلم يجعله شيئا مع نية الدعاء فظاهره أنه شيء مع نية الطلاق بناء على أن الفراق صريح أو للقرينة يؤيده ما قاله الشيخ تقي الدين في إن أبرأتني

فأنت طالق فقالت أبرأك الله مما يدعي النساء على الرجال فظن أنه يبرأ فطلق [ج ٧ - ص ٢٧٦]

قال يبرأ أو ظهر أن في كل مسألة قولين هل يعمل بالإطلاق للقرينة وهي تدل على النية أم تعتبر النية قال في الفروع إن الله قد باعك أو قد أقالك ونحو ذلك

(واختلف في قوله الحقي بأهلك وحبلك على غاربك) الغارب مقدم السنام أي أنت مرسلة مطلقة غير مشدودة ولا ممسكة بعقد النكاح (وتزوجي من شئت وحللت للأزواج ولا سبيل لي عليك) السبيل الطريق يذكر ويؤنث لقوله تعالي ﴿ وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ﴾ وقوله تعالى ﴿ قل هذه سبيلي ﴾ ولا سلطان لي عليك أي لا ولاية لي عليك والسلطان الوالي من السلاطة وهو القهر وكذا غط شعرك وتقنعي (هل هي ظاهرة أو خفية على روايتين) أشهرهما أنها كناية ظاهرة جزم بها في الوجيز كأنت حرة أو أعتقتك على الأصح فيهما لأن النكاح رق والثانية خفية لأنه عليه السلام قال لابنة الجون الحقي بأهلك متفق عليه ولم يكن ليطلق ثلاثا لنهيه عنه وكاعتدي واستبرئي والحقي بأهلك على الأصح فيهن وجعل أبو بكر لا حاجة لي فيك وباب الدار لك مفتوح كأنت بائن وفي الفراق والسراح وجهان

(ومن شرط وقوع الطلاق بالكناية) ولو ظاهرة فيها رواية اختارها أبو بكر (أن ينوي بها الطلاق) لأنها كناية فلا يقع بها طلاق إلا بنية كالخفية ويشترط فيها أن تكون مقارنة للفظ وقيل أوله وقدمه في المحرر

وفي الرعاية أو قبله قال في الشرح فإن وجدت في أوله وعريت عنه في سائره وقع خلافا لبعض الشافعية (إلا أن يأتي بها حال الخصومة والغضب [ج ٧ - ص ٢٧٧]

فعلى الروايتين) أشهرهما وهو مختار كثير من الأصحاب أنها تطلق قال في رواية الميموني إذا قال لزوجته أنت حرة لوجه الله في الغضب أخشى أن يكون طلاقا إذ دلالة الحال كالنية بدليل أنها تغير حكم الأقوال والأفعال فإن من قال يا عفيف ابن العفيف حال تعظيمه كان مدحا ولو قاله حال الشتم كان ذما وقذفا والثانية لا يقع لأنه ليس بصريح في الطلاق ولم ينوه فلم يقع كحالة الرضى وعلى المذهب لو لم يرده أو أراد غيره لم يقبل حكما في الأشهر (وإن جاءت جوابا لسؤالها الطلاق فقال أصحابنا يقع بها الطلاق) لأن في ذكر الكناية عقيب سؤالها دلالة ظاهرة على إرادته فوجب الحكم بوقوعه عملا بالدلالة الظاهرة (والأولى في الألفاظ الذي يكثر استعمالها لغير الطلاق نحو اخرجي واذهبي وروحي أنه لا يقع بها طلاق حتى ينويه) لأن ما كثر استعماله إذا وجد عقيب خصومة أو غضب أو سؤال طلاق لا يغني عن النية لأن الكثرة تصرفه عن إرادة الطلاق بخلاف ما قل فلو ادعى أنه لم ينو فالمنصوص أنه لا يصدق في عدمها لأن الجواب ينصرف إلى السؤال وقيل يقبل في الحكم لأثر رواه سعيد بن عثمان ولأن قوله محتمل فقبل كما لو كرر لفظا وقال أردت التأكيد

(ومتى نوى بالكناية الطلاق) وقع بها رجعي مالم يقع به الثلاث في ظاهر المذهب ويشترط فيها أن تكون مقارنة للفظ وقيل أوله في الرعاية أو قبله وعنه مع خصومة وغضب قطع به أبو الفرج وغيره (وقع بالظاهر

ثلاث وإن نوى واحدة) هذا ظاهر المذهب روي ذلك عن علي وابن عمر وزيد بن ثابت [ج ٧ - ص ٢٧٨]

وابن عباس وأبي هريرة في وقائع مختلفة ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة ولأنه لفظ يقتضي البينونة بالطلاق فوقع ثلاثا كما لو طلق ثلاثا وإفضاؤه إلى البينونة ظاهر وظاهره لا فرق بين المدخول بها وغيرها لأن الصحابة لم يفرقوا ولأن كل لفظة أوجبت الثلاث في حق المدخول بها أوجبتها في غيرها كأنت طالق ثلاثا وحديث ركانة ضعفه أحمد وغيره (وعنه يقع مانواه) اختاره أبو الخطاب لما روى ركانة أنه طلق امرأته البتة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال والله ما أردت إلا واحدة فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمن عمر والثالثة في زمن عثمان وفي لفظ قال هو ما أردت رواه أبو داود وصححه ابن ماجه والترمذي وقال سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب ولأنه عليه السلام قال لابنة الجون الحقي بأهلك وهو لا يطلق ثلاثا (وعنه ما يدل على أنه يقع واحدة بائنة) نقلها حنبل لأن لفظه اقتضى البينونة دون العدد فوقعت واحدة بائنة كالخلع واعلم أن كلام أكثر الأصحاب كالمؤلف وخالفهم المجد فجعل الخلاف في قبول قوله في دعوى عدم النية فإنه قال ولا يقع بكناية إلا بنية فإن كان في حال خصومة أو غضب أو ذكر الطلاق وقال لم أرد بها الطلاق قبل منه وعنه لا يقبل في الحكم خاصة وقيل يقبل منه في الألفاظ التي يكثر استعمالها في غير الطلاق فإذا نوى بالكناية الظاهرة

الطلاق لزمه الثلاث إلا أن ينوي دونها فيدين فيه ويكون رجعيا وفي قبوله في الحكم روايتان وعنه يقطع طلقة بائنة [ج ٧ - ص ٢٧٩]

فرع إذا قال أنت طالق بائن أو البتة أو بلا رجعة فالخلاف السابق ذكره معظم الأصحاب زاد في الشرح أنه لا يحتاج إلى نية لأنه وصف بها الطلاق الصريح فإن قال أنت واحدة بائنة أو بتة فرجعية وعنه بائنة وعنه ثلاث كأنت طالق واحدة ثلاثا وفي الفصول عن أبي بكر في أنت طالق ثلاثا واحدة تقع واحدة لأنه وصف الواحدة بالثلاث وليس كذلك لأنه إنما وصف الثلاث بالواحدة فوقعت الثلاث ولغا الوصف

(ويقع بالخفية ما نواه) لأن اللفظ لا دلالة له على العدد والخفية ليست في معنى الظاهرة فوجب اعتبار النية ويكون الواقع رجعيا فيما إذا نواها وإن نوى أكثر في غير أنت واحدة قاله القاضي والمؤلف وقع (فإن لم ينو عددا وقع واحدة) لأنها اليقين (وأما مالا يدل على الطلاق نحو كلي واشربي واقعدي واقربي وبارك الله فيك وأنت مليحة أو قبيحة فلا يقع بها طلاق) لأنه ليس بكناية (وإن نوى) لأن اللفظ لا يحتمل الطلاق فيه فلو وقع به الطلاق وقع بمجرد النية وقيل كلي واشربي كناية لأنه يحتمل كلي ألم الطلاق واشربي كأس الفراق فرقع كتجرعي وجوابه أن اللفظ لا يستعمل إلا فيما لا ضرر فيه نحو قوله تعالى ﴿ كلوا واشربوا هنيئا ﴾ ﴿ فكلوه هنيئا مريئا ﴾ فلم تكن كناية وفارق تجرعي وذوقي فإنه يستعمل في المكاره لقوله تعالى ﴿ ذق إنك أنت العزيز الكريم ﴾ وكذا قوله أنا طالق لأن الزوج ليس محلا للطلاق

(فإن قال أنا منك طالق فكذلك) أي لا تطلق زوجته نص عليه

[ج ٧ - ص ٢٨٠]

في رواية الأثرم وقاله ابن عباس رواه أبو عبيد والأثرم ولأن الرجل مالك في النكاح والمرأة مملوكة فلم يقع بإضافة الإزالة إلى المالك كالعتق (ويحتمل أنه كناية) تطلق به بالنية روي عن عمر وابن مسعود لأن الطلاق إزالة النكاح وهو مشترك بينهما فإذا صح في أحدهما صح في الآخر والأول أولى لأنه لا خلاف أن الطلاق المذكور لا يقع من غير نية ولو ساوى الرجل المرأة لوقع بغير نية كما لو قال لها أنت طالق ولأن وقوعه هنا يستلزم وقوعه في أنا طالق إذ لا فرق بينهما

(وإن قال أنا منك بائن أو حرام) أو بريء (فهل هو كناية أو لا على وجهين) كذا أطلقهما في الفروع وهذه المسألة توقف عنها أحمد أشهرهما أنه لغو لأن الرجل محل لا يقع الطلاق بإضافة صريحه إليه فلم يقع بإضافة كنايته إليه كالأجنبي والثاني كناية لأن هذا اللفظ يوصف به كل من الزوجين يقال بان منها وبانت منه وحرم عليها وحرمت عليه وبريء منها وبرئت منه وكذا لفظ الفرقة فإن قال أنا بائن بحذف منك فذكر القاضي إذا قال أمرك بيدك فقالت أنت بائن ولم تقل مني أنه لا يقع وجها واحدا وإن قالت أنت مني بائن فعلى وجهين فيخرج هنا مثله (وإن قال أنت علي كظهر أمي ينوي به الطلاق لم يقع وكان ظهارا) لأنه صريح في الظهار فلم يكن كناية في الطلاق كما لا يكون الطلاق صريحا في الظهار ولأن الظهار تشبيه بمن تحرم عليه على التأبيد والطلاق يفيد تحريما غير

مؤبد ولو صرح به فقال أعني به الطلاق لم يصر طلاقا لأنه لا تصلح الكناية به عنه [ج ٧ - ص ٢٨١]

(وإن قال أنت علي حرام أو ما أحل الله علي حرام) أو الحل علي حرام زاد في الرعاية أو حرمتك (ففيه ثلاث روايات) عن الإمام أحمد رضي الله عنه (إحداهن أنه ظهار وإن نوى الطلاق اختاره الخرقي) وهو المنصوص في رواية جماعة وقاله عثمان وابن عباس وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع لقول ابن عباس في الحرام تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا رواه الأثرم ولأنه صريح في تحريم الزوجة فكان ظهارا وإن نوى غيره (والثانية كناية ظاهرة) نقل الأثرم وحنبل الحرام ثلاث حتى لو وجدت رجلا حرم امرأته عليه وهو يرى أنها واحدة فرقت بينهما مع أن أكثر الروايات عنه كراهة الفتيا في الكناية الظاهرة قال في المستوعب لاختلاف الصحابة ولأنه لو قال أنا منك حرام كان كناية في وجه فتجب إذا قال أنت حرام كذلك وعنه كناية خفية (والثالثة) هو (يمين) وقاله أبو بكر وعمر وابن عباس وعائشة روى سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس يقول إذا حرم الرجل عليه امرأته فهو يمين يكفرها ولقوله تعالى ﴿ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ﴾ فجعل الحرام يمينا قال في رواية مهنا إذا قال أنت علي حرام ونوى يمينا ثم تركها أربعة أشهر لا يكفر إيلاء إنما الإيلاء أن يحلف بالله أن لا يقرب امرأته فظاهره أنه إذا نوى اليمين كان يمينا فإن نوى شيئا فعنه والأشهر أنه ظهار فإن نوى ظهارا [ج ٧ - ص ٢٨٢]

أو طلاقا فظهار وإن قاله لمحرمة بحيض ونحوه ونوى أنها محرمة به فلغو وكذا إن أطلق لأنه يحتمل الخبر ويحتمل إنشاء التحريم ذكره المؤلف قال في الفروع ويتوجه كإطلاقه لأجنبية

فرع من حلف بالطلاق أنه لا حق عليه لزيد فقامت عليه بينة شرعية حنث حكما ذكره السامري وابن حمدان

(وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق فقال أحمد تطلق امرأته ثلاثا) لأنه صريح بلفظ الطلاق ووقع ثلاثا لأن الطلاق معرف بالألف واللام وهو يقتضي الاستغراق وعنه يقع ما نواه لأنهما يرادان لغير الاستغراق لا سيما في أسماء الأجناس ونقل أبو داود فيمن قال لرجل ما أحل الله عليه حرام يعني به الطلاق إن دخلت لك في خير أو شر والرجل مريض يعوده قال لا ولا يشيع جنازته أخاف إنه ثلاثا ولا أفتى به (وإن قال أعني به طلاقا طلقت واحدة) رواه عنه جماعة وهي المشهورة لأنه صريح في الطلاق وليس هذا صريحا في الظهار إنما هو صريح في التحريم وهو ينقسم إلى قسمين فإذا بين بلفظ إرادة تحريم الطلاق صرف إليه (وعنه أنه ظهار فيهما) أي في المسألتين لأنه صريح فيه فلم يصر طلاقا بقوله أعني به الطلاق أو طلاقا

فرع لو نوى في حرمتك على غيري فكطلاق ذكره في الترغيب وغيره ولو قال فراشي علي حرام فإن نوى امرأته فظهار وإن نوى فراشه فهو يمين

نقله ابن هانىء [ج ٧ - ص ٢٨٣]

(وإن قال أنت علي كالميتة والدم) والخمر (وقع ما نواه) على المذهب (من الطلاق) لأنه إذا نواه فهو طلاق لأنه يصلح أن يكون كناية فيه ويقع ما نواه من العدد (والظهار) إذا نواه وهو يقصد تحريمها عليه مع بقاء نكاحها لأنه يشبهه ويحتمل أن لا يكون ظهارا وجزم به في عيون المسائل كما لو قال أنت علي كظهر البهيمة (واليمين) وهو يريد بذلك ترك وطئها لا تحريمها ولا طلاقها فهو يمين ولأن فائدة كونه يمينا ترتب الحنث والبر ثم ترتب الكفارة وعدمها وفي ذلك نظر من حيث إن قوله كالميتة ليس بصريح في اليمين لأنه لو كان صريحا لما انصرف إلى غيرها بالنية وإذا لم يكن صريحا لم تلزمه الكفارة لأن اليمين بالكناية لا تنعقد لأن الكفارة إنما تجب لهتك القسم (وإن لم ينو شيئا فهل يكون ظهارا أو يمينا على وجهين) هما روايتان أصحهما أنه ظهار لأن معناه أنت حرام علي كالميتة والدم فإن تشبيهها بهما يقتضي التشبيه بهما في الأمر الذي اشتهر أنه هو التحريم لقوله تعالى ﴿ حرمت عليكم الميتة والدم ﴾ والثاني أنه يمين لأن الأصل براءة الذمة فإذا أتى بلفظ محتمل ثبت فيه أقل الحكمين لأنه اليقين وما زاد مشكوك فيه (وإن قال حلفت بالطلاق) أو قال علي يمين بالطلاق (وكذب لزمه إقراره في الحكم) على الأصح لأنه خلاف ما أقر به ولأنه إذا أقر ثم قال كذبت كان جحودا بعد الإقرار فلا يقبل كما لو أقر بدين ثم أنكر والثانية لا يلزمه شيء لأنه لم يحلف واليمين إنما تكون

بالحلف (ولا يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى) على الأصح لأنه يحتمل ما قاله [ج ٧ - ص ٢٨٤]

لأن الذي قصد الكذب لا نية له في الطلاق فلا يقع به شيء لأنه ليس بصريح في الطلاق فلم يقع به كسائر الكنايات وحكى في زاد المسافر عن الميموني أن أحمد قال إذا قال حلفت بالطلاق ولم يكن حلف يلزمه الطلاق ويرجع إلى نيته في الثلاث والواحدة وقال القاضي مقتضى قول أحمد يلزمه الطلاق أي في الحكم ويجعل أنه طلاق إذا نواه

فرع يقبل قوله في قدر ما حلف به وفي الشرط الذي علق اليمين به لأنه أعلم بحاله ويمكن حمل كلام أحمد على هذا فيلزمه في ظاهر الحكم لا فيما بينه وبين الله تعالى

فصل

(إذا قال لامرأته أمرك بيدك) فهي كناية ظاهرة (فلها أن تطلق ثلاثا وإن نوى واحدة) في ظاهر المذهب وأفتى به أحمد مرارا ورواه البخاري في تاريخه عن عثمان وقاله علي وابن عمر وابن عباس وفضالة ونصره في الشرح لما روى أبو داود والترمذي بإسناد رجاله ثقات عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو ثلاث قال البخاري هو موقوف على أبي هريرة ولأنه يقتضي العموم في جميع أمرها لأنه اسم جنس مضاف فيتناول الطلقات الثلاث كما لو قال طلقي نفسك ما شئت فلو قال أردت واحدة لم يقبل لأنه خلاف مقتضى اللفظ ولا يدين وعنه واحدة ما لو ينو أكثر قطع به أبو الفرج وصاحب التبصرة كاختاري عنه وفيه غير مكرر

ثلاثا وعنه ثلاث بنيتها لها كقوله في الأصح طلقي نفسك ثلاثا فتطلق بنيتها (وهو في يدها) أي على التراخي [ج ٧ - ص ٢٨٥]

نص عليه لقول علي ولم يعرف له مخالف في الصحابة فكان كالإجماع ولأنه نوع تمليك في الطلاق فملكه المفوض إليه في المجلس وبعده كما لو جعله لأجنبي (ما لم يفسخ) فإن فسخها بطلت الوكالة كسائر الوكالات (أو يطأ) لأنه يدل على الفسخ أشبه ما لو فسخ بالقول وقيل يتقيد بالمجلس كالخيار وجوابه بأنه توكيل مطلق أشبه التوكيل في البيع ويعتبر أهليتها فلا يصح من صغيرة ولا مجنونة

فرع يجوز أن يجعل أمر امرأته بعوض قال أحمد إذا قالت اجعل أمري بيدي وأعطيك عبدي فلها أن تختار ما لم يطأ لأن التوكيل لا يبطل بدخول العوض فيه

(وإن قال لها اختاري نفسك لم يكن لها أن تطلق أكثر من واحدة) رجعية حكاه أحمد عن ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وعائشة وغيرهم ولأن اختاري تفويض معين فيتناول ما يقع عليه الاسم وهو طلقة رجعية لأنها بغير عوض بخلاف ما سبق فإنه أمر مضاف اليها فيتناول جميع أمرها (إلا أن يجعل اليها أكثر من ذلك) كاختاري ما شئت أو ثنتين أو ثلاثا أو نيته وهو أن ينوي بقوله اختاري عددا فإنه يرجع إلى ما نواه لأنها كناية خفية (وليس لها أن تطلق إلا ما دامت في المجلس) وظاهره ولو طال (ولم يتشاغلا بما يقطعه) ذهب أكثر العلماء أن التخيير على الفور رواه النجاد عن عمر وعثمان وروي عن ابن مسعود

وجابر ونص عليه أحمد وقيل متراخ كالأمر وقاله ابن المنذر واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا

[ج ٧ - ص ٢٨٦]

تعجلي حتى تستأمري أبويك وكان واجبا عليه وجوابه أنه قول من سمينا ولأنه خيار تمليك فكان على الفور كخيار القبول وأما الخبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها الخيار على التراخي وخلافنا في المطلق وأمرك بيدك توكيل والتوكيل يعم الزمان ما لم يقيده بقيد بخلاف مسألتنا وعنه إن لم يتصل الجواب لم يقع وشرطه ما لم يشتغلا بقاطع لأنه بالتشاغل يكون إعراضا عن قوله اختاري ومن المقول لها إعراضا عن القبول أشبه ما لو افترقا (فإن جعل لها الخيار اليوم كله) جاز (أو جعل أمرها في يدها فردته) بطل كالوكيل (أو رجع فيه أو وطئها بطل خيارها هذا المذهب) المنصوص عليه أن أمرك بيدك على التراخي واختاري على الفور ويحتمل ألا تنفسخ الوكالة كما لو وكله في بيع دار وسكنها (وخرج أبو الخطاب في كل مسألة وجها مثل حكم الأخرى) أي يقاس كل من المسألتين على الأخرى وقد ذكر المؤلف في كل مسألة حكمين الأول على التراخي وأن لها أن تطلق ثلاثا وفي الثانية الفور وان ليس لها أن تطلق أكثر من واحدة إلا بشرطه قلت كلام أبي الخطاب في كتابه من حيث اللفظ لا يقتضي تخريج العدد من إحدى المسألتين على الأخرى ومن حيث إنه نفي الفرق بينهما يقتضي ذلك إلا أنه يمكن حمله على نفي الفرق من حيث التراخي والفور لا من حيث العدد

تنبيه إذا قال اختاري اليوم وغدا وبعد غد فلها ذلك فإن ردته في الأول بطل كله لأنه خيار واحد بخلاف ما لو قال اختاري اليوم بعد غد فإنها

إذا ردته في الأول لم يبطل بعد غد لأنهما خياران ينفصل أحدهما

[ج ٧ - ص ٢٨٧]

عن صاحبه فإن نوى بقوله اختاري نفسك إيقاع الثلاث وقع وإن كرر اختاري ثلاثا فإن أراد إفهامها وليس له نية فواحدة وإلا فثلاث نص عليه وإن أطلق فروايتان قاله في المغني فلو خيرها شهرا فاختارت نفسها ثم تزوجها لم يكن لها عليه خيار لأن الخيار المشروط في عقد لا يثبت في عقد سواه كالبيع

فرع إذا قال اختاري نفسك يوما فابتداؤه من حين تطلق إلى مثله من الغد وإن قال شهرا فمن ساعة نطق إلى استكمال ثلاثين يوما إلى مثل تلك الساعة

(ولفظه الأمر والخيار كناية) ظاهرة وخفية (في حق الزوج يفتقر) وقوع الطلاق (إلى نيته) لأن كلاهما يفتقر إلى النية على ما مضى وكذا كذبه بعد سؤالها الطلاق (فإن قبلته بلفظ الكناية نحو اخترت نفسي افتقر إلى نيتها أيضا) لأنها موقعة للطلاق بلفظ الكناية فافتقر إلى نيتها كالزوج فلو قالت اخترت نفسي وأنكر وجوده قبل قوله لأنه منكر أشبه ما لو علق طلاقها على دخول الدار فادعته وأنكر (وإن قالت طلقت نفسي وقع من غير نية) لأنه صريح كأنت طالق ويقع من العدد ما نوياه دون ما نواه أحدهما وإن نوى أحدهما دون الآخر لم يقع لفقد النية (وإن اختلفا في نيتها فالقول قولها) لأنها أعلم بنيتها ولا يعلم ذلك إلا من جهتها (وإن

اختلفا في رجوعه فالقول قوله) لأنهما اختلفا فيما يختص به كما لو اختلفا في نيته

مسائل الأجنبي في ذلك كالمرأة والمذهب إلا أنه متراخ ويقع بإيقاع

[ج ٧ - ص ٢٨٨]

الوكيل بصريح أو كناية بنية وفي وقوعه بكناية بنية ممن وكل فيه بصريح وجهان وكذا عكسه وفي الترغيب ولا يقع بقولها اخترت بنية حتى تقول نفسي أو أبوي أو الأزواج ونقل ابن منصور إن اختارت زوجها فواحدة ونفسها ثلاث وعنه إن خيرها فقالت طلقت نفسي ثلاثا وقعت وإن أنكر قولها قبل قوله وتقبل دعوى الزوج أنه رجع قبل إيقاع وكيله عند أصحابنا والمنصوص أنه لا يقبل إلا بنية قال الشيخ تقي الدين وكذا دعوى عتقه ورهنه ونحوه ومن وكل في ثلاث فأوقع واحدة أو عكسه فواحدة نص عليهما ولا يملك بالإطلاق تعليقا

(وإن قال طلقي نفسك) فهل يختص بالمجلس فيه وجهان أصلهما هل تلحق بالأولى أو الثانية وذلك توكيل يبطل برجوعه وكذا لو وكلها بعوض نص عليه ويرد الوكيل (فقالت اخترت نفسي ونوت الطلاق وقع) نصره في الشرح وغيره لأنه فوض إليها الطلاق وقد أوقعته أشبه ما لو أوقعته بلفظه (ويحتمل أن لا يقع) لأنه فوضه إليها بلفظه الصريح فلا يصح أن يوقع غير ما فوضه إليها والأول أصح لأن التوكيل في شيء لا يقتضي إيقاعه بلفظه كما لو وكله في البيع فباعه بلفظ التمليك وكما لو قال اختاري نفسك فقالت طلقت نفسي فإنه يقع مع اختلاف اللفظ (وليس لها أن تطلق أكثر من واحدة) لأنه أقل ما يقع عليه الاسم (إلا أن يجعل إليها أكثر منها) لأن الطلاق يكون واحدة وثلاثا فأيهما نواه

فقد نوى بلفظه ما احتمله ومميز ومميزة في ذلك كله كالبالغين نص عليه

[ج ٧ - ص ٢٨٩]

(وإن قال وهبتك لأهلك) فهو كناية إن نوى به الإيقاع وقع وإن لم ينو به الإيقاع فهو كناية في حقها فيفتقر إلى قبولهم والنية من الزوج لأنه ليس بصريح (فإن قبلوها فواحدة) رجعية (وإن ردوها فلا شيء) هذا هو المشهور وهو قول ابن مسعود وعطاء ومسروق لأنه تمليك للبضع فافتقر إلى القبول كاختاري وكالنكاح وعلى أنه لا يكون ثلاثا لأنه محتمل فلا يحمل عليها عند الإطلاق كاختاري ولأنها طلقة ليس عليها عدة بغير عوض قبل استيفاء فكانت رجعية كأنت طالق وقوله واحدة محمول على ما إذا أطلق النية أو نواها فإن نوى ثنتين أو ثلاثا فهو على مانوى كسائر الكنايات (وعنه إن قبلوها فثلاث وإن ردوها فواحدة) رجعية وقاله زيد بن ثابت والحسن وعن أحمد إن قبلوها فواحدة بائنة وإن ردوها فواحدة رجعية وقاله علي بن أبي طالب وصيغة القبول أن يقول أهلها قبلناها نص عليه (وكذلك إن قال وهبتك لنفسك) أي فيها من الخلاف ما سبق فإن ردت ذلك فلغو وعنه رجعية إذا نوى بالهبة والأمر والخيار الطلاق في الحال وقع

تنبيه لم يتعرض المؤلف لمسألة البيع وحكمها أنه إذا باعها لغيره فلغو وإن نوى الطلاق نص عليه لأنه لا يتضمن معنى الطلاق لكونه معاوضة والطلاق مجرد إسقاط وفي الترغيب في كونه كناية كهبة وجهان وذكر ابن حمدان إن ذكر عوضا معلوما طلقت مع النية والقبول نقل حنبل وبائع ومشتر نكائن يؤدبان ولا قطع ويحبسان حتى يظهرا توبة [ج ٧ - ص ٢٩٠]

باب ما يختلف به عدد الطلاق

(يملك الحر ثلاث تطليقات وإن كان تحته أمة والعبد اثنتين وإن كان تحته حرة) وهذا مختار لعامة الأصحاب وهو قول عثمان وزيد وابن عباس لما روى أبو رزين قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قوله تعالى ﴿ الطلاق مرتان ﴾ فأين الثالثة قال تسريح بإحسان رواه أبو داود وصححه ابن القطان وقال عمر يطلق العبد تطليقتين رواه الشافعي والدارقطني بإسناد جيد وعن عائشة مرفوعا قال طلاق العبد اثنتان رواه الدارقطني بإسناد ضعيف ولأن الطلاق خالص حق الزوج وهو مما يختلف بالحرية والرق فكان اختلافه كعدد المنكوحات وظاهره ولو طرأ رقه كلحقوق ذمي بدار حرب فاسترق وقد كان طلق ثنتين وقلنا ينكح عبد حرة نكح هنا وله طلقة ذكره المؤلف وفي الترغيب وجهان (وعنه أن الطلاق بالنساء فيملك زوج الحرة ثلاثا وإن كان عبدا وزوج الأمة اثنتين وإن كان حرا) هذا قول ابن مسعود وروي عن علي لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة طلقتان رواه أبو داود والترمذي والبيهقي ولأن المرأة محل الطلاق فيعتبر بها كالعادة والأول أصح والجواب عن حديث عائشة بأنه من رواية طاهر بن أسلم وهو منكر الحديث قاله أبو داود مع أن الدارقطني أخرجه في سننه عن عائشة مرفوعا قال طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ولأن

الحر يملك أن يتزوج أربعا فملك ثلاث طلقات كما لو كان تحته حرة ولا خلاف في أن [ج ٧ - ص ٢٩١]

الحر الذي زوجته حرة طلاقه ثلاثا والعبد الذي تحته أمة طلاقه اثنتان وإنما الخلاف فيما إذا كان أحدهما حرا والآخر رقيقا

فرع المعتق بعضه كحر وفي الكافي كقن والمكاتب والمدبر والمعلق عتقه بصفة كالقن

(فإذا قال أنت الطلاق أو الطلاق لي لازم) أو الطلاق يلزمني أو علي الطلاق أو أنت طالق الطلاق أو يلزمني الطلاق (ونوى الثلاث طلقت ثلاثا) لأن ذلك صريح في المنصوص لأنه لفظ بالطلاق وهو مستعمل في عرفهم قال الشاعر % أنوهت باسمي في العالمين % % وأفنيت عمري عاما فعاما % % فأنت الطلاق وأنت الطلاق % % وأنت الطلاق ثلاثا تماما %

وقيل ليس بصريح لأنه وصفها في قوله أنت الطلاق بالمصدر وأخبر به عنها وهو تجوز والباقي كذلك لأن من كثر منه شيء يضره فهو عليه كالدين قلت وقد اشتهر استعماله في الإيقاع فكان صريحا وسواء كان منجزا أو معلقا بشرط أو محلوفا به (وإن لم ينو شيئا) فعنه يقع ثلاث اختاره أبو بكر وفي الروضة هو قول جمهور الأصحاب لأن الألف واللام للاستغراق فيقتضي استغراق الكل وهو الثلاث والثانية واحدة قال في المغني وهي الأشبه لأنه اليقين والألف واللام تستعملان لغير الاستغراق كثيرا ولأن أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثا ولا يفهمون أنهما للاستغراق

فرع إذا كان له أكثر من امرأة وثم نية أو سبب يقتضي تعميما أو تخصيصا [ج ٧ - ص ٢٩٢]

عمل به وإلا وقع بالكل وقيل بواحدة بقرعة (أو قال أنت طالق ونوى الثلاث ففيه روايتان أحداهما تطلق ثلاثا) اختارها جمع لأنه نوى بلفظه ما يحتمله فوقع كقوله أنت طالق ثلاثا ولأن طالق اسم فاعل وهو يقتضي المصدر كما يقتضيه الفعل والمصدر يقع على القليل والكثير (والأخرى واحدة) وهي قول الحسن والثوري والأوزاعي واختارها أكثر المتقدمين لأن هذا اللفظ لا يتضمن عددا ولا بينونة فلم يقع به الثلاث ولأن أنت طالق إخبار عن صفة هي عليها فلم يتضمن العدد كقوله حائض وطاهر والأولى أصح والفرق ظاهر لأنه لا يمكن تعددهما في حقها في آن واحد بخلاف الطلاق ولو قال أنت طالق ثلاثا ونوى واحدة فهي ثلاث بغير خلاف نعلمه لأن اللفظ صريح في الثلاث والنية لا تعارض الصريح لأنها أضعف

(وإن قال أنت طالق واحدة ونوى ثلاثا لم تطلق إلا واحدة في أحد الوجهين) وهو الأصح لأنه نوى مالا يحتمله لفظه فلو وقع أكثر منها وقع بمجرد النية والثاني يقع ثلاث لأنه نواها ولأنه يحتمل أنت طالق واحدة معها اثنتان قال في المغني والشرح وهذا فاسد لأن قوله معها اثنتان لا يؤديه معنى الواحدة ولا يحتمله فنيته فيه نية مجردة فلا تعمل كما لو نوى الطلاق من غير لفظ وفيه نظر فإن الواحدة إذا لم تحتمل ذلك فأنت طالق تحتمله قاله ابن المنجا فعلى الثاني لو قال أنت طالق وصادف قوله ثلاثا موتها أو قارنه فواحدة وعلى الأول يقع ثلاثا لوجود المفسر في الحياة

قاله في الترغيب ولعل فائدة الخلاف تظهر في المدخول بها هل يرثها أم لا

[ج ٧ - ص ٢٩٣]

(وإن قال أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاث طلقت ثلاثا) قال ابن حمدان مع النية لأن التفسير يحصل بالإشارة وذلك يصلح للبيان لقوله عليه السلام الشهر هكذا وهكذا وهكذا فإن لم يقل هكذا فواحدة ذكره في الشرح والفروع لأن إشارته لا تكفي وتوقف أحمد واقتصر عليه في الترغيب (وإن قال أردت بعد المقبوضتين قبل منه) أي يقع ثنتان لأنه يحتمل ما يدعيه كما لو فسر المجمل بما يحتمله وفي الرعاية إن أشار بالكل فواحدة (وإن قال) لإحدى امرأتيه (أنت طالق واحدة بل هذه) أي الأخرى (ثلاثا طلقت الأولى واحدة) لأنه طلقها واحدة والإضراب بعد ذلك لا يصح لأنه رفع للطلاق بعد إيقاعه (والثانية ثلاثا) لأنه أوقعه بها أشبه ما لو قال له علي هذا الدرهم بل هذا ولأن الإضراب إثبات للثاني ونفي الأول وإن قال هذه لا بل هذه طلقتا نص عليه وإن قال هذه أو هذه وهذه طالق وقع بالثانية وإحدى الأوليين كهذه أو هذه بل هذه وقيل يقرع بين الأولى والآخرتين وإن قال هذه وهذه أو هذه وقع بالأولى وإحدى الآخرتين كهذه بل هذه أو هذه وقيل يقرع بين الأوليين والثالثة

(وإن قال أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو جميعه أو منتهاه) أو غايته (أو طالق كألف أو بعدد الحصى أو القطر أو الريح أو الرمل أو التراب) وما أشبه ذلك مما يتعدد (طلقت ثلاثا وإن نوى واحدة)

نص عليه في كألف لأن هذا يقتضي عددا ولأن الطلاق أقل وأكثر فأقله واحدة وأكثره ثلاث [ج ٧ - ص ٢٩٤]

وكذا إن قال أنت طالق كمائة أو ألف لأن قوله كألف تشبيه العدد خاصة لأنه لم يذكر إلا ذلك كقوله أنت طالق كعدد ألف وفي الانتصار والمستوعب ويأثم بالزيادة وإن نوى كألف في صعوبتها ففي الحكم الخلاف والأشهر أنه يقبل (وإن قال أشد الطلاق أو أغلظه أو أطوله أو أعرضه أو ملء الدنيا) أو مثل الجبل أو عظمه (طلقت واحدة) رجعية لأن هذا الوصف لا يقتضي عددا والطلقة الواحدة توصف بأنها يملأ الدنيا ذكرها وأنها أشد الطلاق وأعرضه (إلا أن ينوي ثلاثا) فيقع لأن اللفظ صالح لأن يراد به ذلك فإذا نواه وجب إيقاعه لترجحه بالنية ونقله ابن منصور في ملء البيت وفي أقصاه أو أكثره أوجه ثالثها أكثره ثلاث وفي الفنون أن بعض أصحابنا قال في أشد الطلاق كأبح الطلاق يقع طلقة في الحيض أو ثلاث على احتمال وجهين وأنه كيف يسوى بين أشد الطلاق وأهونه

فرع إذا أوقع طلقة ثم قال جعلتها ثلاثا ولم يرد استئناف طلاق بعدها فواحدة قاله في الموجز والتبصرة (فإن قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث طلقت طلقتين) نصره في الشرح وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع لأن ما بعد الغاية لا يدخل فيها بمقتضى اللغة وإن احتمل بوصوله لم يوقعه بالشك (ويحتمل أن تطلق ثلاثا) هذا رواية كما لو قال بعتك هذا الثوب من أوله إلى آخره قال القاضي وأصل الروايتين إذا حلف لا يفعل شيئا إلى يوم الفطر هل يدخل يوم الفطر فيه فيه روايتان

مسألة إذا طلق زيد امرأته فقال عمرو لزوجته وأنت مثلها أو كهي

[ج ٧ - ص ٢٩٥]

ونوى الطلاق طلقت واحدة وإلا فلا

(وإن قال أنت طالق طلقة في اثنتين ونوى طلقة مع طلقتين طلقت ثلاثا) لأنه يعبر ب في عن مع كقوله تعالى ﴿ فادخلي في عبادي ﴾ فإذا نوى ذلك بلفظه قبل منه ووقع ما نواه فإن قال أردت واحدة قبل منه وإن كان حاسبا وقال القاضي تقع طلقتان إذا كان حاسبا لأنه خلاف ما اقتضاه اللفظ وجوابه أنه فسر كلامه بما يحتمله فإنه لا يبعد أن يريد بكلامه ما يريده العامي (وإن نوى موجبه عند الحساب وهو يعرفه طلقت طلقتين) لأن ذلك مدلول اللفظ عندهم وقد نواه وعرفه فيجب وقوعه كما لو قال أنت طالق ثنتين (وإن لم يعرفه فكذلك عند ابن حامد) قدمه في الرعاية وهو أشهر قياسا على الحاسب لاشتراكهما في النية (وعند القاضي تطلق واحدة) لأنه لا يصح منه قصد مالا يعرفه فهو كالأعجمي ينطق بالطلاق بالعربي ولا يفهمه وقيل ثلاثا بناء على أن في معناها معنى مع فالتقدير أنت طالق مع طلقتين (وإن لم ينو وقع بامرأة الحاسب طلقتان) لأنه لفظ موضوع في اصطلاحهم لاثنين فوجب العمل به (وبغيرها طلقة) لأن اللفظ إنما جاز مصروفا إلى اثنتين بوضع أهل الحساب فإذا لم يعرفه يلزمه مقتضاه كالعربي ينطق بالطلاق بالعجمية وهو لا يعرف معناها وقيل ثنتان ووجهه ما سبق (ويحتمل أن تطلق ثلاثا) لأنه إذا لم يكن له نية وجب حمل في على معنى مع وقيل بعامي قال

المؤلف لم يفرق أصحابنا بين أن يكون المتكلم بذلك ممن له عرف في هذا اللفظ أو لا والظاهر أنه إن كان المتكلم بذلك ممن [ج ٧ - ص ٢٩٦]

عرفهم أن في بمعنى مع لأن الظاهر إرادة ما تعارفوه وقال أبو الخطاب ويحتمل أنه لا يقع طلاقه كل هذا إذا أطلق ولم يعرف الحساب

مسألة إذا قال أنت طالق بعدد ما طلق فلان زوجته وجهل عدده فطلقة وقيل بعدده

فصل

جزء طلقة كهي (إذا قال أنت طالق نصف طلقة أو نصفي طلقة) فتقع واحدة لأن الطلاق لا يتبعض في قول عامتهم وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه (أو نصف طلقتين طلقت طلقة) لأن نصف الطلقتين طلقة وذكر بعض العلماء أنها تطلق طلقتين لأن اللفظ يقتضي النصف من كل واحدة منهما ثم تكمل وما ذكرناه أولى لأن التصنيف يتحقق به وفيه عمل باليقين وإلغاء الشك وإيقاع ما أوقعه من غير زيادة (وإن قال نصفي طلقتين) وقع طلقتان لأن نصفي الشيء جميعه أشبه ما لو قال أنت طالق طلقتين (أو ثلاثة أنصاف طلقة طلقت طلقتين) لأن ثلاثة أنصاف طلقة ونصف فيكمل النصف فصار ذلك طلقتين وقيل واحدة لأن الأجزاء من طلقة فالزائد عليها يكون لغوا لأنه ليس منها وكذا الخلاف في خمسة أرباع طلقة أو أربعة أثلاث (وإن قال ثلاثة أنصاف طلقتين طلقت ثلاثا) نص عليه في رواية منها ونصره جمع لأن نصف الطلقتين طلقة وقد كرر ثلاثا [ج ٧ - ص ٢٩٧]

(ويحتمل أن تطلق طلقتين) هذا قول ابن حامد لأن معناه ثلاث أنصاف من طلقتين وذلك طلقة ونصف ثم تكمل فتصير طلقتين وجوابه بأنه تأويل يخالف ظاهر اللفظ قال في الفروع ويتوجه مثلها ثلاثة أرباع ثنتين وفي الروضة تقع ثنتان (وإن قال نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة) أي يقع واحدة لأن ذلك أجزاء طلقة واحدة وليس في اللفظ ما يقتضي التغاير لأنه غير معطوف (أو نصف وثلث وسدس طلقة طلقت طلقة) لأن الإضافة إلى الطلقة فيجب أن تطلق واحدة (وإن قال نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة طلقت) سواء كانت مدخولا بها أو لا (ثلاثا) لأنه علق أجزاء الطلقة على جزء آخر وهو يدل على المغايرة فيقع جزءا ثم يكمل بالسراية لأنه لو كانت الثانية هي الأولى لجاء بها بلام التعريف فقال ثلث الطلقة سدس الطلقة لأن أهل العربية قالوا إذا ذكر لفظ ثم أعيد منكرا فالثاني غير الأول وإن أعيد معرفا بها فالثاني هو الأول لقوله تعالى ﴿ فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ﴾) فالعسر الثاني هو الأول بخلاف اليسر ولهذا قيل لن يغلب عسر يسرين وقيل لو أراد بالثانية الأولى لذكرها بالضمير لأنه هو الأولى

(وإن قال لأربع أوقعت بينكن) أو عليكن نص عليه (طلقة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا وقع بكل واحدة طلقة) لأن اللفظ اقتضى قسم الطلقة بينهن أو عليهن لكل واحدة ربعها ثم تكمل وكذا إن قال أوقعت بينكن

طلقتين ذكره أبو الخطاب لأنه إذا قسم لم يزد واحدة على طلقة وعنه يقع

[ج ٧ - ص ٢٩٨]

بكل واحدة طلقتان وقال أبو بكر والقاضي لأنه إذا قسمت اثنتان بينهن كان لكل واحدة جزآن من طلقتين ثم يكمل كل جزء قال في المغني والأول أولى لأنه إنما يقسم بالأجزاء مع الاختلاف كالدور ونحوها من المختلفات فأما الجمل المتساوية من جنس كالنقود فإنما يقسم برؤوسها ويكمل نصيب كل واحدة من واحد كأربعة لهم درهمان صحيحان فإنه يجعل لكل واحد نصف درهم واحد والطلقات لا اختلاف فيها ولأن فيما ذكرنا أخذا باليقين فكان أولى من إيقاع طلقة زائدة بالشك وكذا إذا قال لهن أوقعت بينكن ثلاثا فإنه يصيب كل واحدة ثلاثة أرباع طلقة ثم تكمل (وعنه إذا قال أوقعت بينكن ثلاثا ما أرى إلا قد بن منه) نقلها الكوسج (واختاره القاضي) لأن الثلاث إذا قسمت بينهن كان لكل واحدة جزء من ثلاث طلقات ثم تكمل وفي المغني والشرح أنهن يطلقن ثلاثا ثلاثا على قول أبي بكر والقاضي

(وإن قال أوقعت بينكن خمسا فعلى الأولى يقع بكل واحدة طلقتان) لأن لكل واحدة طلقة وربعا ثم تكمل وعلى الثانية يقع بكل واحدة ثلاث لأنه إذا طلقت ثلاثا فيما إذا أوقع ثلاثا فلأن تطلق ثلاثا إذا أوقع خمسا بطريق الأولى فإن قال أوقعت ستا أو سبعا أو ثمانيا فكذلك فإن قال أوقعت بينكن تسعا وقع بكل واحدة ثلاث عليهما وإن قال أوقعت بينكن طلقة وطلقة وطلقة فثلاث في قياس المذهب لأن الواو لا تقتضي ترتيبا وقيل واحدة على الأولى فإن قال أوقعت بينكن ثلث طلقة وثلث

طلقة وسدس طلقة وقع ثلاث كما لو عطفه بالفاء أو ثم إلا التي لم يدخل بها فإنها تبين بالأولى [ج ٧ - ص ٢٩٩]

فصل

(إذا قال نصفك أو جزء منك) سواء كان معينا أو مشاعا أو مبهما (أو اصبعك أو دمك طالق طلقت) نص عليه لصحته في البعض بخلاف زوجتك بعض وليتي وذكر ابن البنا لا تطلق بدمها كلبنها وإن أضافه إلى سوادها أو بياضها لم يقع لأنه عرض وقيل بلى فإن قال يدك طالق ولا يد لها أو إن قمت فهي طالق فقامت وقد قطعت فوجهان بناء على أنه هل هو بطريق السراية أو بطريق التعبير بالبعض عن الكل

(وإن قال شعرك أو ظفرك أو سنك طالق لم تطلق) نص عليه لأنها تزول ويخرج عوضها في الشعر ولأنه لا روح فيه لا ينتقض الوضوء بمسه أشبه العرق وقيل تطلق وهو قول الحسن وغيره لأنه جزء يستباح بنكاحها فتطلق به كالأصبع وجوابه بأنه جزء ينفصل عنها في حال السلامة بخلاف الاصبع

(وإن أضافه إلى الريق والدمع والعرق والحمل لم تطلق) بغير خلاف نعلمه لأنه ليس من ذاتها وإنما هو مجاور لها والحمل وإن كان متصلا بها فمآله إلى الانفصال وهو مودع فيها لقوله تعالى ﴿ وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع ﴾ قيل هو مستودع في بطن الأم وفي الانتصار هل يقع ويسقط القول بإضافته إلى صفة كسمع وبصر إن قلنا تسمية الجزء عبارة عن الجميع وهو ظاهر [ج ٧ - ص ٣٠٠]

كلامه صح وإن قلنا بالسراية فلا (وإن قال روحك طالق طلقت) جزم به جمع من أصحابنا لأن الجملة لا تبقى بعدم مزايلها أشبه الحياة والدم (وقال أبو بكر لا تطلق) نص عليه وهو ظاهر ما في الفروع قال أبو بكر لا يختلف قول أحمد أنه لا يقع طلاق وعتق وظهار وحرام بذكر الشعر والظفر والسن والروح فبذلك أقول ولأنها ليست عضوا ولا شيئا يستمتع به وحكى في المستوعب عن أحمد التوقف عنها

مسألة العتق في ذلك كطلاق

فصل فيما تخالف المدخول بها غيرها

(إذا قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق طلقت طلقتين) بغير خلاف لأن كل واحد يقتضي وقوع إذا وكذا إذا اجتمع مع غيره وإن قاله ثلاثا طلقت ثلاثا أشبه ما لو قال أنت طالق ثلاثا (إلا أن ينوي بالثانية التأكيد أو إفهامها) لأنه قصد بالثاني غير الأول فلم يقع به شيء وشرطه الاتصال فلو قال أنت طالق ثم مضى زمن طويل ثم أعاد ذلك لها طلقت ثانية ولم يقبل منه التأكيد لأنه تابع للكلام فقبل متصلا كسائر التوابع من العطف والصفة والبدل فلو نوى بالثانية تأكيد الأولة لم يقبل ووقع الثلاث وإن أكد الثانية بالثالثة ففي قبوله بالحكم روايتان قال في الفروع [ج ٧ - ص ٣٠١]

ويتوجه مع الإطلاق وجه كإقرار وقد نقل أبو داود في قوله اعتدي اعتدي فأراد الطلاق هي تطليقة

تنبيه إذا قال أنت طالق طالق فهي واحدة لأن اللفظ الثاني لا يصلح للاستئناف فيصرف إلى التأكيد كقوله عليه السلام فنكاحها باطل باطل وإن قصد بالثانية الإيقاع طلقت طلقتين ويقدر له ما يتم الكلام به فلو قال أنت طالق وطالق وطالق فثلاث نص عليه وعنه تبين قبل الدخول بالأولى بناء على أن الواو للترتيب ولو قال طالق وكرره وقعن ولو قصد التأكيد قبل منه لأن الطلاق تكرر للتأكيد وكان قبل الأخيرة أنت ومقتضاه أنه إذا لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة وصرح به في المغني لأنه لم يأت بحرف يقتضي المغايرة

فرع إذا أتى شرط أو استثناء أو صفة عقب جملة اختص بها بخلاف المعطوف والمعطوف عليه

(وإن قال لها أنت طالق فطالق أو ثم طالق أو بل طالق أو طالق طلقة بل طلقتين أو بل طلقة أو طالق طلقة بعدها طلقة أو قبل طلقة طلقت طلقتين) وفيه مسائل

الأولى إذا قال أنت طالق فطالق تقع طلقتان لأن الثانية صادفت محل النكاح فيقع ولأن الفاء تقتضي الجمع مع التعقيب وثم تقتضيه مع التراخي

الثانية إذا قال أنت طالق بل طالق تطلق طلقتين لأن الأول اقتضى إيقاع طلقة والطلاق لا يرتفع بعد وقوعه والثاني يقتضي إيقاع طلقة لأن بل لإثبات الثاني والإضراب عن الأول فإذا لم يصح إضرابه وجب وقوعهما جميعا [ج ٧ - ص ٣٠٢]

وعنه في أنت طالق طلقة بل طلقة أو طالق بل طالق واحدة كما لو قال له علي درهم بل درهم

الثالثة إذا قال أنت طالق طلقة بل طلقتين أو بل طلقة تقع ثنتان لما ذكرنا وأوقع أبو بكر وابن الزاغوني في طلقة بل طلقتين ثلاثا لأن الأول إيقاع واحدة والثاني يقتضي إيقاع طلقتين والمنصوص أنه تقع ثنتان لأن الأولى يصح دخولها في الثنتين فلا يكون الإضراب عنها مستدركا لأن فيه زيادة فائدة وهو الوقوع والثانية ظاهرة

الرابعة إذا قال أنت طالق طلقة بعدها طلقة أو قبل طلقة فإنها تطلق اثنتين لأن ذلك صريح في الجمع والمحل يحتمله فإن أراد في بعدها طلقة سأوقعها ففي الحكم روايتان وفي الروضة لا يقبل حكما وفي الباطن روايتان وقيل تطلق واحدة قطع به في قبل طلقة في المذهب والمستوعب وزاد بعد طلقة

(وإن كانت غير مدخول بها بانت بالأولى) لأنها صادفت محلا (ولم يلزمها ما بعدها) لأنها بائن فلم يلحقها طلاق كالأجنبية (وإن قال لها أنت طالق طلقة قبلها طلقة فكذلك عند القاضي) أي تطلق واحدة إذا كانت غير مدخول بها لأنه طلاق بعضه قبل بعض فلم يقع بغير المدخول بها جميعه كما لو قال طلقة بعد طلقة (وعند أبي الخطاب تطلق اثنتين) وقاله أبو بكر (ويقعان معا) لأنه استحال وقوع الطلقة الأخرى قبل

الطلقة الموقعة فوقعت معها لأنها لما تأخرت عن الزمن الذي قصد إيقاعها فيه لكونه زمنا ماضيا وجب إيقاعها في أقرب الأزمنة إليه وهو معها ولا يلزم تأخيرها إلى ما بعدها لأن قبله زمنا يمكن الوقوع فيه وهو زمن قريب فلا يؤخر إلى البعيد [ج ٧ - ص ٣٠٣]

(وإن قال أنت طالق طلقة معها طلقة) أو مع طلقة طلقت اثنتين لأن لفظه يقتضي وقوعهما معا كما لو قال أنت طالق اثنتين فلو قال معها اثنتان وقع ثلاث في قياس المذهب وكذا إن قال أنت طالق طلقة تحت طلقة أو تحتها أو فوق طلقة أو فوقها (أو مع طلقة أو طالق وطالق طلقت طلقتين) لأن الواو تقتضي الجمع ولا ترتيب فيها ولأن الكلام إنما يتم بآخره في الشرط والصفة والاستثناء فكذا في العطف ويفرق بينها فإن الثلاثة مغيرة له بخلاف العطف فإنه لا يغير وجوابه أن العطف هنا يبين عدد الواقع فهو كالصفة

تنبيه إذا غاير بين الحروف ونوى التأكيد لم يقبل منه لأنه إنما يكون بتكرير الأول بصورته وإن قال أنت مطلقة أنت مسرحة أنت مفارقة ونوى التأكيد بالثانية والثالثة قبل لأنه لم يغاير بينها بالحروف الموضوعة للمغايرة بين الألفاظ بل أعاد اللفظ بمعناه ومثل هذا يعاد توكيدا فلو عطف فقال مطلقة ومسرحة ومفارقة وقال أردت التأكيد فاحتمالان

(والمعلق كالمنجز في هذا) لأن المعلق على الشرط يجب تحققه عند وجود الشرط فيجب أن يقع على الصفة التي كان يقع عليها لو كان منجزا تقدم الشرط أو تأخر (فلو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق أو طالق طلقة معها طلقة أو مع طلقة فدخلت طلقت طلقتين) لأنه وجد شرط وقوعهما معا أشبه ما لو قال أنت طالق اثنتين فلو كرره ثلاثا بالجزاء

أو مع طلقتين طلقت ثلاثا (وإن قال إن دخلت فأنت طالق فطالق أو ثم طالق فدخلت طلقت طلقة واحدة إن كانت غير مدخول بها) لأنها تبين بالأولى [ج ٧ - ص ٣٠٤]

فيجب ألا يلحقها ما بعدها (واثنتين إن كانت مدخولا بها) لأنها لا تبين بالأولى فيتعين إيقاع الثانية أيضا وفي المغني عن القاضي تطلق من لم يدخل بها طلقة منجزا كذا قال والذي اختاره القاضي وجماعة أن ثم كسكتة لتراخيها فيتعلق بالشرط معها طلقة فيقع بالمدخول بها ثنتان واحدة اذن وطلقة بالشرط ويقع بغيرها إن قدم الشرط الثانية والثالثة لغو والأولى معلقة وإن أخره فطلقة منجزة والباقي لغو وفي المذهب فيما إذا تقدم الشرط أن القاضي أوقع واحدة فقط في الحال وذكر أبو يعلى الصغير أن المعلق كالمنجز لأن اللغة لم تفرق وأنه إذا أخر الشرط فطلقة منجزة وإن قدمه لم يقع إلا طلقة بالشرط (وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت طلقت طلقتين بكل حال) لأن التعليق يقتضي إيقاع الطلاق بشرط الدخول وقد كرر التعليق فيتكرر الوقوع كما لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق طلقتين وإن كرر الشرط ثلاثا طلقت ثلاثا في قول الجميع لأن الصفة وجدت فاقتضى وقوع الثلاث دفعة واحدة والله أعلم

باب الاستثناء في الطلاق

الاستثناء إخراج بإلا أو إحدى أخواتها قيل من متكلم واحد لوقوعه في القرآن والسنة ولسان العرب (حكي عن أبي بكر أنه لا يصح الاستثناء في

الطلاق) لأن الطلاق لا يمكن رفعه بعد إيقاعه ولو صح لرفعه (والمذهب أنه يصح استثناء ما دون [ج ٧ - ص ٣٠٥]

النصف) في الطلاق والإقرار لأنه استثناء فيه فجاز كما في عدد المطلقات وليس الاستثناء رافعا لواقع وإنما هو مانع لدخول المستثنى في المستثنى منه (ولا يصح فيما زاد عليه) أي على النصف أي لا يصح استثناء الكل ولا الأكثر نص عليه ونصره في الشرح وقواه ابن حمدان وقيل يصح فيه وهو قول الأكثر (وفي النصف وجهان) وذكر أبو الفرج وصاحب الروضة روايتين ظاهر المذهب صحته وجزم به في الوجيز وجاز الأكثر إن سلم في قوله تعالى ﴿ إلا من اتبعك من الغاوين ﴾ لأنه لم يصرح بالعدد وذكر أبو يعلى الصغير أنه استثناء بالصفة وهو في الحقيقة تخصيص وأنه يجوز فيه الكل نحو اقتل من في الدار إلا بني تميم وهم بنو تميم فيحرم قتلهم وسيأتي في الإقرار (فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت اثنتين) لأن الواحدة دون النصف (وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا) طلقت ثلاثا بغير خلاف (أو ثلاثا إلا اثنتين) وقع ثلاث بناء على أنه لا يصح استثناء الأكثر (أو خمسا إلا ثلاثا) وقعت الثلاث لأن الاستثناء إن عاد إلى الخمس فقد استثنى الأكثر وإن عاد إلى الثلاث التي يملكها فقد رفع جميعها وكلاهما غير صحيح وإن صح الأكثر فثنتان وإن قال خمسا إلا طلقة فقيل يقع اثنتان وقيل ثلاث (أو ثلاثا إلا ربع طلقة طلقت ثلاثا) لأن الطلقة الناقصة تكمل فتصير ثلاثا ضرورة أن الطلاق لا يتبعض وفي الرعاية وجه أنها تطلق اثنتين

(وإن قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة فعلى وجهين) بناء على صحة استثناء النصف وإن قال أنت طالق أربعا إلا اثنتين فقيل تقع طلقتان وقيل [ج ٧ - ص ٣٠٦]

ثلاث وإن قال أنت طالق اثنتين واثنتين إلا اثنتين لم يصح وفيه احتمال وإن استثنى واحدة ففي صحته احتمالان

(وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين على وجهين (لا يصح الاستثناء من الاستثناء في الطلاق خلافا ل الرعاية إلا في مسألة واحدة وهي أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة في أحد الوجهين ذكره في الكافي والشرح وجزم به في الوجيز لأنه استثناء الواحدة مما قبلها فتبقى واحدة وهي مستثناة من ثلاثة فتصير كقوله أنت طالق ثلاثا إلا واحدة ويمكن أن يقال إن الواحدة مخرجة من الثلاث لإبطال استثناء الثنتين والثاني تطلق ثلاثا لأن استثناء الثنتين لا يصح لكونهما أكثر من النصف ولا يصح استثناء الواحدة لأنه استثناء من استثناء باطل

(وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة لم يصح) ويقع الثلاث لأن استثناء الأول باطل ولا يصح الاستثناء منه وقيل يعود استثناء الواحدة إلى أول الكلام فتقع طلقتان (أو طالق وطالق وطالق إلا واحدة أو طلقتين وواحدة إلا واحدة أو طلقتين ونصفا إلا طلقة طلقت ثلاثا) على المذهب لأن تصحيح الاستثناء يجعل المستثنى منه لغوا فبطل كاستثناء الجمع (ويحتمل أن تقع طلقتان) ذكر في الواضح أنه أشبه لأن

العطف بالواو ويجعل الجملتين كالجملة الواحدة فتصير الواحدة مستثناة من الثلاث فلو كان العطف بالفاء أو ثم لم يصح الاستثناء

تنبيه إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقة وطلقة فقيل تقع الثلاث

[ج ٧ - ص ٣٠٧]

وقيل يصح الاستثناء في طلقة وكذا الخلاف في أنت طالق طالق إلا طلقة وطلقة وفي أنت طالق ثلاثا إلا طلقة ونصفا وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وإلا واحدة طلقت اثنتين وقيل واحدة وإن أسقط الواو فقيل يقع ثلاث وقيل ثنتان فلو قال أنت طالق طلقتين ونصفا إلا نصف طلقة فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين على وجهين وفي المستوعب إنها تطلق ثلاثا وجها واحدا

(وإن قال أنت طالق ثلاثا واستثنى بقلبه إلا واحدة وقعت الثلاث) لأن العدد نص فيما يتناوله فلا يرتفع بالنية لأن اللفظ أقوى ولو ارتفع بالنية لرجح المرجوح على الراجح وقال أبو الخطاب وقدمه في الرعاية يلزمه الثلاث حكما ويدين فيما بينه وبين الله تعالى وكذا الخلاف لو قال نسائي الأربع طوالق واستثنى واحدة بقلبه وإن لم يقل الأربع ففي الحكم روايتان (وإن قال نسائي طوالق واستثنى واحدة بقلبه لم تطلق) لأنه لا يسقط اللفظ وإنما استعمل العموم في الخصوص وذلك شائع بخلاف ما قبلها وهل يقبل في الحكم على روايتين وفي الترغيب إذا قال أربعتكن طوالق إلا فلانة لم تصح على الأشبه لأنه صريح وأوقع ويصح أربعتكن إلا فلانة طوالق وإن استثنى من سألته طلاقها دين ويتوجه أنه كنسائي الأربع ولم يقبل في الحكم لأن السبب لا يجوز إخراجه وقيل يقبل لجواز تخصيص العام وإن قالت طلق نساءك فقال نسائي طوالق طلقت لأن اللفظ لا

يقتصر على سببه وإن استثناها قبل في الحكم لأن السبب يدل على نيته

[ج ٧ - ص ٣٠٨]

فرع يعتبر للاستثناء ونحوه اتصال معتاد قطع به الجماعة ونيته قبل تكميل ما ألحقه به حكاه الفارسي إجماعا وقيل وبعده وفي الترغيب هو ظاهر قول أصحابنا واختاره الشيخ تقي الدين وقال دل عليه كلام أحمد ومتقدمي أصحابه وإنه لا يضر فصل يسير بالنية وبالاستثناء قال وفي القرآن جمل قد فصل بين أبعاضها بكلام آخر كقوله تعالى ﴿ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا ﴾ إلى قوله ﴿ هدى الله ﴾ فصل بين أبعاض الكلام المحكي عن أهل الكتاب وسأله أبو داود عمن تزوج امرأة فقيل له ألك امرأة سواها فقال كل امرأة لي طالق فسكت فقيل إلا فلانة قال إلا فلانة فإني لم أعنها فأبى أن يفتي فيه

مسألة إذا قال أنت طالق ثم وصله بشرط أو صفة فإن كان نطقا صح بغير خلاف وإن نواه ولم يلفظ به دين وفي الحكم روايتان

باب الطلاق في الماضي والمستقبل

(إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ينوي الإيقاع وقع) لأنه اعترف على نفسه بما هو أغلظ (فإن لم ينو لم يقع في ظاهر كلامه) وجزم به في الوجيز وغيره لأنه أضافه إلى زمن يستحيل وقوعه فيه وهو الزمن الماضي وقبل نكاحه فلم يقع كما لو قال أنت طالق قبل قدوم زيد بيومين فقدم [ج ٧ - ص ٣٠٩]

اليوم فإنه لا خلاف عند أصحابنا أنه لا يقع (وقال القاضي يقع) ولو لم ينوه وهو رواية لأنه وصف الطلقة بما لا تتصف به فلغت الصفة ووقع الطلاق كما لو قال لآيسة أنت طالق للبدعة (وحكي عن أبي بكر لا يقع إذا قال أنت طالق أمس) لعدم إمكان وقوع الطلاق فيه (ويقع إذا قال قبل أن أنكحك) لأنه يمكن أن يتزوجها ثانيا وهذا الوقت قبله فيقع فيه بخلاف الأولى قاله القاضي وعنه في الأولى إن كانت زوجته أمس فإن قال أردت أني طلقتها أمس طلقت بإقراره ولزمتها العدة في يومها لاعترافها أن أمس لم يكن من عدتها (فإن قال أردت أن زوجا قبلي طلقها أو طلقته في نكاح قبل هذا قبل منه إذا احتمل الصدق في ظاهر كلام أحمد) لأنه فسر كلامه بما يحتمله وقوله إذا احتمل الصدق مشعر بأنه يشترط أن يكون قد وجد لأنه إذا لم يوجد لم يكن كلامه محتملا للصدق وفي المغني إن لم يكن وجد وقع طلاقه ذكره أبو الخطاب وقال القاضي يقبل ظاهر كلامه ولم يشترط الوجود فإذن فيه وجهان وعلى الأول ما لم تكذبه قرينة من غضب أو سؤالها الطلاق ونحوه (فإن مات) القائل (أو جن أو خرس قبل العلم بمراده فهل تطلق) المقول لها (على وجهين) بناء على الخلاف في اشتراط النية في وقوع الطلاق المتقدم ذكره فإن قيل باشتراطه لم تطلق لأن شرط الطلاق النية ولم يتحقق وجودها وإن قيل بعدم اشتراطها طلقت لأن المقتضي للوقوع قد وجد فوجب العلم به

(وإن قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر) فلها النفقة (فقدم قبل مضي [ج ٧ - ص ٣١٠]

شهر لم تطلق) بغير خلاف بين أصحابنا لأنه تعليق للطلاق على صفة ممكنة الوجود فوجب اعتبارها ذكره في الشرح وغيره وفيه وجه تطلق بناء على قوله أنت طالق أمس وجزم به الحلواني فلو قدم مع مضي الشهر لم تطلق لأنه لا بد من جزء يقع الطلاق فيه (وإن قدم بعد شهر وجزء يقع الطلاق فيه تبينا وقوعه فيه) لأنه أوقع الطلاق في زمن على الصفة فإذا حصلت وقع كما لو قال أنت طالق قبل شهر رمضان بشهر أو قبل موتك بشهر فلو وطئها كان محرما ولها المهر (فإن خالعها بعد اليمين بيوم) فأكثر (وكان الطلاق بائنا ثم قدم زيد بعد الشهر بيومين صح الخلع) لأنه وقع مع زوجه (وبطل الطلاق) لأنه صادفها بائنا ولا إرث لها لعدم التهمة (وإن قدم بعد شهر وساعة) فأقل (وقع الطلاق) لأنها طلقت في الساعة وهي زوجة (دون الخلع) لأنه صادفها بائنا وخلع البائن غير صحيح وحينئذ لها الرجوع بالعوض إلا أن يكون الطلاق رجعيا لأن الرجعية يصح خلعها

فرع إذا قال لعبده أنت حر قبل قدوم زيد بشهر ثم باعه بعد عقد الصفة فأعتقه المشتري ثم قدم زيد بعد عقدها بشهر ويوم فإنا نحكم بوقوع عتق البائع وبطلان البيع وما ترتب عليه ونقل مهنا عنه إذا قال أنت طالق ثلاثا قبل موتي بشهر أنها تطلق في الحال وهذه تعطي أنه علقه بشرط يأتي لا محالة أنه يقع في الحال والأول أصح

(وإن قال أنت طالق قبل موتي طلقت في الحال) لأنه قبل موته وكذا إن قال قبل موتك أو موت زيد فإن قاله بالتصغير لم يقع إلا في الجزء الذي يليه الموت لأن ذلك تصغير يقتضي الجزء اليسير (فإن قال بعد موتي أو [ج ٧ - ص ٣١١]

مع موتي لم تطلق) نص عليه وكذا إن قال بعد موتك أو مع موتك بغير خلاف علمناه لأنها تبين بموت أحدهما فلم يصادف الطلاق نكاحا يزيله فإن قال مع موتي فوجهان

فرع إذا قال إن مت فأنت طالق قبله بشهر ونحو ذلك لم يصح ذكره في الانتصار لأنه أوقعه بعده فلا يقع قبله لمضيه وإن لم يقل بشهر وقع إذن وفي التبصرة في جزء يليه موته كقبل موتي وإن قال أطولكما حياة طالق فبموت إحداهما يقع بالأخرى إذن وقيل وقت يمينه فإن قال أنت طالق قبل موت زيد وعمرو بشهر تعلقت بالصفة بأولهما موتا

(وإن تزوج أمة أبيه ثم قال إذا مات أبي أو اشتريتك فأنت طالق فمات أبوه أو اشتراها لم تطلق) اختاره القاضي وقدمه في الكافي وجزم به في الوجيز لأنه بالموت والشراء يملكها فينفسخ نكاحها بالملك وهو زمن الطلاق فلم يقع كما لو قال أنت طالق مع موتي وكقوله إذا ملكتك فأنت طالق في الأصح (ويحتمل أن تطلق) اختاره في الجامع والشريف وابو الخطاب وقدمه في المحرر والفروع وهو رواية في التبصرة لأن الموت سبب ملكها وطلاقها وفسخ النكاح يترتب على الملك فيوجد الطلاق في زمن الملك السابق على الفسخ فيثبت حكمه وفي المستوعب إذا علق طلاقها على الشراء لم تطلق حتى يتفرقا في أظهر الوجهين وفي الآخر تطلق وهو احتمال في عيون المسائل بناء على انتقال الملك زمن الخيار

(وإن كانت مدبرة) أي دبرها أبوه (فمات أبوه وقع الطلاق) لأن الحرية [ج ٧ - ص ٣١٢]

تمنع ثبوت الملك له فلا ينفسخ نكاحه فيقع طلاقه (والعتق) لأنه معلق بالموت وقد وجدا معا لأن كل واحد منهما معلق بالموت وهذا إذا كانت تخرج من الثلث فإن أجاز الابن وقلنا إجازته عصية مبتدأة فهل يقع الطلاق على وجهين وإن قلنا تنفيذ وقعا معا فإن كان على الأب دين يستغرق تركه لم يعتق والأصح أن ذلك لا يمنع نقل التركة إلى الورثة فهو كما لو لم يكن عليه دين في فسخ النكاح وإن كانت تخرج من الثلث بعد أداء الدين وقعا وإلا حكمها في فسخ النكاح ومنع الطلاق كما لو كان مستغرقا لها فإن أسقط الغريم الدين بعد الموت لم يقع الطلاق لأن النكاح انفسخ قبل إسقاطه

فصل

(وإن قال أنت طالق لأشربن الماء الذي في الكوز ولا ماء فيه أو لأقتلن فلانا الميت أو لأصعدن السماء أو لأطيرن أو إن لم أصعد السماء ونحوه طلقت في الحال) هذا المذهب كما لو قال أنت طالق إن لم أبع عبدي فمات العبد ولأنه علق الطلاق على نفي فعل المستحيل وعدمه معلوم في الحال وفي الثاني فإنه يوقع الطلاق (وقال أبو الخطاب في موضع لا تنعقد يمينه) وحكاه عن القاضي لأن اليمين المنعقدة هي التي يمكن فيها البر والحنث وهو منتف هنا قال في الشرح والصحيح أنه يحنث فإن الحالف على فعل الممتنع كاذب حانث قال الله تعالى ﴿ وأقسموا بالله جهد أيمانهم ﴾ ولأنه لو حلف على فعل متصور [ج ٧ - ص ٣١٣]

فصار ممتنعا حنث فهذا أولى وقيل لا تطلق في المحال لذاته وإن المحال عادة كالممكن في تأخير الحنث إلى آخر حياته وقيل إن وقته كقوله لأطيرن اليوم لم تطلق إلا في آخر الوقت وإن أطلق طلقت في الحال وذكره أبو الخطاب اتفاقا

فرع إذا حلف ليقتلن فلانا وهو ميت فقيل يحنث وهو الأشهر وقيل لا وقيل إن كانت يمينه بطلاق أو عتاق حنث وإن كان بغيرهما فلا وفرق القاضي في الجامع فقال إن لم يعلم بموته لم يحنث وإلا حنث

(وإن قال أنت طالق إن شربت ماء الكوز ولا ماء فيه أو صعدت السماء أو شاء الميت أو البهيمة) أو إن قلبت الحجر ذهبا أو إن جمعت بين الضدين أو إن رددت أمس (لم تطلق في أحد الوجهين) صححه في الشرح وقدمه في المحرر والرعاية والفروع لأنه علق الطلاق بصفة لم توجد لأن ما يقصد تبعيده يعلق على المحال كقوله تعالى ﴿ ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ﴾ ولقول الشاعر % إذا شاب الغراب أتيت أهلي % % وعاد القار كاللبن الحليب %

وكحلفه بالله عليه (وتطلق في الآخر) ويلغى الشرط لأنه أردف الطلاق بما يرفع جملته ويمنع وقوعه في الحال وفي الثاني فلم يصح كاستثناء الكل وكما لو قال أنت طالق طلقة لا تقع عليك وقيل إن علقه على مستحيل

عقلا وقع في الحال لأنه لا وجود له وإن علقه على مستحيل عادة كالطيران [ج ٧ - ص ٣١٤]

وصعود السماء لم يقع لأن له وجودا وقد وجد في معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء

تذنيب العتق والظهار والحرام والنذر كالطلاق واليمين بالله تعالى قيل كذلك وقيل لا كفارة فيها كالغموس وفي المستوعب تعليقه كقوله لأفعلن أو لا فعلت نحو لأقومن أو لا قمت يصح بنية جاهل بالعربية وإن نواه عالم فروايتا أنت طالق ثم يريد إن قمت وإلا لم يصح لأنه لم يأت بحرف الشرط وتبعه في الترغيب وذكر الشيخ تقي الدين أنه خلاف الإجماع القديم وجزم به في المغني وغيره

(وإن قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد فعلى الوجهين) لأن الطلاق إذا علق على شرط مستحيل فهل يقع فيه وجهان لأنه جعل وقوع الطلاق مظروفا لليوم ومشروطا للغد والجمع بينهما محال والمذهب عدم الوقوع (وقال القاضي لا تطلق) لأن شرط الطلاق لم يتحقق لأن مقتضاه وقوع الطلاق إذا جاء في اليوم ولا يجيء غد إلا بعد فوات اليوم وذهاب محل الطلاق وفي المغني إن اختيار القاضي أنها تطلق في الحال لأنه علقه بشرط محال فلغا الشرط ووقع الطلاق كما لو قال لآيسة أنت طالق للبدعة وقال في المجرد إنها تطلق في غد

تنبيه إذا قال أنت طالق لأقومن وقام لم تطلق وإن لم يقم في الوقت الذي عينه حنث في قول أكثرهم وإن قال أنت طالق إن أخاك لعاقل وكان

كذلك لم يحنث كقوله والله إن أخاك لعاقل وإن شك في عقله لم يقع

[ج ٧ - ص ٣١٥]

وإن قال أنت طالق لا أكلت هذا الرغيف فأكله حنث وإن قال ما أكلته لم يحنث إن كان صادقا وحنث إن كان كاذبا كقوله والله ما آكله وإن قال أنت طالق لا دخلت الدار ولا ضربتك ونوى به التعليق صح إن كان جاهلا وإلا فروايتان وإن قال أنت طالق ثلاثا على مذهب السنة والشيعة واليهود والنصارى طلقت ثلاثا لاستحالة الصفة لأنه لا مذهب لهم وكقصده التأكيد

فصل في الطلاق في زمن مستقبل

(إذا قال أنت طالق غدا أو يوم السبت أو في رجب طلقت بأول ذلك) لأنه جعل ذلك ظرفا للطلاق فإذا وجد ما يكون ظرفا طلقت كما لو قال إذا دخلت الدار فأنت طالق إذا دخل أول جزء منها طلقت وحاصله أنه إذا علق الطلاق بشهر أو وقت عينه وقع في أوله بخلاف ما لو قال إن لم أقضك حقك شهر رمضان فامرأته طالق لم تطلق حتى يخرج الشهر قبل قضائه لأنه إذا قضاه في آخره لم توجد الصفة وله الوطء قبل الحنث

(وإن قال أنت طالق اليوم أو في هذا الشهر طلقت في الحال) لأن اليوم والشهر ظرف لإيقاع الطلاق فوجب أن يقع إذن وكذا إن قال في الحول وعنه أنه في رأسه اختاره ابن أبي موسى قال في الفروع وهي أظهر (وإن قال أردت في آخر هذه الأوقات دين) في الأصح لأنه يجوز

أن يريد ذلك فلا يلزمه الطلاق في غيره (وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين) أظهرهما القبول لأن آخر الشهر منه فإرادته لا تخالف ظاهره وكذا وسطه إذا ليس أوله أولى في ذلك من وسطه والثانية لا يقبل لأنه لو أطلق تناول أوله وكلامه شامل للصورتين وهو قول والمنصوص أنه لا يدين ولا يقبل حكما فلو قال أنت طالق في أول رمضان أو مجيئه أو غرته طلقت بأول جزء منه ولا يقبل قوله نويت آخره أو وسطه لأنه لا يحتمله فلو قال أردت بالغرة اليوم الثاني قبل منه لأن الثلث الأول من الشهر يسمى غررا

فرع إذا قال أنت طالق إذا كان رمضان أو إلى رمضان أو إلى هلال رمضان أو في هلال رمضان طلقت ساعة يستهل إلا أن يقول من الساعة إلى الهلال فتطلق في الحال وإن قال أنت طالق في مجيء ثلاثة أيام طلقت في أول اليوم الثالث

(وإن قال أنت طالق اليوم وغدا أو بعد غد أو في اليوم وفي غد وفي بعده فهل تطلق واحدة أو ثلاثا على وجهين) أحدهما تطلق واحدة إلا أن ينوي أكثر جزم به بعض أصحابنا لأنها إذا طلقت اليوم فهي طالق في غد وفي بعده وكقوله كل يوم ذكره في الانتصار والثاني ثلاثا لأن ذكره في أوقات الطلاق يدل على تعداده (وقيل تطلق في الأول واحدة) لأن من طلقت في اليوم الأول يصح أن يقال هي طالق في الثاني والثالث (

وفي الثانية ثلاثا) وهذا القول قدمه في المحرر والرعاية وجزم به في الوجيز

[ج ٧ - ص ٣١٧]

لأن إعادة في تقتضي فعلا فكأنه قال أنت طالق في اليوم وأنت طالق في غد وأنت طالق في بعد غد قال في الفروع ويتوجه أن يخرج أنت طالق كل يوم أو في كل يوم على هذا الخلاف (وإن قال أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم طلقت في آخر جزء منه) نص عليه واختاره أبو الخطاب ونصره في الشرح قال ابن حمدان وهو أظهر لأن خروج اليوم يفوت به طلاقها فوجب وقوعه قبله في آخر وقت الإمكان كما لو مات أحدهما قي اليوم (وقال أبو بكر لا تطلق) وقدمه في الرعاية لأن شرط طلاقها خروج اليوم وبخروجه يفوت به طلاقها فوجب وقوعه قبله في آخر وقت الإمكان كما لو مات أحدهما في اليوم (وقال أبو بكر لا تطلق) وقدمه في (الرعاية) لأن شرط طلاقها خروج اليوم وبخروجه يفوت محل طلاقها قال في المغني ويبطل هذا بما إذا مات أحدهما في اليوم فإن محل الطلاق يفوت بموته ومع ذلك فإنها تطلق قبل موته فكذا هنا وكذا إن أسقط اليوم الأخير وإن أسقط الأول وقع قبل آخره وقيل بعد خروجه ويأتي إن أسقطهما واحتج بها المؤلف على ضعف قول أبي بكر فدل أنها مثلها وأنه لا يقع فيها على قول أبي بكر

مسائل إذا قال أنت طالق إن لم أتزوج عليك اليوم أو إن لم أشتر لك ثوبا اليوم فالخلاف كقوله لعبده إن لم أبعك اليوم فامرأته طالق ولم يبعه حتى خرج اليوم وإن مات العبد أو عتق أو مات الحالف أو المرأة في اليوم طلقت لأنه قد فات بيعه وإن دبره أو كاتبه فلا ولن منع بيعها قال تطلق

وإن وهب العبد لم تطلق لأنه يمكن عوده إليه ببيعه وإن قال إن لم أبع عبدي فامرأتي طالق وكاتب العبد لم تطلق لأنه يمكن عجزه فلم يعلم فوات البيع وإذا قال إذا مضى يوم فأنت طالق فإن كان نهارا وقع إذا عاد النهار إلى مثل وقته وإن كان ليلا فبغروب شمس الغد [ج ٧ - ص ٣١٨]

(وإن قال أنت طالق يوم يقدم زيد فماتت غدوة وقدم بعد موتها فهل وقع بها الطلاق على وجهين) أحدهما تطلق من أوله قال في الشرح وهو أولى كما لو قال أنت طالق يوم الجمعة وقيل بعد قدومه قدمه في الرعاية لأنه جعل قدومه شرطا فلا تطلق قبله والثاني لا تطلق لأن شرطه قدوم زيد ولم يوجد إلا بعد موت المرأة فلم يقع بخلاف يوم الجمعة وينبني عليها الإرث فلو مات الرجل غدوة ثم قدم زيد أو مات الزوجان قبل قدوم زيد كان الحكم كما لو ماتت المرأة

فرع إذا قال أنت طالق في شهر رمضان إن قدم زيد فقدم زيد فيه فوجهان أحدهما لا تطلق حتى يقدم زيد لأن قدومه شرط فيه والثاني أنه إن قدم زيد تبينا وقوع الطلاق من أول الشهر وهو أصح قاله في الشرح وإن قال أنت طالق غدا أمس أو عكس طلقت طلقة غدا قال ابن حمدان ويحتمل عدمها

(وإن قال أن طالق في غد أو إذا قدم زيد فماتت قبل قدومه لم تطلق) صححه السامري وجزم به في الوجيز لأن الوقت الذي أوقع طلاقها فيه لم يأت وهي محل الطلاق فلم تطلق كما لو ماتت قبل دخول ذلك اليوم وقيل إن قدم فيه طلقت بعد قدومه وقيل من أوله وظاهره أنه إذا قدم بعد الغد أنها لا تطلق (وإن قال أنت طالق اليوم غدا طلقت اليوم

واحدة) لأن من طلقت اليوم فهي طالق غدا (إلا أن يريد طالق اليوم وطالق غدا) [ج ٧ - ص ٣١٩]

فتطلق اثنتين في اليومين فإن قال أردت أنها تطلق في أحد اليومين طلقت اليوم ولم تطلق غدا لأنه جعل الزمان كله ظرفا للطلاق فوقع في أوله (أو نصف طلقة اليوم ونصفها غدا فتطلق اثنتين) لأن كل نصف يكمل ضرورة عدم تبعيض الطلاق) وإن نوى نصف طلقة اليوم وباقيها غدا احتمل وجهين) أصحهما أنها تطلق واحدة لأنه إذا قال نصفها اليوم كملت فلم يبق لها بقية يقع غدا ولم يقع شيء غيرها لأنه ما أوقعه والثاني تقع اثنتان في اليومين

(وإن قال أنت طالق إلى شهر أو حول طلقت عند انقضائه) روي عن ابن عباس وأبي ذر لأنه جعل ذلك غاية للطلاق ولا غاية لآخره فوجب أن يجعل غاية لأوله ولأن هذا يحتمل أن يكون مؤقتا لإيقاعه فلم يقع الطلاق بالشك وعنه تطلق إذن كنيته وذكر ابن عقيل الخلاف مع النية وكقوله أنت طالق إلى مكة ولم ينو بلوغها مكة وإن قال بعد مكة وقع إذن (إلا أن ينوي طلاقها في الحال) لأنه يقر على نفسه بما هو أغلظ ولفظه يحتمله

فرع إذا قال أنت طالق من اليوم إلى سنة طلقت في الحال لأن من لابتداء الغاية فيقتضي أن طلاقها في اليوم فإن أراد وقوعه بعد سنة لم يقع إلا بعدها وإن قال أردت تكرير طلاقها من حين لفظت به إلى سنة طلقت من ساعتها ثلاثا إذا كانت مدخولا بها

(وإن قال أنت طالق من آخر الشهر أو أول آخره طلقت بطلوع فجر آخر يوم منه) اختاره الأكثر لأن آخر الشهر آخر يوم منه ولأنه إذا علق

[ج ٧ - ص ٣٢٠]

الطلاق على وقت تعلق بأوله وقيل تطلق في الأولى بآخر جزء منه فيحرم وطؤه في تاسع عشرين ذكره في المذهب قال في الفروع ويتوجه تخريج

(وإن قال في آخر أوله طلقت في آخر يوم من أوله) على المذهب لأن ذلك آخر يوم من أوله (وقال أبو بكر تطلق في المسألتين بغروب شمس الخامس عشر منه) لأن نصف الشهر فما دون يسمى أوله فإذا شرع في النصف الثاني صدق أنه آخره فيجب أن يتحقق الحنث لأنه أول آخره وآخر أوله والأول أصح وهو قول أكثر العلماء لأن ما عدا اليوم الأول لا يسمى أول الشهر ويصح بنية عنه فإن قال في أول الشهر أو فيه فبدخوله (فإن قال إذا مضت سنة فأنت طالق طلقت إذا مضى اثنا عشر شهرا بالأهلة) أي إذا كان حلفه في أول الشهر لأن السنة كلها معتبرة بالأهلة لأنها السنة التي جعلها الله تعالى مواقيت للناس بالنص (ويكمل الشهر الذي حلف في أثنائه بالعدد) أي إذا كان الحلف في أثناء الشهر وجب تكميل الشهر بالعدد ثلاثين يوما وصفته إذا كان قد مضى منه عشرة أيام ناقصا بقي تسعة عشر يوما فإذا فرغ من الأحد عشر بالأهلة أضاف إلى التسعة عشر أحد عشر يوما وعنه أنه يعتبر العدد في الشهور كلها وهو ظاهر كلامه في الصوم لأنه لما صام نصف الشهر وجب تكميله من الذي يليه فكان ابتداء الثاني من نصفه فيكمل من الذي يليه وهلم جرا

فرع إذا قال أردت سنة شمسية أو عددية قبل منه سنة حقيقية

كما يقبل إذا قال أردت سنة إذا انسلخ ذو الحجة

(فإن قال إذا مضت السنة فأنت طالق طلقت بانسلاخ ذي الحجة) لأنه لما ذكرها بلام التعريف انصرف إلى السنة المعروفة وهي التي آخرها ذو الحجة ووقع في مختصر ابن رزين أن إشارته إليها كتعريفها فإن قال أردت سنة كاملة دين وهل يقبل في الحكم على روايتين ذكره في الكافي وغيره (وإن قال أنت طالق في كل سنة طلقة طلقت الأولى في الحال) لأنه جعل السنة ظرفا للطلاق فيقع إذن (والثانية في أول المحرم) لأن السنة الثانية ظرف للطلقة فتطلق في أولها (وكذا الثالثة) ومحله إذا أدخلنا عليها وهي في نكاحه أو ارتجعها في عدة الطلاق أو جدد نكاحها بعد أن بانت منه فإذا دخلت الثانية لم تطلق فإذا تزوجها في أثناء وقعت الطلقة عقب العقد في ظاهر قول أكثر أصحابنا وقال ابن حمدان إن صح تعليق الطلاق بالنكاح وقال القاضي تطلق بدخول السنة الثانية وعلى قول التميمي ومن وافقه تخل الصفة بوجودها حال البينونة فلا تعود بحال وكذا إن لم يتزوجها حتى دخلت الثالثة ثم نكحها فإنها تطلق عقب تزويجها ولو دامت بائنا حتى مضى العام الثالث لم تطلق بعده واختلف في مبدأ السنة الثانية فقدم في الكافي أن أولها بعد انقضاء اثنى عشر شهرا من حين يمينه وقال أبو الخطاب أولها المحرم لأنها السنة المعروفة

(فإن قال أردت بالسنة اثني عشر شهرا دين) لأن ذلك سنة حقيقية (وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين) أصحهما القبول لأنها سنة حقيقية والثانية [ج ٧ - ص ٣٢٢]

لا لمخالفة الظاهر (وإن قال أردت أن يكون ابتداء السنين المحرم دين) لأنه يحتمل (ولم يقبل في الحكم) ذكره القاضي لأنه خلاف الظاهر قال المؤلف والأولى أن يخرج على روايتين (وإن قال أنت طالق يوم يقدم زيد فقدم ليلا لم تطلق) نص عليه لأنه لم يوجد الشرط إذ اليوم اسم لبياض النهار ولم يوجد وفي الواضح يحتمل وجهين فلو قدم نهارا طلقت قيل عقبه وقيل من أوله وعليها ينبني الإرث (إلا أن يريد باليوم الوقت فتطلق) وقت قدومه لأن الوقت يسمى يوما لقوله تعالى ﴿ ومن يولهم يومئذ دبره ﴾ وقيل إذا لم ينو شيئا فهو كمن نوى الوقت (وإن قدم به ميتا أو مكرها) محمولا أو ماشيا (لم تطلق) وهو المذهب لأنه لم يقدم وإنما قدم به إذ الفعل ينسب إلى فاعله يقال دخل الطعام البلد وهو لا يدخل بنفسه ولا ينسب إلى غيره إلا مجازا وعنه يحنث نقلها محمد بن الحكم واختارها أبو بكر في التنبيه فإن مات في غيبته فذكر أبو بكر أنها تطلق والمذهب خلافه واقتضى ذلك أنه إذا قدم مختارا فإنه يحنث الحالف قولا واحدا وقال ابن حامد إن كان يمتنع باليمين من القدوم لجهل اليمين أو نسيها فروايتان وينبغي أن تعتبر على هذا نية الحالف وقرائن أحواله الدالة على قصده ومتى أشكل الحال وقع [ج ٧ - ص ٣٢٣]

باب تعليق الطلاق بالشروط

وهو ترتيب شيء غير حاصل على شيء حاصل أو غير حاصل ب إن أو إحدى أخواتها (يصح ذلك من الزوج ولا يصح من الأجنبي) أي من صح منه الطلاق بطريق الاستقلال صح منه أن يعلق الطلاق على شرط إذ التعليق مع وجود الصفة تطليق فإذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجوده أي إذا استمرت الزوجية ولا يقع قبله وإن كان الشرط متحقق الوجود على المذهب وحكاه ابن المنذر وابن عبد البر اجماعا ويصح مع تقدم الشرط وتأخره وعنه يتنجز به ونقله ابن هانئ في العتق قال الشيخ تقي الدين وتأخر القسم كأنت طالق لأفعلن كالشرط وأولى بألا يلحق وذكر ابن عقيل في أنت طالق وكرره أربعا ثم قال عقب الرابعة إن قمت طلقت ثلاثا لأنه لا يجوز تعليق ما لم يملك بشرط ويصح بصريحه وكنايته مع قصده

(فلو قال إن تزوجت فلانة أو تزوجت امرأة فهي طالق لم تطلق إذا تزوجها) على المشهور لقوله عليه السلام لا طلاق ولا عتاق لابن آدم فيما لا يملك رواه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد جيد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال الترمذي هو حديث حسن وهو أحسن شيء في الباب ورواه الدارقطني وغيره من حديث عائشة وزاد وان عينها وعن المسور مرفوعا قال [ج ٧ - ص ٣٢٤]

لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك رواه ابن ماجه بإسناد حسن قال أحمد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدة من الصحابة (وعنه تطلق) لأنه يصح تعليقه على الإحضار فصح على حدوث الملك كالوصية وعنه يصح في العتق فقط لتشوف الشارع إليه

(وإن قال لأجنبية إن قمت فأنت طالق فتزوجها ثم قامت لم تطلق رواية واحدة) لأنه لم يضفه إلى زمن يقع فيه الطلاق أشبه ما لو قال لأجنبية أنت طالق ثم تزوجها وعنه صحة قوله لزوجته ان تزوجت عليك فهي طالق أو لعتيقته ان تزوجتك فأنت طالق أو لرجعيته ان راجعتك فأنت طالق ثلاثا وأراد التغليظ عليها وجزم به في الرعاية في الأوليين قال أحمد في العتيقة قد وطئها والمطلق قبل الملك لم يطأ وظاهر كلامه وكلام الأصحاب التسوية

(وإن علق الزوج الطلاق بشرط لم تطلق قبل وجوده) لأنه زوال بني على التغليب والسراية أشبه العتق وذهب أحمد إلى قول أبي ذر أنت حر إلى الحول وعنه يقع في الحال مع تيقن وجوده وخصها الشيخ تقي الدين بالثلاث لأنه الذي يصيره كمتعة ونقل مهنا في هذه الصورة تطلق إذن قيل له فتتزوج في قبل موتي بشهر قال لا ولكن يمسك عن الوطء حتى يموت وذكر في الرعاية تحريمه وجها (فإن قال عجلت ما علقته لم يتعجل) لأنه حكم شرعي فلم يملك تغييره وقيل بل يتعجل وهل تطلق أخرى عند

الشرط قال ابن حمدان يحتمل وجهين قال في الفروع ويتوجه مثله دين

[ج ٧ - ص ٣٢٥]

(وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال) لأنه أقر على نفسه بما يوجب الطلاق فلزمه كما لو قال طلقتها فلو فصل بين الشرط وحكمه بكلام منتظم نحو أنت طالق يا زانية إن قمت لم يقطعه وقال القاضي يحتمل أن يقطعه كسكتة وتسبيحة وإن قال أنت طالق مريضة رفعا ونصبا وقع بمرضها (وإن قال أنت طالق ثم قال أردت إن قمت دين) لأنه أعلم بنيته وما ادعاه محتمل (ولم يقبل في الحكم نص عليه) لأنه خلاف الظاهر وإرادة التعليق من التنجيز بعيدة جدا وفيه فتح باب عظيم الخطر لكن ذكر في الكافي والمستوعب فيه روايتان كقوله أنت طالق ثم قال أردت من وثاق

تنبيه إذا قال إن تركت هذا الصبي يخرج فأنت طالق فخرج بغير اختيارها فإن كان نوى لا يخرج حنث وإن نوى لا تدعه يخرج لم يحنث نص عليه فإن لم تعلم نيته لم يحنث إلا أن يخرج باختياره وإن حلف لا تأخذ حقك مني فأكره على الدفع حنث وإن أكره صاحب الحق على أخذه فوجهان وإن وضعه الحالف في حجره أو بين يديه فلم يأخذ لم يحنث وإن أخذه الحاكم من الغريم فدفعه إلى المستحق فأخذه حنث كما لو قال لا تأخذ حقك علي وقال القاضي لا كما لو قال أعطيك حقك

فصل

(وأدوات الشرط ستة) كذا وقع بخط المؤلف والوجه ست ويمكن

[ج ٧ - ص ٣٢٦]

تخريجه على الحمل على المعنى على تأويل الأدوات بالألفاظ أو هو جمع لفظ وهو مذكر نظيره قول الشاعر % ثلاثة أنفس وثلاثة ذود % لقد جار الزمان على عيالي %

والنفس مؤنثة لكن أريد بها الإنسان وليس المراد حصر أدوات الشرط فيها فإن غيرها أداة له كما وإنما خص الستة بالذكر لأنها غالب ما تستعمل له (إن وإذا ومتى ومن وأي وكلما وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما) بغير خلاف نعلمه لقوله تعالى ﴿ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ﴾ و ﴿ كلما دخلت أمة لعنت أختها ﴾ وفي متى وجهان أحدهما تستعمل للتكرار قال الشاعر % متى تأته تعشو إلى ضوء ناره % تجد خير نار عندها خير موقد %

ولأنها تستعمل للشرط والجزاء ومتى وجد الشرط ترتب عليه جزاؤه والثاني لا يقتضيه وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع لأنها اسم زمن بمعنى أي وقت وبمعنى إذا وكونها تستعمل للتكرار لا يمنع استعمالها في غيره كإذا وأي وقت فإنهما يستعملان في الأمرين كقوله تعالى ﴿ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا ﴾ ﴿ وإذا لم تأتهم بآية ﴾ وكذلك أي وقت وأي زمان فإنهما يستعملان للتكرار وسائر الحروف يجازى بها إلا أنها لما كانت تستعمل للتكرار وغيره فلا تحمل على التكرار إلا بدليل

فرع من وأي المضافة إلى الشخص يقتضيان عموم ضميرهما فاعلا كان أو مفعولا

(وكلها على التراخي إذا تجردت عن لم) أو نية الفور أو قرينته لأنها

[ج ٧ - ص ٣٢٧]

مستعملة فيه لكون أنها لا تقتضي وقتا إلا ضرورة أن الفعل لا يقع إلا في وقت فهي مطلقة في الزمان كله (فإن اتصل بها صارت على الفور) لأن متى وأي معناهما أي زمان وذلك شائع في الزمان كله فأي زمن وجدت الصفة فيه وجب الحكم بوقوع الطلاق ولا بد أن يلحظ في أي كونها مضافة إلى زمن فإن أضيفت إلى شخص كان حكمها حكم من وظاهره أن من للفور وصرح به في المغني وفيه نظر لأن من لا دلالة لها على الزمان إلا ضرورة أن الفعل لا يقع إلا في زمان فهي بمنزلة أي فيجب ألا تكون على التراخي مع أن صاحب المحرر حكى في من وأي المضافة إلى الشخص وجهين ويتوجهان في مهما فإن اقتضت فورا فهي في التكرار كمتى وأما كلما فدلالتها على الزمن أقوى من دلالة أي و متى فإذا صارتا للفور عند اتصالهما بلم فلأن تصير كلما كذلك بطريق الأولى (إلا أن) أي مع عدم نية أو قرينة فإذا قال إن لم تدخلي الدار فأنت طالق لم يقع إلا عند تعذر ايقاعه بموت أو ما يقوم مقامه (وفي إذا وجهان) أحدهما أنها على التراخي نصره القاضي لأنها تستعمل شرطا بمعنى إن كقول الشاعر % وإذا تصبك خصاصة فتجمل %

فجزم بها كإن ولأنها تستعمل بمعنى متى وإن فلا يقع بالشك والثاني على الفور وهو أشهر لأنها اسم لزمن مستقبل فيكون كمتى فأما المجازاة بها فلا تخرجها عن موضوعها

مسألة قد علم حكم المعلق بالشرط وأنها لا تطلق قبل وجوده وعنه يحنث بعزمه على الترك وجزم به في الروضة لأنه أمر موقوف على القصد والقصد

[ج ٧ - ص ٣٢٨]

هو النية ولهذا فعله ناسيا أو مكرها لم يحنث لعدم القصد فأثر فيه تعيين النية كالعبادات من الصلاة والصيام إذا نوى قطعهما ذكره في الواضح

تذنيب قولهم الأدوات الأربع في النفي على الفور صحيح في كلما وأي ومتى فإنها تعم الزمان بخلاف من لأنها ليست من أسماء الزمان وإنما تعم الأشخاص فلا يظهر أنها تقتضي الفور فعلى هذا إذا قال من لم أطلقها منكن فهي طالق لم تطلق واحدة منهن إلا أن يتعذر طلاقها أو ينوي وقتا أو تقوم قرينة بفور فيتعلق به

(فإذا قال إن قمت أو إذا قمت أو من قامت منكن أو أي وقت قمت أو متى قمت أو كلما قمت فأنت طالق فمتى قامت طلقت) لأن وجود الشرط يستلزم وجود الجزاء وعدمه عدمه إلا أن يعارض معارض (وإن تكرر القيام لم يتكرر الطلاق) لأنها ليست للتكرار (إلا في كلما) فإنها تقتضي التكرار (ومتى في أحد الوجهين) بناء على مقتضاها التكرار وعدمه ولو قمن الأربع فيمن قامت وأيتكن قامت أو من أقمتها أو أيتكن أقمتها طلقن (ولو قال كلما أكلت رمانة فأنت طالق وكلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق فأكلت رمانة طلقت ثلاثا) لوجود وصفه النصف مرتين والجميع مرة لأن كلما تقتضي التكرار واختار الشيخ تقي الدين تطلق واحدة

(وإن علق طلاقها على صفات ثلاث فاجتمعن في عين واحدة مثل أن يقول إن رأيت رجلا فأنت طالق وإن رأيت فقيها فأنت طالق وإن

[ج ٧ - ص ٣٢٩]

رأيت أسود فأنت طالق فرأت رجلا أسود فقيها طلقت ثلاثا) لوجود الصفات الثلاث فيه أشبه ما لو رأت ثلاثة فيهم الثلاث صفات

أصل أدوات الشرط إذا تقدم جزاؤها عليها لم يحتج إلى الفاء في الجزاء كقوله أنت طالق إن دخلت الدار وإن تأخر احتاجت إلى حرف واختصت الفاء لأنها للتعقيب

(وإن قال إن لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها لم تطلق) لأن إن لم لا تقتضي الفور (إلا في آخر جزء من حياة أحدهما) أي أحد الزوجين لأنه لا يمكن إيقاع الطلاق بها بعد موت أحدهما فتبين أنه يقع لجواز أن يطلقها قبل موته أو موتها (إلا أن تكون له نية) فيعمل بها لأنه نوى الطلاق بقول صالح فوجب أن يقع عملا بالمقتضي السالم عن المعارض وكذا إذا دلت قرينة على الفور وفي الإرشاد رواية يقع بعد موته وأيهما مات قبل إيقاعه وقع الحنث بموته وورثه صاحبه إذا كان أقل من ثلاث وإن كان ثلاثا ورثته ولم يرثها هو ولا يرث ثانيا وترثه ويخرج لا ترثه من تعليقه في صحته على فعلها فيوجد في مرضه والفرق ظاهر وفي الروضة في إرثهما روايتان لأن الصفة في الصحة والطلاق في المرض وفيه روايتان

فرع لا يمنع من وطء زوجته قبل فعل ما حلف عليه وعنه بلى جزم به جماعة والأول أصح لأنه نكاح صحيح لم يقع فيه طلاق فحل له الوطء

(وإن قال من لم أطلقها أو أي وقت لم أطلقك) أو متى لم أطلقك

[ج ٧ - ص ٣٣٠]

فأنت طالق فمضى زمن يمكن طلاقها فيه طلقت) في الحال لوجود الصفة فإنها اسم لوقت الفعل فيقدر بهذا أو لهذا يصح به السؤال فيقال متى دخلت أو أي وقت دخلت وأما من فتقتضي الفور وحينئذ يتحقق الطلاق بمضي زمن عقيب اليمين إذا لم يطلق لأن شرطه يتحقق حينئذ فيلزم منه الطلاق ضرورة أن وجود الشرط يستلزم وجود المشروط وفي وجه أن حكم من لم أطلقها أو إذا لم أطلقك أو أيتكن لم أطلقها كحكم إن لم أطلقك

(وإن قال إذا لم أطلقك فأنت طالق فهل تطلق في الحال) أو في آخر جزء من حياة أحدهما (على وجهين) بناء على أنها للفور أو على التراخي (وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثا ولم يطلقها طلقت ثلاثا) لأن كلما تقتضي التكرار فيقتضي تكرار الطلاق بتكرر الصفة والصفة عدم طلاقه لها فإذا مضى زمن يمكن فيه أن يطلقها ولم يفعل فقد وجدت الصفة فيقع واحدة وثانية وثالثة إذا كانت مدخولا بها (إلا التي لم يدخل بها فإنها تبين بالأولى) ولم يقع شيء بعدها لأن البائن لا يقع عليها طلاق (وإن قال العامي أن دخلت الدار فأنت طالق بفتح الهمزة فهو شرط) لأن العامي لا يريد به إلا الشرط ولا يعرف أن مقتضاها التعليل فلا يريده فلا يثبت له حكم ما لا يعرفه وكنيته (وإن قاله عارف بمقتضاه طلقت في الحال) لأن أن للتعليل لا للشرط لقوله

تعالى ﴿ يمنون عليك أن أسلموا ﴾ الحجرات 17 و ﴿ وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا ﴾ [ج ٧ - ص ٣٣١]

قال القاضي وهذا التفصيل قياس المذهب (وحكي عن الخلال أنه إن لم ينو مقتضاه فهو شرط أيضا) لأن الطلاق يحمل على العرف فإذا لم ينو مقتضاه استوى العارف وغيره وفيه وفي الترغيب وجه يقع إذن ولو لم يوجد كتطليقها لرضى أبيها يقع كان فيه رضاه أو سخطه وأطلق جماعة عن أبي بكر فيهما يقع إذن ولو بدل أن كهي وفي الكافي يقع إذن كإذ ذكره في الكافي والشرح وفيها احتمال كأمس

فرع إذا قال إن دخلت الدار أنت طالق فهو شرط قدمه في المحرر و الرعاية كما لو قال أنت طالق إن دخلت الدار وإنما حذفت الفاء لحذف المبتدأ أو الخبر لدلالة باقي الكلام عليه وفي الكافي احتمال يقع في الحال لأن جواب الشرط إذا تأخر عنه لم يكن إلا بالفاء أو إذا وقيل إن نوى الشرط وإلا طلقت في الحال

(وإن قال إن قمت وأنت طالق طلقت في الحال) لأن الواو ليست جوابا للشرط لأن معناه أنت طالق في كل حال لقوله عليه السلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وفي الفروع كالفاء (فإن قال أردت الجزاء أو أردت أن أجعل قيامها وطلاقها شرطين لشيء ثم أمسكت) دين لأنه محتمل وهو أعلم بمراده من غيره (وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين) كذا أطلقهما في الفروع وغيره أشهرهما القبول فيه لما ذكرنا والثانية لا لأنه خلاف الظاهر فلو جعل له جزاءا بأن قال إن

قمت أنت طالق فعبدي حر صح ولم يعتق العبد حتى يقوم وهي طالق لأن الواو هنا للحال فلو قال [ج ٧ - ص ٣٣٢]

إن قمت طالقا فقامت وهي طالق طلقت أخرى وإن قامت وهي غير طالق لم تطلق لأن هذا حال فجرى مجرى قوله إن قمت ساكتة

فرع إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق وإن دخلت الأخرى رجع إلى ما أراد فإن عدمت فمتى دخلت الأولى طلقت سواء دخلت الأخرى أو لا ولا تطلق الأخرى فلو قال إن دخلت الدار وإن دخلت هذه الأخرى فأنت طالق فقيل لا تطلق إلا بدخولهما ويحتمل أن تطلق بأحدهما أيهما كان لأنه ذكر شرطين بحرفين فيقتضي كل واحد منهما جزاء فترك جزاء الأول والجزاء الأخير دال عليه كقوله تعالى ﴿ عن اليمين وعن الشمال قعيد ﴾ ق 17

وإن قال إن قمت فقعدت فأنت طالق أو إن قعدت إذا قمت أو إن قعدت إن قمت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد) لأن القعود شرط يتقدم مشروطه وكذا إن قال إن قمت ثم قعدت لأن الفاء وثم للترتيب وذكر القاضي في إن كالواو بناء على أن فيه عرفا وذكر جماعة في الفاء وثم رواية كالواو

تتمة إذا قال أنت طالق إن أكلت إذا أو إن أو متى لبست لم تطلق حتى تلبس ثم تأكل وتسميه النحاة اعتراض الشرط على الشرط فيقتضي تقديم المتأخر وتأخير المتقدم لأنه جعل الثاني في اللفظ شرطا للذي قبله والشرط يتقدم المشروط كقوله تعالى ﴿ ولا ينفعكم نصحي ﴾ هود 34

الآية وقال القاضي إذا كان الشرط بإذا كقولنا وفيما إذا قال إن شربت إن أكلت أنها تطلق بوجودهما كيفما وجدا لأن أهل العرف لا تعرف ما يقوله أهل العربية في هذا فقال المؤلف والأول أصح وليس لأهل العرف في هذا عرف

(وإن قال إن قمت وقعدت فأنت طالق طلقت بوجودهما كيفما كانا)

[ج ٧ - ص ٣٣٣]

ولا تطلق بوجود أحدهما لأنها للجمع لا للترتيب (وعنه تطلق بوجود أحدهما) لأن الحالف على فعل شيء يحنث بفعل بعضه على رواية وكإن قمت وإن قعدت (إلا أن ينوي) فعل الأمرين لأنه حينئذ لا يحنث بفعل أحدهما لأن الخلاف في بعض المحلوف إنما هو عند الإطلاق أما إذا نوى الكل فلا يحنث بفعل البعض رواية واحدة (والأول أصح) لأن هذه الرواية تخالف الأصول والقواعد فإنه لا خلاف أن الحكم المعلق بشرطين لا يثبت إلا بهما (وإن قال إن قمت أو قعدت فأنت طالق طلقت بوجود أحدهما) لأن أو تقتضي تعليق الجزاء على واحد كقوله تعالى ﴿ فمن كان منكم مريضا أو على سفر ﴾ البقرة 184

فصل في تعليقه بالحيض

(إذا قال إذا حضت فأنت طالق طلقت بأول الحيض) لأن الصفة وجدت بدليل منعها من الصلاة والصيام نقل مهنا تطلق برؤية الدم لتحريم مباشرتها طاهرا فيه وفي قبل موتي بشهر وكل زمن يحتمل أن يتبين أنه زمن الطلاق في الأصح ولمنع المعتادة من العبادة إجماعا وفي الانتصار والفنون وغيرهما بتبينه بمضي أقله

(فإن بان أن الدم ليس بحيض لم تطلق به) لأنه تبين أن الصفة لم توجد وذلك بأن تكون بنت دون تسع سنين أو ينقطع لأقل من أقل

الحيض ويتصل الانقطاع إلى أكثر الحيض ولم يشترط في المغني الاتصال واشترطه أبو الخطاب [ج ٧ - ص ٣٣٤]

وغيره ولا بد منه لأنه إذا انقطع لما ذكر ثم جاء قبل الأكثر كان حيضا لكون من رأته ملفقة ومعنى لم تطلق أي لم يقع (وإن قال لطاهر إذا حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر) نص عليه لأنها لا تحيض حيضة إلا بذلك وقيل لا تطلق حتى تغتسل منها وذكره ابن عقيل رواية من أول حيضة مستقبلة والأول أصح والظاهر أنه يقع سنيا (ولا يعتد بالحيضة التي هي فيها) لأنها ليست حيضة كاملة

فرع إذا قال إذا حضت حيضة فأنت طالق وإذا حضت حيضتين فأنت طالق فحاضت حيضة طلقت واحدة فإذا حاضت الثانية طلقت الثانية عند طهرها فلو قال ثم إذا حضت حيضتين فأنت طالق لم تطلق الثانية حتى تطهر من الحيضة الثالثة لأن ثم للترتيب تقتضي حيضتين بعد الطلقة الأولى

(وإن قال إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق احتمل أن يعتبر نصف عادتها) جزم به في الوجيز وصححه في الشرح لأن الأحكام تعلقت بالعادة فيتعلق بها وقوع الطلاق (واحتمل أنها متى ظهرت تبينا وقوع الطلاق في نصفها) وهو أشهر لأنها إذا طهرت في ستة أيام مثلا تحقق أن نصف حيضها ثلاثة فيجب أن يحكم بوقوع الطلاق فيها لوجود شرطه وفيه إشعار أنها لا تطلق حتى تطهر وهو صحيح لأن شرط الطلاق مضي نصف الحيضة ولا يتحقق نصفها إلا بكمالها (واحتمل أن يلغو قوله نصف حيضة

) وهو قول القاضي لأن الحيضة لا تتنصف لأنها عبارة عن جريان الدم فعلى هذا يتعلق [ج ٧ - ص ٣٣٥]

طلاقها بأول الدم كقوله إذا حضت (وقيل إذا حاضت سبعة أيام ونصفا طلقت) لأنه لا يتيقن مضي الحيضة إلا بذلك ولأنه نصف أكثر الحيض قال في الكافي بمعنى والله أعلم أنه مادام حيضها باقيا لا يحكم بوقوع طلاقها حتى يمضي نصف أكثر الحيض لأن ما قبل الحيض لا يتيقن به مضي نصف الحيضة فلا يقع الطلاق بالشك

(وإن قال إذا طهرت فأنت طالق طلقت بانقطاع الدم) نص عليه لأنه بانقطاعه ثبت لها أحكام الطاهرات في وجوب الصلاة وصحة الصيام فيجب أن يتعلق به وجوب الطلاق وفي عبارته تسامح ولو قال بأول طهر مستقبل لكان أولى وظاهر أنها تطلق وإن لم تغتسل لأنه ثبت لها أحكام الطهر لأنها ليست حائضا فلزم أن تكون طاهرا لأنهما ضدان وفي التنبيه قول حتى تغتسل لأن بعض أحكام الحيض باقية وبناه في الشرح على العدة (وإن كانت طاهرا أطلقت إذا أطهرت من حيضة مستقبلة) لأن قوله لها إذا طهرت يقتضي تجدد الطهارة فإذا كانت طاهرا لم توجد الطهارة المتجددة إلا إذا طهرت من حيضة مستقبلة ضرورة كونها طهارة متجددة وإذا قالت حضت وكذبها قبل قولها في نفسها بغير يمين في ظاهر المذهب لقوله تعالى ﴿ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ﴾ البقرة 228 قيل هو الحيض فلولا أن قولها مقبول فيه ما حرم عليها كتمانه ولأنه لا يعرف إلا من جهتها ولقوله إن أضمرت بغضي فادعته

بخلاف دخول الدار وعنه تطلق بنيته فيختبرنها النساء بإدخال قطنة في الفرج زمن دعواها [ج ٧ - ص ٣٣٦]

الحيض فإن ظهر دم فهي حائض واختاره أبو بكر لأن الحيض يمكن معرفته من غيرها كدخول الدار وعلى الأول هي يعتبر يمينها فيه وجهان مبنيان على ما إذا ادعت أو زوجها طلقها وأنكرها وفاقا لأبي حنيفة وقوله قبل قولها في نفسها أي دون غيرها من طلاق أخرى أو عتق عبد نص عليه في الطلاق لأنها مؤتمنة في حق نفسها دون غيرها

(وإن قال قد حضت فأنكرته طلقت بإقراره) لأنه أقر بما يوجب طلاقها أشبه ما لو قال طلقتها (وإن قال إن حضت فأنت وضرتك طالقتان فقالت قد حضت وكذبها طلقت) لأن قولها مقبول في حق نفسها (دون ضرتها) أي أن الضرة لا تطلق إلا أن تقيم بينة على حيضها فإن ادعت الضرة أنها حاضت لم تقبل لأن معرفتها بحيض غيرها كمعرفة الزوج به وعنه تختبر وعنه إن أخرجت على خرقة دما طلقت الضرة اختاره في التبصرة وحكاه عن القاضي فإذا قال حضت وأنكرت طلقت بإقراره (وإن قال إن حضتما فأنتما طالقتان فقالتا قد حضنا فصدقهما طلقتا) لأنهما أقرتا وصدقهما فوجدت الصفة في حقهما (وإن كذبهما لم تطلقا) ولا واحدة منهما لأن طلاق كل واحدة منهما معلق على شرطين حيضها وحيض ضرتها ولا يقبل قول واحدة منهما في حق ضرتها فلم يوجد الشرطان (وإن كذب إحداهما طلقت وحدها) لأن قولها مقبول في حقها وقد صدق الزوج ضرتها فوجد الشرطان في

حقها ولم تطلق المصدقة لأن قول المكذبة غير مقبول في حقها ولم يصدقها الزوج فلم يوجد شرط طلاقها [ج ٧ - ص ٣٣٧]

فرع إذا قال لزوجتيه إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان بحيضتين منهما عملا باليقين وفي الكافي والمستوعب يلغى قوله حيضة ويصير كقوله إن حضتما قاله القاضي وقدمه في الرعاية زاد في الكافي فإن قال أردت إذا حاضت كل واحدة منهما حيضة قبل لأنه محتمل لذلك والأشهر تطلقان بالشروع فيهما وقيل بحيضة من واحدة وقيل لا تطلقان بحال كمستحيل

(وإن قال ذلك لأربع) فقد علق طلاق كل واحدة منهن على حيض الأربع (فقلن قد حضنا فصدقهن طلقن) لأنه قد وجد حيضهن بتصديقه (وإن صدق واحدة أو اثنتين لم يطلق منهن شيء) لأن شرط طلاقهن حيض الأربع ولم يوجد وكذا إن كذب الكل (وإن صدق ثلاثا طلقت المكذبة وحدها) لأن قولها مقبول في حيضها وقد صدق الزوج صواحبها فوجد حيض الأربع في حقها فطلقت ولا تطلق المصدقات لأن قول المكذبة غير مقبول في حقهن

فائدة الأفصح في صاحبة أن تجمع على صواحب كضوارب ووقع لبعضهم صواحباتها وهي لغة قليلة

(وإن قال كلما) أو أيتكن (حاضت إحداكن فضرائرها طوالق فقلن قد حضنا فصدقهن طلقن ثلاثا ثلاثا) لأن حيض كل واحدة منهن صفة لطلاق البواقي ولكل واحدة ثلاث ضرائر وقد حضن فتطلق ثلاث تطليقات فإن كذبهن لم يطلق منهن شيء لأن قولهن غير مقبول في طلاق

غيرهن (وإن صدق واحدة لم تطلق) لأنه ليس لها صاحبة ثبت حيضها (وطلق ضراتها طلقة طلقة) لأن لكل [ج ٧ - ص ٣٣٨]

منهن صاحبة ثبت حيضها (وإن صدق اثنتين طلقت كل واحدة منهما طلقة) لأن لكل واحدة منهما ضرة مصدقة (وطلقت المكذبتان طلقتين طلقتين) لأن لكل واحدة منهما ضرتين مصدقتين (وإن صدق ثلاثا طلقت المكذبة ثلاثا) لأن لها ثلاث ضرائر ثبت حيضهن وطلقت كل واحدة من المصدقات طلقتين لأن لكل واحدة ضرتين مصدقتين

فرع العتق المعلق بالحيض كذلك

تذنيب إذا قال لأربع أيتكن لم أطأها فضرائرها طوالق فإن قيده بوقت معين فمضى ولم يطأهن طلقن ثلاثا ثلاثا لأن لكل واحدة ثلاث ضرائر غير موطوآت فإن وطىء ثلاثا وترك واحدة لم تطلق المتروكة لأنها ليس لها ضرة غير موطوءة وتطلق كل واحدة من الموطوآت طلقة طلقة وإن وطىء طلقتا طلقتين وإن أطلق تقيد بالعمر فإذا مات هو طلقن كلهن في آخر جزء من حياته وعنه فيمن قال لعبيده أيكم أتاني بخبر كذا فهو حر فجاء به جماعة عتقوا ونقل حنبل أحدهم بقرعة فيتوجه مثله في نظائرها ذكرهما في الإرشاد

فصل في تعليقه بالحمل

(إذا قال إن كنت حاملا فأنت طالق فتبين أنها كانت حاملا تبينا

وقوع الطلاق حين اليمين) بأن تلد لأقل من ستة أشهر من حين اليمين فيقع الطلاق بوجود شرطه منذ حلف وكذا بينهما ولم يطأ (وإلا فلا) بأن تلد لأكثر من أربع سنين فإنها لا تطلق فإن ولدت بين المدتين وكان الزوج يطؤها فولدت لدون نصف سنة منذ وطئ وقع لعلمنا أنه ليس من الوطء وإن ولدته لأكثر منها فوجهان أصحهما لا تطلق لأن النكاح باق بيقين والظاهر حدوث الولد من الوطء لأن الأصل عدمه قبله ونصه يقع إن ظهر للنساء أو خفي فولدته لتسعة أشهر فأقل

(وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق فهي بالعكس) فيما إذا كان الشرط عدميا فتطلق في كل موضع لا تطلق في المسألة السابقة وعكسه بعكسه وفي الكافي كل موضع لا يقع ثمة يقع هنا وفيه وجهان أحدهما تطلق لأن الأصل عدم الحمل والثاني لا لأن الأصل بقاء النكاح (ويحرم وطؤها قبل استبرائها) في المسألتين (في إحدى الروايتين إن كان الطلاق بائنا) نص عليه لأنه يحتمل أن يكون شرط الطلاق حاصلا فيكون واطئا بائنا وشرط البينونة لأنه إذا كان رجعيا وقدر حصول الشرط يكون واطئا رجعية وهو حلال على المذهب وقال القاضي ولو رجعية مباحة منذ حلف وعنه بظهور حمل ويكفي الاستبراء بحيضة ماضية أو موجودة نص عليه وقيل لا وذكره في الترغيب عن أصحابنا وعنه تعتبر ثلاثة أقراء لأنها حرة أنهت العدة والصحيح الأول لأن المقصود معرفة براءة رحمها وذلك حاصل بحيضة لأن ما تعلم به البراءة في حق

الأمة تعلم به في حق الحرة لأنه أمر حقيقي لا يختلف بالحرية والرق

[ج ٧ - ص ٣٤٠]

وأما العدة ففيها نوع تعبد وهل تعتد بالاستبراء قبل عقد اليمين أو بالحيضة التي حلف فيها على وجهين أصحهما الاعتداد به قاله في الشرح والثانية لا يحرم وطؤها لأن الأصل بقاء النكاح

فرع إذا قال إذا حملت لم يقع إلا بحمل متجدد ولا يطأ حتى تحيض ثم يطأ كل طهر مرة وعنه يجوز أكثر

(وإن قال إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق واحدة وإن كنت حامل بأنثى فأنت طالق اثنتين فولدت ذكرا وأنثى طلقت ثلاثا) لوجود الصفة واستحقا من وصيته وإن ولدت ذكرا فطلقة وإن كانا ذكرين فطلقة وقيل اثنتان وإن ولدت أنثى أو اثنتين فطلقتين وقال ابن حمدان تطلق بالاثنتين ثلاثا (وإن كان مكان قوله إن كنت حاملا إن كان حملك) أو ما في بطنك (لم تطلق إذا كانت حاملا بهما) وهو قول أبي ثور لأن حملها كله ليس بغلام ولا جارية وقال القاضي في وقوع الطلاق وجهان بناء على الروايتين فيمن حلف لا لبست ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه

فصل في تعليقه بالولادة

إذا علقه بها فألقت ما تصير به الأمة أم ولد وقع ويقبل قوله في عدم الولادة قال القاضي وأصحابه إن لم يقر بالحمل وإن شهد بها النساء وقع في

ظاهر كلامه وقيل لا كمن حلف بطلاق ما غضب أو لا غضب فثبت ببينة مال لم تطلق في الأصح

(إذا قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة وإن ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين فولدت ذكرا ثم أنثى) أو خنثى قاله في الكافي (طلقت بالأول) لأن شرطه ولادة ذكر وأنثى وقد وجد (وبانت بالثاني ولم تطلق به ذكره أبو بكر) وصححه في الكافي والشرح لأن العدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق بائنا كقوله إذا مت فأنت طالق (وقال ابن حامد تطلق به) وأومأ إليه قاله في المنتخب لأن زمن البينونة زمن الوقوع فلا تنافي بينهما وفي نكت المحرر ويعايا بها على أصلنا إن الطلاق بعد الدخول ولا مانع والزوجان مكلفان لا عدة فيه ويقال طلاق بلا عوض دون الثلاث بعد الدخول في نكاح صحيح لا رجعة فيه فإن ولدتهما معا طلقت ثلاثا لوجود الشرطين وان سبق أحدهما بدون ستة أشهر وقع ما علق به وانقضت العدة بالثاني وإن كان بستة أشهر فالثاني من حمل مستأنف بلا خلاف فلا يمكن ادعاء أن تحبل بولد بعد ولد وفي الطلاق به وجهان الا أن يقول لا تنقضي به عدة فيقع الثلاث وكذا في الأصح إن ألحقنا به لثبوت وطئه به فتثبت الرجعة على الأصح فيها واختار في الترغيب أن الحمل لا يدل على الوطء المحصل للرجعة

(وإن أشكل كيفية وضعهما وقعت واحدة بيقين) جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والفروع لأن من وقع بها طلقتان فيقع بها واحدة

[ج ٧ - ص ٣٤٢]

(ولغا ما زاد) على المذهب لأنه مشكوك فيه والأصل بقاء النكاح ولا يزول عنه بالشك لكن الورع أن يلتزمها ذكره في الشرح (وقال القاضي قياس المذهب أن يقرع بينهما) وأومأ إليه قال في الفروع وهو أظهر لأنه يحتمل كل واحد منهما احتمالا مساويا للآخر فيقرع بينهما كما لو أعتق أحد عبديه معينا ثم أنسيه (ولا فرق بين أن تلده حيا أو ميتا) لأن الشرط ولادة ذكر وأنثى وقد وجد ولأن العدة تنقضي به وتصير الجارية أم ولد فكذا هنا فلو قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثة معا فثلاث وكذا إن لم يقل ولدا واختار المجد واحدة فإن قال أول ولد تلدينه ذكرا فأنت طالق واحدة وإن كانت أنثى فاثنتين فولدتهما معا لم تطلق لأنه لا أول فيهما فإن ولدتهما دفعتين طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق إلا على قول ابن حامد

تنبيه إذا قال لأربع نسوة كلما ولدت إحداكن فضرائرها طوالق فولدن دفعة واحدة طلقن ثلاثا ثلاثا وإن ولدن متعاقبات طلقت الأولى والرابعة ثلاثا ثلاثا والثانية طلقة والثالثة طلقتين فلو قال إن ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ولدين على التعاقب طلقت بالأول وفرغت عدتها من الثاني ولم تطلق به في الأصح فإن كان بينهما نصف سنة فأكثر ودون أكثر مدة الحمل فهل يلحقه الثاني وتنقضي به العدة فيه وجهان [ج ٧ - ص ٣٤٣]

فصل في تعليقه بالطلاق

(إذا قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال إذا قمت فأنت طالق فقامت طلقت طلقتين) لأنها تطلق واحدة بقيامها وأخرى بالصفة لأن الصفة تطليقة لها وتعليقه لطلاقها بقيامها إذا اتصل به القيام تطليق لها فلو قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال أنت طالق وقعت واحدة بالمباشرة وأخرى بالصفة إن كانت مدخولا بها لأنه جعل تطليقها شرطا لوقوع طلاقها وإن كانت غير مدخول بها بانت بالأولى ولم تقع الثانية لأنه لا عدة عليها فإن قال عنيت بأنه يقع عليك ما باشرتك به دين وفي الحكم روايتان

فرع إذا وكل من طلقها فهو كمباشرته لأن فعل الوكيل كموكله

(وإن قال إن قمت فأنت طالق ثم قال إذا طلقتك فأنت طالق فقامت طلقت واحدة) لقيامها ولم تطلق بتعليق الطلاق لأنه لم يطلقها بعد ذلك لأن هذا يقتضي ابتداء ايقاع ووقوع الطلاق هنا بالقيام إنما هو وقوع بصفة سابقة لعقد الطلاق شرطا (وإن قال إن قمت فأنت طالق ثم قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق فقامت طلقت طلقتين) واحدة بالقيام والثانية بوقوع الطلاق عليها إن كانت مدخولا بها لأن الطلاق الواقع بها طلاقه فقد وجدت الصفة وإن كانت غير [ج ٧ - ص ٣٤٤]

مدخول بها فواحدة (وإن قال كلما طلقتك فأنت طالق ثم قال أنت طالق طلقت طلقتين) إحداهما بالمباشرة والأخرى بالصفة ولا تقع ثالثة لأن قوله كلما طلقتك تقتضي كلما أوقعت عليك الطلاق وهذا يقتضي تجديد إيقاع طلاق بعد هذا القول فلو قال لها بعد عقد الصفة إن خرجت فأنت طالق فخرجت طلقت بالخروج طلقة وبالصفة أخرى لأنه قد طلقها فلو قال كلما أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق فهو كقوله كلما طلقتك فأنت طالق وذكر القاضي في هذا أنه إذا أوقع عليها طلاقه بصفة عقدها لم تطلق لأن ذلك ليس بإيقاع منه وفيه نظر فإنه قد أوقع عليها الطلاق بشرط فإذا وجد الشرط فهو الموقع للطلاق عليها

(وإن قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم وقع عليها طلاقه بمباشرة أو سبب طلقت ثلاثا) لأنه إذا طلقها بمباشرة أو سبب طلقت واحدة فيصدق أنه وقع عليها طلاقه فتطلق أخرى بالصفة وتقع الثالثة لأن كلما للتكرار وفي الكافي والشرح لأن الثانية طلقة واقعة عليها فتقع بها الثالثة (وإن قال كلما وقع عليك طلاقي أو إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم قال أنت طالق فلا نص فيها) أي لم ينقل عن الإمام أحمد فيها شيء والصواب وقوع الطلاق لعمومات النصوص ولأن الله تعالى شرع الطلاق لمصلحة تتعلق به فلا يجوز إبطالها وفي القول بعدمها إبطال لها ولأنه طلاق من مكلف مختار في محل النكاح صحيح فيجب أن يقع كما لو لم يعقد هذه [ج ٧ - ص ٣٤٥]

الصفة (وقال أبو بكر والقاضي تطلق ثلاثا) واختاره الجمهور ذكره في الترغيب وجزم به في المستوعب عن أصحابنا لأنه وصف المعلق بصفة فيستحيل وصفه بها فإنه يستحيل وقوعها بالشرط قبله فلغت صفتها بالقبلية وصار كأنه قال إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثلاثا قيل معا وقيل المعلق وقيل المنجز ثم تمتها من المعلق لكن إذا كان المنجز أقل من ثلاث كملت من المعلق وإن كان ثلاثا لم يقع من المعلق شيء لأنه لم يصادف محلا (وقال ابن عقيل تطلق بالطلاق المنجز) لأن المحل صالح له (ويلغو ما قبله) أي تعليقه باطل لأنه طلاق في زمن ماض أشبه قوله أنت طالق أمس ولأنه لو وقع المعلق لمنع وقوع المنجز فإذا لم يقع المنجز بطل شرط المعلق فاستحال وقوع المعلق ولا استحالة في وقوع المنجز فيقع وقيل لا يقع شيء أما المنجز فلأنه لو وقع لوقع ثلاث قبله لوجود الشرط ولو كان كذلك لما وقع إذ لا مزيد على الثلاث فلزم من وقوعه عدم وقوعه فلم يقع وأما المعلق فإنه إذا لم يقع المنجز لم يوجد الشرط وهذا ما صححه الأكثرون من الشافعية وحكاه بعضهم عن النص وقاله الشيخ أبو حامد شيخ العراقيين والقفال شيخ المراوزة قال في المهمات فكيف تسوغ الفتوى بما يخالف نص الشافعي وكلام الأكثرين ونصر في الشرح الأول وأكده بقوله إذا انفسخ نكاحك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم وجد ما يفسخ النكاح من رضاع أو ردة فإنه يرد على ابن سريج فيها ولا خلاف في انفساخ النكاح قال القاضي ما ذكروه ذريعة إلى أنه

لا يقع عليها الطلاق جملة ولو قال لزوجته الأمة إذا ملكتك فأنت طالق ثلاثا ثم ملكها طلقت في الاقيس وفي المحرر لا تطلق وجها واحدا

[ج ٧ - ص ٣٤٦]

تنبيه إذا قال كلما طلقتك طلاقا أملك فيه رجعتك فأنت طالق ثم قال أنت طالق طلقت طلقتين إحداهما بالمباشرة والأخرى بالصفة إلا أن تكون الطلقة بعوض أو غير مدخول بها فلا تقع ثانية وإن طلقها ثنتين طلقت الثالثة نصره في الشرح وهو الأصح وإن قال كلما طلقت ضرتك فأنت طالق ثم قال مثله للضرة ثم طلق الأولة طلقت الضرة طلقة بالصفة والأولة طلقتين بالمباشرة ووقوعه بالضرة تطليق لأنه أحدث فيها طلاقا بتعليقه طلاقها بائنا وإن طلق الثانية فقط طلقتا طلقة طلقة

(وإن قال لأربع نسوة أيتكن وقع عليها طلاقي فصواحبها طوالق ثم وقع على إحداهن طلاقه طلقن ثلاثا ثلاثا) لأنه إذا وقع طلاقه على واحدة وقع على صواحبها ووقوعه على واحدة منهن يقتضي وقوعه على صواحبها فيتسلسل الوقوع عليهن إلى أن تكمل الثلاث بكل واحدة

فرع لو كان له ثلاث نسوة فقال إن طلقت زينب فعمرة طالق وإن طلقت عمرة فحفصة طالق وإن طلقت حفصة فزينب طالق ثم طلق زينب طلقت عمرة ولم تطلق حفصة وإن طلق عمرة طلقت حفصة ولم تطلق زينب وإن طلق حفصة طلقت زينب ثم طلق عمرة وقع الطلاق بالثلاث لأنه أحدث في زينب طلاقا بعد تعليقه طلاق عمرة بطلاقها

(وإن قال كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر وكلما طلقت اثنتين فعبدان حران وكلما طلقت ثلاثا فثلاثة أحرار وكلما طلقت أربعا

[ج ٧ - ص ٣٤٧]

فأربعة أحرار ثم طلقهن جميعا) مجتمعات أو متفرقات (عتق خمسة عشر عبدا) هذا هو الأصح لأن فيهن أربع صفات هن أربع فيعتق أربعة وهن أربعة آحاد فيعتق أربعة أيضا وهن اثنتان واثنتان فيعتق كذلك وفيهن ثلاث فيعتق بذلك ثلاث وإن شئت قلت يعتق بالواحدة واحد وبالثانية ثلاثة لأن فيها صفتين هي واحدة وهي مع الأولى اثنتان ويعتق بالثالثة أربعة لأنها واحدة وهي مع الأولى والثانية ثلاث ويعتق بالرابعة سبعة لأن فيها ثلاث صفات هي واحدة وهي مع الثانية اثنتان وهي مع الثلاث التي قبلها أربع قال في المغني وهذا أولى من الأول لأن قائله لا يعتبر صفة الطلاق الواحدة في غير الأولى ولا صفة التثنية في الثالثة والرابعة (وقيل عشرة) بالواحدة واحد وبالثانية اثنان وبالثالثة ثلاثة وبالرابعة أربعة وقيل يعتق سبعة عشر لأن صفة التثنية قد وجدت ثلاث مرات فإنها توجد فيضم الأولى إلى الثانية ويضم الثانية إلى الثالثة ويضم الثالثة إلى الرابعة وقيل عشرون لأن صفة الثلاثة وجدت مرة ثانية بضمه الثانية والثالثة إلى الرابعة وردهما في المغني والشرح بأن كلا منهما غير سديد (ويحتمل ألا يعتق إلا أربعة) واختاره في الرعاية إن طلقن معا كقوله كلما اعتقت أربعة فأربعة أحرار لأن هذا الذي يسبق إلى أذهان العامة وهذا مع الإطلاق (إلا أن تكون له نية) فيعمل بها لأن مثل ذلك لا يراد منه عرفا غير ذلك ومتى لم يعين العبيد المعتقين أخرجوا بالقرعة والأول أصح قاله في المغني لأن كلما تقتضي التكرار والصفات

المتقدمة متكررة فيجب أن يتكرر الطلاق بتكرر الصفات فلو جعل مكانها إن لم يتكرر [ج ٧ - ص ٣٤٨]

لعدم تكرارها ولم يعتق سوى عشرة كالقول الثاني

تنبيه لو قال كلما صليت ركعة فعبدي حر وهكذا إلى آخره فصلى عشرة عتق سبعة وثمانون عبدا على الأول ولو علق طلاقها بدخول الدار على صفات أربع بأن قال إن دخلها رجل فعبد من عبيدي حر وإن دخلها طويل فعبدان حران وإن دخلها أسود فثلاثة أحرار وإن دخلها فقيه فأربعة أحرار فدخلها رجل متصف بما ذكرنا عتق عشرة

فرع إذا قال إن طلقتك فبعدي حر ثم قال لعبده إن قمت فامرأتي طالق فقام طلقت وعتق ولو قال لعبده إن قمت فامرأتي طالق ثم قال لامرأته إن طلقتك فعبدي حر فقام العبد طلقت ولم يعتق العبد لأن وقوع الطلاق بالصفة إنما يكون تطليقا مع وجودها

(وإن قال لامرأته إذا أتاك طلاقي فأنت طالق ثم كتب إليها إذا أتاك كتابي فأنت طالق فأتاها الكتاب طلقت طلقتين) لأنه علق طلاقها بصفتين مجيء طلاقه ومجيء كتابه وقد اجتمعتا في مجيء الكتاب وفي الكافي إذا ذهبت حواشيه أو انمحى كل ما فيه إلا ذكر الطلاق طلقت لأنه أتاها كتابه مشتملا على المقصود فإن انمحى ذكر الطلاق أو ضاع الكتاب لم تطلق لأن المقصود لم يأت

(وإن قال أردت أنك طالق بذلك الطلاق الأول دين) لأنه محتمل وهو أعلم بإرادته (وهل يقبل في الحكم على روايتين) كذا في الفروع

أشهرهما [ج ٧ - ص ٣٤٩]

القبول لما ذكرنا والثانية لا يقبل لأنه خلاف الظاهر فلو علق طلاقها على قراءة الكتاب فقرأته أو قرئ عليها وقع إن كانت أمية وإن كانت قارئة فوجهان قاله في الترغيب والرعاية قال أحمد لا تتزوج حتى يشهد عندها شاهدا عدل لا حامل الكتاب وحده

فصل في تعليقه بالحلف

(إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن قمت أو دخلت الدار) أو إن لم تدخلي الدار أو إن لم يكن هذا القول حقا (طلقت في الحال) لأنه حلف بطلاقها وكذا كل شرط فيه حث أو منع والأصح أو تصديق خبر أو تكذيبه وعلم منه أن كل شرط ممكن الوجود ممكن العدم يقع به الطلاق واستثنى جماعة ثلاث صور أحدها تعليقه على المشيئة لأن ذلك تمليك لا حلف الثاني تعليقه على الحيض لأنه تعليق بدعة الثالث تعليقه على الطهر لأنه طلاق سنة وأبى آخرون استثناءها ذكره الشيخ تقي الدين واختار العمل بعرف المتكلم وقصده في مسمى اليمين وأنه موجب أصول أحمد ونصوصه

(وإن قال أنت طالق إن طلعت الشمس أو قدم الحاج فهل هو حلف فيه وجهان) أحدهما لا تطلق حتى تطلع الشمس أو يقدم الحاج قاله القاضي في المحرر واختاره ابن عقيل وقدمه في المحرر والفروع لأن

الحلف ما قصد به المنع من شيء أو الحث عليه وليس فيهما شيء من ذلك والثاني أنه حلف قاله القاضي في الجامع وأبو الخطاب وقدمه السامري لأنه علق على شرط ويسمى حلفا عرفا فتعلق الحكم به كما لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق ولأن في الشرط معنى القسم من حيث كونه جملة غير مستقلة دون الجواب أشبه قوله والله وبالله وتالله (وإن قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق أو قال ان كلمتك فأنت طالق وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة) لأنه حلف بطلاقها لكن لو قصد بإعادته إفهامها لم يقع ذكره أصحابنا بخلاف ما لو أعاده من علقه بالكلام وأخطأ بعض أصحابنا وقال فيها كالأولى ذكره في الفنون (وإن أعاده ثلاثا) أي غير المرة الأولى (طلقت ثلاثا) وحاصله أنه إذا أعاده ثلاثا طلقت اثنتين وإن أعاده أربعا طلقت ثلاثا لأن كل مرة يوجد فيها شرط الطلاق وينعقد شرط لطلقة أخرى هذا إذا كانت مدخولا بها وإلا بانت بالأولة (وإن قال لامرأتيه إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان وأعاده طلقت كل واحدة طلقة) لأن شرط طلاقهما الحلف بطلاقهما وقد وجد وإن أعاده ثلاثا طلقتا طلقتين وإن أعاده أربعا فثلاث لوجود الشرط وهو الحلف (وإن كانت إحداهما غير مدخول بها وأعاده بعد ذلك لم تطلق واحدة منهما) لأن شرط طلاقهما الحلف بطلاقهما ولم يوجد لأن غير المدخول بها لا يصح الحلف بطلاقها لأنها بائن فإن جدد نكاح البائن ثم قال لها إن كلمتك فأنت طالق فاختار المؤلف أنه لا تطلق وهو معنى

كلامه في الكافي أنه لا يصح الحلف بطلاقها لأن الصفة لم تنعقد لأنها بائن وكذا جزم به في الترغيب [ج ٧ - ص ٣٥١]

أنه لا يصح التعليق بعد البينونة وإنما عللوا بذلك أن ما يقع به الطلاق لا تنعقد به الصفة كمسألة الولادة في الأشهر وقيل تطلقان لأنه صار بهذا حالفا بطلاقهما وقد حلف بطلاق المدخول بها بإعادة قوله فطلقتا حينئذ

(وإن قال لمدخول بهما كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فأنتما طالقتان وأعاده ثانيا طلقت كل واحدة طلقتين) لأنه بإعادته حالف بطلاق كل واحدة منهما وهو شرط لطلاقهما وكلمة كلما للتكرار فيتكرر طلاقهما لتكرر عددهما (وإن قال كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فهي طالق أو فضرتها طالق وأعاده طلقت كل واحدة طلقة) لأن حلفه بطلاق واحدة إنما اقتضى طلاقها وحدها وما حلف بطلاقها إلا مرة فتطلق واحدة (وإن قال لإحداهما إذا حلفت بطلاق ضرتك فأنت طالق ثم قال ذلك للأخرى طلقت الأولى) لأن التعليق حلف وقد علق طلاق ضرتها فتطلق الأولى لوجود شرط طلاقها وهو تعليق طلاق ضرتها (وإن أعاده للأولى طلقت الأخرى) لأن ذلك تعليق لطلاقها وكلما أعاده لامرأة طلقت الأخرى إلى أن يبلغ ثلاثا وإن كانت إحداهما غير مدخول بها فطلقت مرة لم تطلق الأخرى لأنه ليس حلفا بطلاقها لكونها بائنا فلو قال كلما حلفت بطلاقكما فإحداكما طالق وكرره ثلاثا أو أكثر لم يقع شيء ذكره في المحرر والرعاية والفروع لأن هذا حلف طلاق واحدة ولم يوجد الحلف بطلاقهما وإن قال لمدخول بهما كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فإحداكما طالق ثم قاله ثانيا [ج ٧ - ص ٣٥٢]

وقعت بإحداهما طلقة وتعين بقرعة ذكره الأصحاب

مسائل إذا قال إن حلفت بطلاق زينب فنسائي طوالق ثم قال إن حلفت بطلاق عمرة فنسائي طوالق وإن حلفت بطلاق حفصة فنسائي طوالق طلقت كل واحدة طلقتين فلو قال كلما حلفت لطلاق واحدة منكن فأنتن طوالق ثم قال ذلك مرة ثانية طلقن ثلاثا ثلاثا ولو كان مكان كلما إن وأعاده طلقن واحدة واحدة وإن قال بعد ذلك لإحداهن إن قمت فأنت طالق طلقت كل واحدة طلقة أخرى وإن قال كلما حلفت بطلاقكن فأنتن طوالق ثم أعاد ذلك طلقت كل واحدة طلقة وإن قال بعد ذلك لإحداهن إن قمت فأنت طالق لم تطلق واحدة منهن وإن قال ذلك للاثنتين الباقيتين طلق الجميع طلقة طلقة

فصل في تعليقه بالكلام

(إذا قال إن كلمتك فأنت طالق فتحققي ذلك أو زجرها فقال تنحي أو اسكتي أو قال إن قمت فأنت طالق طلقت) لأنه علق طلاقها على كلامها وقد وجد لأن قوله تحققي وتنحي واسكتي وإن قمت فأنت طالق كلام لها بعد عقد اليمين إلا أن ينوي كلاما (ويحتمل ألا يحنث بالكلام المتصل بيمينه) وعلله بقوله (لأن إتيانه به يدل على إرادته الكلام المنفصل عنها) لأن القرينة تصرف عموم اللفظ إلى خصوصه إذ قرينة الحال تجعل المطلق كالمقيد بالمقال [ج ٧ - ص ٣٥٣]

وإن سمعها تذكره فقال الكاذب عليه لعنة الله حنث نص عليه لأنه كلمها

فرع إذا قال إن كلمتك فأنت طالق إن قمت فأنت طالق طلقت في الحال طلقة وأخرى بالقيام إن كان دخل بها فلو قال إن كلمتك فأنت طالق وأعاده ثانية فواحدة وإن ثالثا فثانية وإن رابعا فثالثة وتبين غير المدخول بها بطلقة ولا ينعقد ما بعدها ذكر القاضي وجزم به في المغني وقدمه في المحرر ثم قال وعندي تنعقد الثانية بحيث إذا تزوجها وكلمها طلقت إلا على قول التميمي تحل الصفة مع البينونة فإنها قد انحلت بالثالثة لأنه قد كلمها ولا يجيء مثله في الحلف بالطلاق لأنه لا ينعقد لعدم إمكان إيقاعه قال في الفروع ويتوجه أنه لا فرق بينها وبين مسألة الحلف السابقة

(وإن قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت إن بدأتك به فعبدي حر انحلت يمينه) في الأصح لأنها كلمته فلم يكن كلامه لها بعد ذلك ابتداء (إلا أن ينوي) أنه لا يبدؤها في مرة أخرى وبقيت يمينها معلقة فإن بدأها بكلام انحلت يمينها وإن بدأته هي عتق عبدها ذكره الأصحاب (ويحتمل أن يحنث ببداءته إياها بالكلام في وقت آخر) وعلله بقوله (لأن الظاهر أنه أراد ذلك بيمينه) لأن الحلف بمثل ذلك يفهم منه قصد هجران بدائته كلامها وذلك يقتضي تعميم البداءة في المجلس وغيره (وإن قال إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمته فلم يسمع لتشاغله وغفلته) أو لفظه أو

ذهوله حنث نص عليه لأنها كلمته وإنما لم يسمع لشغل قلبه وغفلته (أو كاتبته أو راسلته حنث) لأن [ج ٧ - ص ٣٥٤]

الكلام يطلق ويراد به ذلك بدليل صحة استثنائه منه في قوله تعالى ﴿ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ﴾ الشورى 15 لأن القصد بيمينه هجرانه ولا يحصل ذلك مع مواصلته بالكتابة والرسل إلا أن يكون قصد أن تشافهه نص عليه ويحتمل ألا يحنث إلا أن ينوي ترك ذلك لأن هذا ليس بكلام حقيقة بدليل الحلف بالله

فرع إذا أرسلت إنسانا ليسأل أهل العلم عن حديث أو مسألة فجاء الرسول فسأل المحلوف عليه لم يحنث (وإن أشارت إليه) برمز (احتمل وجهين) كذا في الفروع أولاهما لا تطلق لأنه لم يوجد الكلام والثاني بلى لأنه يحصل به مقصود الكلام

(وإن كلمته سكران أو أصم بحيث يعلم أنها تكلمه أو مجنونا يسمع كلامها حنث) لأن الطلاق معلق على الكلام وقد وجد فإن كان السكران أو المجنون مصروعا لم يحنث وكذا إذا كانا لا يعلم واحد منهما أنها تكلمه والمجنون إذا لم يسمع كلامها صرح به في المغني في الآخرين (وقيل لا يحنث) اختاره القاضي وغيره لأن السكران والمجنون لا عقل لهما والأصم لا سمع له فلم يحنث بكلامها وقيل لا السكران

فرع إذا جنت هي وكلمته لم يحنث لأن القلم رفع عنها وإن كلمته سكرانة فقال في الشرح يحنث لأن حكمها حكم الصاحي وإن كلمت صبيا يسمع ويعلم أنها تتكلم حنث وكذا إن سلمت عليه لأنه كلام فإن [ج ٧ - ص ٣٥٥]

كان تسليم الصلاة فلا حنث لأنه للخروج منها إلا أن ينوي بتسليمه على المأمومين فيكون كما لو سلم عليهم في كغير الصلاة ويحتمل لا حنث بحال لأن هذا يعد تكليما ولا يريده الحالف

(وإن كلمته ميتا أو غائبا أو مغمى عليه أو نائما لم يحنث) في الأصح لأن التكلم فعل يتعدى المتكلم وقيل هو مأخوذ من الكلم وهو الجرح لأنه يؤثر فيه كتأثير الجرح ولا يكون ذلك إلا باستماعه (وقال أبو بكر) وحكاه رواية (يحنث) لأن إشعاره بالكلام غير معتبر لقوله كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها وجوابه بأن تكليمه لهم كانت من معجزاته عليه السلام فإنه قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولم يثبت هذا لغيره مع أن قول الصحابة له حجة لنا فإنهم قالوا ذلك استبعادا وسؤالا عما خفي عليهم سببه حتى كشف لهم حكمة ذلك بأمر مختص به فبقي الأمر فيمن سواه على النفي

تتمة إذا حلف لا يكلم إنسانا فكلم غيره وهو يسمع يقصد بذلك إسماعه كما يقال إياك أعني واسمعي يا جارة حنث نص عليه وعنه لا كنية غيره والأول أصح لأنه أسمعه كلامه يريده به أشبه ما لو خاطبه به ولأن مقصود تكليمه قد حصل بإسماعه كلامه وإن حلف لا يكلم امرأته فجامعها لم يحنث إلا أن تكون نيته هجرانها

فرع إذا حلف لا يقرأ كتاب زيد فقرأه في نفسه ولم يحرك شفتيه به حنث لأن هذا قراءة الكتب في عرف الناس إلا أن ينوي حقيقة القراءة

(وإن قال لامرأتيه إن كلمتما هذين فأنتما طالقتان) وقلنا لا يحنث ببعض [ج ٧ - ص ٣٥٦]

المحلوف عليه (فكلمت كل واحدة واحدا منهما طلقتا) لأن تكليمهما وجد منهما وكما لو قال إن ركبتما هاتين الدابتين فأنتما طالقتان فركبت كل واحدة دابة (ويحتمل ألا يحنث حتى يكلما جميعا كل واحد منهما) لأنه علق طلاقهما بكلامه لهما فلا تطلق واحدة بكلام الأخرى وحدها كقوله إن كلمتما زيدا وكلمتما عمرا وهذا أظهر الوجهين وهو أولى إن شاء الله تعالى إذا لم يكن له نية قال في المغني هذا معنى الخلاف فيما لو تجر العادة بانفراد الواحدة به فأما ما جرى العرف فيه بانفراد الواحدة به كلبس ثوبيهما وتقليد سيفيهما ونحوه لأن اليمين تحمل على العرف فأما إن قال إن أكلتما هذين الرغيفين فأكلت كل واحدة منهما رغيفا فإنه يحنث لأنه يستحيل أن تأكل واحدة منهما الرغيفين

مسألة إذا قال لا أكلت هذا الخبز وهذا اللحم فكقوله لا أكلتهما هل يحنث بأحدهما فيه وجهان وكذا لو قال ولا هذا اللحم وقيل يحنث كما لو قال لا آكل شيئا منهما

(وإن قال إن أمرتك فخالفتني فأنت طالق فنهاها فخالفته لم يحنث إلا أن ينوي مطلق المخالفة) وهو المذهب لأنها خالفت نهيه لا أمره ولأنه يحنث إذا نوى مطلق المخالفة بغير خلاف لأن مخالفة النهي مخالفة (ويحتمل أن تطلق) قدمه في الرعاية لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عنه أمر بضده فإذا تكون خالفت أمره (وقال أبو الخطاب إن لم

يعرف حقيقة الأمر والنهي حنث) لأنه إذا كانت كذلك فإنما يريد نفي المخالفة فلو قال إن [ج ٧ - ص ٣٥٧]

نهيتني عن نفع أمي فأنت طالق فقالت له لا تعطها شيئا من مالي لم يحنث لأنه نفع محرم فلا يتناوله يمينه وقيل يحنث لأن لفظه عام

فرع إذا قال أنت طالق إن كلمت زيدا ومحمد مع خالد لم تطلق حتى تكلم زيدا في حال كون محمد مع خالد لأنها حال من الجملة الأولى وقال القاضي تطلق بكلام زيد لأن الجملة الثانية استئناف لا تعلق لها بالأولى والأول أصح كما لو تقدم الشرط ولأنه متى أمكن جعل الكلام متصلا كان أولى فلو قال أنت طالق إن كلمت زيد إلى أن يقدم فلان فكلمته قبل قدومه طلقت وإلا فلا لأن الغاية رجعت إلى الكلام لا إلى الطلاق بخلاف ما لو قدم الشرط فإنها تطلق بكلامه قبل قدوم فلان أو بعده لأن الغاية عادت إلى الطلاق والطلاق لا يرتفع بعده وقوعه

فصل في تعليقه بالإذن

(إذا قال إن خرجت) قال في الانتصار أو إن خرجت مرة (بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك فأنت طالق ثم أذن لها فخرجت ثم خرجت بغير إذنه طلقت) بخروجها بغير إذنه هذا المذهب ولم يحك ابن هبيرة عن أحمد غيره لأنها خرجت بغير إذنه (وعنه لا تطلق) نقلها عبد الله ذكره في المستوعب لأن إن لا تقتضي التكرار فيتناول الخروج في المرة الأولى (إلا أن ينوي الإذن في كل مرة) على الروايتين لأن الخروج الثاني خروج غير مأذون فيه وهو [ج ٧ - ص ٣٥٨]

محلوف عليه أشبه ما لو خرجت أولا بغير إذن فلو قال اخرجي كلما شئت كان إذنا عاما نص عليه وفي الروضة إن أذن لها بالخروج مرة أو مطلقا أو أذن بالخروج لكل مرة فقال اخرجي متى شئت لم يكن إذنا إلا لمرة واحدة فإن قال إلا بإذن زيد فمات زيد لم يحنث وحنثه القاضي وجعل المستثنى محلوفا عليه (وإن أذن لها من حيث لا تعلم فخرجت طلقت) نص عليه لأن الإذن هو الإعلام مع أن إذن الشارع وأوامره ونواهيه لا يثبت حكمها إلا بعد العلم بها وكذا إذن الآدمي ولأنها قصدت بخروجها مخالفته وعصيانه أشبه ما لو يأذن لها في الباطن لأن العبرة بالقصد لا بحقيقة الحال (ويحتمل ألا تطلق) قدمه الحلواني لأنه يقال أذن لها ولم يعلم به وإن أذن لها في الخروج فلم تخرج حتى نهاها عنه ثم خرجت فوجهان أحدهما لا يحنث لأنه قد أذن لها والثاني بلى لأن هذا الخروج جرى مجرى خروج ثان وهو محتاج إلى إذن

فرع إذا قال كنت أذنت لك قبل ببينة ويحتمل الاكتفاء بعلمه للبينة

(وإن قال إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت تريد الحمام وغيره طلقت) في الأشهر لأنها خرجت إلى غير الحمام وانضم إليه غيره فحنث كما لو حلف لا يكلم زيدا فكلم زيدا وعمرا والوجه الثاني لا لأنها ما خرجت إلى غير الحمام بل الخروج مشترك وظاهره أنها إذا

خرجت إلى غير الحمام أنها تطلق سواء عدلت إلى الحمام أو لا (وإن خرجت إلى الحمام [ج ٧ - ص ٣٥٩]

ثم عدلت إلى غيره طلقت) هذا ظاهر ما روي عن أحمد وهو قياس المذهب لأن ظاهر هذه المنع من غير الحمام فكيفما صارت إليه حنث كما لو خالف في لفظه (ويحتمل ألا تطلق) أطلق في المحرر الخلاف لأنها لم تفعل ما حلف عليه إذ هو عبارة عن الخروج إلى غير الحمام ولم يوجد

مسألة قال أحمد في رجل حلف بالطلاق ألا يأتي أرمينية إلا بإذن امرأته فقالت امرأته اذهب حيث شئت فقال لا حتى تقول إلى أرمينية قال القاضي هذا من كلام أحمد محمول على أن هذا خرج مخرج الغضب والكراهة ولو قالت هذا بطيب قلبها كان إذنا منها وله الخروج وإن كان بلفظ عام

فصل في تعليقه بالمشيئة

(إذا قال أنت طالق إن شئت أو كيف شئت أو حيث شئت أو متى شئت) أو أي وقت شئت (لم تطلق حتى تقول قد شئت) لأن ما في القلب لا يعلم حتى يعبر عنه اللسان فيتعلق الحكم بما ينطق به دون ما في القلب فلو شاءت بقلبها دون نطقها لم تطلق ولو شاءت وهي كارهة طلقت اعتبارا بالنطق ولو رجع قبل مشيئتها لم يصح رجوعه على الأصح كبقية التعليق (سواء شاءت على الفور أو التراخي) نص عليه في تعليق الطلاق بمشيئة فلان وقاله الزهري وقتادة لأنه تعليق للطلاق على شرط

أشبه سائر التعليقات ولأنه إزالة ملك معلق على المشيئة فكان على التراخي

[ج ٧ - ص ٣٦٠]

كالعتق (ويحتمل أن يقف على المجلس كالاختيار) وهو قول الحسن وعطاء لأنه تمليك للطلاق فكان على الفور كاختاري والأول أصح وفرق بينهما في المغني والشرح من حيث إن اختاري ليس شرط وإنما هو تخيير محض فيتقيد بالمجلس نكيار المجلس بخلاف المشيئة فإنها هنا شرط فوجب حملها على إن فإن قيد المشيئة بوقت تقيد به (وإن قال أنت طالق إن شئت فقالت قد شئت إن شئت فقال قد شئت لم تطلق) نص عليه لأنه لم يوجد منها مشيئة وإنما وجد منها تعليق مشيئتها بشرط وليس بمشيئة لا يقال إذا وجد الشرط يجب أن يوجد مشروطه لأن المشيئة أمر حقيقي فلا يصح تعليقها على شرط ووجه الملازمة إذا صح التعليق وكذا إن قالت قد شئت إن طلعت الشمس نص عليه وهو قول سائر الفقهاء وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه

(وإن قال أنت طالق إن شئت وشاء أبوك لم تطلق حتى يشاءا) لأن الصفة بمشيئتهما فلا تطلق بمشيئة أحدهما لعدم وجود الشرط وخرج القاضي أنها تطلق بمشيئة أحدهما كفعل بعض المحلوف عليه وعلى الأول كيف شاءا طلقت فإن شاء أحدهما على الفور والآخر على التراخي وقع لأن المشيئة وجدت منهما جميعا

فروع إذا قال إذا ضاجعتك على فراش فأنت طالق فاضطجعت هي معه فقام لوقته لم يحنث وإلا حنث

ولو اختصم رجلان فقال أحدهما للآخر زوجة السفلة بكسر السين مع إسكان الفاء منا طالق فقال الآخر نعم قال أحمد السفلة الذي لا يبالي بما قال [ج ٧ - ص ٣٦١]

ولا ما قيل فيه وقال في رواية عبد الله هو الذي يدخل الحمام بلا مئزر ولا يبالي على أي معصية رئي

إذا حلف بالطلاق ليفعلن محرما في وقت معين لم يحل له فعله وتطلق نص عليه فيمن حلف بالطلاق ليطأن زوجته في وقت بعينه فإذا هي حائض قال لا يطؤها وتطلق فإن فعله فقد عصى الله ولم تطلق وإن لم يعين وقتا لفعله لم يحنث إلا في آخر وقت الإمكان

(وإن قال أنت طالق إن شاء زيد فمات أو جن أو خرس قبل المشيئة لم تطلق) اختاره ابن حامد لأن شرط الطلاق لم يوجد وقال أبو بكر يقع لأنه علقه على شرط تعذر الوقوف عليه فوقع كقوله أنت طالق إن شاء الله تعالى وليس بصحيح لأن الطلاق المعلق على شرط لا يقع إذا تعذر شرطه كالمعلق على دخول الدار وعلم منه أنه إذا شاء وهو مجنون لا يقع طلاقه لأنه لا حكم لكلامه ويستثنى منه أنه إذا فهمت إشارة أخرس فهي كنطقه وقيل إن خرس بعد يمينه فلا (وإن شاء وهو سكران خرج على الروايتين في طلاقه) قاله أصحابنا لأن قوله قد شئت يترتب عليه وقوع الطلاق فوجب كونه بمنزلة نفس الطلاق قال في المغني والصحيح أنه لا يقع لأنه زائل العقل أشبه المجنون ثم الفرق بين إيقاع طلاقه وبين المشيئة أن إيقاعه عليه تغليظ عليه لئلا تكون المعصية سببا للتخفيف عنه وهنا إنما يقع الطلاق بغيره فلا يصح منه في حال زوال عقله (وإن كان صبيا)

أي مميزا قاله في الكافي وغيره (يعقل المشيئة فشاء طلقت) لأن له مشيئة بدليل صحة اختياره لأحد أبويه والثانية لا لأن شرطه التكليف (وإلا فلا) أي إذا كان صبيا لا يعقل المشيئة لم تطلق كالمجنون

[ج ٧ - ص ٣٦٢]

(وإن قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد فمات أو جن أو خرس طلقت) في الحال لأنه أوقع الطلاق وعلقه بشرط ولم يوجد وقيل في آخر حياته وقيل يتبين حنثه منذ حلف

فرع إذا قال أنت طالق وعبدي حر إن شاء زيد ولاينه فشاءهما ونقل أبو طالب أو تعذر بموت ونحوه اختاره أبو بكر وابن عقيل وحكي عنه أو غاب وقعا

(وإن قال أنت طالق واحدة إلا أن يشاء ثلاثا فشاء ثلاثا طلقت ثلاثا في أحد الوجهين) وكذا عكسه قدمه في الكافي والرعاية والفروع وجزم به في الوجيز لأن هذا هو السابق إلى الفهم من ذلك كما لو قال له علي درهم إلا أن يقيم بينة بثلاثة وخذ درهما إلا أن يريد أكثر منه (وفي الآخر لا تطلق) لأن الاستثناء من الإثبات نفي ولأنه علق وقوع الواحدة على عدم مشيئتها الثلاث ولم يوقع بمشيئتها شيئا أشبه قوله إلا أن يشاء زيد فأما إذا لم يشأ زيد أو شاء أقل من ثلاث فواحدة

(وإن قال أنت طالق إن شاء الله طلقت وإن قال لأمته أنت حرة إن شاء الله عتقت) نص عليه وفي زاد المسير لا تختلف الرواية فيه وهو قول سعيد والحسن ومكحول وقتادة والزهري والأوزاعي لما روى أبو حمزة قال سمعت ابن عباس يقول إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن

شاء الله فهي طالق رواه أبو حفص وروى ابن عمر وأبو سعيد

[ج ٧ - ص ٣٦٣]

قالا كنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نرى الاستثناء جائزا في كل شيء إلا في الطلاق والعتاق ولأنه استثناء يرفع جملة الطلاق حالا ومآلا فلم يصح كاستثناء الكل ولأنه تعليق على ما لا سبيل إلى علمه أشبه تعليقه على المستحيل (وحكي عنه أنه يقع العتق دون الطلاق) وعلله أحمد بأن العتق لله تعالى والطلاق ليس هو لله ولا فيه قربة إليه ولأنه لو قال لأمته كل ولد تلدينه فهو حر فهذا تعليق للحرية على الملك وهو صحيح ولأن نذر العتق يلزم الوفاء به بخلاف الطلاق فافترقا قال في المحرر ولا يصح عن أحمد التفرقة بينهما لكن حكاها أبو حامد الإسفراييني قال أبو الخطاب في الانتصار ولقد أبطل في حكاية ذلك عنه وعكس في الترغيب هذه الرواية وقال يا طالق إن شاء الله تعالى أولى بالوقوع وعنه لا يقعان اختاره أكثر العلماء كما لو علقه على مشيئة زيد ولقوله عليه السلام من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه من حديث ابن عمر وإسناده ثقات قال الشيخ تقي الدين ويكون معناه هي طالق إن شاء الله الطلاق بعد هذا والله لا يشاؤه إلا بتكلمه به والجواب عنه أن الطلاق والعتاق ليسا من الإيمان قاله أحمد وإن سمي بذلك فمجاز ثم إن الطلاق إنما يسمى يمينا إذا كان معلقا على شرط يمكن فعله وتركه ومجرد قوله أنت طالق ليس بيمين حقيقة ولا مجازا وكذا إذا قدم الاستثناء كقصده تأكيد الإيقاع وذكر الخرقي أن أكثر الروايات عن أحمد توقف عن الجواب عنها

(وإن قال أنت طالق إلا أن يشاء الله طلقت) في المنصوص لأنه أوقع الطلاق وعلق رفعه بمشيئة لم تعلم قال أحمد قال قتادة قد شاء الله

[ج ٧ - ص ٣٦٤]

الطلاق حين أذن فيه قال ابن حمدان ويحتمل ألا تطلق كالأول (وإن قال إن لم يشاء الله) أو ما لم يشاء الله (فعلى وجهين) أحدهما تطلق قدمه في الكافي وصححه في الفروع لتضاد الشرط والجزاء فلغا تعليقه بخلاف المستحيل والثاني لا لأنه بمنزلة تعليقه الطلاق على المحال كقوله إن جمعت بين الضدين أو شربت ماء الكوز ولا ماء فيه قال في الرعاية وكذا العتق (وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق) أو حرة (إن شاء الله فدخلت فهل تطلق على روايتين) إحداهما تطلق قدمه في الرعاية لما تقدم والثانية لا لأن الطلاق المعلق بشرط يمين فيدخل في عموم الخبر وفارق إذا لم يعلقه فإنه ليس بيمين فلا يدخل في العموم قال في المحرر و الفروع إلا أن ينوي رد المشيئة إلى الفعل فلا تطلق كقوله أنت طالق لا فعلت أو لأفعلن إن شاء الله وإن أراد بالاستثناء والشرط رده إلى الطلاق فقط ففيه الخلاف وإن لم تعلم نيته والظاهر رجوعه إلى الفعل

غريبة إذا قال أنت طالق يوم أتزوجك إن شاء الله فتزوجها لم تطلق وإن قال أنت حر يوم أشتريك إن شاء الله فاشتراه عتق

(وإن قال أنت طالق لرضى زيد أو مشيئته) أو لدخول الدار (طلقت في الحال) لأن معناه أنت طالق لكونه قد شاء ذلك أو رضيه وذلك كقوله هو حر لوجه الله أو لرضى الله بخلاف قوله لقدوم زيد (وإن قال

أردت الشرط) فيما ظاهره التعليل (دين) لأنه أعلم بمراده (وهل يقبل في الحكم [ج ٧ - ص ٣٦٥]

يخرج على روايتين) أصحهما يقبل لأن ذلك يستعمل للشرط كقوله أنت طالق للسنة والثانية لا وجزم به في الوجيز لأنه خلاف الظاهر

فرع إذا قال إن رضي أبوك فأنت طالق فقال ما رضيت ثم قال رضيت وقع لأنه مطلق وكان متراخيا ذكره في الفنون وإن قوما قالوا ينقطع بالأول

(وإن قال إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار) أو تبغضين الجنة (فأنت طالق أو قال إن كنت تحبينه بقلبك فقالت أنا أحبه فقد توقف أحمد عنها) لتعارض الأدلة عنده وسئل عنها فلم يجب فيها بشيء (وقال القاضي تطلق) قدمه في الرعاية وجزم به في الوجيز وفي الفنون هو مذهبنا لأن ما في القلب لا يوقف عليه إلا من اللفظ فاقتضى تعليق الحكم بلفظها به صادقة أو كاذبة كالمشيئة (والأولى أنها لا تطلق إذا كانت كاذبة) وهو المذهب وقاله أبو ثور لأن المحبة في القلب ولا توجد من أحد محبة ذلك وخبرها بالمحبة كاذب لا يلتفت إليه واختار في الفنون أنها لا تطلق لاستحالته عادة كقوله إن كنت تعتقدين أن الجمل يدخل في خرم الإبرة فأنت طالق فقالت أعتقده فإن عاقلا لا يجوز فضلا عن اعتقاده ثم إن قال كذبت لم تطلق وهي يعتبر نطقها أو تطلق بإقرار الزوج فيه احتمالان وقيل لا تطلق إن لم يقل بقلبك

فرع إذا قال إن كنت تحبين زيدا أو تبغضيني فأنت طالق فأخبرته به طلقت وإن كانت كاذبة فإذا قال أنت طالق إن أحببت أو

إن أردت أو إن كرهت احتمل أن يتعلق الطلاق بلسانها كالمشيئة واحتمل أن يتعلق الحكم بما في القلب من ذلك ويكون اللسان دليلا عليه فعلى هذا لو أقر الزوج بوجوده طلقت ولو أخبرت به ثم قالت كنت كاذبة لم تطلق ذكره في الشرح

فرع إذا قالت أريد أن تطلقني فقال إن كنت تريدين فأنت طالق فيقتضي أنها تطلق بإرادة مستقبلة ودلالة الحال على أنه أراد إيقاعه للإرادة التي أخبرته بها قاله في الفنون قال ولو قال إن كان أبوك يرضى بما فعلتيه فأنت طالق فقال ما رضيت ثم قال رضيت طلقت لأنه علقه على رضى مستقبل وقد وجد بخلاف إن كان أبوك راضيا به لأنه ماض وتعليق كطلاق ويصح بالموت

فصل في مسائل متفرقة

(إذا قال أنت طالق إذا رأيت الهلال طلقت إذا رؤي) بعد الغروب أو أكملت العدة لأن رؤيته في الشرع عبارة عما يعلم به دخوله لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فانصرف لفظ الحالف إلى عرف الشرع كما لو قال إذا صليت فأنت طالق فإنه ينصرف إلى الشرعية وفارق رؤية زيد فإنه لم يثبت له عرف شرعي (إلا أن ينوي حقيقة رؤيتها فلا يحنث حتى تراه) [ج ٧ - ص ٣٦٧]

لأنها رؤية حقيقية ويقبل ذلك حكما على الأصح وقيل يقبل بقرينة ويتعلق الحكم برؤيتها له بعد الغروب لأن هلال الشهر ما كان في أوله وقيل تطلق برؤيتها له قبل الغروب لأنه يسمى رؤية والحكم يتعلق برؤيته في الشرع فإن قال أردت إذا رأيته أنا بعيني فلم يره حتى أقمر لم تطلق لأنه ليس بهلال وهو هلال إلى الثالثة ثم يقمر وقيل إلى الثانية وقيل إذا استدار وبهر ضوؤه

فرع إذا قال إذا رأيت فلانا فأنت طالق فرأته ولو ميتا أو في ماء أو زجاج شفاف طلقت إلا مع نية أو قرينة لا خياله في ماء ومرآة وفي مجالستها له وهي عمياء وجهان أصحهما لا حنث

(وإن قال من بشرتني بقدوم أخي فهي طالق فأخبره به امرأتاه طلقت الأولى منهما) إذا كانت صادقة لأن البشارة خبر تتغير به بشرة الوجه من سرور أو غم وإنما يحصل بالأول لأنها عند الإطلاق للخير كقوله تعالى ﴿ فبشر عباد ﴾ الزمر 17 فإن أريد الشر قيدت قال تعالى ﴿ فبشرهم بعذاب أليم ﴾ التوبة 34 (إلا أن تكون الثانية هي الصادقه وحدها فتطلق وحدها) لحصول الغرض ببشارتها وإن كانتا كاذبتين لم تطلق واحدة منهما لأنه لا سرور في الكذب وعلم منه أنه إذا بشره نساؤه معا طلقن لأن من تقع على الواحد فما زاد لقوله تعالى ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ﴾ الزلزله 7 ويتوجه تحصل البشارة بالمكاتبة [ج ٧ - ص ٣٦٨]

وإرسال رسول بها (وإن قال من أخبرتني بقدومه فهي طالق فكذلك عند القاضي) وجزم به في الوجيز لأن المراد من الخبر الإعلام ولا يحصل إلا بالخبر الصادق (وعند أبي الخطاب تطلقان) أي تطلق الصادقة والكاذبة لأن الخبر يدخله الصدق والكذب قال في المحرر وعندي يطلقن مع الصدق ولا تطلق منهما كاذبة وفي المستوعب حكى ابن أبي موسى فيمن قال لعبيده أيكم جاءني بخبر كذا فهو حر فجاءه به اثنان أو أكثر فيه روايتان إحداهما يعتق واحد منهم بالقرعة والثانية يعتقون جميعا ولم يفرق بين الصدق والكذب ولا بين المتقدم والمتأخر

تنبيه إذا قال أول من تقوم منكن فهي طالق فقام الكل دفعة واحدة لم تطلق واحدة منهن وإن قامت واحدة ولم يقم أحد بعدها فوجهان فإن قلنا لا يقع لم يحكم بوقوع ذلك ولا انتفائه حتى ييأس من قيام واحدة منهن فتنحل يمينه وكذا العتق وإن قام اثنتان أو ثلاثة معا وقام بعدهن أخرى وقع بمن قام أولا والعتق كذلك وقال القاضي فيمن قال أول من يدخل من عبيدي فهو حر فدخل اثنان دفعة واحدة ثم دخل آخر لم يعتق واحد منهن وهو بعيد وإن قال آخر من تدخل منكن الدار فهي طالق فدخل إحداهن لم يحكم بطلاق واحدة منهن حتى ييأس من دخول غيرها فيتبين وقوع الطلاق بآخرهن دخولا من حين دخولها

(وإن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا) أو جاهلا (حنث في الطلاق

[ج ٧ - ص ٣٦٩]

والعتاق ولم يحنث في اليمين المكفرة في ظاهر المذهب نقله عن أحمد جماعة واختاره الخلال وصاحبه وذكر القاضي في المجرد أنه هو المعمول به في المذهب لأن الكفارة تجب لرفع الإثم ولا إثم عليهما وأما الطلاق والعتاق فهو معلق بشرط فيقع بوجود شرطه من غير قصد كما لو قال أنت طالق إن قدم الحاج ولأن هذا يتعلق به حق آدمي فتعلق الحكم مع النسيان كالإتلاف (وعنه يحنث في الجميع) قدمها في الرعاية لأنه فعل ما حلف عليه قاصدا لفعله أشبه الذاكر وكالطلاق والعتاق وحينئذ يلزمه الكفارة في اليمين المكفرة وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد والزهري (وعنه لا يحنث في الجميع) وقاله عطاء وعمرو بن دينار ولقوله تعالى ﴿ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ﴾) الأحزاب 5 ولقوله عليه السلام إن الله تجاوز لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولأنه غير قاصد للمخالفة أشبه النائم ولأنه أحد طرفي اليمين فاعتبر به القصد كحالة الابتداء على الأول ولو فعله حين جنونه لم يحنث كالنائم وقيل هو كالناسي وإن حلف على غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد ففعله ناسيا أو جاهلا فعلى الخلاف قال في الرعاية وإن قصد بمنعهم أن لا يخالفوه أو فعلوه كرها لم يحنث وعنه يحنث المكره فيتخرج ألا يحنث إلا في الطلاق والعتاق قال في المستوعب فإن كان يمكنه الامتناع فلم يمتنع فوجهان فإن قلنا لا يحنث فأقام بعد دخولها فهل يحنث ينبني على ما إذا حلف لا يدخل الدار وهو فيها وإن عقدها يظن

صدق نفسه فبان بخلافه فكمن حلف على مستقبل وفعله ناسيا يحنث في طلاق وعتاق فقط [ج ٧ - ص ٣٧٠]

(وإن حلف لا يدخل على فلان بيتا ولا يكلمه ولا يسلم عليه أو لا يفارقه حتى يقضيه حقه فدخل بيتا هو فيه ولم يعلم أو سلم على قوم هو فيهم ولم يعلم أو قضاه حقه ففارقه فخرج رديئا أو أحاله بحقه ففارقه ظنا منه أنه قد بر خرج على الروايتين في الناسي والجاهل) لأنه غير قاصد للمخالفة أشبه الناسي وظاهره أنه إذا دخل بيتا هو فيه عالما حنث وصرح به غيره لأن شرط الحنث أنه قد وجد سالما عن المعارض وكذا ما بعده لأنه معطوف عليه فإن نوى السلام على الجميع أو كلامهم حنث رواية واحدة وإن نوى غيره فلا وإن أطلق فالخلاف وإن علم به ولم ينوه ولم يستثنه بقلبه فروايتان أصحهما الحنث وكذا إن حلف لا يكلم فلانا فسلم عليه يحسبه أجنبيا أو حلف لا بعت لزيد ثوبا فوكل زيد من يدفعه إلى من يبيعه فدفعه إلى الحالف فباعه من غير علمه

(وإن حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه لم يحنث) نص عليه في رواية صالح وحنبل) اختاره أبو الخطاب كالإثبات ولأنه عليه السلام كان يخرج رأسه وهو معتكف إلى عائشة لترجله وهي حائض والمعتكف ممنوع من الخروج من المسجد والحائض عكسه (وعنه يحنث) اختاره الخرقي وصححه في المغني لأن اليمين تقتضي المنع من المحلوف عليه فاختص المنع بشيء منه كالنهي (إلا أن ينوي جميعه) فعلم منه أن الخلاف إنما هو في اليمين المطلقة فإن نوى الجميع أو البعض عمل بنيته وكذا إن كانت قرينة وعلى الأولى [ج ٧ - ص ٣٧١]

لو حلف على من يمتنع بيمينه كزوجة وقرابة وقصد منعه ولا نية ولا سبب ولا قرينة لم يحنث بفعل بعضه

(وإن حلف ليفعلنه لم يبر حتى يفعل جميعه) لأن ذلك حقيقة اللفظ ولأن مطلوبه تحصيل الفعل فهو كالأمر ولو أمر الله تعالى بشيء لم يخرج عن العهدة إلا بفعل جميعه فكذا هنا (وإذا حلف لا يدخل دارا فأدخلها بعض جسده أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه خرج على الروايتين) في فعل بعض المحلوف عليه والمذهب أنه لا يحنث كما لو حلف لا يبيع عبده ولا يهبه فباع أو وهب بعضه (وإن حلف لا شربت ماء هذا النهر فشرب منه حنث) وجها واحدا لأن فعل الجميع ممتنع فلا تصرف اليمين إليه وكذلك إن قال والله لا آكل الخبز ولا أشرب الماء مما علق على اسم جنس أو جمع كالمسلمين فإنه يحنث بفعل البعض فإن نوى فعل الجميع أو كان في لفظه ما يقتضي ذلك لم يحنث إلا بفعل الجميع بلا خلاف

فرع إذا حلف لا شربت من ماء الفرات فشرب منه حنث سواء كرع منه أو اغترف منه فشربه وإن شرب من نهر يأخذ منه حنث في وجه اقتصر عليه في المستوعب كما لو حلف لا يشرب من شيء فاستقى أو لا يشرب من شاة فحلب وشربه والثاني لا يحنث لأنه يضاف إلى النهر لا إلى

الفرات وكغيره فلو حلف لا يأكل من هذه النخلة فلقط من تحتها

[ج ٧ - ص ٣٧٢]

وأكل وحنث بخلاف أكل ورقها وأطراف أغصانها

مسألة إذا قال إن قربت بكسر الراء دار أبيك فأنت طالق لم يقع حتى تدخلها فلو قاله بضم الراء وقع بوقوفها تحت فنائها ولصوقها بجدارها لأن مقتضاهما كذلك ذكرهما في الروضة ولم يذكر الجوهري قرب بالكسر بمعنى دخل ولعله عرف خاص

(وإن حلف لا يلبس ثوبا اشتراه زيد أو نسجه أو لا يأكل طعاما طبخه زيد فلبس ثوبا نسجه هو وغيره أو اشترياه أو أكل من طعام طبخاه فعلى روايتين) أشهرهما يحنث جزم به في الوجيز كما لو حلف لا يلبس شيئا من غزل فلانة فلبس ثوبا من غزلها وغزل غيرها والثانية لا يحنث لأنه لم يلبس ثوبا كاملا كما لو حلف لا يلبس ما خاطه زيد فإنه يحنث بكل ثوب خاطاه جميعا بخلاف ما لو قال ثوبا خاطه زيد وإذا حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل طعاما اشتراه هو وغيره حنث إلا أن يكون أراد أن لا ينفرد أحدهما بالشراء وذكر أبو الخطاب احتمالا لا حنث لأن كل جزء لم ينفرد أحدهما بشرائه كما لو حلف لا يلبس ثوبا اشتراه زيد فلبس ثوبا اشتراه هو وغيره (فإن اشترى غيره شيئا فخلطه بما اشتراه فأكل أكثر مما اشتراه شريكه حنث) وجها واحدا لأنه يعلم بالضرورة أنه أكل مما اشتراه زيد وهو شرط الحنث (وإن أكل مثله فعلى وجهين) أحدهما

يحنث لأنه يستحيل في العادة انفراد ما اشتراه زيد من غيره فيكون الحنث ظاهرا [ج ٧ - ص ٣٧٣]

والثاني لا يحنث وجزم به في الوجيز لأن الأصل عدم الحنث ولم نتيقنه فعلى هذا كل موضع لا يحنث فحكمه حكم ما لو حلف لا يأكل تمرة فوقعت في تمر فأكل منه واحدة على ما نذكره وإن قابل زيد في مأكول كان باعه شيئا فأكل منه فهل يحنث على وجهين فإن كان اشترى شيئا سلما أو أخذه على وجه الصلح فأكل منه حنث

باب التأويل في الحلف

(ومعنى التأويل أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره) مثل أن يحلف أنه أخي يريد أخوة الإسلام وبالسقف والبناء السماء وبالبساط والفراش الأرض وبالأوتاد الجبال وباللباس الليل أو يقول ما رأيت فلانا أي ما ضربت رئته وما ذكرته أي ما قطعت ذكره وكقوله جواري أحرار يعني سفنه ونسائي طوالق أي أقاربه أو يقول ما كاتبت فلانا ولا عرفته ولا علمته ولا سألته حاجة ولا أكلت له دجاجة ولا فروجة ولا شربت له ماء ولا في بيتي فراش ولا حصير ولا بارية ويعني بالمكاتبة مكاتبة الرقيق وبالتعريف جعله عريفا وبالإعلام جعله أعلم الشفة والحاجة الشجرة الصغيرة والدجاجة الكبة من الغزل والفروجة الدراعة والفرش صغار الإبل والحصير الجيش والبارية السكين التي يبرى بها فهذا وأشباهه مما يسبق إلى فهم السامع خلافه إذا عناه بيمينه فهو تأويل لأنه خلاف الظاهر [ج ٧ - ص ٣٧٤]

(فإن كان الحالف ظالما لم ينفعه تأويله) بغير خلاف نعلمه (لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك) وفي لفظ اليمين على نية المستحلف رواهما مسلم وعلم منه أنه إذا كان مظلوما فله تأويله نص عليه لحديث سويد بن حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا فحلفت أنه أخي فخلي سبيله فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك فقال كنت أبرهم وأصدقهم المسلم أخو المسلم رواه أبو داود وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب رواه الترمذي قال محمد بن سيرين الكلام أوسع من أن يكذب ظريف خص الظريف بذلك يعني به الكيس الفطن فإنه يفطن التأويل فلا حاجة إلى الكذب فإن كان لا ظالما ولا مظلوما فظاهر كلام أحمد أن له تأويله لأنه عليه السلام كان يمزح ولا يقول إلا حقا ومزاحه أن يوهم السامع بكلامه غير ما عناه وهو التأويل فقال عليه السلام لعجوز لا تدخل الجنة عجوز يعني أن الله تعالى ينشئهن أبكارا عربا أترابا

مسائل الأولى إذا حلف ليقسمن بين ثلاث نسوة ثلاثين قارورة عشر مملوءة وعشر فرغ وعشر منصف قلب كل منصفة في أخرى فلكل واحدة خمس مملوءة وخمس فرغ

الثانية إذا كان له ثلاثون نعجة عشر ولدت كل واحدة سخلة وعشر اثنتين وعشرة ثلاثا وحلف ليجعلن لكل امرأة ثلاثا ولا يفرق بين سخلة وأمها أعطى الكبرى عشرة نتجت عشرين والوسطى نصف ما نتج سخلة

[ج ٧ - ص ٣٧٥]

ونصف ما نتج ثلاثا بسخالها وكذا الصغرى

الثالثة إذا حلف أنه رأى ثلاث إخوة لأبوين أحدهم عبد والآخر مولى والآخر عربي لا ولاء عليه هذا رجل تزوج بأمة فولدت ابنا فهو عبد ثم كوتبت فأدت وهي حامل فأتت بابن فتبعها فهو مولى ثم ولدت بعد الأداء ابنا فهو عربي بلا ولاء

الرابعة إذا حلف أن خمسة زنوا بامرأة فلزم الأول القتل والثاني والرجم والثالث الجلد والرابع نصف الحر ولم يلزم الخامس شيء فالأول ذمي والثاني محصن والثالث بكر والرابع عبد والخامس حربي

الخامسة إذا حلف ليخبرنه بشيء رأسه في عذاب وأسفله في شراب وأوسطه في طعام وحوله سلاسل وأغلال وحبسه في بيت ضيق فهو فتيلة القنديل

السادسة إذا حلف أنه يحب الفتنة ويكره الحق ويشهد بما لم يره وهو بصير ولا يخاف من الله ولا رسول الله وهو مؤمن عدل فجوابه أنه يحب المال والولد ويكره الموت ويشهد بالغيب والحساب ولا يخاف من الله ولا رسوله الظلم والجور

السابعة لو سئل عن طعم نجو الآدمي قيل إنه أولا حلو لسقوط الذباب عليه ثم حامض لأنه يدود ثم مر لأنه يلدح

(فإذا أكلا تمرا فخلف لتخبرني بعدد ما أكلت أو لتميزن نوى ما أكلت فإنها تفرد كل نواة وحدها وتعد من واحد إلى عدد يتحقق دخول ما أكل فيه) ولا يحنث إذا كان نيته ذلك وإن نوى الإخبار بكميته من غير زيادة ولا نقص [ج ٧ - ص ٣٧٦]

لم يبرأ إلا بذلك وإن أطلق فقياس المذهب أنه كذلك لأن الأيمان تنبني على المقاصد إلا أن تكون حيلة فيحنث

فرع لو كان في فيها تمرة فقال أنت طالق إن أكلتها أو ألقيتها أو أمسكتها فأكلت بعضها وألقت بعضها انبنى على فعل بعض المحلوف عليه

(وإن حلف ليقعدن على بارية في بيته ولا تدخله بارية فإنه يدخل قصبا وينسجه فيه) ويجلس عليها في البيت ولا يحنث لأنه لم يدخله بارية وإنما أدخله قصبا وفي المحرر وإن حلف لا يدخل بيته بارية فأدخل قصبا لذلك فنسجت فيه حنث وإن طرأ قصده والقصب فيها فوجهان (وإن حلف ليطبخن قدرا برطل ملح ويأكل منه فلا يجد طعم الملح فإنه يسلق فيه بيضا) لأن الصفة وجدت لكون أن الملح لا يدخل في البيض (وإن حلف لا يأكل بيضا ولا تفاحا وليأكلن مما في هذا الوعاء فوجده بيضا وتفاحا فإنه يعمل من البيض ناطفا ومن التفاح شرابا) ويأكل منه بغير حنث لأن ذلك ليس ببيض ولا تفاح وقيل يحنث مع التعيين (وإن كان على سلم فحلف لا صعدت إليك ولا نزلت إلى هذه ولا أقمت مكاني ساعة فلتنزل العليا وتصعد السفلى فتنحل يمينه) لأن ما فعله سبب إلى عدم حنثه وأما كونه تنحل يمينه فلأنه لم يبق حنثه ممكنا لزوال الصورة المحلوف عليها

(وإن حلف لا أقمت عليه ولا نزلت منه ولا صعدت فيه فإنه ينتقل

[ج ٧ - ص ٣٧٧]

إلى سلم آخر) فتنحل يمينه لأنه إنما نزل أو صعد من غيره (وإن حلف لا أقمت في هذا الماء ولا خرجت منه فإن كان جاريا لم يحنث) لأن الماء المحلوف عليه جرى وصار في غيره فلم يحنث سواء أقام أو خرج لأنه إنما يقف في غيره أو يخرج منه ذكره القاضي في المجرد لأن الأيمان تنبنى على اللفظ لا على القصد وقال في موضع آخر قياس المذهب أنه لا يحنث (إذا نوى ذلك الماء بعينه) لأن ذلك الماء بعينه يصدق أنه ما أقام فيه ولا خرج منه ضرورة كونه جاريا فلم تحصل المخالفة في المحلوف عليه (وإن كان واقفا حمل منه مكرها) فلا ينسب إليه فعل

فرع إذا حلف لا لبست أنت هذا القميص ولا وطئتك إلا فيه فلبسته ووطئها لم يحنث وإن حلف ليجامعن على رأس رمح فنقب السقف وأخرج منه رأس الرمح يسيرا وجامع عليه بر في الأشهر (وإن استحلفه ظالم ما لفلان عندك وديعة وكانت له عنده وديعة فإنه يعني ب ما) الذي أي الموصولة أو ينوي غير الوديعة أو غير مكانها أو يستثنى بقلبه (ويبر في يمينه) لأنه صادق

مسألة إذا حلف لتصدقني هل سرقت مني شيئا أم لا وخافت أن تصدقه فتقول سرقت منك ما سرقت منك وتعني ما الذي (وإن حلف له ما فلان هاهنا وعنى موضعا معينا بر في يمينه) لصدقه في ذلك وروي أن

مهنا والمروذي كانا عند أحمد فجاء رجل يطلب المروذي ولم يرد المروذي أن [ج ٧ - ص ٣٧٨]

يكلمه فوضع مهنا اصبعه في كفه وقال ليس المروذي هاهنا يريد ليس هو في كفه فلم ينكره أحمد (وإن حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعته لم يحنث) لأن الخيانة ليست بسرقة (إلا أن ينوي) ذلك فيحنث لأن اللفظ صالح أن يراد به ذلك وقد نواه فوجب الحنث ضرورة المخالفة في المحلوف عليه أو يكون له سبب

فرع إذا استحلفه ظالم هل رأيت فلانا أو لا وكان قد رآه فإنه يعني برأيت ما ضربت رئته وإن قال إن كانت امرأتي في السوق فعبدي حر وإن كان عبدي في السوق فامرأته طالق وكانا في السوق عتق العبد ولم تطلق لأنه عتق باللفظ الأول فلما عتق لم يبق له في السوق عبد ويحتمل أن يحنث إن أراد عبدا بعينه بناء على من حلف على معين تعلق اليمين بعينه دون صفته

مسائل إذا حلف أنه يطأ في يوم ولا يغتسل فيه مع قدرته على استعمال الماء ولا تفوته صلاة مع الجماعة فإنه يصلي الفجر والظهر والعصر ويطأ بعدها ويغتسل بعد المغرب ويصلي معه

إذا قال أنت طالق إن لم أطأك في رمضان ثم سافر ثلاثة أيام ثم وطىء فقال أحمد لا يعجبني لأنها حيلة وقال في رواية بكر بن محمد إذا حلف على فعل شيء ثم احتال بحيلة فصار إليها فقد صار إلى ذلك الذي حلف عليه

بعينه وقال القاضي الصحيح أنها تنحل به اليمين ويباح به الفطر لأن إرادة حل اليمين من المقاصد الصحيحة

إذا حلف في شعبان ليجامعن امرأته في شهرين متتابعين فدخل

[ج ٧ - ص ٣٧٩]

رمضان سافر بها فإن حاضت فوطىء فيه كفر عن كل وطء في الحيض كفارته وعنه لا يطأ وتطلق كمن حلف ليسقين ولده خمرا نص عليه سئل أحمد عن رجل حلف لا يفطر في رمضان فقال للسائل اذهب إلى بشر ابن الوليد فاسأله ثم ائتني فأخبرني فذهب فسأله فقال له بشر إذا أفطر أهلك فاقعد معهم ولا تفطر فإذا كان السحر فكل واحتج بقوله عليه السلام هلموا إلى الغداء المبارك فاستحسنه أحمد رضي الله عنه

باب الشك في الطلاق لا) أوشك في وجود شرطه (لم تطلق) نص عليه وهو قول أكثرهم لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بالشك ويشهد له قوله عليه السلام فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فأمره بالبناء على اليقين واطراح الشك قال المؤلف والورع إلزام الطلاق وعن شريك أنه إذا شك في طلاقه طلقها واحدة ثم راجعها لتكون الرجعة عن طلقة صحيحة فتكون صحيحة في الحكم وفيه نظر لأن التلفظ بالرجعة ممكن مع الشك في الطلاق ولا يفتقر إلى ما تفتقر إليه العبادات من النية ولأنه لو شك في طلقتين فطلق واحدة لصار شاكا في تحريمها عليه فلا تفيده الرجعة وقيل يلزمه حكمه مع شرط عدمي نحو لقد فعلت كذا أو إن لم أفعله اليوم فمضى وشك

في فعله لزمه الطلاق قال في المحرر وتمام الورع في الشك قطعه برجعة أو عقد إن أمكن وإلا فتفرقة متيقنة بأن يقول إن لم تكن طلقت فهي طالق

(وإن شك في عدده بنى على اليقين) نص عليه لأن ما زاد على اليقين طلاق مشكوك فيه فلم يقع كما لو شك في أصل الطلاق فلو شك هل طلق اثنتين أو واحدة فهي واحدة لأنها اليقين وأحكامه أحكام المطلق دون الثلاث من إباحة الرجعة وحل الوطء وإذا راجع عادت إلى ما كانت عليه قبل الطلاق وكذا لو قال لها أنت طالق بعدد ما طلق فلان زوجته وجهل عدده فطلقة (وقال الخرقي إذا طلق فلم يدر أواحدة طلق أم ثلاثا لا يحل له وطؤها حتى يتيقن) هذا رواية عن أحمد أنه يحرم عليه وطؤها لأنه متيقن للتحريم شاك في التحليل وعليه نفقتها ما دامت في العدة لأن الأصل بقاؤها استنادا لبقاء النكاح ولأنه لو تنجس ثوبه ولم يدر موضع النجاسة منه لا يحل له أن يصلي فيه حتى يغسل ما تيقن به طهارته فكذا هنا والجامع بينهما تيقن الأصل والشك فيما بعده وظاهر كلام الإمام والأصحاب أنه إذا راجعها حلت له لأن الرجعة مزيلة لحكم المتيقن من الطلاق فإن التحريم أنواع تحريم تزيله الرجعة وتحريم يزيله نكاح جديد وتحريم يزيله نكاح بعد زوج وإصابة ومن تيقن الأدنى لا يثبت فيه حكم الأعلى كمن تيقن الحدث الأصغر لا يثبت فيه حكم

الأكبر ويخالف الثوب فإن غسل بعضه لا يرفع ما تيقنه من النجاسة ومن أصحابنا من منع حصول التحريم بالطلاق [ج ٧ - ص ٣٨١]

لكون الرجعة مباحة فلم يكن التحريم متيقنا (وكذلك قال فيمن حلف بالطلاق لا يأكل تمرة فوقعت في تمر فأكل منه واحدة منع من وطء امرأته حتى يتيقن أنها ليست التي وقعت اليمين عليها ولا يتحقق حنثه حتى يأكل التمر كله) إذا تيقن أكل التمرة المحلوف عليها أو أنه لم يأكلها فلا إشكال في ذلك بغير خلاف فإن أكل منها شيئا قل أو كثر ولم يدر أكلها أو لا فلا يتحقق حنثه لأن الباقية يحتمل أنها المحلوف عليها ويقين النكاح ثابت فلا يزول بالشك فعلى هذا حكم الزوجية باق إلا في الوطء فإن الخرقي يمنع منه لأنه شاك في حلها كما لو اشتبهت امرأته بأجنبية وذكر أبو الخطاب وغيره أنها باقية على الحل لأن الأصل الحل فلا يزول بالشك كسائر أحكام النكاح وكما لو شك هل طلق أم لا فإن كانت يمينه ليأكلن هذه التمرة فلا يتحقق بره حتى يعلم أنه أكلها

فرع إذا قال لزوجتيه أو أمتيه إحداكما طالق أو حرة غدا فماتت إحداهن قبل الغد طلقت وعتقت الباقية في ظاهر المذهب وقيل يقرع بينهما كموتهما وهل تطلق إذن أو منذ طلق فيه وجهان

(وإن قال لامرأتيه إحداكما طالق ينوي واحدة معينة طلقت وحدها) لأنه عينها بنيته أشبه ما لو عينها بلفظه فإن قال أردت فلانة قبل لأن ما قاله محتمل ولا يعرف إلا من جهته (وإن لم ينو أخرجت المطلقة بالقرعة

) نص عليه في رواية جماعة روي عن علي وابن عباس ولا مخالف لهما في

[ج ٧ - ص ٣٨٢]

الصحابة وقاله الحسن وأبو ثور ولأنه إزالة ملك بني على التغليب والسراية فتدخله القرعة كالعتق وقد ثبت الأصل بقرعته عليه السلام بين العبيد الستة ولأن الحق لواحد غير معين فوجب تعيينه بقرعة كإعتاق عبيده في مرضه وكالسفر بإحدى نسائه وكالمنسية وعنه يعين أيتهما شاء وقاله أكثر العلماء وذكرها بعضهم في العتق لأنه لا يمكن إيقاعه ابتداء ويعينه فإذا أوقعه ولم يعينه ملك تعيينه لأنه استيفاء ما ملكه وقال قتادة يطلقن جميعا ورد بأنه إضاف الطلاق إلى واحدة فلم تطلق الجميع كما لو عينها

فرع لا يطأ إحداهما قبل القرعة أو التعيين وهل وطء إحداهما تعيين لغيرها قال ابن حمدان يحتمل وجهين والأصح أنه ليس تعيينا لغيرها ولا يقع بالتعيين بل يتبين وقوعه في المنصوص فإن مات أقرع الورثة فمن قرعت لم تورث نص عليه

تنبيه إذا قال امرأتي طالق أو أمتي حرة ونوى معينة انصرف إليها وإن نوى مبهمة فهي مبهمة فيهن وإن لم ينو شيئا فالمذهب تطلق نساؤه وتعتق إماؤه روي عن ابن عباس لأن الواحد المضاف يراد به الكل لقوله تعالى ﴿ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ﴾ إبراهيم 34 وقال الجماعة يقع على واحدة مبهمة كما لو قال إحداكما طالق لأن لفظ الواحد لا يستعمل في الجميع إلا مجازا ولو احتمل وجب صرفه على الواحدة لأنها اليقين وما زاد مشكوك فيه قال في الشرح وهذا أصح [ج ٧ - ص ٣٨٣]

(وإن طلق واحدة بعينها وأنسيها فكذلك عند أصحابنا) أي ذهب أكثر الأصحاب إلى أنه إذا طلق امرأة من نسائه وأنسيها أنها تخرج بالقرعة قال في المحرر هو المشهور لأنه بعد النسيان لا تعلم المطلقة منهما فوجب أن تشرع القرعة فيها وحينئذ تجب النفقة حتى يقرع وقد روى إسماعيل بن سعيد عن أحمد أن القرعة لا تستعمل هنا لمعرفة الحل وإنما تستعمل لبيان الميراث قال في الشرح لا ينبغي أن يثبت الحل بالقرعة وهو قول أكثر أهل العلم فالكلام إذا في شيئين أحدهما في استعمال القرعة في المنسية في التوريث الثاني استعمالها في الحل فالأول جائز لأن الحقوق إذا تساوت على وجه لا يمكن التمييز إلا بالقرعة صح كالشركاء في القسمة وأما الثاني فلا يصح استعمالها لأنها اشتبهت زوجته بأجنبية فلم تحل إحداهما بالقرعة (وإن تبين أن المطلقة غير التي خرجت عليها القرعة ردت إليه في ظاهر كلامه) لأنه ظهر أنها غير مطلقة والقرعة ليست بطلاق ولا كناية وهذا إذا لم تكن تزوجت لأنه أمر لا يعرف إلا من جهته فقبل قوله (إلا أن تكون قد تزوجت) لأنها قد تعلق بها حق الزوج الثاني (أو تكون) القرعة (بحكم حاكم) نص عليه في رواية الميموني لأن قرعة الحاكم بينهما حكم بالتفريق وليس لأحد رفع ما حكم به الحاكم قال ابن أبي موسى وفي هذا دليل على أن لحكم الحاكم تأثيرا في التحريم (وقال أبو بكر وابن حامد) وقدمه في الرعاية (تطلق المرأتان) أما المطلقة فحقيقة وأما التي خرجت بالقرعة فلأن الطلاق إذا [ج ٧ - ص ٣٨٤]

وقع يستحيل رفعه ولأنها حرمت عليه بقوله وترثه إن مات ولا يرثها وعلى قولهما يلزمه نفقتها ولا يحل له وطؤها والأولى بالقرعة قاله في الشرح وذكر في الرعاية على قولهما إن مات قبلها أقرع الورثة فمن قرعت لم ترث وإن ماتتا أو إحداهما قبله فمن قرعت لم يرثها مع طلاق بائن (والصحيح) عند المؤلف وهو رواية (أن القرعة لا مدخل لها ها هنا) أي في المعينة المتقدم ذكرها (وتحرمان عليه جميعا كما لو اشتبهت امرأته بأجنبية) ولأن القرعة لا تزيل حكم المطلقة ولا ترفع الطلاق عمن وقع عليها لأنه لو ارتفع لما عاد إذا تبين أنها مطلقة وفارق ما قاسوا عليه فإن الحق لم يثبت لواحد بعينه

تنبيه إذا طلق واحدة لا بعينها أو بعينها ثم نسيها فانقضت عدة الجميع فله نكاح خامسة قبل القرعة في الأصح ومتى علمناها بعينها فعدتها من حين طلقها وقيل من حين التعيين فإن مات الزوج قبل التعيين فعلى الجميع عدة الوفاة عند أهل الحجاز والعراق والصحيح أنه يلزم كل واحدة الأطول من عدة وفاة أو طلاق

(وإن طار طائر فقال إن كان هذا غرابا ففلانة طالق وإن لم يكن غرابا ففلانة طالق) ولم يعلم حاله (فهي كالمنسية) لأن الطائر لابد أن يكون أحدهما فيقع الطلاق بمن وجد شرط طلاقها وقد تقدم ذكر الخلاف فيها

لكن لو قال إن كان غرابا فامرأتي طالق ثلاثا وقال آخر إن لم يكن غرابا

[ج ٧ - ص ٣٨٥]

فامرأتي طالق ثلاثا ولم يعلماه لم تطلقا وحرم عليهما الوطء إلا مع اعتقاد أحدهما خطأ الآخر (وإن قال إن كان غرابا ففلانة طالق وإن كان حماما ففلانة طالق لم تطلق واحدة منهما إذا لم يعلم) لأنه يحتمل أنه غيرهما فلا يزول يقين النكاح بالشك في الحنث فإن ادعت حنثه قبل قوله لأن الأصل معه واليقين في جانبه (وإن قال إن كان غرابا فعبدي حر وقال آخر إن لم يكن غرابا فعبدي حر ولم يعلماه لم يعتق عبد واحد منهما) لأن الأصل بقاء الرق فلا يزول بالشك بخلاف ما إذا كان العبدان لواحد ولأنه معلوم زوال رقه عن أحدهما فلذلك شرعت القرعة

(وإن اشترى أحدهما عبد الآخر أقرع بينهما حينئذ) قاله أبو الخطاب ونصره في الشرح لأن العبدين صارا له وقد علم عتق أحدهما لا بعينه فيعتق لقرعة إلا أن يكون أحدهما أقر أن الحانث صاحبه فيؤخذ بإقراره (وقال القاضي) وقدمه في الرعاية (يعتق الذي اشتراه) لأنه ينكر حنث نفسه وذلك يقتضي حنث رفيقه في الحلف فيكون مقرا بحريته فإذا اشتراه وجب الحكم عليه بالعتق ولم يفرق المؤلف بين ما إذا اشتراه بعد أن انكر حنث نفسه وبين شرائه قبل أن ينكر وفرق بينهما في المغني وقال في المحرر فاشترى أحدهما نصيب صاحبه وقيل إنما يعتق إذا تكاذبا وإلا أحدهما بالقرعة وهو الأصح وولاء المبيع إن عتق لبيت المال وقيل للمشتري

فرع إذا كان الحالف واحدا فقال إن كان هذا غرابا فعبدي حر

وإن لم يكن غرابا فأمتي حرة عتق أحدهما بالقرعة فإن ادعى أحدهما أنه الذي عتق أو ادعى ذلك كل واحد منهما قبل قول السيد مع يمينه وإذا قال إن كان غرابا فنساؤه طوالق وإن لم يكن فعبيده أحرار وجهل أقرع بين النساء والعبيد وعليه نفقة الكل قبلها فإن ادعى كل منهم أنه عتق قبل قول السيد وفي يمينه وجهان وكل موضع قلنا يستحلف فنكل قضى عليه فإن قال أنا أعلم أنه كان غرابا أو غير غراب قبل منه وإن مات أقرع الورثة وقيل لهم التعيين

مسألة إذا زوج بنتا من ثلاث ثم مات وجهلت حرمن ونقل أبو طالب وحنبل تخرج بقرعة قال القاضي وأبو الخطاب وكذا يجيء إذا اختلطت أخته بأجنبيات وفي عيون المسائل لا يجوز اعتبار ما لو اختلط ملكه بملك لأجنبي ما لو اختلط ملكه بملكه لأنه إذا اختلط عبده بعبد غيره لم يقرع

(وإن قال لامرأته وأجنبية إحداكما طالق أو سلمى طالق واسم امرأته سلمى طلقت امرأته) لأن الأصل اعتبار كلام المكلف دون إلغائه فإن أضافه إلى إحدى امرأتين وإحداهما زوجته أو إلى اسم وزوجته مسماة بذلك وجب صرفه إلى امرأته لأنه لو لم يصرف إليها لوقع لغوا (فإن أراد الأجنبية لم تطلق امرأته) لأنه لم يصرح بطلاقها ولا لفظ بما يقتضيه ولا نواه فوجب بقاء نكاحها على ما كان عليه (وإن ادعى ذلك دين) لأنه يحتمل ما قاله [ج ٧ - ص ٣٨٧]

(وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين) أشهرهما أنه لا يقبل ونصره في الشرح لأن غير زوجته ليست محلا لطلاقه والثانية بلى وقاله أبو ثور لما قلنا وعلى الأولى إذا كان ثم قرينه دالة على إرادة الأجنبية مثل أن يدفع بيمينه ظلما أو يتخلص بها من مكروه فإنه يقبل في الحكم ونقل أبو داود فيمن له امرأتان اسمهما واحد ماتت إحداهما فقال فلانة طالق ينوي الميتة فقال الميتة تطلق كأن أحمد أراد لا يصدق حكما وفي الانتصار خلاف في قوله لها ولرجل إحداكما طالق فإن لم ينو زوجته ولا الأجنبية طلقت زوجته لأنها محل للطلاق

(وإن نادى امرأته فأجابته امرأة له أخرى فقال أنت طالق يظنها المناداة طلقتا في إحدى الروايتين) اختارها ابن حامد لأنها خاطبها بالطلاق فطلقت كما لو قصدها (والأخرى تطلق التي ناداها) فقط قدمها في المحرر و الفروع لأنه قد تعلق بخطابه المناداة وليست الأخرى مناداة ولأنه لم يقصدها بالطلاق فلم تطلق كما لو أراد أن يقول طاهر فسبق لسانه فقال أنت طالق قال أبو بكر لا يختلف كلام أحمد أنها لا تطلق (وإن قال علمت أنها غيرها وأردت طلاق المناداة طلقتا معا) في قولهم جميعا لأن المناداة توجه إليها لفظ الطلاق ونيته والمجيبة توجه إليها بخطابها بالطلاق (وإن قال أردت طلاق الثانية طلقت وحدها) لأنه خاطبها بالطلاق ونواها به ولا تطلق غيرها لأن لفظه غير موجه إليها ولا هي منوية

(وإن لقي أجنبية ظنها امرأته فقال فلانة أنت طالق) هذا قول في المذهب أنها تطلق إذا سمى زوجته والمذهب أنه يقع لقوله (طلقت امرأته) نص عليه لأنه قصد زوجته بصريح الطلاق كما لو قال علمت أنها أجنبية وأردت طلاق زوجتي ويحتمل أنها لا تطلق لأنه لم يخاطبها بالطلاق وكما لو علم أنها أجنبية فإن لقي امرأته ظنها أجنبية فقال أنت طالق فهل تطلق فيه روايتان هما أصل المسائل قال ابن عقيل وغيره وجزم به في الوجيز على أنه لا يقع وكذا العتق قال أحمد فيمن قال يا غلام أنت حر يعتق عبده الذي نوى وفي المنتخب أو نسي أن له عبدا أو زوجة فبان له

فرع إذا لقي امرأته يظنها أجنبية فقال أنت طالق أو قال تنحي يا مطلقة أو قال لأمته يظنها أجنبية تنحي يا حرة فقال أبو بكر لا يلزمه عتق ولا طلاق ونصره في الشرح لأنه لم يردهما بذلك فلم يقع بهما شيء كسبق اللسان ويخرج على قول ابن حامد أنهما يقعان ويحتمل ألا يقع العتق فقط لأن عادة الناس مخاطبة من لا يعرفها بقوله يا حرة بخلاف المرأة فإنها تطلق

تذنيب إذا أوقع كلمة وجهلها هل هي طلاق أو ظهار فقيل يقرع بينهما لأنها تخرج المطلقة بها فكذا أحد اللفظين وقيل لغو قدمه في الفنون كمني في ثوب لا يدري من أيهما هو قال في الفروع ويتوجه مثله من حلف يمينا ثم جهلها يريد أنه لغو في قول أحمد في رجل قال له حلفت بيمين لا

أدري أي شيء هي قال ليت أنك إذا دريت دريت أنا وذكر ابن عقيل رواية تلزمه كفارة يمين [ج ٧ - ص ٣٨٩]

كتاب الرجعة

الرجعة بفتح الراء أفصح من كسرها قاله الجوهري وقال الأزهري الكسر أكثر وهي لغة المرة من الرجوع وشرعا عبارة عن إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى ﴿ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ﴾ البقرة 228 أي رجعة قاله الشافعي والعلماء وقوله تعالى ﴿ فأمسكوهن بمعروف ﴾ الطلاق 65 فخاطب الأزوج بالأمر ولم يجعل لهن اختيارا وقد روى ابن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها متفق عليه وطلق عليه السلام حفصة ثم راجعها رواه أبو داود من حديث عمر رضي الله عنه

(إذا طلق الحر امرأته بعد دخوله بها أقل من ثلاث والعبد واحدة بغير عوض فله رجعتها ما دامت في العدة) أجمع أهل العلم على ذلك ذكره ابن المنذر وإذا فقد قيد منها لم يملك الرجعة فالأول يحترز عن غير المدخول بها لأنه إذا طلقها قبل الدخول فلا رجعة لأنه لا عدة عليها فلا تربص في حقها برجعتها فيه وبالثاني عن المطلقة تمام العدد وبالثالث عن الخلع ونحوه وبالرابع عن انقضاء العدة والمنصوص أن الخلوة هنا كالدخول وقيل لا رجعة لمن خلا بها ولم يطأ وهو قول أكثرهم (رضيت أو كرهت) لعموم المنصوص [ج ٧ - ص ٣٩٠]

ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية فلم يعتبر رضاها في ذلك كالذي في صلب نكاحه ولو بلا إذن سيد وغيره ولو كان مريضا مسافرا نص عليه وقال الشيخ تقي الدين لا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحا وأمسك بمعروف وظاهره للحر رجعة أمة وإن كان تحته حرة وشرط المرتجع أهلية النكاح بنفسه فخرج بالأهلية المرتد وبنفسه الصبي والمجنون ولو طلق فجن فلوليه الرجعة على الأصح حيث يجوز له ابتداء النكاح فلو كانت حاملا فوضعت بعض الولد فله رجعتها لأنها لم تضع جميع حملها فإذا كانت حاملا باثنين فله رجعتها قبل وضع الثاني في قول عامتهم وقال عكرمة تنقضي عدتها بوضع الأول

(وألفاظ الرجعة راجعت امرأتي أو رجعتها أو ارتجعتها أو رددتها أو أمسكتها) لقوله تعالى ﴿ وبعولتهن أحق بردهن ﴾ البقرة 228 ﴿ فأمسكوهن بمعروف ﴾ الطلاق 65 والرجعة ورد بها السنة واشتهرت في العرف كاشتهار اسم الطلاق فيه وقيل الصريح لفظها لاشتهاره دون غيره كقولنا في صريح الطلاق وذكره في الرعاية تخريجا وذكر الحلواني ألفاظها الصريحة ثلاثاة أمسكتك وراجعتك وارتجعتك (فإن قال نكحتها أو تزوجتها فعلى وجهين) وفي الإيضاح روايتان إحداهما لا تحصل بذلك قدمه السامري وجزم به في الوجيز لأن هذا كناية والرجعة استباحة بضع مقصود فلا تحصل بالكناية كالنكاح

والثاني بلى أومأ إليه أحمد واختاره ابن حامد لأن الأجنبية تباح

[ج ٧ - ص ٣٩١]

به فالرجعية أولى وعلى هذا يحتاج أن ينوي به الرجعة ذكره في الوجيز والتبصرة والمغني والشرح لأن ما كان كناية تعتبر له النية ككنايات الطلاق وفي الترغيب هل يحصل بكناية أعدتك أو استدمتك فيه وجهان وفيه وجه لا يحصل بكناية رجعة (وهل من شرطها الإشهاد على روايتين) كذا أطلقهما في الفروع إحداهما يجب قدمه الخرقي وجزم به أو إسحاق بن شاقلا ونص عليه في رواية مهنا لقوله تعالى ﴿ فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ﴾ الطلاق 65 وظاهر الأمر الوجوب ولأنه استباحة بضع مقصود فوجبت الشهادة فيه كالنكاح فلو ارتجع بغير إشهاد لم يصح وإن أشهد وأوصى الشهود بكتمانها فالرجعة باطلة نص عليه وقال القاضي يخرج على الروايتين في التواصي بكتمان النكاح

والثانية لا يشترط نص عليه في رواية ابن منصور واختارها أبو بكر والقاضي وأصحابه ورجحها في المغني والشرح وجزم بها في الوجيز لأنها لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد كالبيع وإذا يحمل الأمر على الاستحباب ولا شك أن الإشهاد بعد الرجعة مستحب بالإجماع فكذا عندها حذارا من الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد وما قيل إنها استباحة بضع فغير مسلم إذ الرجعة مباحة وجعل المجد هاتين الروايتين على قولنا إن الرجعة لا تحصل إلا بالقول وهو ظاهر وأما على القول بأنها

تحصل بالوطء فلا يشترط الإشهاد رواية واحدة وعامة الأصحاب كالقاضي [ج ٧ - ص ٣٩٢]

في التعليق يطلقون الخلاف والزم الشيخ تقي الدين بإعلان الرجعة والتسريح أو الإشهاد كالنكاح والخلع عنده لا على ابتداء الفرقة ولئلا يكتم طلاقها وعلى كل تقدير فالاحتياط أن يقول اشهدا علي أني قد راجعت زوجتي إلى نكاحي أو راجعتها لما وقع عليها طلاقي

(والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء) ويرث أحدهما صاحبه إن مات بالإجماع وعنه لا يصح الإيلاء منها فإن خالعها صح خلعه وفيه رواية حكاها في الترغيب لأنه يراد للتحريم وهي محرمة وجوابه أنها زوجة يصح طلاقها فصح خلعها كما قبل الطلاق وليس مقصود الخلع التحريم بل الخلاص من ضرر الزوج على أننا نمنع كونه محرمة وتستحق النفقة كالزوجة

(ويباح لزوجها وطؤها والخلوة والسفر بها ولها أن تتزين وتتشرف له) في ظاهر المذهب وصححه في المستوعب قال أحمد في رواية أبي طالب لا تحتجب عنه وفي رواية أبي الحارث تتشرف له ما كانت في العدة لأنها في حكم الزوجات كما قبل الطلاق (وتحصل الرجعة بوطئها نوى الرجعة أم لم ينو) على المذهب اختاره ابن حامد والقاضي وقاله كثير من العلماء لأنه سبب زوال الملك انعقد مع الخيار والوطء من المالك يمنع زواله كوطء البائع في مدة الخيار وكما ينقطع به التوكيل في طلاقها وقال ابن أبي موسى

تكون رجعة إذا أراد بها الرجعة وقاله إسحاق (ولا تحصل بمباشرتها والنظر إلى [ج ٧ - ص ٣٩٣]

فرجها والخلوة بها لشهوة نص عليه) لأن ذلك كله ليس في معنى الوطء إذ الوطء يدل على ارتجاعها دلالة ظاهرة بخلاف ما ذكر وقال بعض أصحابنا تحصل الرجعة بها لأنه معنى يحرم من الأجنبية والحل من الزوجة فحصلت به الرجعة كالاستمتاع والصحيح الأول لأنه لا يبطل خيار المشتري للأمة وكاللمس لغير شهوة (وخرجه ابن حامد على وجهين) مبنيين على الروايتين في تحريم المصاهرة به أحدهما هو رجعة لأنه استمتاع يباح بالزوجة فحصلت الرجعة به كالوطء والثاني ليس برجعة لأنه أمر لا يتعلق به إيجاب عدة ولا مهر فلا تحصل به كالوطء (وعنه ليست مباحة) لأنها مطلقة فوجب عدم إباحتها كالمطلقة بعوض (ولا تحصل الرجعة بوطئها) بل لا تحصل إلا بالقول وهو ظاهر الخرقي لأنه استباحة بضع مقصود أمر بالإشهاد فيه فلم يحصل من القادر بغير قول كالنكاح ولأن غير القول فعل من قادر على القول فلم تحصل الرجعة به كالإشارة من الناطق فعليها لا مهر لها (وإن أكرهها عليه فلها المهر) لأن وطأها حرمه الطلاق فأوجب المهر كوطء البائن (إن لم يرتجعها بعده) وقاله جمع لأنه إذا ارتجعها بعده تبينا أن الطلاق السابق لم يكن مفضيا إلى البينونة فوجب ألا يكون محرما فلا يكون موجبا والمذهب أنه لا مهر بوطئها فلزمه سواء رجع أم لا لأنه وطئ زوجته التي يلحقها طلاقه فلم يلزمه مهرها كالزوجات قال في الشرح والأول أولى لظهور الفرق فإن البائن ليست زوجة له وهذه زوجة يلحقها طلاقه [ج ٧ - ص ٣٩٤]

فرع لا حد عليه في هذا الوطء وهل يعزر فيه خلاف

(ولا يصح تعليق الرجعة بشرط) لأنه استباحة فرج مقصود أشبه النكاح فلو قال كلما طلقتك فقد راجعتك أو راجعتك إن شئت أو إن قدم أبوك لم يصح لأنه تعليق على شرط لكن لو قال كلما راجعتك فقد طلقتك صح وطلقت (ولا الارتجاع في الردة) أي إذا راجع في الردة من أحدهما لم يصح كالنكاح وقال القاضي إن قلنا تتعجل الفرقة بالردة لم تصح الرجعة لأنها قد بانت بها وإن قلنا لا تتعجل الفرقة فالرجعة موقوفة إن أسلم المرتد منهما صحت الرجعة وإن لم يسلم لم يصح كما يقف الطلاق والنكاح وهذا قول المزني واختاره ابن حامد وكذا إذا راجعها بعد إسلام أحدهما

(وإن طهرت من الحيضة الثالثة والأمة من الحيضتين ولما تغتسل فهل له رجعتها على روايتين) ذكرهما ابن حامد إحداهما لا تنقضي حتى تغتسل ولزوجها رجعتها نص عليه في رواية حنبل قدمها السامري وابن حمدان وهي قول كثير من الأصحاب روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وقاله شريك وإن فرطت في الغسل عشرين سنة ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان كالإجماع ولأن أكثر أحكام الحيض لا تزول إلا بالغسل والثانية أنها تنقضي بانقطاع الدم وإن لم تغتسل اختارها أبو الخطاب والحلواني قال ابن حمدان وهي أولى وفي

الوجيز والصحيح ما لم يمض عليها وقت صلاة لقوله تعالى ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ [ج ٧ - ص ٣٩٥]

البقرة 228 والقرء الحيض وقد زالت فيزول التربص ويحمل قول الصحابة حتى تغتسل أي يلزمها الغسل ولأن انقضاء العدة يتعلق ببينونتها من الزوج وحلها لغيره فلم تتعلق بفعل اختياري من جهة المرأة بغير تعليق الزوج كالطلاق فإن كانت العدة بوضع الحمل فله رجعتها بعد وضعه وقبل أن تغتسل من النفاس قال ابن عقيل له رجعتها على رواية حنبل والصحيح لا نص عليه سواء طهرت من النفاس أم لا

(وإن انقضت عدتها ولم يرتجعها بانت ولم تحل له إلا بنكاح جديد) بشروطه بالإجماع (وتعود إليه على ما بقي من عدد طلاقها سواء رجعت بعد نكاح زوج غيره أو قبله) وجملته أنها إذا رجعت إليه قبل زوج ثان فإنها تعود إليه على ما بقي من طلاقها بغير خلاف علمناه وإن عادت إليه بعد زوج وإصابة وكان الأول طلقها ثلاثا عادت إليه بطلاق ثلاثا إجماعا حكاه ابن المنذر وإن طلقها دون الثلاث فأظهر الروايتين أنها تعود إليه على ما بقي من طلاقها وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وأبي هريرة وابن عمر وعمران وقاله أكثر العلماء لأن وطء الثاني لا يحتاج إليه إلا في الإحلال للأول فلا يغير حكم الطلاق كوطء السيد وكما لو عادت إليه قبل نكاح آخر (وعنه إن رجعت بعد نكاح زوج غيره رجعت بطلاق ثلاث) وهي قول ابن عمر وابن عباس لأن وطء الثاني يهدم الطلقات الثلاث فأولى أن يهدم ما دونها ولأن وطء الثاني سبب للحل وجوابه أنه

لا يثبت الحل لأنه في الطلقات الثلاث غاية للتحريم وإنما سماه محللا تجوزا ولأن الحل إنما يثبت [ج ٧ - ص ٣٩٦]

في محل فيه تحريم وهي المطلقة ثلاثا وها هنا هي حلال له فلا يثبت فيها حل

(وإن ارتجعها في عدتها وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم فاعتدت وتزوجت من أصابها ردت إليه) وحاصله أن زوج الرجعية إذا راجعها من حيث لا تعلم صحت المراجعة لأنها لا تفتقر إلى رضاها فلم تفتقر إلى علمها كطلاقها فإذا راجعها ولم تعلم فانقضت عدتها وتزوجت ثم جاء وادعى أنه كان راجعها قبل انقضاء عدتها وأقام البينة على ذلك فهي زوجته وإن نكاح الثاني فاسد لأنه تزوج امرأة غيره وترد إلى الأول سواء دخل بها الثاني أولا وهو قول أكثرهم لأنها رجعة صحيحة وتزوجت وهي زوجة الأول فلم يصح كما لو لم يطلقها (ولا يطؤها حتى تنقضي عدتها) من الثاني لأنها معتدة من غيره أشبه ما لو وطئت في أصل نكاحه (وعنه أنها زوجة الثاني) إن دخل بها ويبطل نكاح الأول روي عن عمر وسعيد بن المسيب وغيرهما لأن كل واحد منهما عقد عليها وهي ممن يجوز له العقد عليها في الظاهر ومع الثاني مزية وجوابه ما سبق فإن لم يدخل الثاني بها فلا مهر وإن دخل فعليه مهر المثل ومقتضاه أنه إذا لم يدخل بها فإنها ترد إلى الأول بغير خلاف في المذهب وأنه إذا تزوجها مع علمه بالرجعة فالنكاح باطل وحكم العالم كالزاني في الحد وغيره

(وإن لم تكن له بينة برجعتها لم تقبل دعواه) لقوله عليه السلام لو يعطى الناس بدعواهم الخبر ولأن الأصل عدم الرجعة فإذا اعترفا له بها

[ج ٧ - ص ٣٩٧]

كان كإقامة البينة بها في أنها ترد إليه (لكن إن صدقه الزوج الثاني بانت منه) لأنه اعترف بفساد نكاحه فتبين منه وعليه مهرها إن كان دخل بها أو نصفه ولا تسلم إلى المدعي لأن قول الزوج الثاني لا يقبل عليها وإنما يقبل في حقه ويقبل قولها وفي اليمين وجهان وصحح في المغني أنها لا تستحلف لأنها لو أقرت لم يقبل

(وإن صدقته المرأة لم يقبل تصديقها) على الزوج إذا أنكر وإنما يقبل على نفسها في حقها ولا يستحلف الزوج الثاني في وجه اختاره القاضي لأنه دعوى في النكاح والثاني بلى وهو قول الخرقي للعموم وعلى هذا يمينه على نفي العلم لأنه على نفي فعل الغير (ومتى بانت منه) بموت أو طلاق أو فسخ (عادت إلى الأول بغير عقد جديد) لأن المنع من ردها إنما كان لحق الثاني كما لو شهد بحرية عبد ثم اشتراه فإنه يعتق عليه ولا يلزمها مهر الأول إن صدقته في الأصح وفي الواضح إن صدقته لم يقبل إلا أنه يحال بينهما وقال القاضي له عليها المهر لأنها أقرت أنها حالت بينه وبين نصفها بغير حق أشبه شهود الطلاق إذا رجعوا ولنا أن ملكها قد استقر على المهر فلم يرجع به عليها كما لو ارتدت أو أسلمت ويلزمها للثاني مهرها أو نصفه وهل يؤمر بطلاقها فيه روايتان فإن مات الأول وهي في نكاح الثاني ورثته لإقراره بزوجيتها وتصديقها له وإن ماتت لم يرثها لأنها لا تصدق في إبطال نكاحه وإن مات الثاني لم ترثه لأنها تنكر صحة نكاحه فتنكر

ميراثه وإن ماتت ورثها لأنه زوجها في الحكم من إباحة النظر والوطء وكذا في الميراث

فرع إذا تزوجت الرجعية في عدتها وحملت من الثاني انقطعت عدة الأول فإذا وضعت أتمت عدة الأول وله رجعتها في هذا التمام وجها واحدا وإن راجعها قبل الوضع صحت لأن الرجعة باقية وإنما انقطعت لعارض كما لو وطئت في صلب نكاحه وقيل لا لأنها في عدة غيره والأول أولى فعلى الثاني لو حملت حملا يمكن أن يكون منهما وراجعها في هذا الحمل ثم بان أنه من الثاني لم يصح وإن بان من الأول صحت على أصح الاحتمالين

فصل

(وإذا ادعت المرأة انقضاء عدتها) بولادة أو غيرها (قبل قولها إذا كان ممكنا) لقوله تعالى ﴿ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ﴾ البقرة 228 أي من الحمل والحيض فلولا أن قولهن مقبول لم يحرم عليهن كتمانه ولأنه أمر يختص بمعرفته فكان القول قولها فيه كالنية أو أمر لا يعرف إلا من جهتها فقبل قولها فيه كما يجب على التابعي قبول خبر الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (إلا أن تدعيه بالحيض في شهر فلا يقبل إلا ببينة ولو أنه امرأة واحدة) نص عليه لقول شريح إذا ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر وجاءت ببينة فقد انقضت عدتها وإلا فهي كاذبة فقال له علي قالون ومعناه بلسان الرومية أصبت

وأحسنت ولأنه يندر جدا حصول ذلك في شهر فيعمل بالبينة بخلاف ما زاد على الشهر وبخلاف عادة منتظمة [ج ٧ - ص ٣٩٩]

في الأصح وعنه يقبل قولها مطلقا واختاره الخرقي وأبو الفرج كثلاثة وثلاثين يوما ذكره في الواضح والطريق الأقرب ولا فرق بين المسلمة والفاسقة وضدهما

فرع إذا قالت انقضت عدتي ثم قال ما انقضت فله رجعتها ولو قال أخبرتني بانقضاء عدتها ثم راجعتها ثم أقرت بكذبها بانقضاء عدتها وأنكرت ذلك وادعت أن عدتها لم تنقض فالرجعة صحيحة لأنها لم تقر بانقضاء عدتها وإنما أخبرت به وقد رجعت عنه

(وأقل ما يمكن انقضاء العدة به) أي عدة الحرة (من الأقراء تسعة وعشرون يوما ولحظة إذا قلنا الأقراء الحيض وأقل الطهر ثلاثة عشر يوما) وذلك بأن يطلقها مع آخر الطهر ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر ثلاثة عشر يوما ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر ثلاثة عشر يوما ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر لحظة ليعرف بها انقطاع الحيض وإن لم تكن هذه اللحظة من عدتها فلا بد منها لمعرفة انقطاع الحيض ومن اعتبر الغسل فلا بد من وقت يمكن الغسل فيه بعد الانقطاع (وإن قلنا الطهر خمسة عشر فثلاثة وثلاثون يوما ولحظة) لأن الطهرين يزيدان أربعة أيام (وإن قلنا القروء الأطهار فثمانية وعشرون يوما ولحظتان) وهو أن يطلقها من آخر لحظة من طهرها فيحسب به قرءا ثم يحسب طهرين آخرين ستة وعشرين يوما

وبينهما حيضتان فإذا طعنت على الحيضة الثالثة لحظة انقضت عدتها (وإن قلنا الطهر خمسة عشر يوما [ج ٧ - ص ٤٠٠]

فاثنان وثلاثون يوما ولحظتان) زدنا أربعة أيام في الطهرين فأما إن كانت أمة انقضت عدتها بخمسة عشر يوما ولحظة على الأول وفي الرعاية مع بينة على الأصح وعلى الثاني بسبعة عشر يوما ولحظة وعلى الثالث بأربعة عشر يوما ولحظتين وعلى الرابع بستة عشر يوما ولحظتين فمتى ادعت انقضاء عدتها بالقروء في أقل من هذا لم يقبل قولها عند أحد فيما أعلم لأنه لا يحتمل صدقها

تنبيه إذا قالت انقضت عدتي بوضع حمل مصور وأمكن صدقت في المضغة وفي يمين من يقبل قوله روايتان فإذا عينا وقت حيض أو وضع واختلفا في سبق الطلاق قبل قوله في العدة في الأشهر

قال في الشرح وكل موضع قلنا القول قولها فأنكر الزوج فقال الخرقي عليها اليمين وأومأ إليه أحمد في رواية أبي طالب وقال القاضي قياس المذهب لا يمين وأومأ إليه أحمد فقال لا يمين في نكاح ولا طلاق لأن الرجعة لا يصح بذلها فلا يستحلف فيها كالحدود والأول أولى فإن نكلت عن اليمين فقال القاضي لا يقضى بالنكول وقال المؤلف ويحتمل أن يستحلف الزوج وله رجعتها بناء على القول برد اليمين لأنه لما وجد النكول منها ظهر صدقه وقوي جانبه واليمين تشرع في حقه كما شرعت في حق المدعى عليه لقوة جانبه بالعين في اليد

(وإذا قالت انقضت عدتي فقال قد كنت راجعتك فأنكرته فالقول قولها) لأن قولها في انقضاء عدتها مقبول فصارت دعواه للرجعة بعد الحكم بانقضاء عدتها وهذا بخلاف ما إذا ادعى الزوج رجعتها في عدتها

[ج ٧ - ص ٤٠١]

فأنكرته ونبه عليها بقوله (وإن سبق فقال ارتجعتك فقالت قد انقضت عدتي قبل رجعتك) فأنكرها (فالقول قوله) ذكره القاضي وأبو الخطاب وصححه ابن حمدان لأنه ادعى الرجعة قبل الحكم بانقضائها ولأنه يملك الرجعة وقد صحت في الظاهر فلا يقبل قولها في إبطالها (وقال الخرقي) والشيرازي وابن الجوزي ونص عليه ذكره في الواضح (القول قولها) لأن الظاهر البينونة والأصل عدم الرجعة ولأن من قبل قوله سابقا قبل مسبوقا كسائر الدعاوى والأصح قوله جزم به في الترغيب ولم يتعرض الأصحاب لسبق الدعوى هل هو عند الحاكم أم لا (وإن تداعيا معا قدم قولها) على المذهب ذكره ابن المنجا وصححه في الشرح وجزم به في الوجيز لأنه تساقط قولهما مع التساوي والأصل عدم الرجعة (وقيل يقدم قول من تقع له القرعة) ذكره أبو الخطاب وغيره لأن القرعة مرجحة عند الاستواء بدليل الإمامة والأذان والعتق ونحوها وقيل يقبل قوله لأن المرأة تدعي ما يرفع الطلاق وهو ينكره فقبل قوله كالمؤلي والعنين إذا ادعيا إصابة امرأته وأنكرته وحكى في الفروع الأقوال الثلاثة من غير ترجيح كالمحرر في القولين المحكيين هنا وهذا إذا لم تكن المرأة قد نكحت فإذا نكحت بعد انقضاء العدة فادعى الزوج الرجعة في العدة فإن أقام بينة أو صدقاه سلمت إليه وإن كذباه ولا بينة قبل قولها مع يمينها وإن صدقته وكذبه الزوج الثاني صدق الثاني بيمينه

أصل إذا اختلفا في الإصابة فقال قد أصبتك فلي الرجعة فأنكرته

[ج ٧ - ص ٤٠٢]

أو قالت قد أصابني فلي المهر قبل قول المنكر منهما لأن الأصل معه فلا يزول إلا بيقين وليس له رجعتها في الموضعين فإن كان اختلافهما بعد قبض المهر وادعى إصابتها فأنكرته لم يرجع عليها بشيء لأنه يقر لها به ولا يدعيه وإن كان هو المنكر رجع عليها بنصفه والخلوة كالإصابة في إثبات الرجعة للزوج على المرأة التي خلا بها وقال أبو بكر لا رجعة له عليها إلا أن يصيبها لأنها غير مصابة فلا تستحق رجعتها كالتي لم يخل بها ووجه الأول أنها معتدة يلحقها طلاقه فملك رجعتها كالتي أصابها

فرع إذا ادعى زوج الأمة بعد عدتها أنه كان راجعها في عدتها فأنكرته وصدقه مولاها قبل قولها نص عليه وقيل قوله فعلى الأول إن علم مولاها صدق الزوج لم يحل له وطؤها ولا تزويجها وإن علمت هي صدق الزوج في رجعتها فهي حرام على سيدها ولا يحل لها تمكينه من وطئها إلا مكرهة كما قبل الطلاق

فصل

(وإن طلقها) أي الحر (ثلاثا) والعبد اثنتين ولو عبر ك الفروع بقوله من طلق عدد طلاقه لكان أولى (لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره) إجماعا وسنده قوله تعالى ﴿ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ﴾ البقرة 230 وحديث امرأة رفاعة القرظي وقال سعيد بن

المسيب إذا تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد به إحلالا فلا بأس أن يتزوجها الأول قال [ج ٧ - ص ٤٠٣]

ابن المنذر لا نعلم أحدا قال بهذا إلا الخوارج ولإجماعهم على أن المراد بالنكاح في الآية الجماع

وحاصله أن حلها للأول مشروط بأن تنكح زوجا غيره فلو كانت أمة فوطئها السيد فلا وأن يكون النكاح صحيحا على المذهب فلو كان فاسدا فلا وأن يطأها في الفرج لحديث عائشة ونبه عليه بقوله (ويطؤها في القبل) لأنه عليه السلام علق الحل على ذواق العسيلة ولا تحصل إلا بالوطء في الفرج (وأدنى ما يكفي من ذلك تغييب الحشفة) مع الانتشار (في الفرج وإن لم ينزل) لأن أحكام الوطء تتعلق به فلو أولج من غير انتشار لم يحلها لأن الحكم يتعلق بذواق العسيلة ولا يحصل من غير انتشار وليس الإنزال شرطا فيه لأنه عليه السلام جعل ذواق العسيلة غاية للحرمة وذلك حاصل بدون الإنزال والذي يظهر أن هذا في الثيب فأما البكر فأدناه أن يفتضها بآلته (وإن كان مجبوبا بقي من ذكره قدر الحشفة فأولجه) أحلها لأن ذلك منه بمنزلة الحشفة من غيره وفي الترغيب وجه بقيته (أو وطئها زوج مراهق) أحلها في قولهم إلا الحسن لظاهر النص ولأنه وطء من زوج في نكاح صحيح أشبه البالغ وبخلاف الصغير فإنه لا يمكنه الوطء ولا تذاق عسيلته وفي المستوعب يعتبر أن يكون له عشر سنين فصاعدا وقال القاضي يشترط له اثنتا عشرة سنة ونقله مهنا لأن من دون ذلك لا يمكنه المجامعة ولا معنى لهذا فإن الخلاف في المجامع ومتى أمكنه الجماع فقد [ج ٧ - ص ٤٠٤]

وجد منه المقصود (أو ذمي وهي ذمية أحلها) لمطلقها المسلم نص عليه وقال هو زوج وبه تجب الملاعنة والقسم ولظاهر النص ولأنه وطء من زوج في نكاح صحيح أشبه وطء المسلم (وإن وطئها في الدبر أو وطئت بشبهة أو بملك يمين لم تحل) لأن الوطء في الدبر لا تذوق به العسيلة والوطء بشبهة أو ملك يمين وطء من غير زوج فلا يدخل في عموم النص فيبقى على المنع (وإن وطئت في نكاح فاسد لم تحل في أصح الوجهين) نص عليه لأن النكاح المطلق في الكتاب والسنة إنما يحمل على الصحيح وقاله الأئمة وخرج أبو الخطاب وجها يحلها لأنه زوج فيدخل في عموم النص وسماه عليه السلام محللا مع فساد نكاحه والأول المذهب ونصره في الشرح بدليل ما لو حلف لا يتزوج فتزوج تزويجا فاسدا لا يحنث ولأن أكثر أحكام التزويج غير ثابتة فيه من الإحصان واللعان والظهار ونحوها وسماه محللا لقصده التحليل فيما لا يحل ولو أحل حقيقة لما لعن ولا لعن المحلل له لقوله عليه السلام ما آمن بالقرآن من استحل محارمه ولأنه وطء في غير نكاح كوطء الشبهة (وإن وطئها زوجها في حيض أو نفاس أو إحرام) أو صوم واجب منهما أو من أحدهما أحلها في اختيار المؤلف وصححه في الشرح لدخوله في العموم ولأنه وطء تام في نكاح تام فأحلها كما لو وطئها مريضة يضر بها وطؤه فإنه لا خلاف في حلها قاله في الكافي وكما لو تزوجها وهو مملوك ووطئها وكما لو وطئها وقد ضاق وقت

صلاة ومسجد وكقبض مهر ونحوه لأن الحرمة لا لمعنى فيها لحق الله تعالى بخلاف وطئها في إحرام ونحوه [ج ٧ - ص ٤٠٥]

فإن الحرمة هناك لمعنى فيها وفي عيون المسائل والمفردات منع وتسليم (وقال أصحابنا لا يحلها) قدمه في الفروع وهو المنصوص في الكل لأنه وطء حرم لحق الله فلم يحلها كوطء المرتدة أو نكاح باطل

مسائل الأولى إذا وطئها في ردتها أو ردته لم يحلها لأنه إن عاد إلى الإسلام فقد وقع الوطء في نكاح غير تام لانعقاد سبب البينونة وإن لم يسلم في العدة فلم يصادف الوطء نكاحا وكذا لو أسلم أحد الزوجين فوطئها قبل إسلام الآخر

الثانية إذا كانا مجنونين أو أحدهما فوطئها أحلها على المذهب لظاهر النص وكالبالغ العاقل وقال ابن حامد لا يحلها لأنه لا يذوق العسيلة والأول أصح لأن العقل ليس شرطا في الشهوة بدليل البهائم قال في الشرح لكن إن كان المجبوب ذاهب الحس كالمصروع والمغمى عليه فلم يحصل الحل بوطئه

الثالثة إذا وطئ مغمى عليها أو نائمة لا تحس بوطئه لم تحل حكاه ابن المنذر ويحتمل حصول الحل للعموم ولو وطئها يعتقدها أجنبية فإذا هي امرأته حلت لأنه صادف نكاحا صحيحا

الرابعة إذا استدخلت ذكره وهو نائم حلت وقدم في الشرح خلافه لأنه لم يذق عسيلتها وإن وطئها مع إغمائه فوجهان وإن كان خصيا أو مسلولا أو موجوءا حلت لدخوله في عموم الآية في قول الأكثر وعنه [ج ٧ - ص ٤٠٦]

لا لعد ذوقان العسيلة قال أبو بكر والعمل على الأول لأنه يطأ كالفحل ولم يفقد إلا الإنزال وهو غير معتبر في الإحلال

(وإن كانت أمة فاشتراها مطلقها لم تحل) نص عليه رواه مالك والبيهقي عن زيد بن ثابت وقاله الأكثر للآية ولأن الفرج لا يجوز أن يكون محرما مباحا (ويحتمل أن تحل) لأن الطلاق يختص الزوجية فأثر في التحريم

(وإن طلق العبد امرأته طلقتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره) هذا هو المذهب أن الطلاق معتبر بالرجال والتفريع عليه فعلى هذا إذا طلقها طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره (سواء عتقا أو بقيا على الرق) لاستواء حالين في السبب المقتضي للتحريم قبل نكاح زوج آخر وذلك أن سبب التحريم استكمال العدد وهو موجود في حالتي العتق بعد الرق وبقاء الرق والمذهب أنه إذا عتق بعد طلقة ملك تمام الثلاث وإن كان بعد طلقتين فعلى روايتين لأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى به وقال في رواية أبي طالب يتزوجها ولا يبالي في العدة عتقا أو بعد العدة وقال هو قول ابن عباس وجابر لأن ابن عباس أفتى به وقال قضى به النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وقال لا أرى شيئا يدفعه وأبو داود والنسائي من رواية عمر بن معتب عن أبي حسن مولى بني نوفل ولا يعرفان وقال النسائي في عمر ليس بقوي وقال ابن المبارك ومعمر لقد

تحمل أبو حسن هذا صخرة عظيمة وقال أحمد حديث عثمان وزيد في تحريمها عليه جيد وحديث ابن عباس يرويه عمر بن معتب ولا أعرفه وأما أبو حسن فهو عندي معروف وقال أبو بكر إن صح [ج ٧ - ص ٤٠٧]

الحديث فالعمل عليه وإلا فالعمل على حديث عثمان وزيد وبه أقول

فرع إذا علق ثلاثا في الرق بشرط فوجد بعد عتقه لزمته الثلاث وقيل ثنتان ويبقى له واحدة كتعليقها بعتقه في الأصح

(وإذا غاب عن مطلقته ثلاثا فأنته فذكرت أنها نكحت من أصابها أو انقضت عدتها وكان ذلك ممكنا فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها) المطلقة المبتوتة إذا مضى بعد طلاقها زمن يمكن فيه انقضاء عدتين بينهما نكاح ووطء ولم يرجع قبل العقد وأخبرته بذلك وغلب على ظنه صدقها مثل أن يعرف أمانتها أو بخبر غيرها ممن يعرف حالها وفي الترغيب وجه إن كانت ثقة فله أن يتزوجها في قول عامتهم لأنها مؤتمنة على نفسها وعلى ما أخبرت به عنها ولا سبيل إلى معرفة هذه الحال على الحقيقة إلا من جهتها فتعين الرجوع إلى قولها كما لو أخبرت بانقضاء عدتها (وإلا فلا) أي إذا لم يوجد ما ذكر ولم يغلب على ظنه صدقها فلا تحل له لأن الأصل التحريم فوجب البقاء على الأصل وكما لو أخبره عن حالها فاسق فلو كذبها الثاني في وطء قبل قوله في تنصيف مهر وقولها في إباحتها للأول وكذا لو تزوجت حاضرا وفارقها وادعت إصابته وهو منكرها ومثل الأولة لو جاءت حاكما وادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها فله تزويجها إن ظن صدقها بمعاملة وعبد لم يثبت عتقه قاله الشيخ تقي الدين لا سيما إن

كان الزوج لا يعرف وظهر مما سبق لو اتفقا أنه طلقها وانقضت العدة فإنها تزوج [ج ٧ - ص ٤٠٨]

فرع لو شهدا بأن فلانا طلق امرأته ثلاثا ووجد معها بعد وادعى العقد ثانيا بشروطه يقبل منه وسئل عنها المؤلف فلم يجب ولو وطئ من طلقها ثلاثا حد نص عليه فإن جحد طلاقها ووطئها فشهد بطلاقه فلا لأنا لا نعلم معرفته به وقت وطئه إلا بإقراره به

8 [ج ٧ - ص ٤٠٩]